

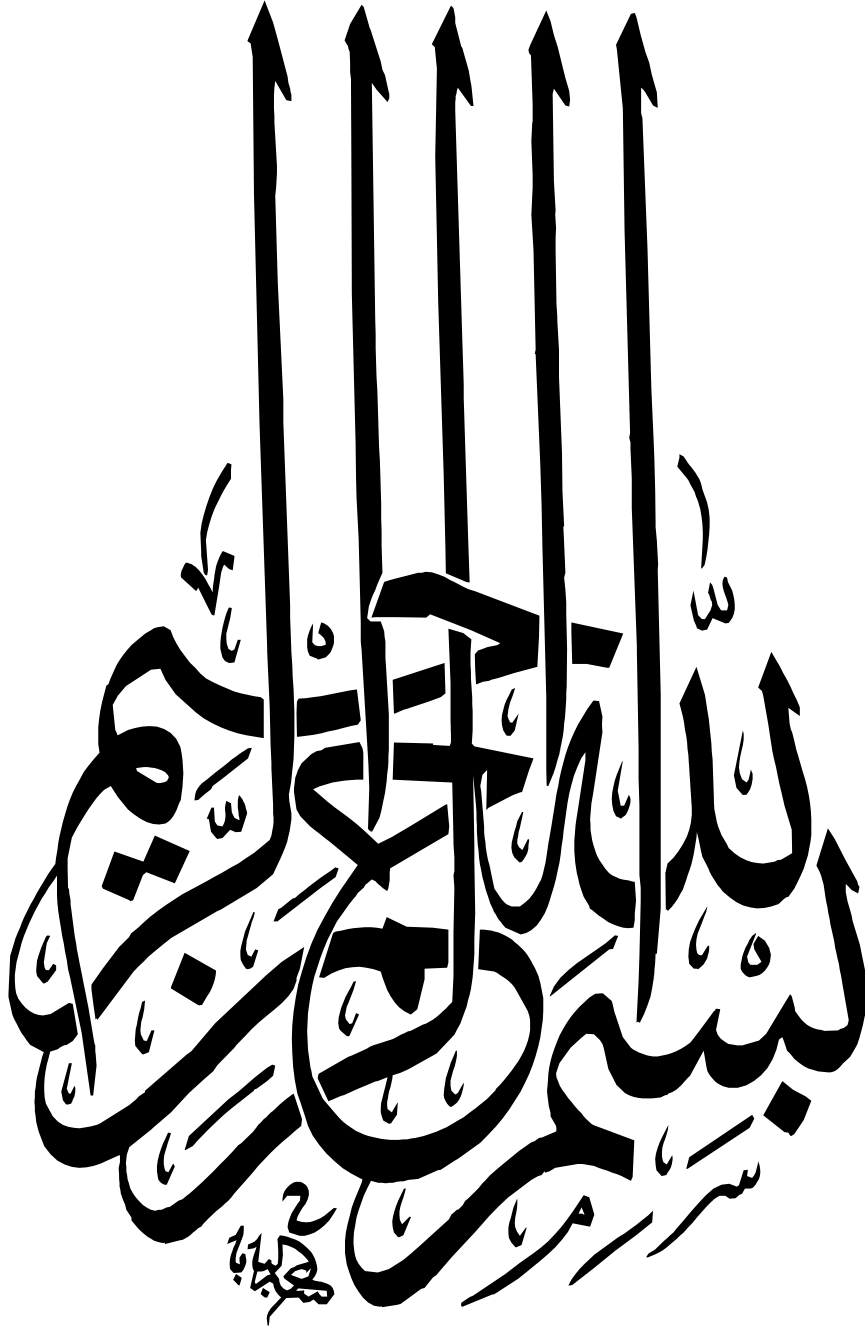
جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون
قسم الفقة

دراسات فقهية

على مذهب السادة المالكية

الدراسة الموضوعية والنصية لطلاب القرقة الثالثة بقسميها

٢٠٢٣-٢٠٢٤م



(توصيف مقرر دراسي)

١. بيانات المقرر:

■ اسم المقرر: الفقه المذهبي (مالكي)

■ الفرقة: الثالثة

■ عدد الوحدات الدراسية: نظري [٥ ساعات] عملي [-]

٢. الهدف العام من تدريس المقرر:

تخريج طالب مزود بالمعارف الفقهية فيما يتعلق ببعض أنواع المعاملات والحدود، مع إلمامه بأحكامها وأدلتها التفصيلية وتربية الملكة الفقهية لديه، بما يمكنه من تصور القضايا وإنزال الحكم الشرعي عليها، متبنيًا الوسطية الأزهرية في الفتوى وبعيدًا عن التعصب أو الغرض.

٣. المستهدف الخاص من تدريس المقرر:

أ- المعلومات: يتوقع من الطالب بعد دراسة المقرر أن يكون ملماً بأحكام الإجارة وتفصيلاتها، والحوالة وأحكامها، والضمان وشروطه وأسباب الحجر وأنواعه، والشركة والمزارعة والإقرار وأحكام الدماء والبغي والحراقة، مدرباً على إنزال هذه الأحكام على واقعة المعاصر، مما يكون له أكبر الأثر في المحافظة على أموال وممتلكات الآخرين، من خلال تشريعات إسلامية فيما ذكر، تحمي الحقوق وتمنع المنازعات قبل وقوعها.

ب- المهارات الذهنية:

تعتمد على العصف الذهني وإمعان النظر في استخراج الأحكام ووضع الضوابط لتطبيقها، وبيان الحكمة الإلهية من تشريعها حتى يتمكن الطالب من إبراز سمو الشريعة الإسلامية الغراء على غيرها من التشريعات.

ت- المهارات المهنية الخاصة بالمقرر:

■ استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وما يترتب عليه في تغير الأحكام طبقاً للزمان والمكان والحادثة والشخص.

■ التدريب العملي من خلال المحاورة بين الأستاذ وطلابه، وعرض بعض الأسئلة والقضايا المعاصرة وتعليمهم كيفية الاستدلال والمناقشة والترجيح لما قوى دليله، والتوصية بتطبيق ما انتهى إليه على الواقع المجتمعي المعاصر.

■ التعليم الذاتي:- ينقسم الطلاب إلى مجموعات، كل مجموعة تتبنى رأياً فقهياً في بعض المسائل وعرض أدلته، ومجموعة أخرى تناقش أدلة الآراء وتدفع ما ورد عليها من اعتراضات، وصولاً إلى حكم متفق عليه يمكن أن يطبق على ما يجد من نوازل وأحداث.

ث- المهارات العامة والوجدانية المستهدفة من دراسة المقرر:-

■ استثمار الدراسة التخصصية في تحقيق طموحات الكالب الشخصية والمهنية، مما يكون دافعاً له على مواصلة دراساته العليا، وعمل أبحاث تفيد مجتمعه الذي يعيش فيه.

■ توظيف قواعد ومبادئ العلم الشرعي في مجال الدعوة إل الله، والتدريس والتعليم وخدمة المجتمع.

■ التواصل من خلال الأبحاث الجديدة مع المؤسسات العلمية والثقافية داخلياً وخارجياً.

■ الاعتزاز بالتشريع الإسلامي، والقرآن الكريم وعلومه، والحديث والتفسير، وكتب التراث في المجال الفقهي، والعمل على تمحيصها وبيان المراد منها؛ مما خفي على البعض أو توهمه آخرون.

■ محتوى المقرر في الدراسة النصية:

باب الحوالة - باب الضمان - باب الإجارة

٤. محتوى المقرر في الدراسة الموضوعية:

الموضوع	الأسبوع
أ- الشركة وأحكامها وأنواعها	الأول والثاني
ب- المزارعة وأحكامها	الثالث والرابع
ج- الإقرار وأحكامه	الخامس والسادس
د- أحكام الدماء - والجنابة على ما دون النفس والديات	السابع والثامن والتاسع
هـ- البغي وأحكامه	العاشر
و- الحراية وأحكامها	الحادي عشر
ز- بيان أسباب الحجر	الثاني عشر
ح- الحوالة - شروطها - وأحكامها	الثالث عشر والرابع عشر
ط- الضمان وأحكامه - والآثار المترتبة عليه	الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر
ي- الإجارة - تعريفها وأدلتها - أنواعها - أحكام كل نوع - أسباب انتهاء الإجارة	الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون
ك- مراجعة على ما سبق دراسته	الحادي والعشرون
ل- مراجعة وتدريب الطالب على كيفية الإجابة	الثاني والعشرون

٥. أساليب التعليم والتعلم، ومنها:

■ إلقاء المحاضرات.

- العصف الذهني مع التطبيق العملي وضرب الأمثلة.
- الأسلوب الحوارى ومناقشة الطلاب فى المعروض عليهم.
- التعليم الذاتى عن طريق تقسيم الطلاب إلى مجموعات.
- التكليف والأبحاث.
- ٦. أساليب التعليم والتعلم للطلاب ذوي القدرات المحدودة:
 - ما سبق فى (٥)
 - استخدام الساعات المكتبية لمساعدة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
 - تكرير المعلومة لتثبيتها فى الذهن.
 - تعليم الأقران.
 - استخدام الوسائل الحديثة (كالحاسوب) - وتسجيل المحاضرات لهم.
- ٧. تقويم الطلاب:
 - أ- الأساليب المستخدمة:
 - تكليف كل طالب بعمل بحث مقيد يختلف عن الآخر.
 - الاختبارات الشفهية والتحريرية فى نهاية الفصل الدراسى.
 - التوقيت للامتحان: نهاية العام [الفصل الدراسى الثانى].
 - ب- توزيع الدرجات: ٨٠ درجة تحريري + ٢٠ درجة شفوي
- ٨. قائمة الكتب الدراسية:
 - أ- كتب ملزمة:
 - للدراسة النصية: الشرح الكبير لأبى البركات الدردير مع حاشية الدسوقي عليه.

■ للدراسة الموضوعية: الكتاب المُعتمد من مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر - قسم الفقه بكليات الشريعة وشعبة الشريعة الإسلامية بكليات الدراسات الإسلامية.

ب- كتب مقترحة للاستزادة:

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (الحفيد)

- المعونة للقاضي عبد الوهاب المالكي.

- الذخيرة للقرافي.

ت- دوريات علمية او نشرات في مجلة الكلية:

■ مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالجامعة

■ حوليات كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر

■ المكتبة الشاملة: <http://shamela.ws/>

ث- مذكرات : لا يوجد

* مدرس المقرر: المكلف من القسم العلمي بالكلية.

رئيس القسم :

مقدمة في التعريف بالمذهب المالكي، ومؤسسه، وأشهر علمائه، وأشهر كتبه.

أولاً: المذهب المالكي.

هو أحد المذاهب الفقهية الأربعة التي اشتهرت من بين مذاهب أهل السنة، وقد نشأ هذا المذهب في دور نضج الفقه الإسلامي وازدهاره، وهو الدور الذي ابتداءً في أوائل القرن الثاني الهجري، وانتهى في منتصف القرن الرابع الهجري^(١). والمذهب المالكي قد كتب الله له البقاء إلى يومنا هذا، وانتشر في جميع أقطار الأرض بعد أن نشأ في المدينة المنورة دار الهجرة ومهبط الوحي ومقر التشريع قرابة أربعين عاماً في عصر النبوة والخلفاء الراشدين، وموطن جمهرة الصحابة ومحط رجال الفقهاء والعلماء، حيث تروى أحاديث رسول الله (ﷺ) القولية، ويتابع الناس سنته العملية جيلاً بعد جيل، ويتناقلون سنة الخلفاء من بعده، فكانت مركز الإشعاع الديني في العالم الإسلامي يقصدها طلاب الحديث والفقه من كل مكان^(٢).

ومن مدرسة المدينة تخرج الفقهاء الذين كانوا حلقة الاتصال بين من سبقوهم ومن جاءوا بعدهم من أساتذة الإمام مالك الذين تتقف عليهم وتأثر بعلمهم^(٣).

ثانياً: مؤسس المذهب.

هو أبو عبد الله: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث، الأصبحي المدني، نسبته إلى قبيلته أصبح اليمنية، قدم أحد أجداده من اليمن وسكن المدينة، وتسلسل نسله حتى ولد له هذا الإمام الجليل، إمام دار

(١) دراسة تحليلية للمذهب المالكي أ. د/ عبد الجليل سعد القرناشي ص ١.

(٢) المرجع السابق ص ٢.

(٣) المرجع السابق.

الهجرة، مؤسس المذهب المالكي ورافع لوائه، وهو من تابعي التابعين، جده أبو عامر صحابي جليل (رضي الله عنه) شهد المغازي كلها مع النبي (ﷺ) إلا بدرًا، والجد الأدنى لمالك من كبار التابعين وعلمائهم، وكان مالك وارئًا من ورثة حديث الرسول (ﷺ) ناشرًا في أمتة العلم والأحكام، ولد بالمدينة سنة ٩٣ من الهجرة، وتوفي بها سنة ١٧٩هـ، وقد عاش مالك بالمدينة ولم يعرف أنه رحل منها إلا إلى مكة للحج، والمدونة المروية عنه، وكتابه الموطأ شاهدان على علمه وفضله، تغمد الله الإمام برحمته وجزاه عنا خير الجزاء^(١).

ثالثًا: أشهر علماء المذهب.

١ - ابن القاسم:

هو عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري، الحافظ الحجة الفقيه، أثبت الناس في مالك وأعلمه بأقواله، صحبه عشرين سنة، وتفقه به وبنظرائه، لم يرو واحد عن مالك الموطأ أثبت منه، روى عن الليث وعبد العزيز بن الماجشون وغيرهما، وخرج عنه البخاري في صحيحه، وأخذ عنه جماعة منهم أصبغ ويحيى بن دينار، وأسد بن الفرات، وابن عبد الحكم وسحنون وجماعة، مولده سنة ١٢٨هـ وتوفي بمصر سنة ١٩١هـ^(٢).

٢ - أشهب:

هو أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري المصري، انتهت إليه رئاسة المالكية بمصر بعد موت ابن القاسم، روى عن الليث والفضيل

(١) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص ٥٢، وما بعدها، ترتيب المدارك للقاضي عياض ١/ ١٠٢، ١٠٣.

(٢) شجرة النور الزكية ص ٥٨، الديباج المذهب لابن فرحون ص ٤٦ وما بعدها.

بن عياض ومالك وبه تفقه، وروى عنه بنو عبد الحكم، والحارث بن مسكين، وسحنون وغيرهم، مولده كان عام ١٤٠هـ - وتوفي بمصر عام ٢٠٤هـ^(١).

٣- ابن وهب:

هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، من أثبت الناس في مالك، روى عن أربع مائة عالم منهم الليث وابن دينار، ومالك وبه تفقه وصحبه عشرين سنة، وروى عنه سحنون وابن عبد الحكم وأبو مصعب الزهري وغيرهم، له تآليف حسنة، منها: سماعه من مالك، وموطأه الكبير والصغير وجامعه الكبير، مولده عام ١٢٥هـ، ومات بمصر عام ١٩٧هـ^(٢).

٤- أسد بن الفرات:

هو أبو عبد الله أسد بن الفرات بن سنان، ولد سنة ١٤٥هـ بخران من ديار بكر، انتقل به أبوه إلى تونس، وتفقّه بأبي الحسن بن زياد، وتفقّه بمصر على ابن القاسم، ثم رحل إلى العراق، وعاد إلى بلده، وتولى القضاء بالقيروان، وله كتاب يسمى بالأسدية على غرار المدونة الكبرى، وولاه ابن الأغلب قيادة الجيش، ومات محاصرًا في غزوة صقلية، وهو أمير الجيش وقاضيه سنة ٢١٣هـ^(٣).

٥- عبد الملك بن حبيب:

هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي الأندلسي، انتهت إليه رئاسة الأندلس بعد يحيى بن يحيى، ألف كتبًا كثيرة منها: الواضحة في الفقه والسنن، وكتاب في فضل الصحابة، وغريب الحديث، وكتاب في تفسير الموطأ، مات سنة ٢٣٨هـ^(٤).

(١) السابق ص ٥٩.

(٢) نفسه ص ٥٨.

(٣) شجرة النور الزكية ص ٦٢.

(٤) السابق ص ٧٤.

٦- سحنون:

هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني، أصله من حمص، أخذ عن أئمة أهل المشرق والمغرب كالبهلول بن راشد وعلي بن زياد وأسد بن الفرات وابن القاسم وابن وهب وغيرهم، وعنه أخذ أئمة: منهم ابنه محمد وابن عبدوس وابن غالب، وحمد يس وغيرهم كثير، انتهت إليه رئاسة العلم بالمغرب، روى المدونة وقام بتتقيح مسائلها وتدوينها، وسحنون لقلب له، ويقال: إن سحنون اسم طائر حاد الذهن، فلقب سحنون به لحدته في المسائل، ولد سنة ١٦٠ هـ وتوفي سنة ٢٤٠ هـ^(١).

٧- ابن المواز:

هو محمد بن إبراهيم الأسكندري المعروف بابن المواز، له كتاب كبير يعرف بالموازية نسبة إليه، قيل عن هذا الكتاب: "... وهو أجل كتاب ألفه المالكيون وأصح مسائل وأبسطه كلاماً، وأوعبه، ورجحه القابسي على سائر الأمهات"، ولد ابن المواز في رجب سنة ١٨٠ هـ، وتوفي في ذي القعدة سنة ٢٦٩ هـ^(٢).

٨- أصبغ:

هو أبو عبد الله أصبغ بن الفرّج بن سعيد بن نافع المصري، سمع من ابن القاسم وأشهب وابن وهب وكان كاتباً له، وعليه تفقه ابن المواز وابن حبيب وغيرهما، له تأليف حسان، منها: كتاب الأصول، وتفسير حديث الموطأ،

(١) ترتيب المدارك للقاضي عياض ٢/ ٥٨٥، وما بعدها، شجرة النور الزكية ص ٦٩، ص ٧٠.

(٢) الديباج المذهب ص ٢٣٣، الذخيرة المطبوعة ١/ ٢٠.

وسمعه من ابن القاسم، وكتاب الرد على أهل الأهواء، ولد سنة ١٥٠ هـ ومات بمصر سنة ٢٢٥ هـ^(١).

٩ - ابن شاس:

هو أبو محمد جلال الدين بن عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المتوفي بدمياط مجاهدًا سنة ٦١٠ هـ صنف كتاب الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، عكف عليه المالكية لحسن ترتيبه، وتنسيق أبوابه، ووضوح عبارته، واختصره أبو عمرو بن الحاجب^(٢).

١٠ - القاضي عبد الوهاب:

هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، ولد في شوال سنة ٣٦٣ هـ، وتفقّه على ابن الجلاب وابن القصار والباقلاني وغيرهم، مؤلفاته كثيرة غاية في الإبداع، منها: كتاب الأدلة في مسائل الخلاف، والإشراف على مسائل الخلاف، وشرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، والتلقين، وكتاب الإفادة في الأصول، والمعونة على مذهب عالم المدينة، وعيون المسائل في الفقه، توفي سنة ٤٢٢ هـ^(٣).

١١ - الباجي:

هو القاضي أبو الوليد: سليمان بن خلف التميمي الباجي، الأندلسي، أخذ عن جُلّة من الفقهاء وتفقّه به جماعة منهم: ابنه أحمد، وأبو بكر الطرطوشي، وغيرهما، صنف كتبًا كثيرة، منها: التسديد إلى معرفة التوحيد، والاستيفاء، والمنتقى، ولد سنة ٤٠٣ هـ، وتوفي سنة ٤٧٤ هـ^(٤).

(١) شجرة النور الزكية ص ٦٦.

(٢) السابق ص ١٦٥، الذخيرة ٢١/١.

(٣) شجرة النور الزكية ص ١٠٣ وما بعدها، الذخيرة ٢١/١.

(٤) شجرة النور الزكية ص ١٢٠، ص ١٢١.

١٢ - اللخمي:

هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي، القيرواني، تفقه بابن محرز والسيوري التونسي وغيرهم، وبه تفقه جماعة منهم الإمام المازري، وعبد الحميد الصفاقسي، ولالإمام اللخمي تعليق على المدونة سماه "التبصرة" معتمد في المذهب، توفي سنة ٤٧٨ هـ بصفاقس بتونس^(١).

١٣ - ابن رشد "الجد":

هو أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي، ألف كتابين من أعظم كتب المالكية: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، وكتاب المقدمات والممهدات، ولد سنة ٤٥٥ هـ - وتوفي في ذي القعدة سنة ٥٢٠ هـ^(٢).

(١) الديباج المذهب ص ٢٠٣.

(٢) شجرة النور الزكية ص ١٢٩.

رابعاً: أشهر كتب المالكية.

- ١- الموطأ للإمام مالك، وشرحه، ومنهم:
 - أ- ابن عبد البر في كتابين:
 - الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار.
 - التمهيد لما في الموطأ من الروايات والأسانيد.
- ب- الباجي الأندلسي: شرح الموطأ في كتاب سماه الاستيفاء، ولخصه في كتاب سماه المنتقى.
- ج- القاضي أبو بكر بن العربي- صنف شرحاً للموطأ سماه بالقبس، وآخر سماه بالمسالك.
- د- السيوطي شرحه في كتاب سماه تنوير الحوالك شرح موطأ مالك.
- هـ- عبد الباقي الزرقاني له كتاب سماه "شرح الموطأ".
- ٢- المدونة: رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك.
- ٣- الواضحة لعبد الملك بن حبيب.
- ٤- العتبية لمحمد بن أحمد العتبي.
- ٥- الموازية لمحمد بن المواز.
- ٦- الذخيرة للقرافي.
- ٧- الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس.
- ٨- جامع الأمهات لابن الحاجب.
- ٩- النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني.
- ١٠ - الرسالة لابن أبي زيد.
- ١١ المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي.
- ١٢ التلقين للقاضي عبد الوهاب.

١٣	البيان والتحصيل لابن رشد "الجد".
١٤	المقدمات والممهّدات لابن رشد "الجد".
١٥	بداية المجتهد لابن رشد "الحفيد".
١٦	القوانين الفقهية لابن جزئ.
١٧	الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر.
١٨	دُرّة الغواص في محاضرة الخواص لابن فرحون.
١٩	التبصرة في الأقضية والأحكام لابن فرحون.
٢٠	أسهل المدارك شرح إرشاد المسالك للكشناوي.
٢١	التفريع لابن الجلاب.
٢٢	التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد الله العبدري الشهير بالمواق.
٢٣	مواهب الجليل للحطاب.
٢٤	حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لابن عرفة الدسوقي.
٢٥	الشرح الكبير لأبي البركات الدردير، والشرح الصغير أيضًا.
٢٦	شرح أحمد بن عيسى البرنسي المعروف بزروق على رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
٢٧	شرح ابن ناجي على الرسالة.
٢٨	شرح الخرشي على مختصر خليل.
٢٩	مختصر خليل بن إسحاق الجندي.
٣٠	شرح الزرقاني على مختصر خليل.
٣١	شرح منح الجليل على مختصر خليل للشيخ محمد عlish.
٣٢	الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي.
٣٣	لباب اللباب لابن راشد البكري.

- ٣٤ كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -
المعروف بشرح أبي الحسن على الرسالة.
- ٣٥ سراج السالك شرح أسهل المسالك للبشار - تأليف عثمان بن
حسين الجعلي المالكي.
- ٣٦ حاشية الشيخ محمد البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل.
- ٣٧ حاشية العدوي على شرح الخرشي.
- ٣٨ حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة بن أبي زيد.

جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

**شرح وتعليق على الدراسة النصية
للفرقة الثالثة / كلية الشريعة والقانون**

جمع وإعداد

أ د / فتحي عثمان عمر الفقي
أ د / محمود علي عبدالجواد
أ د / علي محمد
علي

وكيل كلية الشريعة والقانون الأسبق
أستاذ الفقه المساعد بكلية
أستاذ
الفقه المساعد بكلية

والأستاذ المتفرغ بقسم الفقه بالكلية
والقانون بالقاهرة
الشريعة
والقانون بالقاهرة

وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر الشريف

وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

العام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

الموضوعات المقررة في الدراسة النصية

١ - باب الحوالة.

٢ - كتاب الضمان وأحكامه.

٣ - باب الإجارة.

تمهيد،،

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين
الطاهرين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد،،،،

فنظرا لأهمية المعاملات في حياة كل إنسان؛ لأنها تعتبر الوسيلة
الوحيدة المشروعة لتبادل الأموال والمنافع بين الناس، ولأن معرفة حلالها
وحرامها واجب وضروري على كل مسلم ؛ فلأجل هذا استخرت الله تبارك
وتعالى - وطبقا للمنهج المقرر على طلاب الفرقة الثالثة بكلية الشريعة
والقانون ، الفقه المالكي - اخترت كتابي " الحوالة " و " الضمان " من السفر
الزاهر ألا وهو (الشرح الكبير للعلامة: أحمد الدردير، على مختصر العلامة
: خليل بن إسحاق الجندي) فقامت بالنظر والتأمل في النص، ثم قمت
بصياغته بأسلوب سهل ميسر بما فتح الله به علي؛ لكي يتسنى لأبنائنا
الطلاب الإلمام بأحكام هذين البابين في سهولة ويسر، محاولا قدر جهدي أن
أبحث عن دليل لكل ما أذكر من أحكام قدر الإمكان ، واضعا نصب عيني أن لا
أتعرض لغير مذهب المالكية؛ حيث إن الدراسة مذهبية

وبعد، فهذه محاولة عاجز لا حول له ولا قوة إلا بالله، لم أقصد بها إلا
وجه الله سبحانه وتعالى، فإن كان في هذه المحاولة من توفيق فهو من الله
العلي القدير ، والله وحده الفضل والمنة ، وإن كانت الأخرى ، فمن نفسي ومن
الشيطان ، ومن الله وحده العفو والغفران ، وأهمس - في أذن كل من اطلع
على ما كتبت فوقعت عينه على خطأ - بما قال الإمام الشافعي رحمه الله : -

تعمدني بنصحك في انفرادي ❖ وجنبني النصيح في الجماعة

فإن النصح بين الناس نوع ﴿٥﴾ من التوبيخ لا أرضى استماعه
وإن خالفتني وعصيت قلبي ﴿٥﴾ فلا تجزع إذا لم تعط طاعة
فجزى الله خيرا كل من اطلع على خطأ ، فقام بواجب النصح فأصلح
وستر

فعين الرضا عن كل عيب كليله ﴿٥﴾ وعين السخط تبدي المساويا
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الدراسة النصية

باب الحوالة

باب الحوالة

يقول المصنف : [دَرْسٌ] (بَابُ) فِي شُرُوطِ الْحَوَالَةِ وَأَحْكَامِهَا، وَهِيَ : نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ بِمِثْلِهِ إِلَى أُخْرَى تَبَرُّاً بِهَا الْأُولَى ^(١) "

(١) الشرح والتعليق: تعريف الحوالة ، الحوالة لغة : اسم مأخوذ من التحول، وهو التنقل من موضع إلى موضع، أو حول الشيء من مكانه: نقله منه إلى مكان آخر، وحول وجهه : لفته.

والحوالة شرعا: " نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه " وتعقب هذا التعريف بالآتي : كلمة " نقل " النقل حقيقة في الأجسام، وعرفها العلامة الدردير في النص بقوله : " نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ بِمِثْلِهِ إِلَى أُخْرَى تَبَرُّاً بِهَا الْأُولَى " وتعقب هذا أيضا: بأن جملة : " تبرأ بها الأولى " : حشو ؛ لعدم افادته مدخلا ، أو مخرجا . وعرفت أيضا بأنها : تحول الدين من ذمة تبرأ بها الأولى ، وتعقب هذا أيضا ، بأنه عرف الشيء بنفسه (تحول وحوالة) .

* شرح تعريف الدردير: قوله " بمثله " جار ومجرور متعلق بنقل ، وكذلك قوله " إلى أخرى " أي نقل الدين من ذمة لأخرى بسبب وجود مثله في الأخرى ، قوله : " تبرأ بها الأولى " أي تبرأ به ، أي بالنقل ، وأنت الضمير " بها " نظرا لمعنى النقل لأن معنى النقل (هو الحوالة) وهي مؤنثة ، ولفظ النقل مذكر .

حكم الحوالة:

قال القاضي عياض : هي مندوبة، عند أكثر شيوخ المالكية، وقيل : مباحة ؛ لما أشبهت بيع الدين بالدين ، فهي رخصة مستتناة من بيع الدين بالدين ، جوز للحاجة على خلاف القياس ولهذا لم يشترط التقابض في المجلس إذا كان الدينان ربويين كجنيهات بجنيهات أو جنيهات بريالات ، فهي بيع ؛ لأنها إبدال مال بمال ، فكأن المحيل باع للمحال ما له في ذمة المحال عليه بما للمحال في ذمته ، وجاز تأخير القبض نظرا لمعنى الرخصة لأنها موضوعة على الرفق ، فيدخلها خيار المجلس عند من يقول به - حيث لا يعتبره الحنفية والمالكية - * والصحيح ما قاله ابن قدامة في المعنى : " من أن الحوالة عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس بمحمول على غيره؛ لأنها لو كانت بيعا لما جازت لكونها بيع دين بدين، ولما

جاز التفرق قبل القبض؛ لأنه بيع مال ربوي بجنسه لا يجوز تأخير القبض فيه ، بل لابد من أن يكون يدا بيد.

دليل مشروعية الحوالة:

ثبتت مشروعية الحوالة بالسنة والإجماع :

أولاً : السنة : ما رواه البخاري بسنده - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ»

وفي رواية للبخاري ومسلم : " من أحيل على ملئ فليحتل " * معاني مفردات الحديث : " المطل " : منع قضاء ما استحق عليه قضاؤه ، قوله : " فليتبّع " الصواب : تسكين التاء في " أتبع " ، وفي " فليتبّع " يقال : " تبعت فلانا بحقي وأنا أتبعه بتسكين التاء " وذهب البعض إلى تشديدها وهو ضعيف ، فلا يقال : أتبعه بفتحها وتشديدها إلا في المشي خلفه.

وجه الاستدلال من الحديث : أن لفظ " أتبع " بالتخفيف معناه : إذا أحيل أحدكم على ملئ فليتبّع ، أي فليحتل ، أي فليقبل الحوالة ، يقال : أتبعته غريمي على فلان فتبعه ، أي أحلته فاحتال .

حكم قبول الحوالة:

وليس قبول الحوالة بواجب على المحال بل هو على سبيل الإباحة ، أو الندب ، إن اختار قبول الحوالة قبل وإن شاء لم يقبل ، لم يقبل ، وهذا خلافا لما ذهب إليه أهل الظاهر ، وأكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير ، فإنهم حملوا لفظ الحديث على الوجوب ، أما الجمهور فحملوه على الاستحباب.

ثانياً : الإجماع : حكاه ابن مفلح من الحنابلة في المبدع له ، فقال وهي ثابتة بالإجماع ، ولا عبرة بمخالفة الأصم (الأصم هو : عبد الرحمن بن كيسان الأصم - ٢٠١ - ٢٧٩ هجرية فقيه مفسر ومتكلم معتزلي كان جليل المقدر يكاثبه السلطان وكان صبوراً على الفقر) ، فقد أجمع جمهور العلماء على جوازها في الجملة ، وإن اختلفوا في بعض المسائل.

شروط صحة الحوالة

يقول المصنف : (شَرَطُ) صِحَّةِ (الْحَوَالَةِ رِضَا الْمُحِيلِ وَالْمَحَالِ فَقَطْ) لَا الْمَحَالِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُهُ وَإِقْرَارُهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ الْمُرَجَّحَيْنِ.

وَالثَّانِي يُشْتَرَطُ (وَتُبُوتُ دَيْنٍ لَازِمٍ) لِلْمُحِيلِ فِي ذِمَّةِ الْمَحَالِ عَلَيْهِ وَكَذَا لِلْمَحَالِ عَلَى الْمُحِيلِ ، وَإِلَّا كَانَتْ وَكَالَةً لَا حَوَالَةً ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ دَيْنٌ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى كَانَتْ حَمَالَةً إِنْ رَضِيَ الْمَحَالُ عَلَيْهِ لَا حَوَالَةً وَإِنْ وَقَعَتْ بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ^(١)

(١) * الشرح والتعليق: يشير المصنف في هذا النص إلى بعض شروط صحة الحوالة وهي

: ١ - رضا المحيل والمحال ٢ - حضور المحال عليه وإقراره - طبقا للراجح من أحد القولين المرجحين - ٣ - ثبوت دين المحيل والمحال، وإليك بيانها وتوضيحها:

الشرط الأول : رضا المحيل والمحال ، اختلف فقهاء المذهب في هذا الشرط على رأيين : الرأي الأول : وهو مشهور المذهب (ومعنى المشهور هو : ما كثر قائله) : أنه يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط فلا يشترط رضا المحال عليه.

وحجتهم لهذا : قوله صلى الله عليه وسلم : " من أحيل على ملئ فليحتل " متفق عليه ، ووجه الاستدلال منه : أنه صلى الله عليه وسلم : لم يشترط رضا المحال عليه ، ولأن الحق للمالك فله أن يملكه من شاء ، كسائر الحقوق ، ولأن المحيل أقام المحال في القبض مقام نفسه ، فلم يفتقر إلى رضا من عليه الحق ، قياسا على ما لو وكل المحيل المحال في قبض دينه من المحال عليه.

إضافة : وأضاف المالكية : أن الحوالة صحيحة رضي المحال عليه ، أو لم يرض ، إلا إذا كان بين المحال عليه والمحال عداوة دنيوية سابقة على وقت الحوالة ، فلا تصح الحوالة حينئذ على المشهور ، وهذا قول الإمام مالك ، فإن حدثت العداوة بعد الحوالة أو كانت عداوة دينية منع المحال من اقتضاء الدين من المحال عليه ، ووكل من يقتضيه منه ؛ لئلا يبالغ في إيذائه بعنف مطالبته.

الرأي الثاني : وهو مقابل المشهور في المذهب (حكاه ابن شعبان) : من أنه لا بد من رضا المحال عليه.

وحجة من قال بهذا: أن المحال عليه يلزمه الدين بالحوالة ، ولا لزوم إلا بالتزامه ولو كان مديونا للمحيل ؛ لأن الناس يتفاوتون في الاقتضاء ما بين سهل ميسر ، وصعب معسر ، ثم إن المحال عليه أحد من تتم بهم الحوالة ، فأشبهه المحيل ، فلا بد من رضاه.

الشرط الثاني : حضور المحال عليه وإقراره.

التساؤل : هل يشترط لصحة الحوالة حضور المحال عليه وإقراره أم لا ؟ اختلف الفقهاء في هذا على قولين :

القول الأول : يشترط من يقول به : حضور المحال عليه وإقراره بما عليه من الدين ، وإن كان رضاه بالحوالة لا يشترط وهذا قول ابن القاسم ، واقتصر عليه الوقار وصاحب الإرشاد وصاحب الكافي.

وحجة هذا القول : يشترط حضور المحال عليه وإقراره بما عليه من الدين ؛ لاحتمال أن يكون له مطعنا في البينة ، ولن يتمكن من ذلك إلا إذا حضر ، أو يثبت براءته من الدين ببينة على السداد والدفع ، أو على إقراره بالدفع ، أو إبرائه منه ، أو نحو ذلك.

والأثر المترتب على هذا القول : أنه لا تجوز الحوالة على الغائب ، وإن وقعت الحوالة على هذه الصورة فسخت حتى يحضر المحال عليه ، وهذا هو المعتمد في المذهب والمعتمد معناه : القوي سواء كانت قوته لرجحانه ، أو لشهرته.

القول الثاني : لا يشترط حضور المحال عليه في مجلس الحوالة ، وهذا هو قول عبد الملك وغيره من الموثقين والأندلسيين ، ولم أعر لهذا القول على حجة مستقلة لقولهم هذا إلا ما سوف يستنبط من سبب الخلاف بين القولين

سبب الخلاف بين القولين : هل الحوالة من قبيل بيع الدين بالدين ؟ أم هي أصل مستقل بنفسه ؟ فالقول الأول الذي اشترط حضور المحال عليه وإقراره بما عليه من الدين ، يرى أنها من قبيل بيع الدين بالدين ؛ ولذا فيشترط فيها شروطه ، (ومن أهمها حضور المدين وإقراره بما عليه من الدين) غاية ما في الأمر أنه رخص في جواز بيعه بدين آخر ، أما القول الثاني الذي لا يشترط حضور المحال عليه في مجلس الحوالة ، فبنى وجهته هذه على أساس أن الحوالة أصل مستقل بنفسه ، فلا يسلك بها مسلك بيع الدين بالدين من : اشتراط حضور المحال عليه وإقراره بما عليه من الدين .

الشرط الثالث : ثبوت دين المحيل والمحال ، وهذا الشرط يستلزم : أ - ثبوت دين المحيل في ذمة المحال عليه ب - ثبوت دين المحال في ذمة المحيل.

أ - ثبوت دين المحيل في ذمة المحال عليه.

لزوم الدين

يقول المصنف : **وَاخْتَرَزَ بِقَوْلِهِ (لَازِمٌ) عَنْ دَيْنٍ صَبِيٍّ وَسَفِيهِ وَرَقِيقٍ بِغَيْرِ**
إِذْنٍ وَلِيِّ وَسَيِّدٍ فَلَا تَصِحُّ الْإِحَالَةُ عَلَيْهِمْ بِهِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ ثَمَنُ سِلْعَةٍ مَبِيعَةٍ
بِالْخِيَارِ قَبْلَ لُزُومِهِ (فَإِنْ أَعْلَمَهُ) أَيْ أَعْلَمَ الْمُحِيلُ الْمُحَالَ (بِعَدَمِهِ) أَيْ الدَّيْنِ بِأَنْ
قَالَ لِلْمُحَالَ : لَا دَيْنَ لِي عِنْدَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ ، وَكَذَا إِنْ عَلِمَ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا فِي
الْمُدَوَّنَةِ.

(وَشَرَطَ) الْمُحِيلُ (الْبَرَاءَةَ) مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَرَضِيَ الْمُحَالَ (صَحَّ)
 التَّحَوُّلُ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُحِيلِ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ حَقَّهُ حَيْثُ رَضِيَ بِالتَّحَوُّلِ (وَهَلْ)
 مَحَلٌّ عَدَمَ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُحِيلِ (إِلَّا أَنْ يَفْلَسُ أَوْ يَمُوتَ) الْمُحَالَ عَلَيْهِ فَيَرْجِعُ
 الْمُحَالَ عَلَى الْمُحِيلِ ، أَوْ لَا يَرْجِعُ مُطْلَقًا مَعَ شَرْطِ الْبَرَاءَةِ ، وَإِلَّا رَجَعَ (تَأْوِيلَانِ)
 وَالْمَذْهَبُ الْإِطْلَاقُ^(١)

(١) أولاً : توضيح ما غمض من مفردات النص : معنى : " لزوم الدين " الدين اللازم هو :
 الدين الناشئ عن التزام صادر عن شخص يتمتع بأهلية الأداء الكاملة التي تستلزم : البلوغ
 ، العقل ، والرشد ، أي أن يكون مأدونا له في التصرف ، أي له ولاية إصداره ، سواء
 كانت هذه الولاية أصلية ، أو نيابية .

الخيار : هو : طلب خير الأمرين من الإمضاء ، أو الفسخ
 الفلّس : أفلس الرجل ، أي صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير ، ويستعمل مكان :
 افتقر ، وهو نوعان :

١ - فلّس عام وهو : إحاطة الدين بأموال المدين ٢ - فلّس خاص وهو : قيام الغرماء أي
 الدائنين بالطلب ، وقضاء القاضي بخلع ماله لغرمائه.

* قوله : " تأويلان " هذا من مصطلحات المالكية ، ويراد به : اختلاف شارحي المدونة في
 هذه المسألة - وإن لم يتصدوا لشرح سائرهما - في فهم المراد من ذلك الموضع ، المؤدي فهم
 كل له إلى خلاف فهم الآخر ، ويختلف المعنى به ، ويصير قولاً غير الآخر ، ويجوز الإفتاء
 بكل وإن لم يرجح بعضها على بعض.

المذهب : هذا من مصطلحات المالكية ، يطلق المذهب حيث يكون ذلك الحكم منصوفا عليه من الإمام مالك رحمه الله تعالى أو يكون هو مشهور المذهب.

ثانيا : الشرح والتعليق

يشترط المالكية لصحة الحوالة أن يكون الدين المحال به ، أو عليه لازما ، وهم بذلك يحترزون عن الحوالة على الدين الغير لازم ، كدين على صبي ، أو سفيه ، أو رقيق (والرق لا وجود له الآن) إذا استدان هؤلاء بغير إذن من ولاهم الشارع عليهم من ولي ونحوه ، فلا تصح الحوالة عليهم به ؛ لعدم لزوم الدين لهم لأن لولي الصغير ونحوه طرح الدين عنهم وإسقاطه ، وكذلك ثمن المبيع في زمن الخيار ؛ لأن البيع في زمن الخيار صحيح غير لازم وكذلك دين الكتابة (والمكاتب الذي لا وجود له الآن ؛ ولكن توضيح الحكم يستلزم ذكره) فدين الكتابة غير لازم للمكاتب لأن المكاتب إن عجز عن سداد دين الكتابة لا يتبع به ، فلا يصح أن يحيل السيد أجنبيا دائئا له على المكاتب

* وتصح الحوالة ولا يرجع المحال على المحيل إذا توفر ثلاثة شروط:

الأول منها : أن يعلم المحيل المحال بعدم الدين على المحال عليه بأن يقول المحيل للمحال : " لا دين لي عند المحال عليه " أو علم المحال بذلك من غيره .

الثاني منها : اشتراط المحيل على المحال البراءة من الدين الذي عليه.

والثالث : ورضي المحتال بذلك ، وإن لم يرض المحال عليه لكن إن رضي المحال عليه لزمه ، وإلا فلا يلزمه أن يطالبه المحال ، لا أصل الدين ، كما هو منصوص عليه في المدونة قال ابن القاسم فيها : " إذا علم أنه ليس له عليه دين فرضي بأن يحتال عليه ، وأبرأه من ذلك ، أنه لا يرجع عليه ، ويؤخذ هذا بما أقر به ، وإن كان لم يعلم فله أن يرجع. (المدونة الكبرى ج ٤ / ١٤٩ ، كتاب : الحوالة ، باب : في الرجل يحيل الرجل على الرجل ليس له عليه دين فيرضى المحتال أن يبرئه من الدين) وبناء على وجود هذه الشروط الثلاثة يصح التحول ولا رجوع للمحال على المحيل ؛ لأنه ترك حقه حيث رضي بالتحول على هذه الكيفية

* **تساؤل :** إذا أعلم - بالبناء للمجهول - المحال بعدم الدين على المحال عليه ، واشترط المحيل على المحال البراءة من الدين الذي عليه وأنه لا رجوع له بعد ذلك عليه ، ورضي المحتال بذلك وصح التحول ، فهل لا رجوع له مطلقا ؟ أي سواء فلس المحال عليه ، أو مات ، أو لا ؟

* **والجواب :** تأويلان في هذا:

الأول منهما : أنه لا يرجع المحال على المحيل إذا توافر الشرطان السابقان ما لم يفلس المحال عليه ، أو يموت ، أي أنه إذا أفلس المحال عليه ، أو مات رجع المحال على المحيل ، وهذا تأويل ابن المواز .

الثاني من التأويلين : أنه لا رجوع للمحال مطلقا إذا توافرت الشروط الثلاثة السابقة، أي سواء فلس المحال عليه ، أو مات وهذا هو ظاهر قول ابن القاسم ، ما دام أنه قد اشترط عليه البراءة من الدين ، وهذا هو المذهب .

*** تساؤل آخر :** إذا لم يكن هناك دين في ذمة المحال عليه للمحيل ورضي المحال عليه (مجازا) بالحوالة ودفع فعلا للمحال ، فهل له الرجوع على المحيل بما دفع ، أم لا ؟
*** والجواب :** لقد اختلف فقهاء المذهب في هذا على النحو التالي :

القول الأول : لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي (١٠١٠ - ١١٠١ هـ) لو رضي المحال عليه بالحوالة مع عدم ثبوت دين في ذمته للمحيل ، ومع هذا دفع رجوع له على المحيل بهذا الذي دفعه ؛ لأنه متبرع ؛ حيث لا دين عليه .

القول الثاني : قال به : عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد الزرقاني المصري (١٠٢٠ - ١٠٩٩ هـ) وهو أنه ينبغي أن يكون له الرجوع ؛ لأن اشتراط البراءة إنما هو بالنسبة للمحال (أي براءة المحيل من دين المحال ، أما المحال عليه فله الرجوع وسمي محال عليه تجوزا) ، ولأن رضا المحال عليه بالدفع صيره بمنزلة الحميل ، والحميل أي الضامن يرجع بما غرم وهو كالقرض من المحال عليه . [راجع فيما سبق : الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي ٣ / ٣٢٦ ، الشرح الصغير ٢ / ١٥٣ ، شرح الخرشي بحاشية العدوي ٤ / ٢٣٣ ، مواهب الجليل للحطاب ٥ / ٩٢ ، شرح الزرقاني بحاشية البناني ٦ / ١٨] .

القول الثالث : وقال به العلامة العدوي وهو : أن الذي ينبغي هنا أنه إن قامت قرينة على تبرع المحال عليه بما دفع فلا رجوع له بما دفعه ، وإلا كان له الرجوع ، كأن يكون هذا المحال عليه ذا غنى ويسار ، ومعروف عنه أنه يفرج كرب المكروبين

صيغة الحوالة

يقول المصنف : " (وَصِيغَتُهَا) أَي لَفْظُهَا الْخَاصُّ ، كَأَحْلَتُكَ عَلَى فُلَانٍ وَحَوَّلْتُ حَقَّكَ عَلَيْهِ وَأَنْتَ مُحَالٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَهِيَ مَا دَلَّ عَلَى تَرْكِ الْمُحَالِ دَيْنَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيلِ بِمِثْلِهِ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ انْتَهَى ، وَهُوَ شَامِلٌ لِنَحْوِ خُذْ حَقَّكَ مِنْ فُلَانٍ وَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَلَا تَتَحَصَّرُ صِيغَتُهَا فِي لَفْظِ مُشْتَقٍّ مِنَ الْحَوَالَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنَّفِ ^(١)

(١) الشرح والتعليق : علق ابن عرفة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير بقوله : وهذا محل نظر : لأن ظاهر كلام المصنف لا يقتضي انحصار صيغتها في اللفظ المشتق من الحوالة ، إلا أن يقال : إن هذا ظاهر بمعونة ما ذكره في الهبة حيث قال فيها : " الصيغة أو مفهمها " فأراد بالصيغة ما كان مشتقا من لفظ الهبة بقريضة قوله " أو مفهمها " فلما اقتصر هنا على قوله : " وصيغتها " ولم يقل : " أو مفهمها " دل على أن مراده بصيغتها : ما كان مشتقا من لفظ الحوالة [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ٥٣١] .

قوله : " وصيغتها " عطف على قوله : " ورضا المحيل " ورضا المحيل ركن ، وهو هنا يذكر شروط صحة الحوالة ، ففي كلام المصنف مسامحة ؛ لأن الصيغة ركن لا شرط ، لكن الفقهاء يتسامحون فيطلقون الشرط على الركن ، ووجه هذا التسامح : أن النتيجة المترتبة على تخلف أي منهما الركن أو الشرط واحدة وهي عدم صحة الحوالة.

* هل يشترط في صيغة الحوالة أن تكون بلفظ الحوالة ؟

* والجواب : في هذا اتجاهان :

الأول منهما : ظاهر كلام العلامة " خليل " وبعض الفقهاء أنه يشترط أن تكون الصيغة بلفظ الحوالة ؛ لأن الألفاظ التي ذكرها العلامة الدردير كأمثلة شارحا بها كلام العلامة " خليل " وهي : أحلتك على فلان أو حولت حقك على فلان ، أو أنت محال ، كل هذه العبارات تقتضي انحصار الصيغة فيما ذكر ، أي أن تكون مشتقة من لفظ : " التحول " ، ولأنه لم يقل كما قال في باب الهبة " أو مفهمها " أو ما دل ، وبناء على هذا قال ابن القاسم : في الرجل يطلب الرجل في حقه ، فيذهب به إلى غريم له فيقول له : خذ حقك من هذا ،

وبأمره بالدفع إليه ، فيتقاضاه إياه ، فيقضيه بعض حقه أو لا يقضيه ، فيريد أن يرجع على الأول ببقية حقه ، أو بحقه فله ذلك ، فليس هذا بوجه الحوالة اللازمة ؛ لأن له أن يقول : لم أحتل عليه بشيء ، إنما أردت أن اكفيك التقاضي ، وأما وجه التحول اللازم أن يقول : أحيلك على هذا بحقك علي وتبرئ ذمتي مما تطلبني به ، وأن لا ترجع علي ، وأيد هذا ابن رشد ؛ لأن الحوالة بيع من البيوع ينتقل بها الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فلا يكون ذلك إلا بيقين ، وهو التصريح بلفظ الحوالة.

الاتجاه الثاني : وهو لابن عرفة وهو المذكور في النص بقوله " مَا دَلَّ عَلَى تَرْكِ الْمُحَالِ دَيْنُهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيلِ بِمِثْلِهِ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ انْتَهَى وَهُوَ شَامِلٌ لِنَحْوِ خُذْ حَقَّكَ مِنْ فُلَانٍ وَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا تَنْحَصِرُ صِيَغَتُهَا فِي لَفْظٍ مُشْتَقٍّ مِنَ الْحَوَالَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ (والمعتمد سبق تعريفه في ص ٩)

حلول الدين المحال به

يقول المصنف : " (وَحُلُولُ) الدَّيْنِ (المُحَالِ بِهِ) وَهُوَ الَّذِي عَلَى الْمُحِيلِ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَالًا أَدَّى إِلَى تَغْيِيرِ ذِمَّةٍ بِذِمَّةٍ فَيُؤَدِّي إِلَى بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، أَوْ الْوَرَقِ بِالْوَرَقِ ، أَوْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ لَا يَدَا بَيِّدَ إِنْ كَانَ الدَّيْنَانِ عَيْنًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ حَالًا وَيَقْبِضُهُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا مِثْلَ الصَّرْفِ فَيَجُوزُ ، وَبَالَغَ عَلَى شَرْطِ حُلُولِ الْمُحَالِ بِهِ بِقَوْلِهِ (وَإِنْ كِتَابَةً) حَلَّتْ ، أَوْ عَجَلَ السَّيِّدُ عِتْقَهُ ، وَأَحَالَ بِهَا الْمُكَاتَبُ سَيِّدَهُ عَلَى دَيْنٍ لَهُ عَلَى غَرِيمٍ (لَا) حُلُولَ الدَّيْنِ الْمُحَالِ (عَلَيْهِ) فَلَا يُشْتَرَطُ " (١)

(١) أولاً : الصرف هو : دفع أحد النقدين من الذهب أو الفضة في مقابلة الآخر، ويعبر عنه في وقتنا الحاضر : بمبادلة نقود وطنية بأخرى غير وطنية ، كمبادلة الجنيهاات الوطنية بالدولارات الأمريكية.

ثانيا : قوله في النص : " وَإِنْ كِتَابَةً " الرقيق رغم أنه لا وجود له الآن إلا أنه من باب العلم بالشيء فهي : عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه.

الشرح والتعليق : يشترط لصحة الحوالة أن يكون الدين المحال به حالا ، وهو الذي في ذمة المحيل للمحال ، وعلة هذا الشرط أن الأصل في الحوالة المنع ، لكن رخص فيها الشارع بقيود منها حلول الدين المحال به ، وإلا خرجت عن حدود الرخصة والرخصة لا تتعدى موردها ، وأخذ البعض هذا الشرط من قول النبي صلى الله عليه وسلم : " مطل الغني ظلم " ووجه الاستدلال منه : أن المطل لا يكون إلا بالدين الحال ، ولا يشترط حلول ما على المحال عليه ؛ لأنه إذا احتال على من لم يحل عليه دينه كان ذلك زيادة معروف ، واستثنى من هذا (أي من اشتراط حلول الدين المحال به كشرط لصحة الحوالة) بمعنى أنه إذا كان الدين المحال به غير حال فلا تجوز الحوالة إلا أن يكون دين المحال عليه حالا ، وإلا فلا ، قال الرماصي (العلامة مصطفى الرماصي المالكي ، عالم جزائري ، من مدينة رماصة توفي في ١١٣٦ هـ / ١٧٢٤ م) : " إن خرجت الحوالة عن محل الرخصة لعدم حلول الدين المحال به ففي هذه الحالة تطبق عليها القواعد العامة ، فإن أدت إلى تعيير ذمة المحيل والمحال عليه بالمطالبة فتكون من بيع الدين بالدين ، ويمنع هذا للنهي عن ذلك ؛

لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : " نهى عن بيع الكالئ بالكالئ " وهو النسيئة بالنسيئة ، أي التأخير ، ومعناه لو كان الدينان عينا من ذهب أو فضة فليست يدا بيد عند اتحاد جنس الدينين وكذلك عند اختلافهما

تعليق إضافي : عند قول المصنف : " لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَالًا أَدَّى إِلَى تَعْمِيرِ ذِمَّةٍ بِذِمَّةٍ فَيُؤَدَّى إِلَى بَيْعِ الدَّيْنِ بِالْذَّيْنِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ أَوْ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ لَا يَدًا بِيَدٍ إِنْ كَانَ الدَّيْنَانِ عَيْنًا " قال العلامة العدوي : الصواب في تعليل المنع في هذه المسألة ما ذكره ابن عرفة من أنه يؤدي إلى " ضع وتعجل " و " حط الضمان وأزيدك " حيث إن المحيل ضامن لدين المحال ، فإذا ما أحاله بدينه الذي لم يكن حالا - وبمقتضى الحوالة سوف يبرأ منه - فكأن المحال وضع وأسقط الضمان عن المحيل وزاده في تعجيل دينه ؛ لأن من عجل ما أجل عد مسلفا في مقابل حط الضمان عنه ، أما ما ذكره العلامة الدردير في النص : " تَعْمِيرِ ذِمَّةٍ بِذِمَّةٍ " فهو لازم في جميع صور الحوالة ، كما ذكره القاضي عياض عن شيوخه ، كذا قرره بعض شيوخ أهل المغرب ، ثم بعد ذلك رأيت في " محشي التتائي " قال : مراد الأئمة بهذا : أنها من أصلها مستثناة من بيع الدين بالدين فهو لازم لها إلا أنه إذا حل المحال به كان ذلك محل الرخصة [حاشية العدوي / على شرح الخرشي ٦ / ٢٩٥ ، حاشية الدسوقي / الشرح الكبير ٤ / ٥٣١].

والإجماع منعقد على منع ذلك ، حكاه الإمام أحمد رحمه الله ، وإن أدت إلى بيع الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة ، أو أحدهما بالآخر لا يدا بيد إن كان الدينان عينا ، وهذا منهي عنه شرعا ، ودليل ذلك : ١ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُمَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَفِي لَفْظٍ : « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى ، الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ.

وَفِي لَفْظٍ : « لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ٢ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبَاً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبَاً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبَاً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبَاً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٣ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ،

وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَتْ يَدًا بِيَدٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.

ففي كل ما سبق تمنع الحوالة ؛ لأنها سوف تؤدي إلى ممنوع إلا إذا كان الدين المحال عليه حالا ويقبضه المحال قبل أن يتفرقا مثل الصرف ففي هذه الحالة يجوز .

تساوي الدينين

يقول المصنف : " (و) شَرَطُهَا (تَسَاوِي الدَّيْنَيْنِ) الْمُحَالِ بِهِ وَعَلَيْهِ (قَدْرًا وَصِفَةً) مُرَادُهُ بِالتَّسَاوِي قَدْرًا أَنْ لَا يَكُونَ الْمَأْخُذُ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ الْمُحَالِ بِهِ وَلَا أَقَلَّ فَلَا يُحِيلُ بِخَمْسَةٍ عَلَى عَشْرَةٍ وَعَكْسُهُ ؛ لِأَنَّهُ رَبًّا فِي الْأَكْثَرِ وَمَنْفَعَةً فِي التَّحَوُّلِ إِلَى الْأَقَلِّ ، فَيَخْرُجُ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَسَاوِي مَا عَلَيْهِ لِمَا لَهُ حَتَّى يَمْتَنِعَ أَنْ يُحِيلَ بِخَمْسَةٍ مِنْ عَشْرَةٍ عَلَى مَدِينَةٍ أَوْ بِخَمْسَةٍ مِنْ عَشْرَةٍ عَلَيْهِ كَمَا تُؤْهِمُّ ، وَكَذَا لَا يُحِيلُ بِخَمْسَةٍ مُحَمَدِيَّةٍ عَلَى مِثْلِهَا يَزِيدِيَّةٍ وَلَا عَكْسُهُ وَيَلْزَمُ مِنَ التَّسَاوِي فِي الصَّفَةِ التَّسَاوِي فِي الْجِنْسِ فَلَا حَاجَةَ لَزِيَادَتِهِ " (١)

(١) * الشرح والتعليق : يشترط لصحة الحوالة أن يكون الدين الذي يحيله به مثل الدين الذي يحيل عليه في القدر والصفة ؛ لأنه إذا اختلفا في أحدهما كان بيعا ولم يكن حوالة ، فخرج بذلك من باب الرخصة إلى باب البيع ، وإذا خرج إلى باب البيع دخله بيع الدين بالدين ، بناء على ذلك لا تصح حوالة بعشرة على أكثر منها ، أي على أن يأخذ المحال من المحال عليه خمسة عشر ؛ لأن هذا ربا.....

* اعتراض على هذا التعليق المطلق : قال ابن عرفة الدسوقي : ذكر هذا التعليق على إطلاقه لا يتم إذا كان الدين المحال به ثمن بيع ، إذ يجوز قضاؤه بأزيد عددا ، فالأولى أن يعطل : بأنه بيع دين بدين في غير مورد الرخصة ، وصورة الاعتراض : أن يكون " لمحمد " عند " علي " مبلغ ٥٠٠ ج خمسمائة جنيه ثمن ثلاجة لم يدفعها " علي " عند عقد البيع فيحيل " علي محمدا " على " أحمد " بمبلغ ٥٢٠ ج جنيه ، لمحمد عند أحمد ، فهذا جائز ؛ لأن محمدا ما أخر ثمن الثلاجة ليأخذ ٥٢٠ جنيه ، ولم يخطر في باله ذلك ولم يشترط على " علي " ذلك ولكنه فعل ما مدحه الرسول صلى الله عليه وسلم : " رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع ، وإذا اشترى ، وإذا اقتضى " رواه البخاري.

* وبناء على ما سبق: لا تصح الحوالة بعشرة للمحال عند المحيل على خمسة يأخذها المحال من المحال عليه هي كل ما للمحيل عند المحال عليه حيث قد انتفع المحيل بباقي

الحوالة بالأعلى على الأدنى

يقول المصنف : " (وَفِي) جَوَازِ (تَحْوِيلِهِ) بِالْأَعْلَى (عَلَى الْأَدْنَى) صِفَةً أَوْ قَدْرًا وَمَنْعِهِ (تَرَدُّدٌ) عِلَلُ الْجَوَازِ بِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ ، وَالْمَنْعَ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى التَّفَاضُلِ

ما كان للمحال عليه ، وهي بذلك تخرج عن المعروف الذي هو أصلها ؛ إذ أن من فعل معروفا لا يراعي منفعة دنيوية من ورائه.

فالحوالة إنما تجوز إذا كانت على وجه المعروف ، فإذا دخلها وجه من وجوه المكايسة والمغالبة رجعت إلى الأصل فلم تجز [حاشية الرهوني / على شرح الزرقاني ٥ / ٣٩٢] ، ثم إن الفقهاء قد صرحوا بأن الغرر في الحوالة مغتفر لتصريحهم بأنه لا يشترط فيها الكشف عن ذمة المحال عليه ، مع أن جهل ذلك يؤدي إلى الغرر قطعاً ، فقد نقل اللخمي عن المازري ما نصه : " أنه لا يلزم عند الإمام مالك الكشف عن ذمة المحال عليه ، هل هو غني أم فقير ؟ بخلاف مشتري الدين ، فإنه لا يجوز إلا أن يكون من عليه الدين حاضراً ومقراً ، يعرف غناه من عدمه ، وفرق المازري بينهما : بأن الدين المشتري يختلف مقدار عوضه باختلاف حال المدين من فقر أو غنى ، والمبيع لا يصح أن يكون مجهولاً ، فإذا لم يعلم حال المدين صار مشترياً لمجهول والحوالة ليست بيعاً على أحد الطرفين عندنا ، بل طريقها المعروف [حاشية الرهوني / على شرح الزرقاني ٥ / ٣٩٢]

* **ونلاحظ:** أنه ليس المراد من التساوي أن يتساوى ما للمحيل عند المحال عليه لما للمحال عند المحيل ، حتى لا يمتنع أن يحيل بخمسة عليه للمحال على خمسة من عشرة له عند المحال عليه أو يكون له عند المحال عليه خمسة وللمحال عشرة على المحيل فيحيله بخمسة منها على المحال عليه.

* **والتساوي في الصفة :** فلا يحيل بخمسة دنانير محمية له على المحال عليه بخمسة يزيدية للمحال على المحيل ؛ لأنه ربا ؛ إذ أنه سلف بزيادة حيث يختلف وزن كل منهما عن الآخر ، وكذلك التساوي في الجنس : فلا يحيل بعشرة دنانير عليه للمحال بمائة درهم للمحيل عند المحال عليه ؛ لأنه ربا ، وهو ما يسمى بالصرف المؤخر المنهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم : " فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ

بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ فَمُرَادُهُ بِالْأَدْنَى مَا يَشْمَلُ الْأَقْلَّ وَالْمَذْهَبُ الْمَنْعُ فَكَانَ الْأَوَّلَى
الِإِقْتِصَارَ عَلَى قَوْلِهِ " وَتَسَاوِي إلخ " (١)

(١) معنى بعض المفردات : قول العلامة خليل : " تردد " هذا من مصطلحات المذهب
استعمله بمعنى الاختلاف والتحير وجاء على عدة أوجه : الوجه الأول: تردد المتأخرين
(من أول ابن أبي زيد القيرواني ت ٣٨٦ هـ) في النقل عن المتقدمين ، ولذلك ثلاث صور:
الأولى : أن ينقل أحد المتأخرين أو بعضهم حكما لواقعة معينة في باب ، وينقل آخرون
حكما آخر لنفس الواقعة في باب آخر .

الثانية : أن ينقل بعضهم اتفاق المتقدمين على حكم نازلة معينة وينقل آخرون اختلافهم في
حكم هذه النازلة ؛ ويعود ذلك لأمرين :

١ - إما أن يكون للإمام في المسألة قولان ٢ - أو اختلافهم في فهم كلام الإمام ، فينسب
إليه ما فهمه من كلامه

الثالثة: أن ينقل بعضهم حكما وينقل الآخر خلافاً .

والوجه الأول: هو الغالب ، الوجه الثاني : تردد المتأخرين في استنباط الحكم نفسه ، وذلك
لعدم نص المتقدمين على هذا الحكم .

الوجه الثالث : يستعمل لفظ التردد بشأن الشخص نفسه كأن يستتبط حكما ؛ ويكون متحيراً
فيه ؛ وذلك مثل ما جاء في مصارف الزكاة قوله : «وفي غارم يستغني تردد» يقول الشيخ
عليش : « للخي وحده ونصه : " وفي الغارم يأخذ ما يقضي به دينه ثم يستغني قبل أدائه
إشكال ، ولو قيل تنزع منه لكان وجهها فالأولى واختار نزاعها من غارم استغنى "

الوجه الرابع : استعمله إذا كثر الخلاف بين المتقدمين وتشعبت الطرق ، ومثال ذلك قوله:
«ففي الاكتفاء بالتذكية الأولى تردد» قال الشيخ عليش : «(تردد) للمتأخرين في النقل عن
المتقدمين بطرق كثيرة » ، وقد يأتي بلفظ غير التردد في موضع التردد كالنظر

الشرح والتعليق : أولاً : المراد بالأدنى هنا ما يشمل : الأدنى في الأوصاف ، والقلة ، أي
العدد ؛ حيث إن الشأن عند ما يستعمل كلمة الأدنى فيراد بها : في الأوصاف فبين مراده
هنا من أنها تشمل الأدنى في الذات كذلك ، أي الأقل عدداً .

ثانياً : التحول بالأدنى على الأعلى ، أو الأكثر يمنع قولاً واحداً لأنه ربما [شرح الخرشي
على مختصر خليل ٤ / ٢٣٥] .

* ولكن هل يجوز التحول بالأعلى على الأدنى ؟

للإجابة على هذا التساؤل تردد فقهاء المذهب على رأيين:

الرأي الأول : ذهب إليه ابن رشد ، وعياض إلى المنع من ذلك، وعلا هذا بأن الحوالة بيع ، والحوالة بالأعلى على الأدنى سوف تؤدي إلى التفاضل بين العينين ، وهذا لا يجوز ؛ لأنه إن كان الدينان ذهبا فيشترط فيهما التماثل ، وأن يكونا يدا بيد ، وهذا غير موجود هنا ، وإن كان أحدهما ذهبا والآخر فضة فلن يكون يدا بيد وهذا ممنوع شرعا ؛ لأنه يؤدي إلى الصرف المؤخر المنهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم : " فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا بَيْدٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

الرأي الثاني : ذهب إليه اللخمي والمازري والمتيطي ، فقالوا بجواز ذلك ، أي الحوالة بالأعلى على الأدنى ، وعللوا هذا : بأن الحوالة معروف ؛ لأنها عقد إرفاق يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره.

وسبب الخلاف هو : هل الحوالة مستثناة من بيع الدين بالدين ؟ أم هي عقد مستقل بنفسه قصد به الإرفاق والتيسير على الناس ؟

* **والمختار من الرأيين هو :** الأول حيث إنه المذهب ، ولهذا كان الأولى بالمصنف خليل أن يكتفي بقوله سابقا " وتساوي الدينين " [الشرح الكبير ، بحاشية الدسوقي ٣ / ٣٢٧ ، مواهب الجليل للحطاب ٥ / ١٩] .

ألا يكون المحال به وعليه طعاما من بيع أو أحدهما:

يقول المصنف : " (وَأَنْ لَا يَكُونَ) أَيِ الدَّيْنَانِ الْمُحَالُ بِهِ وَعَلَيْهِ (طَعَامًا مِنْ بَيْعٍ) أَيِ سَلَمٍ ؛ لِئَلَّا يَدْخُلَهُ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَسَوَاءٌ اتَّفَقَتْ رُءُوسُ الْأَمْوَالِ أَوْ اخْتَلَفَتْ ، وَشَمَلَ كَلَامُهُ مَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ بَيْعٍ وَالْآخَرُ مِنْ قَرْضٍ ، فَتَجُوزُ إِذَا حَلَّ الْمُحَالُ بِهِ فَقَطْ أَخْذًا مِمَّا قَدَّمَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ جَمِيعِ الْأَصْحَابِ إِلَّا ابْنَ الْقَاسِمِ فَاشْتَرَطَ حُلُولَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَيْضًا ابْنُ عَرَفَةَ الصَّقَلِيُّ : وَقَوْلُهُمْ أَصَوَّبُ ؛ فَلِذَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنَّفُ هُنَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ : كِلَا الْقَوْلَيْنِ ضَعِيفٌ ، وَأَنَّ الْمَذْهَبَ قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ الْمُصَنَّفُ فِي الْبَيْعِ حَيْثُ قَالَ : وَجَارَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ إِلَّا فِي مُطْلَقِ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ " (١)

(١) أولا : لماذا لم يقل : " طعامين " ؟ لأن طعاما مصدر مؤكد والمصدر اسم معنى يدل على حدث مجرد ، غير مقيد بزمان ولا بمكان ، ولا هيئة حدوثه أو مرات حدوثه ، ولا يدل على من أحدثه أو اتصف به ، ولا على من وقع الحدث عليه فهو يدل على معنى ذهني مطلق من كل القيود والعلاقات والمصدر المؤكّد لفعله هو (المطلق) حقاً ، فلا وجه لتثنيته أو جمعه.

الشرح والتعليق : يشير المصنف بهذا إلى الشرط الأخير من شروط صحة الحوالة ، وهو يحتوي على صورتين الصورة الأولى وهي : ألا يكون الدينان طعاما من بيع لأنه لا يصح أن يقبضه إلا صاحبه ؛ لما يلزم عليه من بيع طعام المعاوضة قبل قبضه وهو منهي عنه ، وتوضيح ذلك أنه يجب أن لا يكون كل من المحال به والدين المحال عليه طعاما من بيع ، أي سلم ؛ لأنه لو كان كذلك فسوف تدخله العلة المحرمة وهي بيع طعام المعاوضة قبل قبضه، وهو لا يجوز، كأن يكون للمحال (المسلم) عند المحيل (المسلم إليه) عشرة أرادب من القمح على سبيل السلم ، فيحيله على المحال عليه الذي هو مدين للمحيل بعشرة أرادب من قمح كذلك.

ودليل النهي عن ذلك : ١ - ما رواه مسلم بسنده عن ابن عباس ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ » قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : « وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ ».

٢ - وما رواه مسلم أيضا بسنده عن ابن عمر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : « مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ».

٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ : أَحَلَلْتَ بَيْعَ الرَّبَا ، فَقَالَ مَرْوَانُ : مَا فَعَلْتَ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : « أَحَلَلْتُ بَيْعَ الصِّكَاكِ ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى » ، قَالَ : فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ ، «فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا» ، قَالَ سُلَيْمَانُ : فَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ ، [والصكاك : جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين ويجمع أيضا على صكوك والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك للإنسان قبل أن يقبضه].

ففي هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه المشتري واختلف العلماء في ذلك، فقال الشافعي : لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منفولا أو نقدا أو غيره وقال عثمان النبتي : يجوز في كل مبيع ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز في كل شيء إلا العقار ، وقال مالك : لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون ، وقال آخرون : لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواهما ، أما مذهب عثمان النبتي فحكاه المازري والقاضي ولم يحكه الاكثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه ، قالوا وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك والله أعلم.

* وما هي علة المنع من هذا ؟ قيل: منع هذا تعبدا ، أي لا يعطل المنع ، وقيل: معطل بأن غرض الشرع سهولة الوصول إلى الطعام ومنع احتكار أقوات الناس من فئة قليلة ، وفي هذا من الضرر ما فيه فمنع هذا ؛ ليتوصل إليه القوي والضعيف ، ولو جاز بيعه قبل قبضه فلربما أخفي بإمكان شرائه من مالكة وبيعه خفية ، فلم يتوصل إليه الفقير ، ولأجل نفع الحمال والكيال .

* الصورة الثانية : أن يكون أحد الدينين طعاما من بيع والاخر طعاما من قرض ، وهذه الصورة اختلف فيها فقهاء المذهب على النحو التالي :

الرأي الأول : وقال به جميع الأصحاب عدا ابن القاسم : أن الحوالة جائزة في هذه الصورة إذا حل المحال به فقط - وهي العشرة أرادب من بيع أي سلم - لأنه طعام لم يبيع قبل قبضه

واعترض ابن عاشر على هذا (وابن عاشر : هو أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر ٩٩٠ - ١٠٤٠ هـ يعد من أبرز علماء المذهب المالكي) بقوله : علة المنع السابقة وهي بيع طعام المعاوضة قبل قبضه موجودة في هذه الصورة فما وجه الجواز ؟
وأجيب عن هذا الاعتراض : بأن قضاء القرض بطعام البيع - السلم - جائز ، وصورتها : أن المحيل مدين للمحال بعشرة أرداد من قمح على سبيل القرض أي السلف والمحال عليه مدين للمحيل بعشرة أرداد من قمح على سبيل السلم أي أن المحيل عجل للمحال عليه ثمن عشرة أرداد من قمح يأخذها منه عند الحصاد قمحا ، فتصح الحوالة بالعشرة قرضا إذا حل أجله على العشرة من سلم الذي لم يحل بعد.

* **تعليق** : هذه الإجابة ظاهرة وواضحة فيما إذا كان المحال به طعام القرض والمحال عليه طعام السلم - البيع - ولكن توقف ابن عاشر في الصور العكسية ، وهي أن يكون المحال به طعام البيع - السلم والمحال عليه طعام القرض ، فإن علية المنع وهي بيع طعام المعاوضة قبل قبضه موجودة هنا تحقيقا [تعليق العلامة عليش / حاشية الدسوقي ٣ / ٣٢٦ ، شرح الخرشي ٤ / ٢٣٥ ، شرح الزرقاني ٦ / ١٩] .

الرأي الثاني : وقال ابن القاسم لا بد من حلول المحال عليه أيضا ، وصوب البعض الرأي الأول ، أي يكفي حلول المحال به فقط ، وقال الدردير : كلا القولين ضعيف ، والمذهب قول ابن رشد : بالمنع مطلقا سواء كان المحال به ، والمحال عليه كلا منهما من بيع ، أو أحدهما من بيع والآخر من قرض ، وذلك لأنه ذكر سابقا في باب البيع قوله : " وجاز لمشتري وموهوب شيئا البيع قبل القبض من البائع والواهب إلا مطلق طعام المعاوضة أي الذي في مقابلة شيء ، وأراد بمطلقه ربويا كقمح ، أو لا كتفاح فلا يجوز بيعه قبل قبضه ، ولو كان طعام المعاوضة كرزق قاض وإمام مسجد ، ومؤذن ، وجندي ، وكاتب ، مما جعل لهم في بيت المال ، كعالم جعل له في نظير التعليم ، ومحل المنع ؛ حيث أخذ أي اشتري بكيل ، أو وزن ، أو عدد لا جزافا فيجوز بيعه قبل قبضه ؛ لدخوله في ضمان المشتري بمجرد العقد ، فهو مقبوض حكما ، فليس فيه توالي عقدتي بيع لم يتخللها قبض .

أحكام الحوالة

الفرق بين الغرر في الحوالة والغرر في البيع

يقول المصنف : " لَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى الشُّرُوطِ السَّتَّةِ أَخْرَجَ مِنْهَا قَوْلَهُ (لَا كَشْفُهُ) أَيَّ لَيْسَ مِنْ شُرُوطِهَا أَنْ يَكْشِفَ الْمُحَالُ (عَنْ ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ) أَغْنَى هُوَ أَمْ فَقِيرٌ ، بَلْ تَصِحُّ مَعَ عَدَمِ الْكَشْفِ عَلَى الْمَذْهَبِ " (١)

(١) الشرح والتعليق : عقد الحوالة من باب المعروف والعقود المبنية على المعروف يتسامح فيها ويغتفر ما لا يتسامح ولا يغتفر في غيرها، ولهذا جاز فيها الغرر (والغرر هو : ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أيكون أم لا ؟) بخلاف بيع الدين فإنه يشترط فيه العلم بحال ذمة المدين ، وإلا كان غررا ، فقد قال المازري : " شرط صحة بيع الدين : علم حال ذمة المدين ، وإلا كان غررا ، بخلاف الحوالة فاغتفر فيها الغرر ، ولهذا اشترط حضور المدين في بيع الدين بالدين ليعلم حاله ، من فقر أو غنى ؛ إذ لا بد من علم ذلك لاختلاف مقدار عوض الدين باختلاف حال ذمة المدين من فقر ، أو غنى ، والبيع لا يصح ان يكون مجهولا وبيع الدين بالدين هو ما يعبر عنه بـ (بيع الكالئ بالكالئ) من الكلاءة بكسر الكاف ، أي الحفظ .

واعترض على هذا : بأن الدين مكلوء لا كالئ ، والكالئ إنما هو صاحبه لأنه الذي يحفظ الدين.

وأجيب عن هذا : بأن هذا مجاز في إسناد معنى الفعل لملايسه ، فحق الكلاءة أن تسند للشخص بأن يقال : كالئ صاحبه ، فأُسندت للدين للملابسة التي بين الدين وصاحبه ، أو أن كالئ بمعنى مكلوء ، فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول لعلاقة اللزوم ؛ لأنه يلزم من الكالئ المكلوء وعكسه.

وصورة بيع الدين بالدين : أن يشتري زيد من الناس شيئا بثمن مؤجل فإذا حل أجل السداد لم يجد زيد ما يسدد به الثمن فيقول لعمره اشتريه مني إلى أجل بزيادة شيء من غير قبض ، أو هو : بيع ما على مدينك (المحال هنا يبيع ما له عند المحيل) بدين في ذمة رجل ثالث فبيعه بمعين حال ، أو بمعين يتأخر قبضه ، أو بمنافع معين فلا يمنع، ولكن بشروط وهي : ١ - أن يكون المدين حيا ٢ - أن يقر المدين بالدين ، فإذا لم يقر بالدين فلا يصح بيع الدين ، ولو كان الدين ثابتا بالبينة ؛ لأنه من بيع ما فيه خصومة ٣ - تعجيل

الثلث حقيقة ، أو حكما ، كبيعه بمنافع معين يتأخر قبضها ؛ لأن قبض الأوائل قبض للأواخر ، كأن يسكنه دارا شهرا ٤ - أن يكون الثمن من غير جنس الدين ، أو من جنسه في غير العين واتحدا قدرا وصفة ، لا إن كان أقل لما فيه من دفع قليل في كثير ، وهو سلف بمنفعة ٥ - أن لا يكون الدين ذهبا بيع بفضة أو العكس ؛ لما في ذلك من الصرف المؤخر المنهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم : " فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " ٦ - ألا يكون الدين طعام معاوضة ، وإلا لزم منه بيع طعام المعاوضة قبل قبضه ، وقد ورد النهي عنه من الشارع سابقا ٧ - أن يكون المدين حاضرا ٨ - أن يكون المدين ممن تأخذه الأحكام ٩ - ألا يكون بين المشتري والمدين عداوة.

تنبيه

يقول المصنف : " تنبيه : من اشترى دينا ، أو وهب له وكان برهن ، أو حميل فإن الرهن والضمان لا ينتقل كلا منهما مع الدين المباع ، أو الموهوب إلا بشرط انتقالهما وحضور الحميل وإقراره بالحمالة .. وإن كره الحميل التحمل لمن ملكه ، وهذا بخلاف من ورث دينا برهن ، أو حميل ، فإنه يكون له ما به ، وإن لم يشترط ذلك وللراهن وضعه عند أمين إذا كره وضعه عند الوارث^(١)

(١) الشرح والتعليق : النص واضح ، والفرق بينهما : من وجهين :

الأول : أن الهبة ، أو الشراء للدين لهما تعلق بالإرادة ، ومبناهما على الرضا ، وسند ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" أما الميراث فلا دخل للإنسان فيه.

الثاني : أن الوارث خليفة المورث فيما يثبت للمورث من حقوق ، والرهن والضمان حق من الحقوق وصورة الميراث الموثق برهن ، أو ضمان : أن يكون لوالد زيد من الناس دين على عمرو من الناس أخذ هذا الوالد من المدين رهنا ، أو ضامنا ، ثم مات هذا الوالد قبل سداد الدين ، فورث ابن هذا الدائن هذا الدين فيرثه بما فيه من وثيقة الرهن ، أو الضامن.

انتقال الدين المحال به بمجرد الحوالة

يقول المصنف : " (وَيَتَحَوَّلُ) بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْحَوَالَةِ (حَقُّ الْمُحَالِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَفْلَسَ أَوْ جَدَّ) الْمُحَالُ عَلَيْهِ الْحَقُّ بَعْدَ عَقْدِ الْحَوَالَةِ ، وَأَمَّا جَعْدُهُ قَبْلَهَا وَلَا بَيِّنَةٌ ، فَلَا تَصِحُّ ؛ لِفَقْدِ شَرْطِهَا مِنْ ثُبُوتِ الدَّيْنِ ، بِخِلَافِ الْفَلَسِ حِينَ الْحَوَالَةِ فَلَا يَمْنَعُ مِنْهَا بَلْ يَتَحَوَّلُ الْحَقُّ مَعَهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ (إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْمُحِيلُ بِإِفْلَاسِهِ) أَيْ إِفْلَاسِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ (فَقَطُّ) أَيْ دُونَ الْمُحَالِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُحِيلِ ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الظَّنَّ الْقَوِيَّ كَالْعِلْمِ ، وَمِثْلُ عِلْمِهِ بِإِفْلَاسِهِ عِلْمُهُ بِلَدِّهِ أَوْ عَدَمِهِ (وَحَلَفَ) الْمُحِيلُ (عَلَى نَفْسِهِ) أَيْ نَفْيِ الْعِلْمِ بِإِفْلَاسِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ إِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ الْمُحَالُ الْعِلْمَ (إِنْ ظَنَّ بِهِ الْعِلْمَ) أَيْ إِنْ كَانَ مِثْلُهُ يُظَنُّ بِهِ ذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يَخْلِفْ وَإِنْ اتَّهَمَهُ الْمُحَالُ فَقَوْلُهُ : " ظُنُّ " بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ ^(١)

(١) الشرح والتعليق : لغويات النص : التفليس : من أفلس الرجل ، إذا لم يبق له مال ، يراد به ، أنه صار إلى حال ، يقال فيها : ليس معه فلس (والفلس عملة يتعامل بها مسكوكة من غير الذهب والفضة ، وتقدر بسدس درهم ، وهي تساوي اليوم جزءا من ألف من الدينار في العراق وغيره) فيقال أفلس الرجل : صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ، وقد فلسه الحاكم تفليسا : نادى عليه أنه أفلس ، والفلس شرعا ، له معنيان ، عام ، وخاص والفلس بمعناه العام : قيام الغرماء على ذي دين حل ليس له ما يفي به ، فلهم سجنه ، ومنعه من البيع والشراء والأخذ والعطاء والفلس بمعناه الخاص هو : حُكْمُ الْحَاكِمِ بِخُلْعِ مَا بِيَدِهِ لِغُرَمَائِهِ لِعَجْزِهِ عَنْ وَقَاءِ مَا عَلَيْهِ ، وَيَتَحَوَّلُ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْحَوَالَةِ حَقُّ الْمُحَالِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَفْلَسَ أَوْ جَدَّ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الْحَقُّ بَعْدَ عَقْدِ الْحَوَالَةِ ، ما دام لم يشترط المحال يسار المحال عليه، وبناء على هذا لا يجوز للمحال الرجوع على المحيل أبدا ، أي سواء أمكنه الاستبفاء ، أو تعذر له لمطل ، أو فلس ، أو غير ذلك ، وهذا ما قاله الليث بن سعد ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وابن المنذر ، وظاهر كلام الخرقى من الحنابلة ، ووافق هؤلاء كلهم

الإمام أحمد إلا فبي مسألة الفلس فقد نقل عنه : انه إذا أفلس المحال عليه ، ولم يعلم المحال بذلك ، فله الرجوع على المحيل إلا إذا علم ورضي فلا يجوز له الرجوع ولكن ما الحكم : لو اشترط المحال بسار المحال عليه فظهر بخلاف ذلك؟ في هذا رايان :

الأول منهما : ومضمونه : انه إن شرط المحال على المحيل أنه إن أفلس المحال عليه أي وجده مفلسا رجع على المحيل فله شرطه ، قال بهذا سحنون نقلا عن المغيرة ، ونقله الباجي كانه المذهب ، وقال ابن رشد : هذا صحيح لا أعلم فيه خلافا
ودليل هذا الرأي : أ - من السنة ، قوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " رواه الترمذي وصححه وأبو داود بلفظ " المؤمنون .. " فهذا شرط يجب الوفاء به ب - ومن المعقول : أن هذا شرط فيه مصلحة العقد ، وهو في عقد معاوضة ، فكان كشرط صفة في المبيع ، فإن بأن معسرا فله الرجوع على المحيل لفوات شرطه وتخلفه.
الرأي الثاني : أن هذا الشرط لا يعمل به ، بل ويفسد العقد عند المالكية (وقيل : الشرط فقط) وأصل المذهب في الشرط المناقض لمقتضى العقد أنه يفسده ، وبناء على ذلك - أي على فساد الشرط - ، فليس له الرجوع ؛ لأنه مقصر بتركه الفحص والاحتياط لماله وما الحكم إذا جحد المحال عليه الحق ، والحال ألا بينة للمحيل بحقه على المحال عليه الجاحد ؟

والجواب : أن جحد المحال عليه الحق والحال ألا بينة للمحيل بحقه على المحال عليه الجاحد ، وكان ذلك قبْلَ الحوالة وَلَا بَيِّنَةٌ للمحيل بحقه على المحال عليه الجاحد فَلَا تَصِحُّ الحوالة لِفَقْدِ شَرْطِهَا مِنْ ثُبُوتِ الدَّيْنِ ؛ لأن المحال عليه لم يصدق على دينه.

فلس المحال عليه

أما فلس المحال عليه حين الحوالة فلا يمنع منها بل يتحول الحق مع إفلاس المحال عليه بشرط أن يكون المحال عالماً بإفلاس المحال عليه * أما إذا علم المحيل وحده فقط بإفلاس المحال عليه أي دون المحال فله الرجوع على المحيل ؛ ويثبت علم المحيل بإفلاس المحال عليه إما ببينة ، أو بإقراره بذلك ؛ لأنه عرّه ، والظاهر أن الظن القوي كالعلم ، ومثل علمه بإفلاسه علمه بلده أو عدمه ، أو أنه سيئ القضاء وهناك قيد آخر : ألا يكتب الموثق في عقد الحوالة : بعد معرفة المحال ملاء المحال عليه وموضعه ، فإذا كتب الموثق هذا فلا رجوع للمحال بأي وجه على المحيل (حاشية العدوي / على شرح الخرشي ج ٤ / ٢٣٦) وحلف المحيل على نفي العلم بإفلاس المحال عليه إذا ادعى عليه المحال العلم إن ظن بالمحيل العلم أي إن كان مثله يظن به ذلك وإلا لم يخلف وإن اتهمه المحال فقله ظن بالبناء للمجهول.

* ولكن ما الحكم إذا علم المحيل بإفلاس المحال عليه وشك المحال في إفلاس المحال عليه ؟ فإن شك المحال في إفلاس المحال عليه مع علم المحيل بذلك ففي ابن عرفة والتوضيح والشامل ، وهو المعتمد : أن للمحال الرجوع على المحيل تقديماً لما أثبتته العلم على الشك ؛ لأن اليقين لا يزال بالشك ، وهذا هو الذي ذهب إليه اللخمي وابن عرفة * قال الخرشي : لا رجوع للمحال على المحيل في هذه الحالة ، وإن جهلا معا ؟ قيل : لا رجوع على المحيل ؛ لأن المحيل ليس منه شيء والمحال هو المقصربعدم الشرط ، أو بعدم الفحص عن ذمة المحال عليه.

* سؤال : ما الحكم إذا ادعى المحال على المحيل أنه كان يعلم بإفلاس المحال عليه ؟ إذا ادعى المحال على المحيل أنه كان يعلم بإفلاس المحال

عليه حلف المحيل على نفي العلم بإفلاس المحال عليه وبرئ من المطالبة بشرط : أن يكون مثله يظن به أنه يتهم بالعلم بإفلاس المحال عليه ، كأن يكون المحال عليه قريبا ، أو مخالطا للمحيل ولا يخفى عليه شأنه وحاله ، فإذا لم يظن به ذلك لم يحلف وإن اتهمه المحال.

* سؤال : ما نوع هذه اليمين ؟ هذه اليمين التي يحلفها المحيل (المدعى عليه بالعلم بإفلاس المحال عليه) يمين اتهام يبرأ بها الحالف بمجرد الحلف ، فإذا نكل أي امتنع منها غرم الحق المدعى به ، ولا ترد اليمين على المدعي ، بمعنى أنه إذا امتنع المحيل - المدعى عليه هنا - من اليمين رجع المحال بحقه عليه مباشرة بخلاف يمين التحقيق - التي فيها : إذا امتنع المدعى عليه وهو هنا المحيل من الحلف فترد اليمين على المدعو هو هنا المحال - خالف في ذلك الخرشي : حيث يرى حلف المحال بعد امتناع المحيل من اليمين ، حيث قال : " وإن نكل حلف المحتال ويرجع بدينه على المحيل " واعترض عليه العدوي (حاشية العدوي / على شرح الخرشي ج ٤ / ٢٣٦) بما ذكرنا من أنها يمين اتهام لا تحقيق ، ودليل هذا ، ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع " ووجه الاستدلال منه : أنه لو أحيل على مفلس وكان حقه نائيا - أي بعيدا - عن المحيل بأن كان المحيل معدما ، فهل كان يزداد بذلك إلا خيرا إن أيسر المفلس أي المحال عليه ، وإلا فحقه حيث كان عند المحيل المعدم.

فروع فقهية على ما سبق

يقول المصنف : " ثُمَّ فَرَعَ عَلَى قَوْلِهِ : وَيَتَحَوَّلُ ...إِلْخَ قَوْلُهُ (فَلَوْ أَحَالَ بَائِعٌ لِسِلْعَةٍ شَخْصًا بَدِينٍ لَهُ كَانَ عَلَى الْبَائِعِ (عَلَى) (مُشْتَرٍ) لِتِلْكَ السِّلْعَةِ (بِالثَّمَنِ) أَيْ بِثَمَنِهَا (ثُمَّ رَدَّ) الْمَبِيعِ الْمَفْهُومَ مِنْ بَائِعٍ عَلَى بَائِعِهِ الْمُحِيلِ (بِعَيْبٍ) أَوْ فُسَادٍ (أَوْ اسْتَحَقَّ) الْمَبِيعِ مِنْ يَدِ مُشْتَرِيهِ (لَمْ تَنْفَسِخْ) الْحَوَالَةُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ؛ لِأَنَّهَا مَعْرُوفٌ ، فَيُلْزَمُ الْمُشْتَرِي دَفْعُهُ لِلْمَحَالِ وَيَرْجَعُ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ الْمُحِيلِ (وَاخْتِيرَ خِلَافُهُ) أَيْ اخْتَارَ ابْنُ الْمَوَازِ وَغَيْرُهُ خِلَافَ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ بِفَسْخِ الْحَوَالَةِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ " (١)

(١) الشرح والتعليق : * أولا شرح معاني مفردات النص : قوله (أو استحق) الاستحقاق هو : رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله ، أو حرية . قوله : (واختير خلافه) مراد المالكية بهذا اللفظ : ما اختاره بعض الأئمة لدليل رجحه به ، وقد يكون ذلك المختار هو المشهور ، أو خلافه ، قوله : (وعليه الأكثر) أي أنه مشهور .

الأحكام التي في النص : يوضح المصنف هنا حكم ما إذا أحال بائع لسلعة ما - لم يقبض هذا البائع ثمن السلعة بعد من المشتري - شخصا ما ، هذا الشخص دائن للبائع بمبلغ من المال فأحاله البائع على مشتري تلك السلعة بثمن هذه السلعة ، ثم رد المبيع لعيب فيه ، أو فساده ، أو أن هذه السلعة استحققت من يد مشتريها ، فقد اختلف فقهاء المالكية في حكم الحوالة هنا على رأيين وهما :

الرأي الأول : قال به ابن القاسم وهو : عدم انفساخ الحوالة ، بناء على ذلك ، يلزم المشتري دفع ثمن ما اشتراه للمحال ، ثم يرجع بما دفعه على المحيل - البائع - ودليل هذا : أن الحوالة معروفة ، والثمن لازم للمشتري حين الحوالة ، وكأنه أي الرد بالعيب ابتداء بيع ، ولتعلق الحق في الحوالة بشخص ثالث وهو الذي انتقل إليه الثمن المحال فلم يبطل حقه بفسخ المتعاقدين ، قياسا على ما لو تصرف البائع في الثمن ثم رد المشتري ما اشتراه بعيب ، فإن تصرف البائع في الثمن لا يبطل ، ثم إن العبرة بحال ووقت عقد الحوالة فالعقد

صحيح لا يبطل [الشرح الكبير للدريير ج ٢ / ٣٢١ ، وقد نص على هذا في المدونة ،
المدونة الكبرى ج ٤ / ١٥٠ كتاب الحوالة ، والبيان والتحصيل ، لابن رشد ج ١١ /
٣٥٧ ، كتاب الحوالة والكفالة]

الرأي الثاني : وهو ما اختاره ابن المواز ، وهو قول أشهب ، وعليه أكثر الفقهاء: أن الحوالة
تتفسخ ، وهذا هو المعتمد [الشرح الكبير للدريير ج ٢ / ٣٢١ ، شرح الخرشي ج ٤ /
٢٣٦ ، ومواهب الجليل ، للحطاب ج ٦ / ٩٠] ودليل هذا القول ، أنه لما رد المبيع بالعيب
، أو الفساد انفسخ البيع فصار كأن لم يكن ، فلا شيء في هذه الحالة على المشتري ،
فعلى ماذا يحيل البائع ؟ والحوالة فرع عن البيع ، فإذا بطل الأصل بطل الفرع المترتب
عليه.

مسألة : إذا أحال مشتر بالثمن الذي عليه البائع على مدين للمشتري ، ثم حصل الرد
بالعيب ، أو بالفساد ، أو حصل استحقاق للمبيع قبل قبض المحال - أي البائع - الثمن
، فإن الحوالة في هذه الحالة تبطل قطعاً ، وذلك لبطلان حق المحال - البائع - بالاستحقاق
، أو أحد سابقه * وذكر الخرشي الجزم بعدم البطلان وأن الحوالة صحيحة ، ولكن هذا
غير ظاهر ، بل ينبغي الجزم ببطلان الحوالة ؛ لبطلان حق المحال - البائع -
بالاستحقاق .

*** مسألة أخرى :** إذا وهب بائع لسلعة شخصاً ثمن هذه السلعة أو تصدق به عليه ، ثم
أحاله على المشتري - أي ثم أحال الواهب ، أو المتصدق الموهوب له ، أو المتصدق
عليه على المشتري - ثم ردت السلعة بعيب ، أو استحققت ، أو ردت لفساد فما حكم هذه
الهبة ، أو الصدقة المحال بها ؟ * في هذا رأيان

الأول منهما : فرق بين قبض الموهوب له والمتصدق عليه وبين عدم قبضه ، فقال :
تبطل الهبة إذا لم يقبضها الموهوب له ، وإن كان قبضها لم يتبع الموهوب له بها ولا الواهب ،
ويضيع ذلك على المشتري وهذا قول ابن القاسم ، نقله عنه اللخمي في التوضيح ، [
وحاشية الدسوقي / الشرح الكبير ج ٣ / ٣٢٩] .

ولعل حجة هذا الرأي : أن الموهوب له لا يتبع بها ؛ لأن الهبة تتم بالقبض عندنا ، ولا يتبع الواهب ؛ لأنه لحظة الهبة أحال بها والعقد صحيح

الرأي الثاني : تبطل الحوالة هنا إذا رد المبيع ، أو استحق ؛ لأن الغيب كشف ، واطهر أنه وهب ، أو تصدق بما لم يملك ، وهذا لا يجوز * **وبناء على هذا:** إن كان الموهوب له قبض الثمن الموهوب له أخذه منه المشتري، أي استرده منه وهذا قول اشهب.

الاختلاف في الحوالة

اختلاف المحيل والمحال

١ - في نفي دين المحال عليه

يقول المصنف : " (وَالْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ) بِبَيِّنٍ أَنَّهُ أَحَالَ عَلَى أَصْلِ دَيْنٍ (إِنْ ادَّعَى عَلَيْهِ) الْمُحَالُ (نَفْيَ الدَّيْنِ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ) إِذَا مَاتَ أَوْ غَابَ غَيْبَةً انْقِطَاعٍ فَلَوْ كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ حَاضِرًا فَهُوَ مَا قَدَّمَهُ فِي قَوْلِهِ وَيَتَحَوَّلُ حَقُّ الْمُحَالِ إلخ " (١)

(١) الشرح والتعليق : قوله : " نفي الدين للمحال عليه " اللام في " للمحال عليه " بمعنى على متعلقة بالدين، أو بمعنى " عن " متعلقة بـ " نفي " والمعنى على الأول : - أي أن اللام بمعنى على - إن ادعى المحال نفي الدين على المحال عليه ، والمعنى على الثاني : - أي أن اللام بمعنى في - إن ادعى عليه نفي الدين عن المحال عليه .

ومعنى النص : هنا حالتان :

الحالة الأولى : أنه إذا تنازع المحيل والمحال بعد موت المحال عليه ، أو غيبته غيبة انقطاع (والغيبة نوعان : ١ - غيبة انقطاع ، وهي : على معنى الاضطراب والغلبة كالأسير . ٢ - وغيبة ارتجاع ، وهي : التي على معنى الترفه والاختيار ، وفيها قد تعلم حياته ، أو تجهل وهي كمن خرج للتجارة ، أو لطلب حاجة) فقال المحال للمحيل : أخلتني على غير ذي دين ، فأنا أرجع عليك بديني . وقال المحيل : بل أخلتكَ على ذي دين في ذمتي ، وقد برئت ذمتي ، فلا رجوع لك علي . فلن يكون القول ؟ القول قول المحيل بيمين ، ولا يصدق المحال في دعواه (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٣ / ٣٢١ ، وهذا قول الإمام مالك في المدونة ، المدونة الكبرى ج ٤ / ١٤٨ ، كتاب الحوالة) فإن كان المحال عليه حاضراً وذكر ما يوافق قول أحدهما ، فهل يعتبر كالشاهد ، أم لا ؟ وهل يجري في الملى والمعسر ؟ فإن قيل : قد تقدم : أنه لا بد من حضور المحال عليه وإقراره ، وإذا حضر وأقر فلا يتأتى تنازعهما في أن الحوالة وقعت على أصل الدين أم لا ؟

* والجواب : أن هذا الكلام مبني على عدم اشتراط الحضور (شرح الخرشي ج ٤ /

٢٣٧ شرح الزرقاني ج ٦ / ٢١)

* الحالة الثانية : أن يكون المحال عليه حاضرا ، أو غائبا ولكنها ليست غيبة انقطاع ، ففي هذه الحالة يتحول حق المحال بمجرد عقد الحوالة ويطبق عليه ما ذكره المصنف عند قوله : " ويتحول بمجرد عقد الحوالة حَقُّ الْمُحَالِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَفْلَسَ أَوْ جَحَدَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الْحَقَّ بَعْدَ عَقْدِ الْحَوَالَةِ ... "

٢ - اختلاف المحيل والمحال في الصيغة

يقول المصنف : " (لَا) يُقْبَلُ قَوْلُهُ (فِي دَعْوَاهُ وَكَالَةً) لِلْمَحَالِ عَلَى قَبْضِ مَالٍ مِنْ مَدِينِهِ (أَوْ سَلَفًا) مِنَ الْمُحِيلِ لِلْمَحَالِ وَيَرُدُّ لَهُ بَدَلُهُ مَعَ صُدُورِ لَفْظِ الْحَوَالَةِ بَيْنَهُمَا ، بَلَّ الْقَوْلُ لِلْقَابِضِ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ مِنْ دِينِهِ أَحَالَهُ بِهِ تَغْلِيْبًا لِلْفَظِ الْحَوَالَةِ وَهَذَا قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَكَالَةِ لَكِنَّهُ قَيَّدَهُ بِأَنْ يَكُونَ الْقَابِضُ يُشَبِّهُ أَنْ يُدَايِنَ الْمُحِيلَ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ وَكَالَةً ، وَخَرَجَ اللَّخْمِيُّ مَسْأَلَةَ السَّلَفِ عَلَيْهِ ، وَالْمَنْصُوصُ لِابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْقَوْلَ فِي دَعْوَى السَّلَفِ لِلْمُحِيلِ وَخَرَجَ عَلَيْهِ مَسْأَلَةُ الْوَكَالَةِ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ الْجَرِيُّ عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَى أَعْلَمُ ^(١)

(١) الشرح والتعليق : معاني مفردات النص : قوله : " .. وكالة .. "
 الوكالة لغة : الحفظ ، والكفالة ، والضمان والتفويض ، يقال : وكلت أمري لفلان ، أي فوضته إليه
 والوكالة شرعا : نيابة في حق غير مشروطة بموته ، ولا إمارة أو : إقامة شخص آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم مملوك قوله : " .. أو سلفا .. "
 السلف ، أو القرض هو في اللغة : القطع ، سمي المال المدفوع للمقترض قرضا ؛ لأنه قطعة من مال المقرض .
 وشرعا : دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا تفضلا فقط لا يوجب إمكان عارية لا تحل متعلقا بذمة .

* شرح النص : أولا : صورة المسألة : أن يدعي المحيل أنه وكل المحال في أن يقبض له دينه من المحال عليه ، ويحضره له ، أو يقبضه من المحال عليه ، ويأخذه المحال سلفا على أن يرد مثله فقال المحال : بل أحلتني بدين لي عليك ، فلمن يكون القول ؟ لا يقبل قول المحيل في دعواه الوكالة في هذه المسألة فيما إذا تم العقد بصيغة الحوالة ولفظها ، بأن قال المحيل : إنما أحلتك لتقبضه لي على سبيل الوكالة ، أو على سبيل أنه سلف ، وقرض مني لك ترد لي بدله ، وقال المحال : إنما قبضته من الدين الذي لي عليك ، فالقول في ذلك قول المحال بيمينه ؛ تغليباً لجانب الحوالة ، إن أشبه أن مثل هذا المحال يداين المحيل

، وإلا يشبهه كان القول قول المحيل في دعواه الوكالة بيمينه ، وهذا قول عبد الملك بن الماجشون ، ولكن القيد الذي ذكره ، وهو : " إن أشبه أن مثل هذا المحال يداين المحيل " محله دعوى الوكالة ، دون مسألة السلف ، ولكن اللخمي هو الذي خرج مسألة السلف على الوكالة . قال ابن الحاجب : " وَإِذَا جَرَى لَفْظُ الْحَوَالَةِ وَتَنَازَعَا فَقَالَ الْمُحِيلُ : وَكَالَةً ، أَوْ سَلَفٌ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الْأَصَحِّ " .

يعني : إذا صدر لفظ الحوالة بين رجلين ، فقال له مثلاً : أحلتك على فلان ، فقبضه المحال ، فقال المحيل : إنما أردت بذلك التوكيل أو التسلف ، وقال المحال : بل قبضته من دين لي عليك ، فالأصح أنه لا يقبل قول المحيل تغليباً للفظ الحوالة ، وقيل : القول قوله ؛ لأنه لا تدرى إرادة نفسه ولا يعلم ذلك إلا من قوله ، وأراد بالأصح قول ابن الماجشون في المبسوط في مسألة الوكالة ، قال فيمن تحول بدين له على رجل ، فقال المحيل : ادفعه لي لأنني إنما وكلتك في قبضه وتسليمه إليّ ، وقال المحال : بل كنت استحققه عليك ديناً قبل الحوالة ، فإن كان القابض ممن يشبه أن يكون له قبل المحيل سبب حلف وسقط عنه قول المحيل ، وإن لم يشبهه فإنما هو وكيل ، ويحلف ما أدخله إلا وكيلاً .

اللخمي : وأرى أنه حوالة حتى يقوم دليل على الوكالة مثل أن يكون هذا ممن يتصرف لصاحب الدين أو تكون عادته التوكيل على التقاضي ، وهذا ممن يتوكل في مثل هذا وغير الأصح هو قول ابن القاسم في العتبية في السلف في من أحال رجلاً بدين له على رجل : فقال المحيل : إنما أحلتك على دين لي ليكون ذلك سلفاً عندك ، وقال القابض : أخذته عن دين كان لي عليك ، وإحالتني إقرار منك بحقي أن القول قول المحيل وهو سلف .

اللخمي : بعد قول ابن الماجشون وابن القاسم والمسألتان سواء .

وخلاصة القول : أن مسألة الوكالة منصوص عليها عند ابن الماجشون ، مخرج عليها مسألة السلف عند اللخمي ، ومسألة السلف منصوص عليها عند ابن القاسم في العتبية مخرج عليها مسألة الوكالة .

فتحصل من هذا : أن كل مسألة فيها قول منصوص ، وخرج عليه آخر في الأخرى وَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ (خليل) الْجَزْيُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي السَّلَفِ لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ جَارِيًا عَلَى الْمُنْصُوصِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ * وَأَقُول : إن المصنف التزم منهجه الذي وضعه للسفر عليه في هذا السفر العظيم من انه يتبع الراجح والأصح من الأقوال ، وفي مسألتنا هذه نجد أن قول ابن القاسم المنصوص عليه في السلف هو مقابل الأصح ؛ لهذا لم يتبعه المصنف خليل جرياً على منهجه .

السفتجة

وتطبيقا لمعايير الجودة المعمول بها في الجامعات المصرية وغيرها ؛ حيث إنه من بين توصيف المقررات بها : تنزيل ما يدرسه الطالب من كتب التراث على النوازل العصرية حتى ينمي في طلاب العلم الشرعي التقدير والاعتزاز بتراث الأمة الفقهي بناء على ذلك استعرض مسألة السفتجة.

والسفتجة هي : التطبيق المعاصر للحوالة : السفتجة بضم السين وفتحها ، وفتح التاء فارسيّ معرّب . قال في القاموس : السفتجة كَقَرْطَقَةٍ ، أن يعطي شخص مالا لآخر ، ولآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك ، فيستفيد أمن الطريق.

والسفتجة اصطلاحاً كما قال ابن عابدين : إقراض لسقوط خطر الطريق ، وفي الدسوقي : هي الكتاب الذي يرسله المقرض لوكيله ببلد ليدفع للمقرض نظير ما أخذه منه ببلده وهي المسماة بالبالوصة.

* هل السفتجة قرض أو حوالة : ؟ السفتجة تشبه الحوالة باعتبار أن المقرض يحيل المقرض إلى شخص ثالث ، فكأنه نقل دين المقرض من ذمته إلى ذمة المحال عليه ، والحوالة لا تخرج عن كونها نقل الدين من ذمة إلى ذمة.

لكن جمهور الفقهاء - المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وبعض الحنفية - اعتبروها من باب القرض ؛ لأنّ الكلام في القرض الذي يجزّ منفعة هل هو جائز أو غير جائز ، أمّا الحوالة فهي في دين ثبت في الذمة فعلا.

وقد ذكرها بعض فقهاء الحنفية كالحصكفي والمرغيناني في آخر باب الحوالة مع ذكرها في باب القرض أيضاً، وقال ابن الهمام والبايرتي : أورد القدوري هذه المسألة هنا لأنها معاملة في الديون كالكفالة والحوالة ، وقال الكرمانى : هي في معنى الحوالة ؛ لأنه أحال الخطر المتوقع على المستقرض وهذا ما قاله الحصكفي : قال : السفتجة : إقراض لسقوط خطر الطريق فكأنه أحال الخطر المتوقع على المستقرض فكان في معنى الحوالة - قال ابن عابدين وفي نظم الكنز لابن الفصيح : وكرّمت سفاتج الطريق وهي إحالة على التحقيق ، قال شارحه المقدسي : لأنه يحيل صديقه عليه، أو من يكتب إليه .الحكم الإجمالي :القرض من القرب المندوب إليها وهو من باب المعروف ، شرع للتعاون بين الناس وتفريج كرب المحتاجين بما يبذله المقرض للمستقرض المحتاج ، وهو لا يطلب من وراء ذلك سوى الثواب من الله سبحانه وتعالى ، فإذا طلب المقرض من وراء إقراضه نفعاً خاصاً له من المستقرض فقد خرج بذلك عن موضوع القرض ؛ لأنه عقد إرفاق وقربة ، ولذلك يحرم إذا كان يجلب نفعاً للمقرض وخاصةً إذا شرط ذلك في عقد القرض ، كأن يشترط المقرض زيادةً عما أقرض ، أو أجود منه ؛ لأن ذلك من باب الربا.

ومن القواعد المعروفة : أن كلّ قرض جرّ منفعةً فهو حرام . روى ذلك عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهم - ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الصحابة والسلف . قال : حدثنا خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال : كانوا يكرهون كلّ قرض جرّ منفعةً ، ومن الصور التي قد تجلب نفعاً للمقرض ما يسمّى بالسفتجة، وصورتها : أن يقرض شخص غيره - تاجراً أو غير تاجر(كبنك مثلاً) - في بلد ويطلب من

المستقرض أن يكتب له كتاباً يستوفى بموجبه بدل القرض في بلد آخر من شريك المقرض أو وكيله .

والنفع المتوقع هنا هو أن يستفيد المقرض دفع خطر الطريق ، إذ قد يخشى لو سافر بأمواله أن يسطو عليه اللصوص وقطاع الطرق فيلجأ إلى هذه الحيلة ليستفيد من وراء هذا القرض دفع الخطر المتوقع في الطريق والحكم في ذلك يختلف ، لأنه إما أن يكون الكتاب الذي يكتبه المستقرض لوكيله " وهو السفتجة " مشروطاً في عقد القرض أو غير مشروط . فإن كان ذلك مشروطاً في عقد القرض فهو حرام والعقد فاسد ؛ لأنه قرض جرّ نفعاً فيشبه الربا ؛ لأنّ المنفعة فضل لا يقابله عوض ، وهذا عند جمهور الفقهاء " الحنفية والشافعية وبعض فقهاء المالكية ورواية عن أحمد " وذكر ابن عبد البر أنّ مالكا كره العمل بالسفاتج بالدنانير والدراهم ولم يحرمها ، وأجاز ذلك طائفة من أصحابه وجماعة من أهل العلم ، وقد روي عن مالك أيضاً أنّه قال : لا بأس بذلك والأشهر عنه كراهيته لما استعمله الناس من أمر السفاتج . وفي رواية عن أحمد جوازها لكونها مصلحةً لهما جميعاً ، وقال عطاء كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه ، فسئل عن ذلك ابن عباس - رضي الله عنهما - فلم ير به بأساً ، وممن لم ير به بأساً : ابن سيرين والنخعي ، رواه كُله سعيد بن منصور .

وذكر القاضي من الحنابلة أنّ للوصيّ قرض مال اليتيم في بلد أخرى ليربح خطر الطريق ، والصحيح جوازه ؛ لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما . والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرّة فيها بل

بمشروعيتها ، ولأنّ هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص فوجب إبقاؤه على الإباحة.

غير أنّ المالكيّة استثنوا ما إذا عمّ الخوف جميع طرق المحلّ التي يذهب المقرض منها إليه، فإذا كان الخوف على النفس أو المال غالباً لخطر الطريق فلا حرمة في العمل بالسّفْتجة بل يندب ذلك تقديمًا لمصلحة حفظ النفس والمال على مضرة سلف جرّ نفعاً ، كما أنّه يجوز ذلك عندهم إذا كان فيه نفع للمقترض ، أو كان المتسلّف هو الذي طلب ذلك .

وإن كان المقترض هو الذي كتب السّفْتجة من غير شرط من المقرض بذلك جاز ذلك باتّفاق ؛ لأنّه من حسن القضاء ، وقد " استسلف النّبيّ صلى الله عليه وسلم من رجل بكرةً فقدمت عليه إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضى الرّجل بكرة ، فرجع إليه أبو رافع ، فقال : لم أجد فيها إلّا خياراً رباعياً فقال : أعطه إيّاه ، إنّ خيار النّاس أحسنهم قضاء. صحيح الترمذي والحديث صحيح وصحيح مسلم برقم (١٦٠٠) * * وخيارا : أي مختارا

* * ورباعيا : وهو من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة " ورخص في ذلك ابن عمر وسعيد بن المسيّب والحسن والنّخعي والشّعبيّ والزّهريّ ومكحول وقتادة وإسحاق

* والله أعلى وأعلم *



كتاب الضمان وأحكامه

كتاب الضمان وأحكامه

يقول المصنف : " (الضَّمانُ شَغْلُ ذِمَّةٍ أُخْرَى بِالْحَقِّ) قَوْلُهُ شَغْلُ ذِمَّةٍ جِنْسٌ ، وَقَوْلُهُ أُخْرَى فَصْلٌ أَخْرَجَ بِهِ الْبَيْعَ وَالْحَوَالَةَ ؛ إِذْ لَيْسَ فِيهِمَا شَغْلٌ بَلْ بَرَاءَةٌ ذِمَّةٌ ، وَقَوْلُهُ شَغْلُ ذِمَّةٍ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ ، أَيُّ أَنْ يَشْغَلَ رَبُّ الْحَقِّ ذِمَّةَ الضَّامِنِ مَعَ الْأُولَى ، وَأَرَادَ بِالذِمَّةِ الْجِنْسَ فَيَشْمَلُ الْوَاحِدَ وَالْمُتَعَدِّدَ ، وَأَرَادَ الشَّغْلَ بِالْحَقِّ بَلَا تَوَقُّفٍ عَلَى شَيْءٍ أَوْ بَعْدَ التَّوَقُّفِ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ كَعَدَمِ إِتْيَانِ الْمَضْمُونِ فِي الْوَجْهِ أَوْ تَهْرِيْبِهِ أَوْ تَفْرِيطِ الضَّامِنِ فِي الطَّلَبِ فَقَدْ اشْتَمَلَ تَعْرِيفُهُ عَلَى أَنْوَاعِهِ الثَّلَاثَةِ ، وَأَلْ فِي الْحَقِّ لِلْعَهْدِ أَيُّ الْحَقِّ الْأَوَّلُ فَخَرَجَ مَا لَوْ بَاعَ سِلْعَةً لِرَجُلٍ بَدَيْنِ ثُمَّ بَاعَ أُخْرَى لِغَيْرِهِ بَدَيْنِ ^(١)

(١) الضمان لغة : الحفظ ، ويسمى حمالة ، وكفالة ، وزعامة قال تعالى " قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ " يوسف (٧٢) أي ضامن وكفيل ، والضمان في اللغة له سبعة أسماء : ١ - زعيم ٢ - كفيل ٣ - قبيل ٤ - أدين ٥ - حميل ٦ - صبير ٧ - ضامن (المقدمات الممهديات لابن رشد الجد ج ٢ / ١٣٥٣) وكلها موجودة في القرآن الكريم والسنة والآثار ، وفيما يحتج به من الأشعار فمثلا من القرآن : قال تعالى : " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ " النحل (٩١) وقال تعالى : " أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا " الإسراء : ٩٢

وقال تعالى : " وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ " الأعراف : ١٦٧ وقال تعالى : " وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ " إبراهيم : ٧ ، فالزعيم من الزعامة ، وهي : السيادة ، فكأنه لما تكفل به صار عليه سيادة ، وحكم عليه ، والكفالة : من الكفيل ، وهو الكساء الذي يطوى حول سنام البعير ليحفظ به الراكب ، والكفيل حافظ لما التزمه ، والقبيل : من القبالة ، وهي القوة ، ومنه قوله : مالي بهذا الأمر قبل ، ولا طاقة ، والقبيل قوة في استيفاء الحق والأدين : من الأذانة ، بمعنى

الإيجاب ، وتوضحه الإيتان المذكورتان ، أي أوجب على نفسه المزيد للشاكر ، والعذاب للكافر *والحميل : وهو مشتق من الحمل ؛ لأن الضامن حمل والمضمون نقل ما كان عليه * والصبر : من الصبر ، وهو الثبات والحبس ، ومنه المصبورة ، وهي المحبوسة للرمي لأنه حبس نفسه لأداء الحق * أما الضمين : فهو من الضمن وهو الحرز ، وكل شيء أحرزته في شيء فقد ضمنته إياه (الذخيرة ، للقرافي ج ٧ / ٣٥٦ ، ٣٥٧)

والضمان شرعا : " التزام مكلف غير سفيه ديناً على غيره أو طلبه من عليه لمن هو له بما يدل عليه " **تعريف آخر ، الضمان :** " شغل ذمة أخرى بالحق " **شرح التعريف :** قوله " شغل ذمة ... " جنس في التعريف والجنس هو : لفظ كلي يطلق على أنواع مشتركين في صفات عامة مثل " الحيوان " فهو يطلق على كل الأحياء عدا النبات ، فشغل ذمة جنس شامل للمعرف - بفتح الراء المشددة - وهو الضمان والبيع والحوالة ؛ لأن في البيع شغل ذمة المشتري بالثمن ، وفي الحوالة شغل ذمة المحال عليه بحق المحال ، وقوله " أخرى " فصل ، والفصل هو : لفظ كلي ذاتي يميز أفراد النوع بصفات أساسية لا توجد في الأنواع الأخرى أي تفصلهم عن غيرهم من أنواع ، وبها يقوم الشيء ، مثلاً : فصل كلمة " الإنسان " أنه ناطق ، وبذلك يفصل عن باقي الحيوان فكلمة " أخرى " هنا فصل أخرج به البيع والحوالة ؛ لأن المراد بقوله " شغل ذمة أخرى " أي كما أن الأولى مشغولة أيضاً ، والحوالة ليست الذمة الأولى فيها مشغولة ؛ لأنها بمقتضى الحوالة برئت ، فالحوالة ليس فيها شغل ذمة ، بل براءة ذمة ، وقوله " شغل ذمة ... " من إضافة المصدر لمفعوله أي أن يشغل رب الدين ، أو الحق ذمة الضامن مع ذمة المدين والمراد من الذمة : الجنس ليشمل الواحد والمتعدد .

والذمة لغة : العهد ؛ لأن نقضه يوجب الذم ، وتطلق على الأمان ، والكفالة ، والحق والحرمة ، وفي الحديث : " المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم " (نيل الأوطار للشوكاني ، ج ٧ / ٨ ، ٩) .

والذمة عند الفقهاء : معنى يصير به الإنسان أهلاً لوجوب الحق له ، أو عليه وجمعها ذمم ، وهذا تعريف لها بالوصف ، أما تعريفها بالذات فهي : نفس لها عهد ، فالإنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه عند جميع الفقهاء (التعريفات للجرجاني ص ٩٥)
* **والمراد من قوله " شغل " الشغل المطلق ، أي سواء توقف هذا الشغل على شيء آخر كعدم الإيتان بالمضمون في ضمان الوجه ، أو تهريبه ، أو تفريط الضامن في ضمان**

الطلب ، أو بلا توقف على شيء ، كضمان المال ، فإننا سوف نعرف أن لرب الحق : أن يطالب أيهما شاء ، وبهذا يشمل التعريف أنواع الضمان الثلاثة ، وهي : المال ، والطلب ، والوجه .

اعتراض : اعترض على هذا التعريف : بأن لفظ " الحق " يدخل فيه الحق البدني (الحدود) والحق المالي .

وأجيب عن هذا : بأن الحقوق البدنية خارجة من التعريف بقوله " شغل ذمة أخرى " والذمة لا تشغل بالحقوق البدنية

نوع " ال " في كلمة " الحق " ال في كلمة " الحق " للعهد ، أي الحق الأول - الحق الذي في الذمة الأولى - فال تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

الأول : العهد الثاني : الجنس ، الثالث : الاستغراق .

والتي للعهد تنقسم إلى قسمين : الأول : العهد الذكري ، مثل : اشتريت كتابا ، ثم بعت الكتاب ، فال في الكتاب للعهد الذكري ، أي الكتاب المذكور أولا وكما في قوله تعالى : " اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ " النور (٣٥)

الثاني : العهد الذهني : مثل : حضر الطالب ، والحال أنك تخاطب إنسانا بينك وبينه عهد في طالب بعينه

أما " ال " التي لتعريف الجنس ، فمثالها : الرجل افضل من المرأة ، بشرط أن لا تريد رجلا بعينه ، ولا امرأة بعينها ، بل المقصود : أن جنس الرجل افضل من جنس المرأة .

أما " ال " التي لاستغراق الجنس ، فهي على قسمين : الأول : استغراق حقيقة الأفراد ، مثل قول الله تبارك وتعالى : " يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً " النساء (٢٨) أي كل واحد من جنس الإنسان ضعيف . **الثاني :** استغراق صفات الأفراد ، مثل : أنت الرجل ، أي الجامع الشامل لصفات الرجل وضابط كل منهما : أن الأولى : أي التي لاستغراق حقيقة الأفراد يصح وضع " كل " محلها على جهة الحقيقة ، أما الثانية : أي التي لاستغراق صفات الأفراد فتوضع " كل " محلها على سبيل المجاز لا الحقيقة

أنواع الضمان

الضمان ثلاثة أنواع : ضمان مال ، ضمان طلب ، وضمان وجه.

وضمان الطلب هو : ما تقوم به المصارف الآن تحت ما يسمى " بخطاب الضمان " الذي يصدره المصرف لعميله ، فإذا كان بدون أجره فهو جائز شرعا ، وإن كان بأجرة فهو محرم ، إلا إذا أخذ المصرف أجره مقابل تكاليف إصدار خطاب الضمان ، فإن ذلك جائز ، إذا كان بقدر تكلفة خطاب الضمان الفعلية ، أو أنقص منها.

ويستثنى من ذلك: إذا كان خطاب الضمان مغطى من قبل الشخص المدين ، و**خطاب الضمان المغطى هو :** أن يكون المدين قد أودع المال الذي ضمنه المصرف فيه في هذا المصرف ، فتكون حقيقة هذا الضمان : أنه ضمان من المودع عنده - بفتح الدال - بما يشبه الرهن ، وليس الضمان من المصرف ، فالمودع ضمن بإيداع هذا المال الذي يساوي المال المضمون في المصرف ، والمصرف وكيل عن هذا الشخص ، أو الشركة في إصدار هذا الضمان

* ويجوز للمصرف في هذه الحالة أخذ الأجرة عليه؛ لأن المصرف مجرد وكيل عن هذا المودع - بكسر الدال - في الضمان ، ويدخل في ضمان المال أيضا : **"الاعتماد المستندي"** وهو عبارة عن : تعهد كتابي يصدره البنك بناء على طلب عميله المدين - المستورد - يلتزم بمقتضاه البنك بالوفاء للمصدر - الدائن - وغالبا يكون المصدر الدائن في بلد آخر بتسديد قيمة السلع المتفق عليها بين المستورد والمصدر عند شحن المصدر السلع إلى المستورد ، ثم يقوم المستورد بالتسديد للبنك جميع ما دفعه البنك للمصدر فحكمه هو نفس حكم خطاب الضمان على ما سبق تفصيله ، فإذا كان البنك يأخذ فوائد مقابل سداد قيمة هذه السلع فهو ربا محرم (شرح عمدة الفقه ، تعليق : الجبرين ج ٢ / ٩٠٠ - ٩٠٢ ، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة للسالوس ص ٦٤١)

* **وفي ضمان الوجه** - كأن يقول : أنا زعيم لك بوجه فلان - خلاف بين الإمامين مالك والشافعي ، فقال الإمام مالك : يلزمه لأن المقصود بالزعامة ، تنزيل الزعيم مقام الأصل (المدين) والمقصود من حضور الأصل (المدين) أداء المال ، فكذاك الزعيم وقال الإمام الشافعي : لا يلزمه ؛ لأنه غرر ؛ إذ لا يدري : هل يجده ، أم لا .

حكم ضمان المال

ضمان المال حكمه الاستحباب ؛ لأنه فعل معروف ، وتعاون بين المسلمين ؛ ولذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم تحمل عن رجل في عشرة

دنانير (سنن أبي داود) وهذا هو الأصل في الضمان ، ولكن قد يعرض له الوجوب ، أو الحرمة ، فيكون الضمان واجبا ، كضمان الابن لوالده ، إذا تعامل الوالد بالدين في أمر مشروع ، واحتاج لضمان فيجب على الابن في هذه الحالة ضمان والده إذا كان والده غير ملد ، ولا مماطل في السداد ، ويكون الضمان محرما ، كضمان شخص يتداين بفائدة من البنك لا تعوه إلى الدين ضرورة ولا حاجة؛ لأن هذا ربا محرم ، ولأن في ضمان هذا الشخص إعانة على الإثم.

وهذا منهي عنه شرعا بنص القرآن الكريم قال تعالى : " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ " سورة المائدة (٢) وكضمان بجعل ، فإنه حرام ؛ حيث إن الضمان لا يكون إلا لله ، فقد قيل " ثلاثة لا تكون إلا لله القرض والضمان والجاه " ، ونظمها بعضهم بقوله:

القرض والضمان رفق الجاه ﴿٥﴾ تمنع أن ترى لغير الله (البهجة / شرح التحفة ، للتسولي ، ج ١ / ٩٦) ثم إنه ربما يسدد الضامن للدائن ، ثم يرجع الضامن على المدين بما سدده بالإضافة إلى هذه الأجرة ، فيكون من قبيل الربا المحرم.

(موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ، للسالوس ، ص ٦٤٦ - ٦٥٦ ، وقرار مجمع الفقه الإسلامي في هذا الموضوع)

دليل مشروعية الضمان

ثبتت مشروعية الضمان بالكتاب ، والسنة ، والإجماع والقياس
أما الكتاب ١ - فقوله تبارك وتعالى : " قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ " سورة يوسف (٧٢)

ووجه الاستدلال من الآية الكريمة : أن مذهب المالكية : أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ ولا ناسخ هنا ، وهي كفالة بالمال

٢ - وقول يعقوب عليه السلام لأبنائه : " قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ " سورة يوسف (٦٦)

* **ووجه الاستدلال من الآية الكريمة** : أن هذه كفالة بالوجه (الذخيرة ، للقرافي ، ج ٧ / ٣٥٨).

* **أما السنة**: فأحاديث كثيرة نذكر منها : ١ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ « كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُ بِمَيْتٍ فَسَأَلَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوا :

نَعَمْ، دِينَارَانِ قَالَ : " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دِينًا فَعَلِيَ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَوَرَّثَتْهُ « رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ. »

٢ - عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ، ولا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها " ف قيل : يا رسول الله ! ولا الطعام ؟ قال " ذاك أفضل أموالنا " ثم قال : " والعارية مؤداه ، والمنحة مردودة والدين مقضي ، والزعيم غارم " (ينظر : فتح الرحيم للشنقيطي ج ٢ / ١٥٢) ، وروى أحمد والنسائي وأبو داود

* فإن قيل : لماذا لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على الميت الذي عليه دين لم

يؤدده ؟

الحكمة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الميت الذي عليه دين ولم يترك وفاء له : في هذا تحريض للناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة من شغل ذممهم بحقوق

العباد

* أما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على مشروعية الضمان من حيث الجملة ، وإن اختلف

الفقهاء في بعض الفروع

* أما القياس : فلأن الضمان باب معروف فيجوز قياسا على العارية ، والقرض ، وغيرهما

من أبواب المعروف ، ولأنه توثق بالحق ، فيجوز كالرهن (الذخيرة ، للقرافي ج ٧ / ٣٥٨) .

أركان الضمان

الركن الأول

الضامن

يقول المصنف : (وَصَحَّ) الضَّمانُ وَلَزِمَ (مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ) وَهُوَ الْمُكَلَّفُ الَّذِي لَا حَجَرَ عَلَيْهِ وَلَوْ فِيمَا ضَمِنَ فِيهِ فَدَخَلَ ضَمَانُ الزَّوْجَةِ وَالْمَرِيضِ بِالثُّلُثِ كَمَا يَأْتِي ، وَمَفْهُومٌ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ فِيهِ تَفْصِيلٌ ، فَتَارَةٌ لَا يَصِحُّ كَالْوَقْعِ مِنْ سَفِيهِ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ صَبِيٍّ ، وَتَارَةٌ يَصِحُّ وَلَا يُلْزَمُ كَالْوَقْعِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ مَرِيضٍ فِي زَائِدِ الثُّلُثِ وَمِنْ الْعَبْدِ بغيرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَمَثَلٌ لِأَهْلِ التَّبَرُّعِ بِقَوْلِهِ (كَمَكَاتِبِ وَمَأْدُونِ) لَهُ فِي التَّجَارَةِ (أَذْنِ سَيِّدُهُمَا) لَهُمَا فِي الضَّمَانِ ، فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُمَا فِيهِ لَمْ يُلْزَمْهُمَا وَإِنْ صَحَّ بِدَلِيلٍ قَوْلُهُ الْآتِي : " وَاتَّبَعَ ذُو الرِّقِّ بِهِ إِنْ عَتَقَ " وَدَخَلَ بِكَافِ التَّمَثِيلِ قِنْ وَذُو شَائِبَةٍ مِنْ مُدَبِّرٍ وَأُمٍّ وَلَدٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ ، وَخَصَّهْمَا بِالذِّكْرِ لِدَفْعِ تَوَهُمِ جَوَازِ ضَمَانِهِمَا بِغَيْرِ إِذْنٍ (وَزَوْجَةٍ وَمَرِيضٍ) مَرَضًا مَخُوفًا (بِثُلُثٍ) أَوْ بِمَا زَادَ عَلَيْهِ بِسِيرِ شَأْنِهِ أَنْ لَا يُفْصَدَ بِهِ الضَّرَرُ كَالدِّينَارِ لَا مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يُلْزَمُ وَإِنْ صَحَّ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَارَةِ الزَّوْجِ أَوْ الْوَارِثِ بِخِلَافِ مَا لَوْ ضَمِنَا قَدْرَ الثُّلُثِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ^(١)

(١) تعريف الركن : رُكْنُ الشَّيْءِ فِي الْإِصْطِلَاحِ : مَا لَا وُجُودَ لِذَلِكَ الشَّيْءِ إِلَّا بِهِ ، وَهُوَ " الْجُزْءُ الدَّائِي الَّذِي تَتَرَكَّبُ الْمَاهِيَّةُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ بِحَيْثُ يَتَوَقَّفُ تَقَوُّمُهَا عَلَيْهِ .
أما الشرط فهو : " مَا يُلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ ، وَلَا يُلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ " كالطهارة بالنسبة للصلاة وبناءً عَلَى هَذَا فَكُلُّ مِنَ الرُّكْنِ وَالشَّرْطِ لَا بُدَّ مِنْهُ لِتَحَقُّقِ الْمُسَمَّى شَرْعًا ، غَيْرَ أَنَّ الرُّكْنَ يَكُونُ دَاخِلًا فِي حَقِيقَةِ الْمُسَمَّى ، فَهُوَ جُزْؤُهُ ، بِخِلَافِ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ يَكُونُ خَارِجًا عَنِ الْمُسَمَّى .

* **الشرح والتعليق :** يشير المصنف بهذا إلى الركن الأول من أركان الضمان ، وهو الضامن الذي يشترط فيه : أن يكون من أهل التبرع ، أي مكافا (بالغا ، عاقلا ، رشيدا) غير محجور عليه ولو فيما ضمن فيه ، فيشمل ضمان الزوجة والمريض بالثلث ، ولقد مثل المصنف لأهل التبرع بعدة أمثلة :

* وألفت النظر إلى أن جل ما سيذكره المصنف من أمثلة عدا الزوجة والمريض لا وجود له في الواقع المعاصر ، والفضل الأول يرجع إلى الشريعة الغراء ؛ حيث قضت على الرق بأن أغلقت كل الأبواب التي يدخل منها الرقيق ، وفتحت كل الأبواب التي يخرج منها كل من ضرب عليه الرق ، إلا أننا نضطر إلى ذكرها كأمتلة لما نتحدث عنه، ولتركب بعض الأحكام عليه ، فلم نقصد إليه لذاته بل لأمر آخر ؛ حتى لا نوصف بما نحن برآء منه براءة الذنب من دم ابن يعقوب ، ألا هل بلغت اللهم فاشهد .أ ، هـ

١ - **المكاتب :** وهو المعتق على مال مؤجل موقوف على أدائه ٢ - **المأذون له في التجارة** ، فهذان يصح منهما الضمان بشرط أن يأذن لهما سيدهما في الضمان ، فإذا ضمنا بدون إذن السيد لهما لم يلزمهما الضمان ، وإن صح.

* **تساؤل :** ألا يعتبر توقف تصرف كل من المكاتب ، والمأذون له في التجارة على إذن السيد معارضا لجعلهما من أهل التبرع ؟

* **والجواب :** أن الكاف في قوله : " (كَمُكَاتِبٍ وَمَأْذُونٍ) تحتل وجهها من اثنين : الأول منها : أنها للتشبيه وليست للتمثيل ووضح البناني في حاشيته على شرح الزرقاني الفرق بينهما بعض الشيء، فقال إن الكاف في الأوليين - المكاتب والمأذون له في التجارة - للتشبيه ؛ لأن كاف التشبيه : تفيد التشبيه في الصفات ، فالمكاتب والمأذون له اشتركا في صفة واحدة وهي الإذن لهما في التجارة ، والكاف للتمثيل في الآخرين وهما الزوجة والمريض ، وكاف التمثيل تفيد تشبيه الذوات بعضها ببعض ذات ونفس الزوجة كالمريض. أما المكاتب والمأذون له في التجارة فصفة المكاتب من حيث الإذن تشبهه بالمأذون له من حيث التجارة ، فالكاف من المشترك المستعمل في أحد معنييه وهما التشبيه والتمثيل.

* **الثاني من الوجهين اللذين تحتلها الكاف :** أن المكاتب والمأذون له في التجارة صارا بعد الإذن لهما من أهل التبرع ، فقوله : (أَذْنٌ سَيِّدُهُمَا) شرط في اتصافهما بكونهما من أهل التبرع ويدخل بكاف التشبيه في قوله : " (كَمُكَاتِبٍ وَمَأْذُونٍ) : ٣ - **الغن وهو :** العبد الخالص الذي ليست فيه شائبة حرية ويدخل كذلك من فيه شائبة حرية مثل : ٤ - **المدير والتدبير عبارة عن :** تعليق مكلف رشيد ، وإن زوجة في زائد الثلث عتق رقبة على

موته لزوما ٥ - أم الولد ، وهي : الأمة التي ولدت من سيدها ، أو هي : الحر حملها من وطء مالكة ، وتعتق من رأس ماله بعد مماته بدون توقف على حكم حاكم
٦ - ومعتق لأجل ، والعتق هو : خلوص الرقبة من الرق بصيغة وهو من أعظم القربات عند الله عز وجل.

لما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمْرًا مُسْلِمًا ، اسْتَقْدَّ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ » قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ : « فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، فَعَمَدَ عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشْرَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَأَعْتَقَهُ ».

* والفرق بين المعتق لأجل والمدير : أن المعتق لأجل لا يتوقف عتقه على موت سيده ، بل على انقضاء الأجل ، أما المدير فيتوقف عتقه على موت سيده.
* تساؤل : لماذا خص المكاتب والمأذون له في التجارة بالذكر ؟ نبه المصنف عليهما بالذكر لدفع ما قد يتوهم من جواز ضمانهما بغير إذن . ٧ - الزوجة : لها أن تضمن في حدود ثلث مالها - ضمان مال ، لا ضمان طلب ولا ضمان وجه - أو ما زاد على الثلث بيسير ، وشأن هذا اليسير أن لا تقصد به الضرر كالدينار مثلا (٢٥ ، ٤ أربعة جرامات وربعا) لا ما زاد على ذلك ، فلا يلزم وإن صح ، أي فيتوقف على إجازة الزوج ، فإن شاء رد الجميع ، وإن شاء أمضى لجميع .

ولماذا للزوج رد الجميع ، لا ما زاد على الثلث فقط ؟ لأن الزوج قد يتضرر من خروج زوجته للبحث عن المدين ، أو الولوج في قاعات المحاكم ، والجلوس أمام المحققين ونحوهم.

وفي ضمان الزوجة تفصيل يوضح غموضه أرى أنه من الواجب استعراضه ليتضح الأمر
ويزال الوهم ، فعن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " وفي لفظ : " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " رواه الخمسة إلا الترمذي [نيل الأوطار للشوكاني ج ٦ / ١٨ ، كتاب : النكاح باب : ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها] والحديث سكت عنه أبو داود ، والمنذري ، وقد أخرجه البيهقي والحاكم في المستدرک ، وفي إسناده عمرو بن شعيب ، هم

رجال الصحيح عند أبي داود ، وفي الباب عن خيرة امرأة كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم .

* وقد استدلت بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة .

وهذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء على النحو التالي :

* **قال الليث بن سعد :** لا يجوز لها ذلك مطلقا لا في الثلث ولا فيما دونه ، إلا في الشيء التافه

* **وقال طاووس ومالك :** يجوز لها أن تعطي من مالها بغير إذنه في حدود الثلث لا فيما فوقه ، فلا يجوز إلا بإذنه

* **وذهب الجمهور** إلى أنه يجوز لها أن تعطي من مالها مطلقا أذن الزوج ، أو لم يأذن ، بشرط ألا تكون سفية فإن كانت سفية لم يجز ، قال ابن حجر في فتح الباري : وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة ، وقد استدلت البخاري في صحيحه على جواز ذلك بأحاديث ذكرها في باب : هبة المرأة لغير زوجها من كتاب الهبة ، ومن جملة أدلة الجمهور : حديث جابر وفيه قال : شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن ، وذكرهن ، وقال : " تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم " فقامت امرأة من سطة - خيرة - النساء سفعاء الخدين - فقالت : لم يا رسول الله ؟ قال : " لأنكن تكثرن الشكاة ، وتكفرن العشير " قالت : فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب " بلال " من أقراطهن " متفق عليه .

* **أولا : التعليق على الحديث :** (فقالت امرأة من سطة النساء) هكذا هو في النسخ سطة بكسر السين وفتح الطاء المخففة ، وفي بعض النسخ (واسطة النساء) قال القاضي : معناه من خيارهن والوسط العدل والخيار قال : وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم ، وأن صوابه (من سفلة النساء) وكذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده ، والنسائي في سننه ، وفي رواية لابن أبي شيبة " : امرأة ليست من علية النساء " وهذا ضد التفسير الأول ، وبعضه قوله : بعده سفعاء الخدين ، هذا كلام القاضي ، وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول بل هي صحيحة ، وليس المراد بها من خيار النساء كما فسر هو بل المراد : امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن قال الجوهري وغيره من أهل اللغة : يقال وسطت القوم أسطهم وسطا وسطة أي توسطتهم ، قوله : (سفعاء الخدين)

بفتح السين المهملة أي فيها تغير وسواد . قوله صلى الله عليه وسلم (تكثرن الشكاة) هو بفتح الشين أي الشكوى ، قوله صلى الله عليه وسلم : (وتكفرن العشير) قال أهل اللغة : يقال : هو العشير المعاشر والمخالط ، وحمله الأكثرون هنا على الزوج وقال آخرون : هو كل مخالط . قال الخليل : يقال : هو العشير ومعنى الحديث : أنهم يجحدن الإحسان لضعف عقلمن وقلة معرفتهم ، فيستدل به على ذم من يجحد إحسان ذي إحسان . قوله (من أقرطتهن) هو جمع قرط . قال ابن دريد : كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط سواء كان من ذهب أو خرز وأما الخرص فهو الحلقة الصغيرة من الحلي .

* **ثانيا : ما يؤخذ من الحديث من أحكام :** حمل الجمهور الحديث المذكور هنا (حديث عبد الله بن عمرو) على ما إذا كانت سفيهة غير رشيدة.

* **وحمل الإمام مالك أدلة الجمهور على الشيء اليسير** وجعل حده الثلث فما دونه ، ومن جملة أدلة الجمهور : الأحاديث المتقدمة في أول الباب ، حديث أم المؤمنين عائشة ، وأبي هريرة وأسماء ، وسعد رضي الله عنهم جميعا القاضية بأنه يجوز لها التصديق من مال زوجها بغير إذنه ، وإذا جاز لها ذلك في ماله بغير إذنه ، فمن باب أولى يجوز لها ذلك في مالها .

* **والأولى :** أن يقال يتعين الأخذ بعموم حديث عبد الله بن عمرو ، وما ورد من الحوادث المخالفة له تكون مقصورة على مواردها ، أو مخصصة لمثل من وقعت له من هذا العموم ، أما مجرد الاحتمالات فليست مما تقوم به الحجة .

٨ - **المريض :** ويقصد به المريض مرضا مخوفا ، وهو الذي يغلب منه الهلاك ، ويتصل بالموت ، ومرض الموت أيضا هو : الذي تزداد علته على المريض باستمرار إلى الوفاة ، وكان الغالب فيه الهلاك ، فإن لم يعلم أنه مهلك كان المعول على اعتباره مرض موت هو : " عجز المريض بسببه عن الخروج لمصلحة نفسه " ومثل الفقهاء لذلك : بالمقعد ، والمشلول ما دام يزداد به لأنه ما دام يزداد في علته فالغالب أن آخره الموت ، ويمكن الاسترشاد الآن برأي أهل الذكر في ذلك من الأطباء المهرة الثققات العدول في الأمراض الميؤس الشفاء منها ، وما قيل في الزوجة يقال هنا في المريض إلا إذا ضمن بأزيد من الثلث بكثير الشأن فيه الضرر بالورثة ، فللورثة إن شاءوا أن يردوا ما زاد على الثلث ، وإن شاءوا أجازوا

الجميع ، فما زاد على الثلث في ضمان كل من الزوجة والمريض صحيح غير لازم ، أي موقوف على إجازة الزوج أو الورثة

* **اعتراض :** في موضع آخر ذكر أن الزوجة أو المريض إذا تبرع أي منهما بأكثر من الثلث ، ولو بيسير كان للزوج أو الوارث الرد ، وهنا قالوا بجواز الضمان بأزيد من الثلث بيسير ! فكيف هذا ؟

* **والجواب :** ما تقدم من منع تبرع كل من الزوجة والمريض بأزيد من الثلث ولو بيسير هذا محله في التبرع المحض المجرد الذي لا رجوع بعوضه ، أما ما هنا ففي الضمان الذي فيه الرجوع على المضمون بما غرم للمضمون له.

* **وما محل ، أو متى يتوقف نفاذ ولزوم ما ضمنته الزوجة بأزيد من الثلث على إجازة الزوج ؟**

يتوقف نفاذ ولزوم ما ضمنته الزوجة بأزيد من الثلث على إجازة الزوج إذا ضمننت غير زوجها ، أما إذا كان الضمان منها لزوجها ، فلا يتوقف على إجازته ، قال الباكي : " لها الكفالة لزوجها بجميع مالها ، أي وليس له الرد " وفي المدونة : إذا ادعت أنه أكرهها في كفالتها له فعليها البينة.

مسألة غير موجودة في الوقت الحاضر

يقول المصنف : " (وَاتَّبَعَ ذُو الرِّقِّ بِهِ) أَيُّ بِالضَّمَانِ بِمَعْنَى الْمَالِ الَّذِي ضَمِنَهُ (إِنْ عَتَقَ) ضَمِنَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ لَا وَلَيْسَ لَهُ إِسْقَاطُهُ عَنْهُ فِي الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الثَّانِي فَلَهُ إِسْقَاطُهُ قَبْلَ عِتْقِهِ فَلَا يَتَّبَعُ بِهِ بَعْدَهُ وَلَا يُبَاعُ فِيهِ قَبْلَ الْعِتْقِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِيهِ (وَلَيْسَ لِلْسَيِّدِ جَبْرُهُ عَلَيْهِ) أَيُّ عَلَى الضَّمَانِ فَإِنْ جَبَرَهُ لَمْ يَلْزَمْ الْعَبْدَ شَيْءٌ إِنْ عَتَقَ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ مَالٌ أَوْ لَهُ مَالٌ وَجَبَرَهُ عَلَى أَكْثَرِ مِمَّا بِيَدِهِ وَأَمَّا لَوْ جَبَرَهُ عَلَى ضَمَانٍ قَدَرٍ مَا بِيَدِهِ فَلَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ انْتِزَاعِ مَا بِيَدِهِ " (١)

(١) الشرح والتعليق : ونظرا لعدم وجود الرق الآن فلن أفيض في شرح هذه الجزئية ، مكتفيا بشرح الفقهاء القدامى لها على النحو التالي : يَعْنِي أَنَّ ذَا الرِّقِّ كَالْمُكَاتِبِ وَالْمُدَبِّرِ وَالْمَادُونِ لَهُ فِي التَّجَارَةِ إِذَا حَصَلَ مِنْهُمْ ضَمَانٌ بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَاسْتَمَرَ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ حَصَلَ لَهُمُ الْعِتْقُ فَإِنَّهُمْ يُنْبَعُونَ بِمَا حَصَلَ مِنْهُمْ مِنَ الضَّمَانِ وَلَيْسَ لِلْسَيِّدِ قَبْلَ الْعِتْقِ إِسْقَاطُهُ ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِإِذْنِهِ وَأَمَّا لَوْ حَصَلَ مِنْ دَكَرِ الضَّمَانِ بغيرِ إِذْنِ السَّيِّدِ، فَإِنَّ لَهُ إِسْقَاطَهُ فَإِنْ لَمْ يُسْقِطْهُ حَتَّى حَصَلَ مَا ذَكَرَ مِنَ الْعِتْقِ فَإِنَّهُمْ يُنْبَعُونَ أَيْضًا، الْمَشْهُورُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ السَّيِّدَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُجْبِرَ عَبْدَهُ عَلَى الضَّمَانِ أَمَّا غَيْرُ مَنْ لَهُ انْتِزَاعُ مَالِهِ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا مَنْ لَهُ انْتِزَاعُ مَالِهِ فَلَأَنَّهُ قَدْ يَعْتَقُ وَالضَّمَانُ بَاقٍ عَلَيْهِ فَيَحْصُلُ لَهُ بِذَلِكَ الضَّرَرُ فَإِنْ جَبَرَهُ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْ الْعَبْدَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ عِتْقِهِ وَقِيلَ لَهُ جَبْرُهُ وَهُوَ الْجَارِي عَلَى النِّكَاحِ وَفُرِّقَ بَيْنَ السَّيِّدِ مَنْفَعَةٍ فِي النِّكَاحِ.

الضمان عن الميت المفلس

يقول المصنف : " (و) صَحَّ الضَّمَانُ (عَنْ الْمَيِّتِ الْمُفْلِسِ) بِسُكُونِ الْفَاءِ وَكَسْرِ اللَّامِ أَيْ الْمُعْسِرِ بِمَعْنَى الْحَمْلِ عَنْهُ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ مِنَ الضَّامِنِ ، وَخَصَّ الْمُفْلِسَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ ؛ إِذْ مَنْعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالنَّوَوِيُّ ، وَأَمَّا الْحَيُّ أَوْ الْمَيِّتُ الْمُؤَسِّرُ فَلَا خِلَافَ فِي صِحَّةِ الضَّمَانِ عَنْهُ وَكَذَا ضَمَانُ الْمُفْلِسِ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ " (١)

(١) أولاً : معنى بعض الكلمات التي في النص : التفليس : من أفلس الرجل، إذا لم يبق له مال ، يراد به ، أنه صار إلى حال يقال فيها : ليس معه فلس (والفلس عملة يتعامل بها مسكوكة من غير الذهب والفضة، وتقدر بسدس الدرهم، وهي تساوي اليوم جزءا من ألف من الدينار في العراق وغيره) فيقال أفلس الرجل: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ، وقد فلسه الحاكم تفليسا : نادى عليه أنه أفلس ،

والفلس شرعا ، له معنيان ، عام وخاص.

والفلس بمعناه العام : قيام الغرماء على ذي دين حل ليس له ما يفي به ، فلهم سجنه ، ومنعه من البيع والشراء والأخذ والعطاء ، ويسمى صاحبه : المفلس (بسكون الفاء وكسر اللام).

والفلس بمعناه الخاص هُوَ : حُكْمُ الْحَاكِمِ بِخُلْعِ مَا بِيَدِهِ لُغْرَمَائِهِ لِعَجْزِهِ عَنْ وَقَاءِ مَا عَلَيْهِ ، ويسمى صاحبه المفلس (بفتح الفاء وكسر اللام المشددة) ، ولا يكون ذلك إلا بثلاثة شروط : ١ - أن يطلب الدائنون ، أو بعضهم تفليسه ٢ - أن يحل أجل الدين أو الديون ٣ - أن يزيد الدين الحال الذي على المدين على ما بيده من مال ، بناء على ذلك يرفعون الأمر للقضاء مطالبين بـ : أ - سجنه إن كان موجودا ، وإلا ب - فيحولون بينه وبين ماله ويمنعونه من التصرفات المالية من بيع وشراء ، وأخذ وإعطاء ولو بغير محاباة ، ويطالبون بمنعه من التزوج ، ولهم المطالبة بقسم ماله بالمحاصة - التي سنوضحها قريبا - أي يأخذوا بنسبة ما لكل منهم.

ثانيا : الشرح والتعليق : لم يَخْتَلَفْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي جَوَازِ الْحَمَالَةِ عَنْ الْحَيِّ مُوسِرًا كَانَ ، أَوْ مُعْسِرًا ، وَلَا فِي الْحَمَالَةِ عَنْ الْمَيِّتِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي الْحَمَالَةِ عَنْ

الْمَيِّتِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا فَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ الْحَمَالَةِ وَانْفَرَدَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ فَمَنَعَا ذَلِكَ أَهـ ، في هذا النص مسألتان :

المسألة الأولى وهي في المفلس بمعناه العام ، ولهذه المسألة صورتان الصورة الأولى : يصح الضمان عن الميت المفلس ويلزم ، إذا تحمل إنسان عن الميت المعسر عالما بعسره وأدى عنه ، وفي

هذه الحالة لا يرجع بما أداه في مال يطرأ لهذا الميت المفلس بعد ذلك لأن تحمله وأدائه عنه تبرع محض ، الصورة الثانية : أن يتحمل إنسان عن الميت المعسر عالما بأن لهذا الميت مالا ، أو ظن أن له مالا ، أو شك ، وأدى عنه ، ثم ظهر المال الذي لهذا الميت ففي هذه الحالة يرجع بما أداه في المال الذي طرأ لهذا الميت المفلس بعد ذلك

المسألة الثانية : وهي في المفلس بمعناه الخاص إذا تحمل إنسان عنه ، وأدى فإنه لا يرجع بعد ذلك في مال يطرأ له سواء علم بأن له مالا ، أو ظن ، أو شك وبمعنى أوضح : أنه إذا قام الغرماء ، أي الدائنون على المفلس ورفعوا أمرهم إلى القضاء ، وحكم القاضي بخلع ماله لدائنيه فضمنه إنسان فإن المال الذي حكم القاضي به لدائنيه يتحاصون فيه ، أي يقتسمونه قسمة محاصة ، أي يأخذ كل منهم من ماله بنسبة دينه.

وبالمثال يتضح المقال : فلو أن شخصا مدين لثلاثة على النحو التالي : س من الناس دائن له بـ ١٠٠٠ من الجنيهات ، ص من الناس دائن له بـ ٢٠٠٠ من الجنيهات ، د من الناس دائن له بـ ٣٠٠٠ من الجنيهات ، كل ما يملكه هذا المدين ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف من الجنيهات ، وهي لا تسد دينهم جميعا ، فيتحاصون في الثلاثة آلاف بنسبة دين كل منهم ، أي بنسبة ١ : ٢ : ٣ فيكون مجموع الأجزاء $1 + 2 + 3 = 6$ فيكون نصيب كل جزء $3000 \div 6 = 500$ من الجنيهات فصاحب الألف يأخذ $500 \times 1 = 500$ ، وصاحب الألفين يأخذ $500 \times 2 = 1000$ من الجنيهات ، وصاحب الثلاثة آلاف يأخذ $500 \times 3 = 1500$ من الجنيهات ، فيدخل عليهم النقص جميعا بنسبة ما لهم ، وما بقي لهم بعد ذلك يدفعه ذلك الضامن عنه ، ولا يرجع عليه بما أداه عنه مطلقا أي سواء علم بأن له مالا ، أو ظن ، أو شك ، أو علم أن لا مال له ، وطرأ له مال ، وهذا بخلاف ما ذكرنا في المسألة الأولى ، ولعل وجه هذا : أن الضامن لم يظلمه أحد ولم يغرر به أحد ، وهو داخل في الضمان وهو على علم بذلك ؛ لأنه يوجد حكم من القاضي ، فكأنه متبرع بما زاد

على ما في تركة الميت المفلس ، هذا هو الذي قاله الشيخ / عبد الباقي الزرقاني في شرحه على مختصر خليل ونقله العدوي ، وقال البناني : وفيه نظر بل ظاهر المدونة أن له الرجوع إن علم له مالا ولا فرق بين المفلس بالتشديد أو بالتخفيف ، وفي كتاب المديان من المدونة ج ٤ / ١٢٤ كتاب : المديان ، باب : في الرجل يموت وعليه دين

" وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَتَبَرَّعَ رَجُلٌ فَضَمَّنَ دَيْنَهُ فَذَلِكَ لَزِمَ لَهُ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ رَجَعَ فِيهِ بِمَا أَدَّى إِنْ قَالَ : إِنَّمَا أَدَيْتُ لِارْجَعِ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَالضَّامِنُ عَالِمٌ فَإِنَّهُ لَا يَرْجَعُ فِي مَالٍ إِنْ ثَابَ لِلْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الْحِسْبَةِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ النَّبْرُ مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ وَالنَّظَرُ مَا كَانَ عَنْ سُؤَالٍ " قول المدونة : (وَالضَّامِنُ عَالِمٌ) جَعَلَ لَهُ الرُّجُوعَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ ، وَقَالَ ثَابَ أَيُّ ظَهَرَ أَهْدُ ثُمَّ قَالَ فِيهَا وَمَنْ ضَمَّنَ لِرَجُلٍ مَالَهُ عَلَى مَيِّتٍ ، ثُمَّ بَدَأَ لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ اللَّخْمِيُّ وَأَرَى إِذَا ضَمَّنَ الْقَضَاءُ عَنْ مَيِّتٍ وَكَانَ ظَاهِرُهُ الْيُسْرُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ إِنَّمَا تَحَمَّلْتُ لِارْجَعِ وَلَوْ عَلِمْتُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ لَمْ أَضْمَنْ أَه

* والمقصود بضمان الميت هنا هو الحمل عنه لا حقيقة الضمان الذي هو : شغل ذمة اخرى بالحق ؛ لأن ذمة الميت قد خربت بالموت ، والدليل على جواز الضمان عن الميت الآتي : عَنْ جَابِرٍ قَالَ « كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُ بِمَيِّتٍ فَسَأَلَ : عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ دَيْنَارَانِ . قَالَ : " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيْ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّيَمِيُّ

تسلسل الضمان

يقول المصنف: " (و) صَحَّ ضَمَانُ (الضَّامِنِ) وَلَوْ تَسَلَّسَلَ وَيُلْزَمُهُ مَا يُلْزَمُ الضَّامِنِ الْأَصْلِيَّ وَظَاهِرُهُ يَشْمَلُ مَا إِذَا كَانَ مَعًا بِالْمَالِ أَوْ بِالْوَجْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا بِالْمَالِ وَالثَّانِي بِالْوَجْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ " (١)

(١) الشرح والتعليق : هل يصح ضمان الضامن ؟ يصح ضمان الضامن ولو تسلسل ، ولا مانع من ذلك ؛ لأن التسلسل في المستقبل ، وإنما يكون محالاً إذا كان في الماضي .
* وظاهر المذهب (مصطلح ظاهر المذهب : يطلق على ما ليس فيه نص ، ويراد به : الظاهر من الدليل ، أو الظاهر من المذهب فالمسألة التي لم ينص على حكمها ينظر في الدليل ، أو فيما تدل عليه قواعد المذهب وأصوله ، فالذي يدل عليه ظاهر الدليل ، أو ظاهر المذهب يكون حكمها حيث لا نص ، ومثال الظاهر من المذهب قول ابن رشد : " إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد فالظاهر لزومها ") **فظاهر المذهب** يشمل ما إذا كانا معا بالمال أو بالوجه ، أو أحدهما بالمال والثاني بالوجه فهو صحيح ، وإنما الاختلاف من حيث الرجوع عندما يغرم ضامن الضامن ، وفي هذه الحالة لا يخلو الأمر من إحدى الصور الآتية :

* **الصورة الأولى** : أن يكونا معا بالمال : ففي هذه الصورة يبدأ بمطالبة المدين إن كان حاضراً مليئاً ، وإلا يكن كذلك فينتقل للضامن الأول إن كان حاضراً مليئاً ، وإلا يكن كذلك فينتقل للضامن الثاني ، وهكذا

* **الصورة الثانية** : أن يكونا معا بالوجه : (و ضمان الوجه هو التزام الإتيان بالمدين عند الأجل، ويبرأ بتسليمه للدائن ، ولو كان عديماً، أو بسجن، أو بغير البلد إن كان به حاكم، وإلا لو أسلمه الضامن في صحراء، أو في بلد لا سلطان فيه، أو كان المدين يقدر على الامتناع من الأداء بسلطانه أو غيره لم تسقط الحماله) ففي هذه الصورة يبدأ بالمدين إن كان حاضراً ، فإن غاب كلف الأول بإحضاره ، فإن غاب الأول كلف الثاني بإحضار أحدهما ، فيبرأ بذلك ، فإن غاب

* **الصورة الثالثة** : أن يكون الأول بالوجه والثاني بالمال : و خلاصة هذه الصورة : أنه إن ترتب على الأول المال لعدم إحضاره المدين غرمه الثاني عنه ، ويبرأ الثاني أيضاً بإحضار المضمون الأول ؛ لأنه يبرأ بما يبرأ به الضامن الأول .

ضمان الدين المؤجل على الحلول

يقول المصنف : " (و) صَحَّ ضَمَانُ الدَّيْنِ (المُؤَجَّلِ حَالًا) أَيِ عَلَى الضَّامِنِ بِأَنْ رَضِيَ الْمَدِينُ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ مِنَ الْأَجَلِ (إِنْ كَانَ) الدَّيْنُ (مِمَّا يُعَجَّلُ) أَيِ يَجُوزُ تَعَجِيلُهُ وَهُوَ الْعَيْنُ مُطْلَقًا وَالْعَرَضُ وَالطَّعَامُ مِنْ قَرْضٍ لَا مِنْ بَيْعٍ فَلَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ حَظِّ الضَّامِنِ وَأَزِيدُكَ تَوْثُقًا بِالضَّامِنِ إِذْ هُوَ مَخْصُوصٌ بِالْبَيْعِ فَقَطْ " (١)

(١) الشرح والتعليق : أولا صورة المسألة : مثلا " محمد " دائن لأحمد ب ١٠٠٠ ألف من الجنيهات إلى شهر ، فأسقط أحمد حقه من الأجل ، وضمنه " علي " ليؤدي أحمد حالا ، وذلك خوف المماطلة مثلا ؛ لأنه وإن كان حالا ، لكن من الجائز أن يماطل المدين وهو أحمد في السداد ، فالضمان - الذي كان بعد أن لم يكن - زيادة توثق ، ولأنه قد يكون للدائن " محمد " مصلحة في الأجل ، كانتظار ارتفاع الأسواق ، أو أن الدين سيكلفه حفظا وحراسة ، ولأن من عجل ما أجل عد مسلفا وذلك نظير إسقاط الضمان بإقباضه أو قد يظهر أن ما يسلمه المدين مغشوشا ، أو معيبا ؛ أو قد يظهر لهذا المبلغ أو الدين الذي يسدد عاجلا مالك آخر غير المدين ، ويستحق في هذه الحالة كالمغصوب ؛ حيث إن بعض البائعين يطلب كفيلا يضمن له سلامة الثمن ، فالضمان في هذه الحالة صحيح ولازم بشرط : أن يكون الدين مما يعجل ، ويكون ذلك في الحالات الآتية :

١ - أن يكون الدين عينا (أي ذهباً أو فضة أو ما حل محلها من أوراق البنكنوت) مطلقا ، أي سواء أكان الدين عينا من قرض - بأن يكون قد سلفه أو أقرضه ذهباً أو فضة أو ما حل محلها من أوراق البنكنوت - ، أو من بيع بأن يكون ثمن بيع مؤجل ، ففي هذه الحالة يجوز ضمانه على الحلول ، وذلك لأن الأجل من حق المدين ، فإذا أسقطه وعجل الأداء جاز هنا.

٢ - أن يكون الدين عرضا (والعرض هو : الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا) أو طعاما من قرض ، مثال الدين الذي من عرض أن يكون لمحمد عند علي مرجع من كتب المالكية أخذها عي على سبيل السلف من محمد لمدة شهر مثلا ، ومثال الطعام الذي من قرض : أن يقرض محمد عليا عشرة أرادب من قمح لمدة شهرين مثلا ، وفي المثالين المذكورين يجوز ضمانهما على الحلول ؛ وذلك للعلة السابقة ، ألا وهي

: أن الأجل فيهما من حق المقرض إن شاء عجل، وإن شاء أبقى للأجل ، ولا يقال عند التعجيل أنه طلب من المقرض حط الضمان عن نفسه ؛ لأن القرض من باب المعروف ، فلا شيء في هذا، بخلاف البيع (المسلم) فإن الحق في الأجل إن كان طعاما أو عرضا للطرفين ؛ لأن للمشتري (المسلم) الحق في تأجيل قبض المثلث ؛ لأنه يرصد به الأسواق ، وللبائع (المسلم إليه) الحق في التأجيل حتى يحصد زرعه ويسلمه في الأجل ، فإذا عجل المسلم إليه شيئا قيل : إنه طلب حط الضمان عن نفسه ؛ لأنه طالما في ذمة المسلم إليه أي البائع فهو من ضمانه فإذا عجله فكأنما رفع الضمان عن نفسه ، فمن عجل ما أجل عد مسلفا في مقابل حط الضمان عن نفسه ، وهذا لا يجوز ؛ لأنه قرض جر نفعاً ، وهذا منهي عنه بالنص.

٣ - أن يكون الدين عرضاً ، أو طعاماً من بيع وهو ما ذكرناه سابقاً ما يسمى بالسلم، وهو بيع عجل فيه الثمن وآخر فيه المثلث ، وهذه الصورة لا يجوز فيها ضمان الدين المؤجل على الحلول ، وذلك لن الحق في الأجل إذا كان طعاماً أو عرضاً منهما ، أي من البائع وهو المسلم إليه ومن المشتري وهو المسلم ، والسلعة، هنا يرصد بها الأسواق غالباً ، فللمشتري وهو المسلم غرض صحيح في تأخير القبض وتسلم السلعة في الأجل لينتفع بالربح فيه ، بخلاف القرض فإنه لا يجوز أن يقصد المقرض النفع الدنيوي بما أقرض ، وإلا كان قرضاً جر نفعاً ، وهو منهي عنه شرعاً .

* **وَأَعْلَمَ أَنَّ مِثْلَ ضَمَانِ الْمُؤَجَّلِ عَلَى الْحُلُولِ فِي الْجَوَازِ بِقِيْدِهِ (أن يكون الدين مما يعجل) ضَمَانُ الْمُؤَجَّلِ لِدُونِ الْأَجْلِ فَإِنْ ضَمِنَهُ لِأَجَلٍ نَفْسِهِ فَجَائِزٌ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَلِأَبْعَدَ مُمْتَنِعٌ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ مَنَفَعَةً فَالْصُّورُ أَرْبَعٌ وَهِيَ:**

* **الصورة الأولى :** ضمان الدين المؤجل على الحلول جائز ، إذا كان الدين مما يعجل ، وهو العين مطلقاً ، والعرض والطعام من قرض لا من بيع

* **الصورة الثانية :** ضمان الدين المؤجل على أن يكون لدون الأجل ، وحكمها كحكم الصورة الأولى

* **الصورة الثالثة :** ضمان الدين المؤجل للأجل نفسه ، وهذه جائزة بلا شرط

* **الصورة الرابعة :** ضمان الدين المؤجل لأبعد من الأجل ، وهذه الصورة غير جائزة ؛ لأنه سلف جر نفعاً

* **فالجواز بشرط في صورتين :** الأولى والثانية ، ويجوز في واحدة وهي الثالثة بلا شرط ، ويمتنع في واحدة وهي الرابعة .

ضمان الدين الحال إلى أجل آخر

يقول المصنف: " (وَعَكْسُهُ) وَهُوَ ضَمَانُ الْحَالِ مُوَجَّلاً كَأَنْ يَقُولَ شَخْصٌ لِرَبِّ دَيْنٍ حَالٌ: أَجَلُ مَدِينِكَ شَهْرًا وَأَنَا أَضْمَنُهُ لَكَ ، فَيَصِحُّ بِشَرْطَيْنِ أَشَارَ لِأَوَّلِهِمَا بِقَوْلِهِ : (إِنْ أَيْسَرَ غَرِيمُهُ) أَي مَدِينُهُ بِالَّذِينَ الْحَالُ وَلَوْ فِي أَوَّلِ الْأَجَلِ ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ ؛ لِلسَّلَامَةِ مِنْ سَلَفٍ جَرَّ نَفْعًا ، فَكَأَنَّهُ بِالتَّأخيرِ ابْتَدَأَ سَلَفًا بِضَامِنٍ وَيُسْرِهِ لَمْ يَحْصُلْ بِالضَّامِنِ نَفْعٌ فَيَكُونُ التَّأخيرُ مُحْضَ سَلَفٍ ، وَأَشَارَ لِلثَّانِي بِقَوْلِهِ (أَوْ لَمْ يُوسِرْ) الْغَرِيمُ (فِي الْأَجَلِ) الَّذِي ضَمِنَ الضَّامِنُ إِلَيْهِ بَلْ أَعْسَرَ وَاسْتَمَرَّ عُسْرُهُ إِلَى انْقِضَائِهِ فَيَجُوزُ ضَمَانُهُ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ حَصَلَ نَفْعٌ بِالضَّمَانِ لَمْ يَحْصُلْ سَلَفٌ بِتَأخيرِهِ لَوْجُوبِ انْتِظَارِ الْمُعْسِرِ ، فَإِنْ لَمْ يُعْسِرْ فِي جَمِيعِهِ بَلْ أَيْسَرَ فِي أَثْنَائِهِ كَبَعْضِ أَصْحَابِ الْغَلَاتِ وَالْوُظَائِفِ ، كَأَنْ يَضْمَنَهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَادَتُهُ الْيَسَارُ بَعْدَ شَهْرَيْنِ فَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الزَّمَنَ الْمُتَأخَّرَ عَنْ ابْتِدَاءِ يَسَارِهِ يُعَدُّ فِيهِ صَاحِبُ الْحَقِّ مُسَلِّفًا لِقُدْرَةِ رَبِّ الْحَقِّ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ عِنْدَ الْيَسَارِ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَسَارَ الْمُتَرَقِّبَ كَالْمُحَقَّقِ وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِصْحَابُ عُسْرِهِ (و) صَحَّ الضَّمَانُ (بِالْمُوسِرِ) بِهِ فَقَطْ (أَوْ بِالْمُعْسِرِ) بِهِ فَقَطْ وَكَلَامُهُ فِي ضَمَانِ الْحَالِ مُوَجَّلاً يَغْنِي إِذَا كَانَ الدَّيْنُ كُلُّهُ حَالًا وَالْغَرِيمُ مُوسِرٌ بِبَعْضِهِ وَمُعْسِرٌ بِالْبَعْضِ الْآخِرِ صَحَّ ضَمَانُهُ مُوَجَّلاً بِهِذَا أَوْ هَذَا (لَا بِالْجَمِيعِ) ؛ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ مَنْفَعَةً إِذْ هُوَ سَلَفٌ لِلْمُوسِرِ بِهِ لِتَأخيرِهِ إِيَّاهُ بِحِمِيلٍ بِهِ وَانْتَفَعَ بِالضَّامِنِ فِي الْمُعْسِرِ بِهِ فَلَيْسَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ كَضَمَانِ الْمُعْسِرِ بِهِ فَقَطْ وَمِثْلُ ضَمَانِ الْجَمِيعِ ضَمَانُ الْبَعْضِ مِنْ كُلِّ " (١)

(١) الشرح والتعليق : وصورة المسألة التي يدور عليها النص ؛ فالحكم على الشيء فرع عن تصوره : دائن لآخر بمبلغ من المال إلى أجل ما ، ثم حل أجل أداء الدين ، فجاء

شخص ثالث وقال للدائن : أجل مدينتك هذا شهرا وأنا ضامن له ، فهذا الضمان جائز بشرطين على البدل ، أي إذا وجد أحدهما كفى في الجواز ، وهما :

* **الشرط الأول :** أن يكون المدين موسرا بالدين الذي حل أجله ، ولو في أول الأجل ، ولو أعسر بعد ذلك (ولكن لماذا التأجيل لأجل آخر ، والمدين موسر وقادر على السداد ؟ لأنه ربما يكون المدين في حاجة لهذا المبلغ لأمر آخر ضروري من نحو طعام ، أو سلعة ضرورية) ولا يقال : إن هذا سلف جر نفعاً إذا أعسر بعد أول الأجل ، وذلك لأن العبرة بحالة المدين الراهنة ، أي عند حلول الجل قبل الضمان ، وهو عنده كان موسرا ، ويسره في أول الأجل والضمان هكذا ، فكأن الدائن ابتداء سلفاً يضمن ، وببسر المدين عند حلول الأجل لم يحصل بالضمان نفع ؛ لأن رب الدين يستطيع أن يستوفي حقه ، وتأخير المدين في هذه الحالة محض سلف.

* **الشرط الثاني :** إذا لم يوسر المدين في أول الأجل بل أعسر ، فيشترط : استمرار حالة الإعسار إلى الأجل الذي سوف يضمنه الضامن إليه ، بمعنى ألا يتقرب يساره أثناء الأجل بغلة ونحوها ، ففي هذه الحالة يجوز ضمانه ، وذلك لأنه وإن حصل نفع للدائن بالضمان نظرا لعسر المدين ، فلم يحصل سلف بتأخيره ؛ لأنه يجب على الدائن انتظار يسر المدين ؛ لقوله تعالى : " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ " البقرة (٢٨٠)

ويفهم من قوله : " واستمر إعساره إلى الأجل الذي سوف يضمن الضامن إليه " أن المدين إذا لم يكن شأنه وحاله الإعسار في جميع الأجل الذي ضمن الضامن إليه بل أيسر في أثناءه ، بأن كانت عادته حصول اليسار له في أثناء الجل كبعض أصحاب الغلات ، والوظائف ، كأن يضمنه إلى أربعة أشهر ، وعادة المدين اليسار بعد شهرين فلا يصح هذا الضمان

←————→ ←————→

أول الأجل ١ / ٤ أثناء الأجل ١ / ٦ آخر الأجل ١ / ٨

هو معسر فيه أيسر أثناء الأجل هنا لا يجوز الضمان

ولماذا لا يجوز الضمان هنا في هذه الصورة ؟ لأن الزمن المتأخر من ابتداء اليسار (١ / ٦) في المثال يعد شرعا أن صاحب الحق مسلف فيه ، وذلك لقدرته على أخذ حقه من المدين عندما كان موسرا ، وقد انتفع الدائن بالضامن الذي توثق به في فترة الإعسار (من

١ / ٦ - ١ / ٨) فيكون سلفا جر نفعا ، وهذا لا يجوز عند ابن القاسم ، واستدل على ذلك بما روي عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل قرض جر منفعة فهو ربا " (وليس من نافلة القول أن نفيض في تخريج هذا الحديث ؛ لأهميته في موضوعنا : الحديث رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده لكنه ساقط الإسناد ؛ لأنه من رواية : سوار بن مصعب وهو متروك ، وقال عمرو بن زيد في المغني : لم يصح فيه شيء ، ولكن له شواهد تؤيده منها : عن فضالة بن عبيد موقوفا قال : " كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا " مسالك الدلالة ص ٢٢٣ ، ٢٢٤ ورواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن سلام ، وابن عباس موقوفا عليهم ، ووهم إمام الحرمين والغزالي ، حيث قالوا : إنه صح ؛ حيث لا خبرة لهما بهذا الفن " نيل الأوطار للشوكاني ج ٥ / ٢٣٢ ، ٢٣٣

* * والله أعلى وأعلم * *

باب الإجارة

باب الإجارة^(١)

قال المصنف:

(باب في الإجارة وكراء الدواب والدور والحمام وما يتعلق بذلك) وهي بكسر الهمزة أشهر من ضمها وهي والكراء شيء واحد في المعنى: وهي تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض، غير أنهم سمو العقد على منافع الآدمي وما ينقل غير السفن والحيوان إجارة، والعقد على منافع ما لا ينقل كالأرض والدور، وما ينقل من سفينة وحيوان كالرواحل كراء في الغالب فيهما^(٢).

(١) كتبه أد/علي محمد علي أحمد، أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

(٢) الشرح: شرع المصنف - رحمه الله - في باب الإجارة وكما جرت العادة في التأليف بدأ بتعريف الإجارة وهي:

تعريف الإجارة في اللغة:

الإجارة مثلثة الهمزة، وتقرأ بالفتح والضم والكسر، وهي بالكسر أفصح، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله وهي بالكسر أفصح وهي مصدر أجر بالقصر، ويقال أجر إيجارًا، كأكرم إكرامًا، ويستعمل الممدود أيضًا من باب المفاعلة، ويكون مصدره المؤجرة. ومجمل معنا في اللغة الأجرة على عمل أو منفعة ذات.

تعريف الإجارة في الشرع: هي: تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض.

شرح التعريف:

قوله "تمليك" جنس في التعريف يشمل سائر عقود التمليك ما يرد منها على الذات كالبيع، وما يرد على المنافع كالإجارة.

قوله "منافع" قيد في التعريف خرج به العقد على الذات كالبيع والهبة، والصدقة؛ فإنها تمليك ذوات.

قوله "مباحة" قيد في التعريف خرج به استئجار منافع الغير منفعة غير مباحة كاستئجار امرأة للرقص أو استئجار رجل لقتل غيره بغير حق، فالإجارة على مثل هذه الأمور غير جائزة؛ لأن المنفعة المراد استيفؤها منفعة غير مباحة.

قوله "مدة معلومة" أفاد ذلك القيد أن الإجارة لا بد أن تكون مؤقتة إذ التأقيت من أبرز خصائصها؛ لأنه يفرق بين الإجارة والبيع.

قوله "بعوض" أي تمليك المنفعة في نظير ومقابلة عوض فخرج بذلك النكاح والجعالة؛ لأن المنفعة في الإجارة تكون في نظير العوض حتى ولو حصل مانع من إتمامه رجع للمحاسبة، بخلاف النكاح والجعالة؛ لأن المنفعة في النكاح هو التمكين من البضع، وفي الجعالة هو التمكين من المجاعل عليه في نظير عوض فيهما، فكل من البضع والمجاعل عليه في المنفعة تحققت أم لا، استمرت أم لا فيثبت العوض بتمامه على كل حال.

حكم الإجارة:

الإجارة من العقود الجائزة دل على جوازها الكتاب، والسنة، والإجماع.

أولاً الكتاب:

- قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ) سورة الطلاق من الآية ٦.
- قوله تعالى: (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَاجٍ) سورة القصص آية ٢٦، ٢٧.

- قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ) سورة الطلاق من الآية ٦.

ثانياً السنة:

- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال الله تعالى: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل ابتاع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره). صحيح البخاري كتب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير.
- وعن عائشة بن عمر - رضي الله عنها - قالت: استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر رجلاً من بني الدئل هادياً خريتماً، وهو على دين كفار قريش، فدفعاً إليه راحلتهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث). وفعل النبي دليل على جواز الإجارة. (صحيح البخاري كتاب الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة).

- وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: (من استأجر أجيراً فليعلمه أجره). نصب الرأية في تخريج أحاديث الهداية. التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني ح ٣، ص ١٣٢ كتاب الإجارة.

ثالثا الإجماع:

أجمع السلف على جواز الإجارة قبل ادعاء ابن عليه والأصم عدم جوازها، وقولهما خرق للإجماع. (بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج ٣، ص ٤١٩، تحقيق وتعليق وتخرير محمد صبحي حلاق، الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة، توزيع مكتبة العلم بجدة، جاء فيه "الإجارة جائزة عند فقهاء الأمصار، والصدر الأول، وحكي عن ابن عليه والأصم منها").

الحكمة من مشروعية الإجارة:

الناس ليسوا في درجة واحدة من المعيشة، ومن امتلاك بعض الأدوات واكتسابهم للمهارات، فيحتاجون إلى خدمة بعضهم البعض فأجيز عقد الإجارة والكراء؛ لما في ذلك من رفع الحرج عن الناس والتيسير عليهم في حياتهم.

والناس محتاجون إلى بعضهم فالفقير محتاج إلى مال الغني والغني محتاج إلى عمل الفقير، ومراعاة حاجة الناس أصل في شرع العقود على وجه ترتفع به الحاجة ويون موافقا لأصل الشرع. (القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، د/ صالح بن غانم السدلان ص ٢٩٢، ٢٩٣، الناشر دار بلنسية، المملكة العربية السعودية، حيث جاء فيه "حيث جاء هناك زمرة من العقود وورد بجوازها نص شرعي استثناء من القواعد العامة على خلاف القياس لحاجة الناس إليها كالسلم والإجارة.... وعقد الإجارة يرد على منافع معدومة تستوفى مع مرور الزمن في المستقبل؛ لكنه أجيز لحاجة الناس إليها لاسيما في عصرنا الحاضر - إلى السكنى).

الفرق بين الإجارة والكراء:

الإجارة والكراء شيء واحد في المعنى. إلا أنهم أطلقوا على العقد على منافع الآدمي ومنافع ما ينقل كالثياب والأواني والأمتعة، إلا السفن والحيوان إجارة؛ وعلى العقد على منافع ما لا ينقل كالأرض والدور، وما ينقل من سفينة وحيوان كالرواحل كراء، وهذا على سبيل الغالب في إطلاق لفظي الإجارة والكراء. وقد يتسمحن بإطلاق الإجارة على الكراء والكراء على الإجارة، فيطلقون على العقد على منافع الآدمي ومنافع ما ينقل غير السفن والحيوان كراء، ويطلقون على العقد على منافع ما لا ينقل ومنافع السفن والرواحل إجارة.

والترقية التي ذكرها المالكية مبنية على العرف، وهي تفرقة اصطلاحية لا يترتب عليها أثر وإلا فالكل يسمى إجارة. (حاشية الدسوقي يهامش الشرح الكبير لمحمد بن عرفة الدسوقي ج ٤، ص ٢).

أركان الإجارة

قال المصنف:

"وأركانها أربعة: العاقد، والأجر، والمنفعة، والصيغة، والمراد ما يدل على تمليك المنفعة بعوض، ويشمل ذلك المعاطاة، وأشار إلى الأولين بقوله: (وصحة الإجارة بعاقده) مؤجر ومستأجر كالبيع؛ فشرطهما التمييز، وشرط اللزوم التكليف؛ فالصبي المميز إذا أجر نفسه أو سلعته صح وتتوقف على رضا وليه ومثله العبد، وأما السفية إن عقد على نفسه فلا كلام لوليه إلا إذا كان في الأجر محاباة فلوليه النظر وإن عقد على سلعة فلوليه النظر مطلقا كالبيع فالشرط لزوم أيضا في الجملة" (١).

(١) الشرح: قول المصنف وأركانها أربعة، يقصد أن للإجارة أربعة أركان وهي:

الركن الأول: العاقدان: وهما المؤجر، والمستأجر.

المؤجر: هو الذي يدفع الأجر مقابل المنفعة.

المستأجر: هو الذي يأخذ المنفعة مقابل الأجر.

يشترط في المؤجر، والمستأجر ما يشترط في البائع والمشتري في عقد البيع؛ لأن الإجارة بيع في المعنى إلا أنه بيع يرد على المنفعة دون الذات.

شروط صحة عقدهم: العقل فلا يصح من مجنون ومعتوه.

شروط لزوم عقدهم:

٣-الرشد

٢ -التكليف

١- الطوع

إجارة ناقص الأهلية

أولاً: إجارة الصبي المميز: تصح إجارة الصبي المميز سواء أجر نفسه، أو أجر سلعته، ويتوقف لزوم إجارته على رضا وليه، ومثله العبد.

ثانياً: إجارة السفية: إن عقد على نفسه، فلا كلام لوليه؛ إلا إذا كان في الأجرة محاباة، كما لو كان مثله يأخذ مقابل عمل مائة جنيه في اليوم وأجر نفسه بعشرين جنيهاً في اليوم، فإن الإجارة في هذه الحالة تكون متوقفة على إذن الولي.

أما إذا أجر السفية نفسه شيئاً مملوكاً له فإن عقده يتوقف على رضا الولي في جميع الأحوال كان الأجر فيه محاباة أم لا، ذلك كالبيع؛ لأن التكليف شرط للتصرف المالي، والتكليف شرط لزوم في الجملة وليس في جميع الأحوال.

الركن الثاني الأجر:

ويقصد به ما يبذله مالك المنفعة مقابل بذله منفعته، ويشترط فيه ما يشترط في البيع في الثمن من كونه طاهراً، منتفعاً به، مقدوراً على تسليمه.

الركن الثالث الصيغة:

وهي كل ما يدل على تمليك المنفعة العوض، ويشمل ذلك الأقوال، والأفعال، والمعاطاة وهي تمليك المنفعة وبذل الأجر دون تلفظ، فمن ذهب إلى الشاطئ وجلس تحت مظلة - مملوكة لغيرة- مدة من الزمن وقام وترك لصاحبها أجرتها صحت الإجارة، وتصح الإجارة بالمعاطاة إذا كانت الأجرة معلومة لدى الطرفين قبل الشروع في العقد.

قول المصنف (وصحت الإجارة بعاقده وأجره) في كلام المصنف حذف الواو وما عطف عليه أي صحة الإجارة ولزومها بعاقده وأجره كالبيع، وإنما قدرنا ذلك؛ لأنه لا يلزم من الصحة اللزوم.

قول المصنف "بعاقده" أي من يلي العقد بنفسه أو نيابة عن غيره، ومن يلي العقد في الإجارة المؤجر أو المستأجر.

قوله "وشروطهما" أي شروط صحة عقدهما أي المؤجر والمستأجر.

قوله في "الجملة" يعني في أغلب الأحوال وليس في كل الأحوال، وقوله "وأجره كالبيع" أي يشترط فيه ما يشترط في الثمن الذي هو ركن في البيع.

حالات وجوب تعجيل الأجرة

قال المصنف:

ولما كانت قاعدة الإمام ابن القاسم أن الثمن في المبيع الأصل فيه الحلول، وأن الأجرة في الإجارة على التأجيل إلا في مسائل يجب فيها تعجيل الأجرة ذكرها المصنف بقوله (وعجل) الأجر وجوباً فلا يؤخر لأكثر من ثلاثة أيام وإلا فسد العقد (إن عين) أي إن كان معيناً كثوب بعينه أي شرط تعجيله أو كانت العادة تعجيله وإلا فسد العقد ولو عجل بالفعل كما يأتي في قوله وفسدت الخ (أو) كان غير معين ووقع التعجيل (بشرط) أي بسببه وهو عطف على معنى إن عين أي وعجل الأجر بتعيينه أو بشرط (أعادة) بأن كان الغرف والعادة التعجيل وسواء كانت المنافع معينة أو مضمونة شرع فيها أم لا فهي صحيحة في هذه الأربع^(١).

(١) الشرح: القاعدة عند ابن القاسم الأصل في الثمن في البيع هو الحلول، وأن الأصل في الأجرة في الإجارة هو التأجيل، إلا في أربع مسائل يجب فيها تعجيل الأجرة وهي:

- ١- إذا اشترط التعجيل وكان الأجر غير معين.
- ٢- إذا اعتيد التعجيل، بأن كان العرف والعادة التعجيل، وكان الأجر غير معين؛ لأن العادة تقوم مقام الشرط.
- فهذا إذا كان الأجر في الحالتين غير معين، كأن يقول المستأجر أكرني دارك سنة مثلاً لأسكنها بكذا، أو أرضك لأزرعها بكذا، وكانت الأجرة دنانير أو دراهم، لأن الدنانير والدرهم لا تتعين، ووجوب تعجيل الأجر في شرط التعجيل واعتياد التعجيل يقضى به عند التنازع، فإن تراضيا على التأخير جاز ذلك.
- ٣- إذا عين الأجر كهذا الثوب -أي في العروض- فإنه يجب تعجيله، إن شرط التعجيل أو كان العرف تعجيله ويغتنر التأخير ثلاثة أيام.
- ٤- إذا لم يتعين الأجر، أي كان في الذمة، والحال أنه لم يجز عرف ولا يوجد شرط بالتعجيل؛ فإنه يجب تعجيل الأجر إن كان في منافع مضمونة في ذمة المؤجر ولم يشرع

فيها مثل أن يقول استأجرتك على فعل كذا مثلا، فإنه يجب تعجيل الأجر، فإن شرع فلا ضرر، وإن لم يشرع فيها وتأخر في الشروع أكثر من ثلاثة أيام فلا يجوز، إلا إذا عجل جميع الأجرة، وإلا لأدي إلى ابتداء الدين بالدين وهو منهي عنه.

ويستثنى من ذلك حالة: يتعاقد فيها السفر مع غيره إلى الحج قبل أوانه كما يحدث في أعرافنا فإنه يجوز له أن يكتفي بدفع بعض الأجرة عربونا في حالة خوف التلاعب، أو عدم الوفاء.

ويشترط لصحة هذا الاستثناء: أن يكون التعاقد في غير أوان الحج، أما إذا كان التعاقد في أوان الحج فلا بد من دفع كامل الأجرة أو الشروع في السفر. فإذا لم توجد حالة من حالات وجوب التعجيل للأجر فيجوز تعجيله وتأجيله حسبما يرضيه الطرفان، فإن اختلفا في الدفع يكون مياومة كلما استوفى منفعة يوم أو تمكن من استيفائها دفع الأجرة.

ويستثنى من ذلك: الأجراء والصناع فإنهم لا يعطون الأجر إلا بتمام العمل كله وذلك عند المشاحة أما عند التراضي فيجوز كل حال، وإلى هذا أشار المصنف بقوله وأما الصانع والأجير فليس أجرة إلا بعد التمام، ففي المدونة وإذا أراد الصناع والأجراء تعجيل الأجر قبل الفراغ وامتنع رب الشيء حملوا على المتعارف بين الناس، فإن لم يكن لهم سنة لم يقض لهم بشيء إلا بعد الفراغ.

الأحوال التي تفسد فيها الإجارة

قال المصنف:

(وفسدت) إجارة عينت فيها الأجرة فهو راجع كقوله وعجل إن عين (إن انتفى) فيها (عرف تعجيل المعين) بأن كان العرف التأخير أولا عرف، وعلل الفساد بأنه كشرط التأجيل فيلزم الدين بالدين ، وعمارة الذمتين، ومحل الفساد فيهما إن لم يشترط التعجيل كما مر (كمع جعل) أي كما تفسد الإجارة إذا وقعت مع جعل صفقة واحدة ؛ لتنافرهما؛ لما في الجعل من عدم لزومه بالعقد، وجواز الغرر ، وعدم الأجل بخلاف الإجارة، (لا) مع (بيع) صفقة واحدة فلا تفسد لعدم منافاتها سواء كانت الإجارة في نفس البيع كشرائه ثوبا بدراهم معلومة على أن يخطه البائع أو جلدا على أن يخرزه الخرازة ، أ و في غيره كشرائه ثوبا بدرهم معلومة على أن ينسج له آخر ، ويشترط في الصورة الأولى شروعه ، أو ضرب أجل الإجارة ، ومعرفة خروجه عين علة أم لا ، أو إمكان إعادته كالنحاس على أن يصنعه قدحا كما قدمه في السلم ، فإن انتفى الأمران كالزيتون على أن يعصره فلا ، وأما إن كانت الإجارة في غير نفس المبيع فتجوز من غير شرط ، ثم عطف على قوله كمع جعل مسائل تفسد فيها الإجارة للجهالة فقال (ومجلد) جعل أجرا (لسلاخ) وأدخلت الكاف اللحم كلا و بعضا وسواء كانت الشاة حية أو مذبوحا ، لأنه لا يستحقه إلا بعد الفراغ ، وقد يخرج صحيحا أو مقطوعا.. (أو نخالة لطحان)؛ لأنها مجهولة القدر كالجزاف غير المرئي ، وأما لو استأجره بكيل معلوم منها على أن يطحن له قدرا من الحب فيجوز (وجزء ثوب) جعل أجرة (لنساج) ينسج ذلك الثوب ، ومثل ذلك الجلود دبغها [جزء منها ؛ لجهل صفة خروجه ، فإن وقع فالثوب لربه ، وله أجر مثله (أو رضيع) آدمي أو غيره جعل جزؤه كربيعة أجرا لمن يرضعه على أن يملكه بعد الرضاع بل (وإن) كان يملكه

(من الآن) ، لأن الصبي قد يتغير ، وقد يتعذر رضاعه لموت أو غيره ، ولا يلزمه خلفه فيصير نقد الأجرة فيها كالنقد في الأمور المحتملة وهو ممتنع سواء كان المنقود مثليا أو مقوما كم هنا (و) فسدت إذا استأجر هـ (بما سقط) أي بجزء منه كثلث (أو) بجزء منها (خرج من عصر زيتون) راجع للثاني للجهل بالكم ، والصفة ؛ لأن من الشجر ما هو قاصر يقل ما يسقط منه ، ومنه ما هو بخلافه (وكاحصد وادرس) هذا الزرع (ولك نصفه) وكذا ادرسه ولك نصفه ففاسد ، وله أجر مثله ، وأما احصده فقط ولك نصفه فسيأتي أنه جائز (وكراء أرض) صالحة للزراعة (بطعام) سواء انبت كالقمح ، أو لم تنبته كاللبن والعسل لئلا يدخله الطعام بالطعام ، لأجل مع التفاضل والغرر ، والمزابنة ، وأما بيعها به فيجوز (أو بما تنبته) غير طعام كقطن وكتان ، وعصفر ، وزعفران ، وتين ، وأما كراء الدور والحوانيت بالطعام فجائز إجماعا (كخشب) وحطب وقصب فارسي ، وعود هندي وصندل من كل ما يطول مكثه فيها حتى يعد كأنه أجنبي منها فيجوز (و) فسدت إجارة على (حمل طعام) مثلا (البلد) بعيد لا يجوز تأخير قبض المعين اليه (بنصفه) مثلا لما فيه من بيع معين يتأخر قبضه ، فإن وقع فأجر مثله ، والطعام كله لربه (إلا أن يقبضه) أي الجزء المستأجر به (الآن) أي حين العقد بالفعل لعرف ، أو يشترط قبضه الآن ولولم يقبض بالفعل لعدم العلة المتقدمة فهذه المسألة من أفراد الإجارة بمعين فيجري فيها تفصيله ، وهو أنه إن وقعت والعرف التعجيل فلا بد منه وإلا فسدت ، وإن كان العرف التأخير أولا عرف فلا بد من اشتراط التعجيل وإلا فسدت ، ويغتفر التأخير اليسير كالثلاثة الأيام (وكان) أي كقوله إن (خطته اليوم) مثلا فهو بكذا من الأجر عشرة (وإلا) تخطه اليوم بل أزيد (فبكذا) أي بأجر أقل كثمانية ففاسدة للجهل بقدر الأجرة ، فإن وقع فله أجرة مثله ، ولو زاد على المسمى خاطه في

اليوم أوفي أكثر (واعمل على دابتي) ولم يقيد باحتطاب ولا غيره (فما حصل) من ثمن أو أجرة (فلك نصفه) مثلا ففاسدة للجهل بقدر الأجرة، وكذا في داري ،أوفي حمامي أو سفينتي ونحوها فيتعين الفسخ إن لم يعمل فإن عمل فأشار له بقوله (وهو) أي ما حصل من عمله (للعامل) وحده (وعليه أجرتها) أي أجرة مثلها لربها بالغ ما بلغ ، ومثل ذلك إذا قال له أعمل عليها فأكرها على الأرجح أوقال له أكرها وما حصل من ذلك فلك نصفه فعمل عليها (عكس) خذها (لكريها) وما حصل فلك نصفه فأكرها فما حصل فلربها وعليه للعامل أجر مثله ؛ لأنه أجر نفسه إجارة فاسده ، فالصور أربع ثلاثة منها الأجر فيها للعامل ، وعليه أجرتها ، والرابعة بالعكس إلا أن الثانية فيها قولان مرجحان وما قدمناه قول ابن القاسم فيها (وكبيعه) عطف على قوله كمع جعل (نصفا) لكثوب بدينار يدفعه الأجير لربه (بأن) أي على أن (يبيع) له (نصفا) ثانيا أي باعه نصف السلعة بدينار مثلا على أن يبيع له النصف الثاني فصار ثمن النصف المبيع للسمسار مجموع الدينار والسمسرة علي بيع النصف الثاني إن أبهم في محل البيع ، أو عين غير بلد العقد ؛ لأنه بيع معين يتأخر قبضه (إلا بالبلد) أي إلا أن يكون محل البيع البلد الذي هما به فيجوز ؛ لأنه متمكن من قبض نصيبه من الآن ، ويلحق به بلد قريب يجوز تأخير قبض المعين له ، وللجواز شرطان زيادة على اشتراط تعيين البلد أشار لهما بقوله (إن أجلا) أي ضربا لبيع النصف الثاني أجلا ليكون إجارة محضة وهي تجامع البيع فيخرجان عن بيع وجعل (ولم يكن الثمن) أي ثمن العمل الذي هو السمسرة على بيع النصف الآخر، وهو النصف المدفوع للسمسار (مثليا) وحينئذ فهو مساو للتعبير بالثمن ، أو المبيع نعم التعبير بما ذكر أوضح ، فلو كان المبيع مثليا منع ؛ لأنه قد يصير تارة إجارة وسلفا ؛ لأنه قبض إجارته وهي مما لا يعرف بعينه فيصير

سلفا إن باع في نصف الأجل؛ لأنه يرد حصة ذلك ، وتارة يكون ثمنا إن باع في آخر الأجل ، أو مضى الأجل ولم يبيع العقد بين الممنوع وهو إجارة وسلف و الجائز وهو الثمن ، ويفهم من هذا أنه إذا شرط عليه أنه باع في أثناء الأجل لا يرد له باقي الثمن بتركه أو يأتيه بطعام آخر يبيعه أنه يجوز وهو كذلك^(١).

(١) الشرح: ذكر المصنف عدة صور تفسد فيها الإجارة وهي:

١- تفسد الإجارة بوقوعها بأجر معين وانتفى عرف تعجيل الأجر المعين؛ لأن انتفاء العرف بمثابة اشتراط التأجيل في حالة يجب فيها التعجيل فيكون ابتداء الدين بالدين وهو مما لا يجوز في الشرع.

ومحل الفساد حيث لا يوجد شرط يوجب تعجيل الأجر ، فإن وجد شرط تعجيل الأجر كانت الإجارة جائزة وصحيحة حتى لو انتفى عرف التعجيل.

٢- وقوع الإجارة مع الجعالة والجعالة هي: التزام أهل الإجارة عوضا علم، لتحصيل أمر يستحقه السامع بالتمام، إلا أن يتم غيره فبنسبة الثاني. (الشرح الكبير شرح مختصر خليل للشيخ أحمد الدردير ، ج٤، ص ٦٠ بهامش حاشية الدسوقي للعلامة محمد عرفة الدسوقي، وبهامشه تعليقات للشيخ محمد عليش) في صفقة واحدة مثل أجرني دابتك وائتني ببعيري الشارد بكذا؛ فتفسد الإجارة والجعل معا؛ وذلك لتنافر أحكامهما؛ إذ الجعالة غير لازمة بالعقد وإنما تلزم بتنفيذ العمل المتفق عليه، فالمقصود بالجعالة التعاقد على إتمام عمل بأجر، وهي التزام من طرف واحد وهو الجاعل ابتداء، بخلاف الإجارة فهي تلزم بمجرد العقد، وعقد الإجارة ملزم للطرفين.

الجعالة يجوز فيها الغرر بجهل مقدار العمل، بخلاف الإجارة فلا يجوز فيها الغرر.

الجعالة لا يجوز فيها الأجل، بخلاف الإجارة فيجوز فيها الأجل.

ويجوز أن تجتمع الإجارة مع البيع في عقد واحد، فلا تفسد لعدم منافاتهما سواء كانت الإجارة في نفس المبيع كشرائه ثوبا بدراهم معلومة عل أن يخطه البائع، أو جلد على أن يخزعه، أو في غيره كشرائه ثوبا بدراهم معلومة على أن ينسج له آخر ويشترط لصحة هذه الصورة عدة شروط:

- شروع الأجير في العمل بحيث لا يتأخر العمل عن ثلاثة أيام من تاريخ الاتفاق على العمل.
- أن يضرب له أجلا للإجارة.
- أن يعرف في العادة الحالة التي يكون عليها المعمول بعد تمامه من الجودة والرداءة حتى تخرج الجهالة، فإذا لم يمكن ذلك فلا تجوز الإجارة إلا إذا كان الشئ الذي أضيفت إليه الصنعة مما يمكن إعادته إلى الحالة الأولى التي كان عليها عند التعاقد كما هو الحال في التعاقد على شراء سبيكة من الذهب على أن يصنعها البائع مشغولات ذهبية.
- أما إذا ورد عقد الإجارة على غير المبيع كما لو اشترى ثوبا على أن يصنع له آخر فهذه الصورة تجوز بدون شروط.
- ٣- تفسد الإجارة إذا كان الاستئجار على أن تكون الأجرة بعض ما استؤجر عليه الأجير، ومن أمثلة ذلك:
- لا يجوز الاستئجار على ذبح شاة على أن يأخذ السلاخ أجرة على السلخ في حيوان مباح الأكل، فالإجارة فاسدة، وقعت قبل الذبح أو بعده؛ لأنه لا يستحق الجلد إلا بعد السلخ، وهو لا يدري هل يخرج الجلد سليما أو مقطوعا، وفي أي جهة يكون القطع، وهل يكون رقيقا أم لا، فعلة المنع هنا الجهل بصفة الجلد بعد السلخ، وهو غرر ممنوع في الإجارة كالبيع، ومثل الجلد اللحم كلا أو بعضا؛ لأن اللحم مجهول مغيب بالجلد ولا بد في عوض الإجارة أن يكون معلوما، وكذلك لا تجوز الإجارة على ذبحها بقطعة من لحمها.
- أن يعطى الطحان النخالة أجرة، كأن تستأجر شخصا يطحن لك حبا بنخالة. ومن أمثلة هذا القبيل ما يقع في بلاد الأرياف من دفع الزرع لمن يدرسه بنورجه وبهائمه ويأخذ تبنة في مقابلة درسه فهي إجارة فاسدة، وأما لو قال له أدرسه ولك حملان تبنا من تبنة، أو من غير تبنة جاز ذلك.
- أن يعطى النساج جزء من الثوب المنسوج أجرة على النسج، والدباغ جزء من الجلد المدبوغ أجرة على الدبغ، فنفسد الإجارة لجهل صفة خروجه.

ما يجوز في الإجارة

قال المصنف: (وجاز) أي عقد الإجارة على دابة (بنصف) جر نصف بالباء، وهي ظاهرة ، وفي نسخة ، فنصف مرفوع بدل من ضمير جاز العائد

- أن يعطى جزء الحيوان الرضيع أجرا لمن يرضعه، وعلل الفساد أن الرضيع قد يتغير، وقد يتعذر رضاعة لموت أو غيره، ولا يلزمه خلفه، فيصير نقد الأجرة فيها كالنقد في الأمور المحتملة، بين السلامة وعدمها وهو ممتنع سواء كان المنقود مثليا أو مقوما.
- ٤- الإجارة على عمل تكون الأجرة للأجير فيها مما يحصله من ثمن أو أجرة ممن يعاملهم بالنصف مثلا. ومثال ذلك: قول الرجل للأجير اعمل على دابتي، أو أعمل على سيارتي، أو في حانوتي ونحو ذلك، وما حصل من ثمن وأجرة فلك نصفه مثلا فهذه الإجارة فاسدة للجهل بقدر الأجرة فتفسخ.
- فإن عمل فجميع ما تحصل يكون للعامل، وعليه لرب الدابة، أو السيارة، أو الحانوت ونحو لك أجرة مثلها، أي الدابة وما معها؛ وذلك لأنه يكون كأنه اكترى ذلك كراء فاسدا.
- ٥- أن يعطى الأجير على الحصاد زرع ودرسه نصف ما يخرج أو ثلثه، وكذا درسه فقط فذلك فاسد، ولالأجير أجرة عمله؛ وذلك للجهل بما يخرج من الحب وهو غرر؛ لأن نصف الحب أو ثلثه مغيب لا يدري كم يخرج وكيف يخرج.
- ٦- كراء الأرض للزراعة بطعام على اختلاف أصنافه، على النحو التالي:
 - كان مما تنبته الأرض كالقمح.
 - أولم تنبته كاللبن والسمن، والعسل، والشاة المذبوحة، والحيوان الذي لا يراد إلا للذبح كخصي المعز، والسماك، وطير الماء، وكذلك الحيوان الذي يراد للبنز
 - أو مما تنبته من غير الطعام، كقطن وكتان، أي شعرهما لا ثيابها وكزعفران وعصفر وتبن وحطب الذرة.
 - أما كراء أرض الزراعة لغير الزراعة بطعام وبما يخرج منها فيجوز.
- كما يجوز بيعها بالطعام وبما يخرج منها وإن لم يكن طعاما 'فالنهى قاصر على الكراء، لا على البيع.
- وكذلك فإن كراء الدور، والحوانيت بالطعام جائز، والدليل هو الأجماع.

على الكراء أو الإجارة أي وجاز كراء هو نصف (ما يحتطب عليها) أي الدابة المتقدم ذكرها بشرط أن يعلم ما يحتطبه عليها بعرف ، أو غيره سواء قيد بزمان كيوم لي ويوم لك أم لا كنقله لي ونقله لك فالأجرة هنا معلومة بخلاف ما تقدم من قوله واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه واحترز بقوله بنصف ما يحتطب عليها فلا يجوز لقوة الغرر ، ومثل السفينة الدابة والشبكة ونحوهما فيجوز بنصف ما يحمل عليها إذا كان معينا من مكان معين فلا مفهوم لدابة ولا النصف ، (و) جاز (صاع دقيق) يدفعه رب القمح ونحوه لمن يطحنه له (منه) أو من غيره في نظير طحنه (أو) صاع (من زيت) يدفعه رب الزيتون لمن يعصره له أجرة لعصره (لم يتخلف) أي إذا لم يختلف كل من الحب أو الزيتون في الخروج ، فإن اختلف بأن كان تارة يخرج منه الدقيق ، أو الزيت ، وترة لا تمنع ؛ للجهالة ، فإن شك في الخروج حمل في الزيتون ونحوه كبزر السمسم على عدم الخروج فيمنع ، وفي الحنطة ونحوها على الخروج فيجوز^(١).

(١) الشرح: بعد أن ذكر المصنف صور من الإجازات الفاسدة تبعه بذكر صورتين من الإجازات الجائزة وهي كما يلي:

١ - إجارة السيارة بجزء من مما ينقل عليها:

يجوز إجارة السيارة التي تنقل أشياء كسيارات النقل المعروفة عندنا على أن تكون معلومة معينة فلا مجال لعدم الجواز ثم إن هذه الصورة تختلف عن الصور التي ذكرها المصنف في الإجازات الفاسدة، وهي إجارة الدابة بنصف ما يحتطب عليها أي بنصف ثمن ما يحتطب عليها لأن الثمن المنقول يتطرق إليه الجهالة بخلاف ما نحن عليه حيث إن المنقول شيء معين ينقل إلى مكان معين فلا جهالة هنا. لكن يشترط للجواز أن يعلم قدر ما يحمل على السيارة ونحوها بعرف أو نحو ذلك للخروج من الجهالة.

٢ - الإجارة على الطحن، أو العصر بجزء معين من المطحون والمعصور:

يجوز الإجارة على طحن حب من القمح وغيره على ان يكون أجرة الطحان جزء معين من الدقيق، وكذلك تجوز الإجارة على عصر حب الزيتون، أو السمس على أن تكون أجرة العاصر جزء مهين من الزيتون المعصور.

ويشترط لجواز ذلك: عدم اختلاف أحوال المعمول - القمح، والزيتون ونحوهما - بعد الخروج على حالة معينة، أما إذا اختلفت بأن كان تارة يخرج منه دقيق، أو الزيت، وتارة لا، مَنع؛ للجهالة، فإن شك في الخروج حمل في الزيتون ونحوه كبزر السمس على عدم الخروج لكون الشأن فيه ذلك لربما كان الزيتون رديئاً لا يخرج منه زيت، فيمَنع، وفي الحنطة ونحوه على الخروج فيجوز؛ لأن العادة في القمح يخرج منه الدقيق، وإن اختلفت درجة الجودة فيه.

إجارة الشيء المؤجر

قال المصنف: (و) جاز استئجار المالك المؤجر لداره، أو دابته مثلاً (منه) أي من المستأجر إلا لتهمة سلف جر منفعة كإيجاره بعشرة لأجل واستئجارها بثمانية نقداً^(١).

(١) الشرح: ذكر المصنف هنا صورة من صور الإجارة الجائزة وهي إيجار الشيء المؤجر - بفتح الجيم - للمالك كأن يستأجر إنسان داراً، أو دابة من شخص ثم يقوم المستأجر بتأجيرها للمالك بمثل الأجرة، أو أقل، أو أكثر، سواء كانت بجنس الأول أولاً، بشرط أن تكون مدة الإجارة الثانية أقل من المدة الأولى، أو مساوية لها؛ لأن الإجارة إذا انتهت مدتها عاد الملك لصاحبه ولا يتصور أن يستأجر الإنسان ملكه. أما إذا وجد تهمة فلا يجوز كاستئجارها بعشرة حالاً، وبثمانية حالاً، فتمنع هنا لتهمة سلف جر نفعا.

جعل الخدمة أجرا على تعليم الصنعة

قال المصنف: (وجاز) لمن له رقيق، أو ولد (تعليمه) أيدفعه لمن يعلمه صنعة معينة (يعمله سنة) مثلاً للمعلم فسنة ظرف لعمله، وأما التعليم فمطلق وابتداء السنة من يوم العقد عند الإطلاق فإن هينا زمنا عمل به فيما يظهر^(١).

(١) الشرح: ذكر المصنف صورة من صور الإجازات الجائزة، وهي جعل الخدمة أجرا على تعليم صنعة معينة على أن يكون الأجر مقابل التعليم، جرت العادة أن يذهب الصبيان إلى أصحاب الحرف - نجار، أو ميكانيكا، أو سباكة... - فترة معينة من الزمن ليتعلم هؤلاء الصبيان الصنعة ولا يتقاضى هؤلاء الصبيان أجرة في تلك الفترة؛ لأن أجرته كانت مقابل تعليمه الحرفة، ويبدأ حساب الفترة التي يعمل فيها الصبي في محل العمل من يوم أخذه لا من يوم العقد فإن حدد زمنا معيناً يبدأ فيه عمل الصبي عند صاحب الحرفة عمل.

الإجارة على حصاد الزرع بجزء معين من المحصول

قال المصنف: (و) جاز (أحصد) زرعي (هذا ولك نصفه)، وجذ نخلي هذا ولك نصفه وأشار إلى أنه لابد من تعيينه وهي إجارة لازمة ليس لأحدهما الترك، وبقية العمل من الدرس والتذرية عليهما، ويمنع قسمة قتا؛ لأنه خطر ويدخله التفاضل قاله ابن يونس، وحصد من باب نصر وضرب فتضم الصاد في الأمر والمضارع وتتكسر، (و) جاز أحصد زرعي و(ما حصدت فلك نصفه) مثلا وهذا من باب الجعالة لعدم تعيين ما يحصد فله الترك متى شاء، وما قبله من الإجارة كما تقدم^(١).

(١) الشرح: ذكر المصنف صورة من صور الإجازات الجائزة وهي الإجارة على حصاد الزرع بجزء معين من المحصول مثل: أن يستأجر شخصا ويقول له المالك: أحصد زرعي، أو جذ نخلي هذا ولك نصفه، وهي من باب الإجارة اللازمة ليس لأحد أن يرجع فيها، فيملك الأجير حصته بالعقد لا بالحصاد خلافا للشيخ عبد الباقي الزرقاني، وحينئذ فهو يحصد النصف له، والنصف الآخر لربه كما صرح به ابن رشد، وعياض، وما هلك قبل الحصاد فضمامنه منهما، وبقية الأعمال من التذرية والدرس عليهما، ولا يجوز قسمته قتا حتى لا يدخله التفاضل.

والفرق بين هذه الصورة، والصورة والتي تقدم ذكرها في قوله " كاحصد وادرس هذا الزرع ولك نصفه" وهي صورة من صور الإجارة الفاسدة، أما الصورة التي نحن بصدد استأجره بجزء من المحصول وهو مشاهد فكان بمثابة الأجر الجزافي وهو جائز عندنا، أما الصورة التي في الإجارة الفاسدة فإنه استأجره على جزء من الحب وهو مغيب لا يرى فتطرق إلى الجعالة المقضية إلى المنازعة.

ويجوز أن يقول المالك للمستأجر وما حصدت فلك نصفه ويكون هذا من باب الجعالة؛ لعدم تعيين ما يحصد، ويحتمل أن يحصده كله، أو نصفه، أو ثلثه، أو غير ذلك، وهي غير لازمة للمستأجر، ولذلك يجوز له أن يترك العمل في أي وقت شاء، ولذا قيد بعض علمائنا الجواز بعدم تعيين زمن معين للحصد كما هو الحال في الجعالة.

إجارة دابة، أو سفينة لمسافة محددة أو مدة محددة

على أنه إن استغنى في المدة أو المسافة حاسب ربحها

قال المصنف: (و) جاز (كراء دابة) أو سفينة (لكذا) أي إلى مدة معينة بأجرة معلومة (على) أنه (إن استغنى فيها) أي في المدة أو المسافة المعينة (حاسب) ربحها أي كان له بحساب ما سار أو ما سكن بحسب الصعوبة والسهولة ويصدق في استغنائه؛ لأنه أمين، وأما إن كان على أنه إن زاد فله بحساب ما أكرى لم يجز إلا إن عين غاية ما يزيد^(١).

(١) الشرح: أشار المصنف هنا إلى مسألة أخرى من الصور الجائزة للإجارة من استأجر دابة ونحوها كسفينة لمسافة محددة، أو مدة محددة على أنه إن استغنى عنها في المدة، أو المسافة المعينة لظفرة حاجته في أثناء الطريق حاسب ربحها، أي: أنه كان لربحها بحساب ما سار المستأجر أو سكن صعوبة وسهولة.

ووجه الجواز هنا: أنه كأنه قال له أكرىك من هذا الطريق كل بريد بكذا، وأجرتك الدار بحساب كل شهر بكذا، فيكون ذكر المسافة لتتقدر الأجرة. ومحل الجواز إن لم ينقد الأجرة فإن نقدها لم يجز.

حكم إيجار شيء مؤجر - بفتح الجيم - وإيجار الشيء المنشئ منفعة

قال المصنف: (و) جاز (استئجار شيء مؤجر) بفتح الجيم من حيوان أو غيره مدة تلي مدة الإجارة الأولى للمستأجر الأول أو لغيره (أو) استئجار شيء مستثنى أي استثناء البائع فيجوز استئجاره من المشتري مدة تلي مدة الانتفاع يعني أن من اشترى سلعة واستثنى بائعها منفعتها مدة معينة جاز له أن يؤجرها لأنسان مدة بعد مدة الانتفاع على أن يقبضها المستأجر بعد مضي مدة الانتفاع وسيأتي المصنف أنه يجوز استثناء العام في الدار وسنين في الأرض ، وثلاثة أيام في الدابة لا جمعة وكره المتوسط (و) جاز (النقد فيه) أي في الشيء المؤجر والمبيع المستثنى منفعته (إن لم يتغير غالبا) أي إن لم يغلب على الظن تغيره مدة الإجارة ، ومدة الاستثناء بأن ظن بقاؤه بحالة ، أو احتمال بأن شك في البقاء وعدمه وهو مسلم في الصورة الأولى دون الثانية ، ويجوز أن يكون قوله إن لم يتغير شرطا في أصل الجواز لا جواز النقد أي محل جواز استئجار ما ذكر ما لم يغلب على الظن تغيره لكن إن ظن البقاء فالجواز قطعا ، وإن احتمل فعلى أحد القولين ، وإن ظن التغير فالمنع قطعا ، وإذا منع العقد منع النقد ضرورة ، (و) جاز لمن استأجر دارا سنين ، أو شهور ، أو أياما بأجر معلوم (عدم التسمية لكل سنة) أو شهر ، أو يوم فإن كانت السنين ، أو الشهور تختلف في القيمة كدور مكة ، ودور النيل بمصر ، وحصل مانع رجوع للقيمة لا التسمية ، فإن شرط في العقد الرجوع للتسمية فسد^(١).

(١) الشرح: ذكر المصنف إيجار شيء مؤجر - بفتح الجيم - أي: إن من أجر حيوانا أو دارا مدة معينة معلومة كشهر أو سنة، يجوز له أن يؤجره قبل انقضائها مدة تلي مدة الإجارة

الأولى للمستأجر، أو لغيره، وذلك ما لم يجر عرف بعدم إيجارها إلا للأول، كالأحكار الموقوفة بمصر، وإلا عمل به؛ لأن العرف كالشرط.

وكذلك يجوز استئجار شيء مستثنى منفعته عند البيع بأن استثنى البائع منفعة ما باع، دار أو غير ذلك مدة معلومة، فللمشتري منه أن يؤجر ما اشتراه مدة تلي مدة الانتفاع، على أن استثناء السنة في الدار والسنتين في الأرض، وثلاثة أيام في الدابة.

النقد في إيجار المؤجر والمبيع المستثنى منفعته، ومحل جواز الإيجار والنقد إن لم يتغير غالبا، بأن كان الشأن عدم تغيره وهو صادق في صورتين ما إذا كان الغالب سلامته أو احتمل السلامة وعدمها، لكن الصورة الأولى متفقع عليها، والثانية فيها خلاف، هذا بالنسبة للإيجار فيهما، وأما النقد يجوز إن غلبت السلامة فيهما، لا إن لم تغلب بأن كان الشأن عدمها لطول المدة أو ضعف البناء أو نحو ذلك من كل ما شأنه التغير لكثرة العلاج فيه كالطاحونة والمعصرة، واحتمل الأمر فعلم أن الصور في عدم التغير غالبا ثلاث:

الأولى: الشأن السلامة فيجوز العقد والنقد قطعا.

الثانية: عدمها، فلا يجوز عقد على نقد.

الثالثة: احتمال الأمرين، فيجوز العقد لا النقد، وقيل لا يجوز عقد ولا نقد.

حكم كراء الأرض لتتخذ مسجدا

قال المصنف: (و) جاز (كراء أرض لتتخذ مسجدا مدة) معينة (والنقض) يكون (لربه) الباني (إذا انقضت) المدة يصنع به ما شاء لتقييده الوقف بتلك المدة، وهو لا يشترط فيه التأييد كما يأتي، وترجع الأرض لمالكها^(١).

حكم الاستئجار على طرح النجاسات

قال المصنف: (و) جاز استئجار (على طرح ميتة) ونحوها من النجاسات وإن استلزم ذلك مباشرة النجاسة للضرورة^(٢).

(١) الشرح: يجوز استئجار أرض ليني عليها المستأجر مسجدا مدة معينة، وعند انتهاء المدة تعود الأرض لمالكها، ويهدم المسجد.

(٢) الشرح: ذكر المصنف صورة من صور الإجارة الجائزة وهي جواز الاستئجار على طرح النجاسات عذرة، وميتة بأجر معلوم، وإن استلزم ذلك مباشرة النجاسة للضرورة الداعية إلى إبعادها عن مجتمعات الناس، فتدخل تحت قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، والضرورة هنا حفظ النفس من أضرار النجاسات وعفونتها.

وكذلك يجوز الإيجار على ما يلي:

- حمل النجاسة للانتفاع بها على الوجه الجائز، كحملها لأكل الكلاب، أو تزييل أرض أو لأكل مضطر سواء كان هو الحامل أو غيره، وحمل جلد مدبوغ لاستعماله في اليايسات والماء، فهو جائز، والإجارة عليه جائزة.

الإجارة على القصاص، وتأديب الابن

قال المصنف: (و) استتجار على (القصاص) من قتل حكم به الحاكم، وسلمه للمجني عليه أو لأوليائه، (و) على (الأدب) لوالده أو عبده إذا ثبت موجب، فلأب أو السيد الاستتجار عليه^(١).

(١) الشرح: ذكر المصنف جواز الاستتجار على القصاص، من قتل أو قطع، حكم به الحاكم العدل، وسلمه للمجني عليه أو وليه، وأما الإجارة على القتل ظلماً فلا تجوز، وعلة عدم الجواز أن المباشر مقدم على المتسبب، فإن نزل اقتص من الأجير، ولا أجر له، ولا يقتص من المؤجر لأن المباشر مقدم على المتسبب.

ويجوز الإيجار على الأدب لابن، ولا يطلب ثبوت موجب الأدب عند الأب إذ يصدق في ابنه الصغير، وأما الولد الكبير فلا يؤدبه الأب بل يؤدبه الحاكم بالثبوت بشهادة بيعة عادلة.

حكم إجارة العبد خمسة عشر عاما، والأرض مأمونة الري

قال المصنف: (و) جاز استئجار (عبد خمسة عشرة عاما) بالنقد، ولو بشرط، وأما الدابة فحد إيجارتها سنة إلا لسفر فالشهور، وأجاز إجارة دار جديدة، وأرض مأمونة الري ثلاثين سنة بالنقد وبالمؤجل، وأما الدار القديمة فدون ذلك، بقدر ما يظن سلامتها اليه، أما الأرض الغير مأمونة الري فيجوز العقد بلا نقد، ومحل ايجار العبد المدة المذكورة ما لم يتغير غالبا فيها، وإلا منع إلا بقدر ما يظن السلامة وسيأتي في الوقف، وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين، ولمن مرجعها له كالعشر، (و) جاز التقييد بالزمن في الإجارة على عمل من حرفة أو غيرها كاستئجار على عمل (يوم) أو ساعة، أو جمعة، أو شهر يخيط له فيه، أو يبني، أو يدرس، أو يحصد له فيه بكذا، والتقييد بالعمل دون الزمن ككتابة كتاب علم، أو بناء حائط، أو قنطرة، حفر بئر وصف، (أو خياطة ثوب) أو سراويل بكذا فقله (مثلا) راجع لليوم، وللخياطة، للثوب (وهل تفسد) الإجارة (إن جمعهما) أي الزمن و العمل (وتساويا) كخط لي هذا الثوب في هذا اليوم بكذا وكان الشأن أنه يخاط في اليوم بتمامه لا في أقل ولا أكثر قال ابن رشد اتفاقا، وقال ابن عبد السلام على أحد المشهورين، والمشهور الثاني عدم الفساد (أو) تفسد (مطلقا) ولو زاد الزمن على العمل عادة بأن كان يمكن خياطته في نصف يوم مثلا وشهره ابن رشد في زائد الزمن، وحكى ابن عبد السلام فيه الجواز اتفاقا فقله (خلاف) الأولى بدله تردد في النقل إلا أن طريقة ابن عبد السلام أظهر في النظر، وعلى القول بالفساد فاللزام أجرة المثل زادت على المسمى أوقلت، (و) جاز (بيع دار) استثنى البائع منفعتها عاما (لتقيض) للمشتري (بعد عام و) بيع (أرض) استثنى البائع

منفعتها (عشر) من الأعوام لقوة الأمن فيها فاغتفر فيها بيع معين يتأخر قبضه، وأما الحيوان والمراد به الرقيق فلا يجوز استثناء الشهر وإنما يمنع بشرط النقد فقط^(١).

(١) الشرح: أشار المصنف إلى جواز إجارة العبد مدة خمسة عشرة عاما بالنقد ولو بشرط، وكذلك يجوز إجارة الدابة مدة سنة إلا أن يكون في سفر فغاية ذلك بالشهور، والحكمة في التفريق بين إجارة العبد، وإجارة الدابة أن العبد إذا حصل له مشقة يستطيع أن يخبر بحال نفسه، بخلاف الدابة لا يتأتى منها ذلك فيؤدي إلى إتلافها.

وأشار المصنف إلى جواز إيجار دار نحو ثلاثين عاما ولو بشرط النقد، ووجه جواز اشتراط النقد هو كونها مأمونة التغير غالبا، فإن كانت قديمة يحتمل بقاؤها ثلاثين وعدمه جاز العقد دون النقد، وإن كانت قديمة جدا لا تبقى ثلاثين عادة لم يجز كراؤها الثلاثين، والعلة في اختلاف الحكم بين الجواز وعدمه هو الوثوق في بقاء الدار على حالها وعدم بقائها وتغييرها.

جواز إجارة الأرض الزراعية المأمونة الري خمسين عاما، لا أكثر، فإن لم يؤمن من ريعها جاز العقد عليها هذه المدة دون النقد.

بيع دار ليقبضها مشتريها بعد عام من يوم بيعها، فيجوز استثناء منفعتها سنة؛ وبيع أرض لتقبض بعد عشر سنين، فيجوز استثناء منفعتها عشرا، وجه جواز ذلك ما في الدور والأرض من قوة الأمن من تغييرهما فاغتفر فيهما بيع يتأخر قبضه. (شرح الخرشي على مختصر خليل ج ٧، ص ١١، حاشية الزرقاني على مختصر خليل ج ٤، ص ١٤).

تجوز الإجارة على صنعة محددة بعمل، نحو خط لي الثوب، أو أحصد هذا الفدان، أو احفر هذا البئر بكذا، أو الإجارة على صنعة محددة بزمان كخط عندي يوما، أو شهرا، أو ابن لي بيتا، ونحو ذلك كل يوم، أو كل جمعة، أو شهرا أو جميع الشهر أو السنة.

وتفسد الإجارة إن جمع العمل والزمن وتساويا، بأن كانت العادة أن الزمن لا يزيد على الفعل ولا ينقص.

وأما إن كان الزمن ينقص عن العمل فإنه يفسد بالأولى، وأما لو كان الزمن أكثر ففيه خلاف في المذهب، قيل يجوز اتفاقا، وقيل تفسد على المشهور، لاحتمال طارئ على الأجير يمنعه من العمل، أي يدخله الغرر. (لمعرفة المزيد يراجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر ج ٤، ص ١٣، ١٢، الذخيرة ج ٥، ص ٤٢٠).

حكم الإجارة على الاسترضاع

قال المصنف:

(و) جاز استئجار على (استرضاع) لرضيع آدمي، أو غيره (والعرف) معتبر (في كغسل خرقة) فإن لم يكن فعلى أبيه على الراجح، فلو قال وغسل كخرقة على أبيه إلا لعرف لشمل المسألتين (ولزوجها) أي الموضع دون غيره (فسخه إن لم يأذن) لها فيه فإن طلقها قبل علمه فلا كلام له (كأهل الطفل) ولو أما، وحاضنة لهم الفسخ (إذا حملت) الظئر؛ لأنه مظنة الضرر والخوف (و) لها الفسخ في (موت إحدى الظئرين) إذا استؤجر بعقد، أو بعقدين وعلمت الثانية بالأولى حين العقد، وماتت الأولى فللثانية الفسخ، وأما إن ماتت الثانية، أولم تعلم الأولى فلا فسخ، (و) لها الفسخ في (موت أبيه و) الحال أنها (لم تقبض أجرة) قبل موته كلا أو بعضا ولم يترك مالا (إلا أن يتطوع بها متطوع) من وارث، أو غيره فلا فسخ كما لو قبضتها من أبيه قبل موته، أو ترك مالا للولد^(١).

(١) الشرح: يجوز استئجار امرأة لترضع طفلا لغيرها - وذلك بالنسبة للأطفال التي تموت أمهاتهم، أو بالنسبة للتوائم الذين لا يكفيهم أمهاتهم، أو تكون الأم قليلة اللبن ولا يكفي لبنها الولد، وإن كان فيه استيفاء عين قصدا - وأن تلك العين مغيبة، وهذا في بني الإنسان والحيوان.

الدليل على ذلك:

قوله تعالى: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُنَّ بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرِفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَرضِعْ لَهُ أُخْرَى" سورة الطلاق آية ٦.

قوله تعالى: "وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرِوفِ" سورة البقرة من الآية ٢٣٣.

أمر الله تعالى المطلقين أن يعطوا مطلقاتهم البائنات أجورهن على الرضاع، إذا رغبن في إرضاع أولادهن منهم حيث كان الرضاع واجبا عليهن ، والأمر بإعطاء الأجرة على الرضاع فرع من جواز الإجارة . (تفسير القرطبي ج ١٨، ص ١٦٨).

الضرورة الداعية على ذلك: ووجهها أن حياة المولود متوقفة عادة على الرضاع ، وهذا من باب حفظ النفس وهو من الكليات الخمس التي أمرت الشريعة بحفظها . (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ محمد بن عرفة الدسوقي ج ١٣، ٤، شرح الخرشي على مختصر خليل ج ٧، ص ١٣).

ويجوز استئجار المرضعة بالنقد، وبالطعام، أو بالنقد والطعام معا كأن يشترط إطعامها بالإضافة إلى الأجر، ولا يكون هذا من باب بيع الطعام لأجل الضرورة؛ لأن النهي ورد في الأطعمة التي جرت عادة الناس أن يقتاتوها. ويكون غسل بدن الطفل وغسل خرقة على أبيه لا على المرضع، إلا لعرف أو شرط فيعمل به.

الأحوال التي يجوز فيها فسخ عقد الإرضاع

ولزوج المرضع فسخ عقد الإجارة إن لم يأذن لها في الإرضاع . أي إذا أقدمت على عقد الإرضاع بدون علمه -، والتعليل في أحقية الزوج في فسخ عقد الإرضاع هو الضرر الذي يلحق الزوج بتشاغلها عنه وتغير حالها، وإن له الحق في الوطء لا يسقط عنه إلا برضاه وإذنه، أما إذا أقدمت على الإرضاع بإذنه فليس له فسخ العقد.

- يجوز لأهل الطفل فسخ العقد إن حملت المرضع من زوجها أو غيره زمن الرضاع. وإنما كان لخم الفسخ؛ لأن الحمل مظنة تضرر الولد بلبنها.

- يجوز للمرضع فسخ العقد إن مات أبو الطفل ولم تقبض الأجرة منه قبل موته ولم يترك له مالا، ولا مال للولد تأخذ منه أجرتها، ولم يتطوع أحد بالأجرة من قريب ولا بعيد، أما إذا ترك له مالا فلا يجوز لها فسخ العقد، وتقبض أجرتها من ميراث الولد من تركه أبيه.

وإن قبضت من الأب أجرتها قبل موته لم يكن لها الفسخ وعندئذ يتبع الورثة الولد بما زاد على يوم موت الأب من الأجرة التي عجلها؛ لأن الزائد يكون ميراثا بينهم وبين الرضيع

فيرجعون به على مال الرضيع لا على المرضعة، وليس إعطاء الأب أجرة رضاعة هبة منه للرضيع، وإنما إرضاعه عليه فرض انقطع بموته، ومحل رجوع الورثة بالأجرة على الرضيع بما زاد على يوم الموت مالم يعجل الأب الأجرة خوفا من موته الآن، وإلا كانت هبة ليس للورثة منها شيء.

- يجوز للمرضع فسخ العقد إذا كانت هي شريكة لأخرى في إرضاع صبي معين بعقد واحد، أو بعقدين متتاليين، وكانت تعلم الثانية بالأولى وماتت الأولى، أو فسخ عقدها فللثانية الفسخ؛ لأنها إنما قبلت القدوم على العقد لعلمها بأن هناك مرضعة أخرى تشاركها في إرضاع الصبي فإذا ماتت هذه المرضعة، أو فسخ عقد إرضاعها فإن الصبي سيكون معتمدا اعتمادا كلياً على لبنها بعد أن كانت الأولى تكفيه نصف الرضعات، وهذا بخلاف مالم ماتت الثانية وكان الاستئجار بعقدين فإن الأولى لا يجوز لها أن تفسخ العقد؛ لأنها قبلت العقد وكانت منفردة بالإرضاع وإدخال الثانية عليها من باب زيادة الاهتمام بالصغير، أو قد يكون من باب التسامح والرفقة بها، وكذلك ليس للثانية الفسخ إذا كانت لا تعلم أن هناك مرضعة أولى تقوم بالإرضاع.

حكم من استأجر عبداً ووجده أكلًا

قال المصنف: (وكظهور مستأجرٍ بفتح الجيم) (أوجر بأكله أكلًا) معمول لظهور أي ظهر حال كونه أكلًا خارجًا عن المعتاد للمستأجر الفسخ؛ لأنه كعيب ظهر به، إلا أن يرضى بطعام وسط فلا كلام لمؤجره، والفرق بينه وبين الزوجة أكلة فلا خيار لزوجها، وهي مصيبة نزلت به فعليه اشباعها أن النكاح مبني على المكارمة بخلاف الإجارة أنها من البيع وهو مبني على المشاحة ويؤخذ منه أن من اشترى عبداً فوجده أكلًا فله رده^(١).

(١) الشرح: من استأجر عبداً فوجده أكلًا أي خارجًا عن الأكل المعتاد فلمستأجره الرد؛ لأنه عيب ظهر به إلا أن يرضى الأجير بطعام الوسط المعتاد فلا كلام لمؤجره، أما الزوجة تظهر أكلة فليس للزوج الفسخ.

والفرق بينها وبين الصورة السابقة: أن النكاح مبني على المكارمة بخلاف الإجارة فإنها من البيع وهو مبني على المشاحة، ويؤخذ من ذلك أن من اشترى عبداً فوجده أكلًا له رده. (الشرح الكبير على مختصر خليل ج ٤، ص ١٤، وأما فتوى الناصر اللقاني 'أن كثرة الأكل ليس بعيب يوجب الرد في المبيع؛ لأن كثرة الأكل الزائد على العادة من جملة ما العادة السلامة منه، والأطباء يجعلون ذلك داءً احترق في المعدة فهو من الأمراض، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤، ص ١٤).

حكم وطئ المرضع إذا استؤجرت للإرضاع، والسفر بها

قال المصنف: (ومنع زوج رضى) بإجارة زوجته ظئرا (من وطئ) لها ؛لأنه مظنة ضرر الطفل بالفعل ، ومثل الزوج السيد كما هو ظاهر (و) منع الزوج من (سفر) بها فيما إذا استؤجرت برضاه (كأن ترضع) غيره (معه) فتمنع ولو كان فيها كفاية لأن أهل الطفل اشتروا جميع لبنها إلا أن يكون لها ولد حال العقد فلا تمنع من إرضاعه، لأنه حينئذ بمنزلة الشرط وهي إذا اشترطت غيره لا تمنع ، (و) الاسترضاع (لا يستتبع) أي لا يستلزم حضانة لزيادتها على المعقود عليه (كعكسه) أي من استأجر امرأة لحضانة طفل لا يستلزم رضاعة فلا يلزمها إلا الشرط ، أو عرف في المسألتين^(١).

(١) الشرح: الزوج إذا رضى لزوجته أن تؤجر نفسها للإرضاع وفعلت فإن الإجارة تلزمها، وبمنع الزوج من وطئ الزوجة حال الإرضاع.
وعلة ذلك: أنه مظنة الإضرار بالطفل ولو لم يحصل إضرار بالطفل.
وكذلك يمنع الزوج السفر بزوجته المرضع إن أذن لها في الإرضاع، فإن لم يأذن لها، له وطئها وله فسخ العقد.

ولو أراد أهل الطفل السفر بالطفل فلا يمكنون من اخ الولد، إلا إذا دفعوا كامل الأجرة للمرضع حيث كانت وجيبه.

وكذلك لا يجوز المرأة المرضع أن ترضع مع الطفل طفلا آخر ولو كان فيها كفايته؛ لأن أهل الطفل اشتروا جميع لبنها إلا أن يكون لها ولد حال العقد فلا تمنع من رضاعه معه، لأنه حينئذ بمنزلة الشرط، وكذلك لا تمنع المرضعة من اشتراط غير الولد للإرضاع مع الطفل.

ومن استرضع امرأة لترضع ولده لا يلزمها حضانتها؛ لأنها زيادة على المطلوب، وكذلك من استأجرها لترضعه ليس عليها أن تحضنه، إلا لم يكن هناك شرط أو عرف، وإلا عمل به.

حكم من باع سلعة وشرط على المشتري أن يعمل فيها سنة
قال المصنف: وعطف على الجائز مسألة مشتملة على بيع وإجارة بقوله
(و) جاز (بيعه) لآخر (سلعة).

بثمن معلوم أي تساوي أكثر منه (على أن يتجر) المشتري للبائع بثمنها
المذكور (سنة) مثلاً فالمراد مدة معلومة، ولا بد من إحضار الثمن ، والإشهاد
عليه لينتقل من ذمة وإلا أدى إلى سلف جر نفعا ؛ لأنه يتهم ليزيده على
تأخيره ولا بد أيضا من تعيين النوع الذي يتجر فيه ، وأن يوجد في جميع الأجل
، وأن يكون مديرا لا محتكرا ؛ لأن المحتكر يرصد الأسواق فيؤدي إلى أجل
مجهول فيدخل الجهل في الثمن ؛ لأن الثمن مجموع النقد والعمل ، وأن لا يتجر
له في الربح ؛ لأن الربح مجهول فهذه سبعة شروط علم الثمن المتجر فيه
ووجوده في الأجل والإدارة ، وعدم التجر في الربح تؤخذ من المصنف بالقوة ،
ولما كان هناك شرط ثامن لا يؤخذ منه صرح به بأداة الشرط بقوله (إن شرط
الخلف) لما يتلف من الثمن ليتم العمل الذي هو جزء من الثمن ، وإلا أدى إلى
الغرر ومثله في الجواز مع شرط الخلف قوله^(١) ...

(١) الشرح: أشار المصنف في النص السابق إلى مسألة مشتملة على بيع وإجارة، فيجوز
للبيع أن يبيع السلعة لآخر بثمن معلوم كمائة أي وهي تساوي أكثر منه على أن يتجر
المشتري للبائع في ثمنها مدة سنة - أي مدة معلومة -.

وصورتها: شخص باع سلعة لآخر تساوي مائة وخمسين مثلاً بمائة على أن يتجر له سنة
فقال الأمر أن ثمن السلعة مائة دينار وعمل سنة فيها، لجواز هذه المسألة ثمانية شروط هي:

- ١- أن يكون الثمن معلوما.
- ٢- أن يكون العمل إلى أجل معلوم.
- ٣- أن يعين النوع الذي يتجر فيه.
- ٤- أن يكون موجودا في السنة.

-
- ٥- أن يحضر الثمن ليخرج من ذمته.
- ٦- أن يكون مديرا؛ لأن المحتكر يبيع إذا غلت السلع، وذلك يؤدي إلى الأجل المجهول.
- ٧- أن يشترط الخلف، وإلا أدى إلى الغرر.
- ٨- ألا يشترط ألا يتجر له في الربح لأن الربح مجهول.

حكم الاستئجار على رعي غنم بشرط الخلف

قال المصنف: (كغنم) أي كجواز الاستئجار على رعاية غنم (عينت) إن شرط الخلف لما يتلف منها لا إن لم يشترطه فلا تصح وله أجر مثله (وإلا) تكن معينة فلا يشترط للجواز شرط الخلف بل يصح العقد بدونه وحينئذ (فله) أي للراعي (الخلف على أجره) أي يقضى له بالخلف على رب الغنم، أو دفع جميع الأجرة (كراكب) تشبيهه في قوله فله الخلف أي أن الراكب إذا تعذر ركوبه لموت، أو مرض، أو حبس لم تنفسخ الإجارة ويلزمه، أو وارثه الاتيان بالخلف، أو دفع جميع الأجرة^(١).

(١) الشرح: يجوز للشخص أن يستأجر شخصا يرعى له غنما بعينها سنة بأجرة معلومة بشرط أن يشترط الراعي في العقد على ربه، أن ما مات من الغنم، أو ما تلف منها أخلفه، أو جرى العرف بالخلف، فإن لم يشترط الخلف في العقد لم يجز، فإن امتنع رب الماشية من الخلف أخذ الراعي جميع الأجرة.

وكذلك راكب السفينة إذا تعذر ركوبه فإن الإجارة لا تنفسخ ويلزمه، أو ورثته إن مات أن يأتوا بخلفه، أو يدفعوا جميع الأجرة فهو تشبيهه في الخلف أي كما يجب خلف الراكب إذا تعذر ركوبه، ولا يفسخ الكراء؛ لأنه مما يستوفي به، أما إذا كانت الدابة غير معينة كأن استأجر دابة غير معينة ليركبها لموضع كذا فهلكت فعلى المكري خلفها.

تابع صور من الإجارة الجائزة

قال المصنف: (و) جاز استئجار (حافتي نهر ك ليبي) عليها المستأجر (بيتا) ويصير النهر تحت سقف ذلك البناء ، (و) جاز استئجار (طريق في دار) للمرور فيها لحاجة ، (و) جاز استئجار (مسيل) أي موضع سيلان، (ومصب مرحاض) أي مصبوب أي ما يصب من الفضلات فالمسيل اسم مكان، وهو المجرة ، والصب بمعنى اسم مفعول ، والمرحاض محل الرحض أي الطرح كالكنيف أي محل جريان ما يسيل من الأكنفة ، أو ما يجتمع في ذلك الجاري من الأكنفة ونحوها (لا ميزاب يعني لا يجوز شراء ماء ميزاب ؛ لأنه يقل ويكثر ويكون مملوكا لك ومستأجر مسيله من أرض جارك ليجري فيه ما نزلت منه (في أرضه) ليخرج إلى الخارج فيجوز ويكون كمسيل مصب مرحاض ، أو ميزاب لا شراء مائه ، (و) جاز (كراء رحي ماء) أي تدور بالماء (بطعام أو غيره) للطحن عليها^(١).

(١) الشرح: ذكر المصنف صوراً من الإجارة الجائزة، فقال : يجوز للإنسان أن يؤجر حافتي نهر لشخص ليبنى عليه بيتاً ، أو لنصب رحي عليها ويصير النهر تحت البناء، ولا يشترط هنا وصف البناء، مما يبنى به من حجر، أو آجر مثلاً مما يثقل أو يخف، أما وصف البناء من حيث عرضه فلا بد منه إذ قد يعرض الجدار فيضيق مجرى الماء بخلاف بناء فوق بناء فلا بد من وصف البناء من حيث ما يبنى به من حجر أو آجر، وكذلك يجوز لك أن تستأجر طريقاً في دار رجل لتتوصل بها إلى منافعك أو ما تريد ، وإلا لم يجز ؛ لأنها من أكل أموال الناس بالباطل ؛ لأن رب الدار أو الأرض أكل منه الأجرة باطلاً ؛ لعدم انتفاعه بالطريق.

وقول المصنف: دار لا مفهوم له ؛ لأن المراد الطريق في أرض غيرك سواء كانت داراً، أو أرضاً ، أو بستاناً أو نحو ذلك.

وقول المصنف: ومسيل مصب مرحاض الثلاثة المذكورة اسم مكان، فمسيل اسم للمكان الذي يسيل فيه الماء كالمجرة، ومصب اسم للمكان الذي يصب فيه الماء، أي يجوز استئجار مكان لصب الماء فيه، ومصب مصدر ميمي بمعنى انصباب، ومرحاض من الرحض وهو الطرح كالكنيف، أي محل جريان ما يسيل من الأكنفة ونحوها . فيجوز استئجار محل جريان الماء المصبوب في الأكنفة، كما هو موجود في مصر من استئجار مجراه يسيل فيها ماء يصب من المراحيض وتوصل بالمجاري، وكذلك يجوز استئجار أرض لوضع الفضلات فيها.

ثم ذكر المصنف أنه لا يجوز شراء ماء ميزاب؛ لأنه يقل ويكثر، ويكون أولاً يكون، إلا أن يكون الميزاب لمنزلك بأن يكون مملوكاً لك فتستأجر مسيله من أرض جارك ليجري فيه ما نزل منه في أرضه ليخرج إلى الخارج دار الجار ويستقر في أرضك فيجوز، وتكون هذه المسألة كمسألة مصب المرحاض لا فرق بينهما، والاستثناء منقطع لأن هذا استئجار، والمستثنى منه بيع...

ذكر المصنف أن من كانت له رحي تدور بالماء يجوز له أن يكرها بالطعام أو غيره للطحن عليها.

حكم الإجارة على تعليم القرآن الكريم

قال المصنف: (و) جازت الإجارة (على تعليم قرآن مشاهرة) مثلا ككل شهر بدرهم ، أو كل سنة بدينار ، (أو على الحِذاق) بكسر الحاء ، والذال والمعجمة أي الحفظ لجميعه ، أو جزء معين بأجر معلوم . وأشار بأو إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما وهو المشهور إذ قد يمضي الشهر ولا يحفظ ما عينه، أو يحفظه في أثنائه، (وأخذها) المعلم أي يأخذ الحذقة بمعنى الاصرافه ففيه استخدام كذا قيل أي يقضى بها للمعلم على ولي الطفل ،أو على القارئ الرشيد (وإن لم تشتترط) ، ومحلها ما تفررت فيه عرفا من السور كسبح ، وعم ، وتبارك، وغيرها ، وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان ، وقد تختلف باختلاف الزمان ، والمكان وقد تختلف باختلاف الأشخاص فقرا، وغنى^(١).

(١) الشرح: تجوز الإجارة على تعليم القرآن الكريم، وتعليم علومه من تجويد، وقراءات، والإجارة على تحفيظ القرآن الكريم على نوعين:

١- مشاهرة أب كلما مر شهر على التحفيظ استحق الشيخ أجرته حتى ولو لم يستوعب الطالب شيئا.

٢- على الحذق أي على الحفظ لكل، أو لبعض أجزاء المصحف حسبما يقضى به العرف، أو الشرط فكلما حفظ الجزء المتفق عليه أخذ الشيخ أجرته المتفق عليها.

لا يجوز الجمع بين الطريقتين السابقتين؛ لأن الطلاب يتفاوتون في الحفظ فقد يمضي الشهر ولا يحفظ الطالب شيئا فيكون في ذلك إجحاف بالشيخ، وقد يكون الطالب ذكيا سريع الحفظ يحفظ الجزء المطلوب منه في مدة وجيزة فيكون في ذلك إجحاف بوليّه.

وإذا اتفق على أجر وجب دفعه إلى الشيخ بل ويقضى بها على الطالب، أو وليّه، وإن لم ينص عليها في العقد.

إجارة ما يحتاج إليه المسلم في حياته اليومية

قال المصنف: (و) جاز (إجارة ماعون) أي ما يستعان به (كصفحة وقدر) وفأس، ودلو كان مما يعرف بعينه أو لا^(١).

(١) الشرح: أشار المصنف إلى جواز إجارة الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان في حياته اليومية، ويقاس عليها جواز الإجارة لكتب العلم، أو أسطوانات علمية للطلاع عليها، وسائر الأشياء النافعة التي يحتاج إليها الإنسان في حياته.

الإجارة على حفر بئر

قال المصنف: (و) جاز العقد (على حفر بئر إجارة ، وجعالة فالإجارة فيما يملك من الأرض ، وفيما لا يملك كالموات إذا عين له مقدار الحفر من طول ، وعرض كخمس أذرع في خمسة ، والعمل عشرة فإن انهدمت قبل تمام العمل فله بحساب ما عمل ، والجعالة فيما لا يملك فقط ، ولا بد من الوصف كالإجارة ، وإنما تتميز عن الإجارة بما يدل على الجعالة بأن يصرح بها ، أو بقول ولك بتمام العمل كذا ، والفرق بينهما أن الجعالة لا تكون إلا فيما لا سيحصل للجاعل فيه نفع حين الترك بخلاف الإجارة ولذا لو وقع العقد على الحفر فيما يملك كان إجارة ، ولا تصح الجعالة فيه ، فإن صرح فيه بالجعالة فسد العقد^(١).

(١) الشرح: تجوز الإجارة على حفر بئر، وإقامة المباني التي توصف وصفا دقيقا ببيانها بالرسم الموضح للمشروع، بيانا كافيا طولا، وعرضا وعمقا وغير ذلك، سواء كانت الأرض مملوكة للمؤجر، أو لم تكن مملوكة له، فالعقد في الصورة الأولى إجارة جائزة إذا دخلا على تعيين العمل، ويستحق الما قول، أو العامل الأجر بمجرد الفراغ من المشروع، أو مضي مدة من تمكين نفسه أن يحفر فيها البئر، أو يقام فيها البناء؛ لأن التمكين من الانتفاع كالانتفاع بالفعل، وإذا انهدم البناء أثناء العمل ، فإذا كان الانهدام بتقصير من المستأجر كما لو خالف ما هو مشروط أو ما هو متعارف عليه بين أهل الصنعة ، فإنه يضمن هذا الانهدام. أما إذا انهدم البناء ولم يكن هناك تقصير أخذ من الأجرة مقدار ما يستحقه عن المرحلة التي عمل فيها أو أقامها.

أما الصورة الثانية: وهي كون الأرض ليست مملوكة للمؤجر فإن العقد تارة يكون إجارة، وتارة يكون جعالة فيكون إجارة إذا دخلا على بيان المشروع المراد عمله بيانا كافيا مع وجود شرط يلزم المؤجر بالأجر، وقد يكون جعالة إذا صرح بها في العقد، أو قامت قرينة على إرادتها بأن يقول له لك بتمام عملك كذا، ففي هذه الصورة فإن العامل يكون له الحق في ترك العمل في أي وقت ولا يستحق شيئا، وكذا لو انهدم المشروع لا يستحق شيئا على ما مضى من عمل وكان التلف بلا تعد أو تقريط فلا ضمان عليه. (تعريف الجعالة هي: التزام

أهل الإجارة جعلاً يستحقه السامع بالتمام. الشرح الكبير شرح مختصر خليل للشيخ أحمد الدردى ج ٤، ص ٦٠، ٦١). (موات الأرض هي: ما سلم عن الاختصاص، الشرح الكبير شرح مختصر خليل ج ٤، ص ٦٦، شرح الخرشي على مختصر خليل ج ٧، ص ٦٦).

الفرق بين الإجارة والجعالة هنا: أن الجعالة لا تكون إلا فيما لا يحصل فيه نفع للجاعل حين الترك لو ترك، بخلاف الإجارة، ولهذا لا يجوز أن يجاعله إلا على حفر بئر في الموات.

مكروهات الإجارة

قال المصنف: ولما تكلم على الممنوع والجائز ذكر المكروه بقوله: (ويكره حلي) أي إجارته بذهب، أو فضة أو غيرهما نقداً أو إلى أجل إذا كان غير محرم الاستعمال وإلا منع (كإيجار مستأجر دابة) لركوب أي يكره لمن استأجر دابة لركوب أن يؤجرها لمثله خفة وأمانة ولا ضمان عليه إن ضاعت بلا تفريط، أو مات، وأما لو استأجرها للحمل عليها فيجوز كراؤها لحمل مثله كما يفيد مما يأتي قوله وفعل المأذون فيه لا أضمر (أو ثوب) أي يكره لمن استأجر ثوباً للبس أن يكره (لمثله) ولكونه مما يغاب عليه يضمنه الأول إلا لبينة على تلفه بلا تفريط من الثاني؛ لأن ضمان التهمة يزول بالبينة، ومحل الكراهة في الدابة والثوب إذا جهل حال المكري، وأما إن علم رضاه فجائز وإن علم عدم رضاه لم يجز، (و) كره (تعليم فقه، وفرائض) بأجرة مخافة أن يقل طلب العلم الشرعي وآلته من نحو، وبيان كذلك، وأما تعليم علم الفرائض بالرسم فلا يكره (كبيع كتبه) أي ما ذكر، وكذا كتب الحديث، والمصاحف، والتفسير، (و) كره (قراءة بلحن) أي تطريب بأنغام حيث لا يخرج عما عليه القراء، وإلا حرمت كقراءة بالشاذ وقد تقدمت المسألة في سجود التلاوة، والمناسب هنا كراهة الإجارة على القراءة، (و) كره (كراء دَف) بضم الدال، وقد تفتح وهو المدور المغشي من جهة كالغريال، (ومعزف) واحد المعازف قال الجوهري المعازف الملاهي فيشمل المزمار والأعواد والسنطير بناء على كراهيته (لعرس) أي نكاح، وقيل هي جائزة في النكاح، ولا يلزم من جوازها جواز كرائها، والراجح أن الدف والكبر جائزان لعرس مع الكراهة، وأن المعازف حرام كالجميع في غير النكاح فبحرم كراؤها، (و) كره (كراء كعبد كافر) المتبادر منه أن كافر نعت لعبد، وهو غير صحيح فكان حقه أن يقول لكافر أو تقديم كافر

على كعبد ، وأجيب بأنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله كعبد وهو جائز على قلة ، والأصل كراء كافر عبدا ونحوه ، وهو من إضافة المصدر لمفعوله أي يكره للمسلم أن يكره عبده أو نفسه ، أو ولده لكافر حيث كان الكافر يستبد بعمل المسلم ولم يكن تحت يده ن ولم يكرهه في فعل محرم فإن لم يستبد الكافر بعمل المسلم كخياط يرد عليه المسلم والكافر فيجوز ، وإن كان تحت يده كأجير خدمة بيته وظئر حرم وفسخت وله اجرة ما عمل وكذا إن استأجره على محرم كخمر ، ورعي خنزير ولكن يتصدق بالأجرة على المسلم أدبا له ، (و) كره (بناء مسجد للكرء) أي لأخذ اجرة ممن يصلي فيه ؛لأنه ليس من مكارم الأخلاق، والمشهور عدم الجواز ، (و) كره (سكنى) بأهله (فوقه) أي المسجد إن بني للسكن قبل وقفه لا بعده فيحرم كم يأتي في الموات في قوله وكمنع عكسه فلا معارضة، وأشار للركن الثالث...^(١)

(١) الشرح: صور من الإيجارات المكروهة:

إجارة الحلي، قال المصنف: ولما تكلم على الممنوع والجائز ذكر المكروه بقوله: (ويكره حلي) أي إجارته بذهب، أو فضة أو غيرهما نقداً أو إلى أجل إذا كان غير محرم الاستعمال وإلا منع.

الشرح: لما فرغ المصنف من صور الإيجارات الممنوعة، والجائزة شرع في سرد بعض صور من الإيجارات المكروهة وبيانها كالآتي:

الحلي هو الذهب، أو الفضة تتحلى بهما المرأة، يكره إجارة الحلي.

وجه الكراهة؛ لأنه ليس من شأن الناس، والأولى إعارته؛ لأنها من المعروف، وأن السلف كانوا يرون إعارته من غير أجر، وعلل بعض فقهاء المذهب أن علة الكراهة أن الحلي قد تنقص قيمته باستعمال المستأجر فتقل قيمته فيكون ما نقص من القيمة مقابل الأجرة النقدية يبيع نقد بنقد ، ولما كان النقصان غير محقق كانت الإجارة مكروهة مقيدة بألا يكون المستأجر يحرم عليه لبس الحلي المستأجر فإن كان المستأجر يحرم عليه لبس الحلي المستأجر تمتع إجارته ؛لأنه سيكون من يباب الإعانة على الإثم وهو منهى عنه بمقتضى قوله تعالى : "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"

إيجار الدابة المستأجرة والثياب المستأجرة

قال المصنف: (كإيجار مستأجر دابة) لركوب أي يكره لمن استأجر دابة لركوب أن يؤجرها لمثله خفة وأمانة ولا ضمان عليه إن ضاعت بلا تفريط، أو مات، وأما لو استأجرها للحمل عليها فيجوز كراؤها لحمل مثله كما يفيد مما يأتي قوله وفعل المأذون فيه لا أضر (أو ثوب) أي يكره لمن استأجر ثوبا للبسه أن يكرهه (لمثله) ولكونه مما يغاب عليه يضمنه الأول إلا لبينة على تلفه بلا تفريط من الثاني؛ لأن ضمان التهمة يزول بالبينة، ومحل الكراهة في الدابة والثوب إذا جهل حال المكري، وأما إن علم رضاه فجائز وإن علم عدم رضاه لم يجز^(١).

(١) الشرح: يكره لمن استأجر سيارة للركوب، أن يكرهها لمثله سواء في الأمانة، أو الخفة، أو النقل أو، الحفاظة والغلظة، ولا ضمان عليه إن تلفت للدابة، أو ماتت بلا تفريط. فإن كان الأول هو اللفظ فلا ضمان بالأولى، وإن كان الثاني هو اللفظ ضمن، ومحل الكراهة إذا لم يعلم حال ربه وعدمه.

ومثل الدابة: الثوب فيكره لمن استأجر ثوبا للبسه أن يكرهه لمثله، ويقال فيه: ما قيل في الدابة إلا أنهما يفترقان في الضمان، فإن الدابة لا ضمان فيها إن ضاعت بلا تفريط، أو ماتت، وأما الثوب فيضمنه -أي: الأول- إلا لبينة على تلفه بلا تفريط من الثاني؛ لأن ضمان الأول ضمان تهمة لا ضمان عداء، وضمان التهمة يزول بالبينة.

الإجارة على تعليم الفقه والفرائض

قال المصنف: (و) كره (تعليم فقه، وفرائض) بأجرة مخافة ان يقل طلب العلم الشرعي وآلته من نحو، وبيان كذلك، وأما تعليم علم الفرائض بالرسم فلا يكره (كبيع كتبه) أي ما ذكر، وكذا كتب الحديث، والمصاحف، والتفسير^(١).

(١) الشرح: ذكر المصنف أن من صور الإجارة المكروهة الإجارة على تعليم الفقه والفرائض، كما يكره بيع كتب الفقه، والفرائض، وعلة الكراهة أن أخذ الأجر يؤدي إلى قلة الإقبال عليها وأما تعليم علم الفرائض بالرسم فلا يكره أخذ الأجرة عليه؛ لأنه صنعة من الصنائع.

يكره الإجارة على تعلم الشعر. وخالف في ذلك ابن حبيب فقال: بجواز تعلم الشعر، وأيام العرب والرسائل ونحوها، مما يليق بذوي المروءات، ويمنع شعر الهجاء، والخمر والخنا.

قراءة القرآن بلحن وتطريب

قال المصنف: (و) كره (قراءة بلحن) أي تطريب بأنغام حيث لا يخرجها عما عليه القراء، وإلا حرمت كقراءة بالشاذ وقد تقدمت المسألة في سجود التلاوة، والمناسب هنا كراهة الإجارة على القراءة^(١).

(١) الشرح: تكرر الإجارة على قراءة القرآن الكريم بلحن تطريب وأنغام؛ لأن القراءة على هذا الوجه مكروهة إذا لم يخرج عن حده، وإلا حرمت، كالقراءة بالشاذ، والقراءة الشاذة ما زاد على العشرة، وهو الراجح، والمراد بالتطريب تقطيع الصوت بالأنغام والأهوية، وتقدمت مسألة كراهة قراءة القرآن الكريم بتطريب وأنغام وأدلتها في سجود التلاوة، وذكرت هنا لبيان كراهة الإجارة على ذلك.

ووجه كراهة قراءة القرآن الكريم بالتطريب: أن المقصود من القراءة التدبر والتفهم والتطريب ينافي ذلك.

إجارة المعازف والدقوف في العرس

قال المصنف: (و) كره (كراء دُف) بضم الدال، وقد تفتح وهو المدور المغشي من جهة كالغريال، (ومعزف) واحد المعازف قال الجوهرى المعازف الملاهي فيشمل المزممار والأعواد والسنطير بناء على كراهيته (العرس) أي نكاح، وقيل هي جائزة في النكاح، ولا يلزم من جوازها جواز كرائها، والراجح أن الدف والكبر جائزان لعرس مع الكراهة، وأن المعازف حرام كالجميع في غير النكاح فيحرم كراؤها^(١).

(١) الشرح: تكره إجارة الدف ومعزف في النكاح، والدف طبل مغشي من جهة يسمى في العرف بالطار، والمعزف آلة اللهو فيشمل المزممار، ولا يلزم من جوازها في النكاح جواز أخذ الأجرة عليها. والراجح أن الدف والكبر جائزان في العرس مع الكراهة، وأن المعازف حرام في غير النكاح فيحرم كراؤها.

وهذا القول مبني على الكراهة سماع المعازف في العرس، وقيل سماعها في العرس جائز، أما في غير العرس فالمذهب على حرمتها.

إيجار مسلم نفسه أو ولده لكافر

قال المصنف:

(و) كره (كراءُ كعبد كافرٍ) المتبادر منه أن كافر نعت لعبد وهو غير صحيح فكان حقه أن يقول لكافر، أو تقديم كافر على كعبد، وأجيب بأنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله كعبد وهو جائز على قلة، والأصل كراء حيث كان الكافر يستبد بعمل المسلم ولم يكن تحت يده، ولم يكثره في فعل محرم، لا إن لم يستبد بعمل المسلم كخياط يرد عليه المسلم، والكافر فيحوز، وإن كان تحت يده كأجير لخدمة بيته، وظئر حرم، وفسخت وله أجرة ما عمل، وكذا إن استأجره في فعل محرم كعصر خمر، ورعي خنزير ولكن يتصدق بالأجرة على المسلم أدبا له^(١)

بناء مسجد للكراء، والسكنى فوقه

(١) الشرح: يكره للمسلم أن يؤاجر نفسه، أو ولده، أو عبده المسلم، أو دابته لكافر فيما يحل، كخياطة ثوب، وبناء، وحرث، وما أشبه ذلك إذا كان الكافر يستبد بالمسلم. أما إذا أجر المسلم نفسه لكافر فيما لا يحل كعصر خمر، ورعاية خنزير فيحرم، وترد الإجارة قبل العمل، أما بعد العمل فتفسخ الإجارة، ويتصدق بالأجرة أدبا للمسلم، إلا أن يعذر لأجل جهل فلا تؤخذ منه.

وكذلك إذا كان العمل فيه إهانة للمسلم، بحيث يكون تحت يده خادما له في بيته، ويقدم له الطعام، ويغسل يديه، ويجرى خلفه، ومرضعة لولده، يحرم ويفسخ العقد، وله أجر ما عمل.

وأما إذا لم يكن الكافر مستبدا بعمل المسلم، بحيث يكون المسلم في حانوته كخياط، ويأتيه الكافر والمسلم فيجوز.

قال المصنف: (و) كره ممن يصلي فيه؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق، والمشهور عدم الجوار، (بناء مسجد للكراء) أي لأخذه (سكنى) بأهله (فوقه) أي المسجد إن بنى المسكن قبل وقفه لا بعده فيحرم كما يأتي له في الموات في قوله ومنع عكسه فلا معارضة^(١).

(١) الشرح: أشار المصنف إلى أنه يكره بناء مسجد ليكره لمن يصلي فيه، ويأخذ الأجرة ممن يصلي فيه، فالمشهور في المذهب أنه غير جائز؛ لأنه حبس لله لا يباع ولا يكرى، وعن القاضي عياض أنه مكروه، وعلل الكراهة بأنه ليس من مكارم الأخلاق. وكذلك لا يجوز لو بناه الله تعالى ثم قصد أخذ الكراء ممن يصلي فيه؛ لأنه خرج عنه الله تعالى أي كان حبسا لا حكم له، ولا لأحد فيه؛ والحبس لا يباع ولا يكرى. (شرح الخرشي على مختصر خليل، ج ٧، ص ٢٠، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ محمد عرفة الدسوقي بهامش الشرح الكبير، ج ٤، ص ١٩).

أما السكنى فوق المسجد المعد للكراء بالأهل -أي الزوجة- مكروه؛ لما فيه من إذلال المسجد بوطء أهله فوقه.

أما إذا كان المسجد غير معد للكراء وتم وقفه يحرم السكنى فوقه بأهله.

أما لو كانت السكنى للعبادة بمفرده فجائز كما ذكر المصنف في باب إحياء الموات من جواز سكنى الرجل المتجرد للعبادة فيه.

أما السكنى تحت المسجد فجائز مطلقا سواء كانت السكنى بمفرده أو بأهله، بني المسجد للعبادة، أو لغيره.

الركن الثالث (المنفعة)

قال المصنف: وأشار للركن الثالث بقوله (بمنفعة) متعلق بأجر، والباء بمعنى في، أي وصحت الإجارة بعاقده، وأجرني مقابل منفعة لها شروط أشار لها بقوله (تتقوم) لأي لها قيمة شرعا لو تلفت احترازا عن رائحة الرياحين ونحوها فلا يجوز استئجارها للشم، وكذا البساتين ونحوها للفرجة، والدنانير ونحوها لتزيين الحوانيت، والجدران للاستغلال، والسراج للاستصباح، وكذا آلات اللهو، وتعليم الأنعام إذ لا قيمة لها شرعا، فلا تصح إجارة ما ذكر وتفسخ إن وقعت ولا أجرة، (قدر على تسليمها) فلا يجوز استئجار آبق، أو بغير شارد أو أي شيء غير مملوك للمؤجر، أو بعيد غيبة ونحو ذلك (بلا استيفاء عين) احترز من نحو استئجار شجر لأكل ثمره، واستثنى من ذلك مسألة الظئر للرضاع (ولا حظر) احترز عن استئجار شخص لعصر خمر أو رقص ونحو ذلك من كل منفعة محرمة (و) بلا تعين يأتي بيانه ومحترزه (ولو مصحفا) للقراءة فيه فيصح إجارته له، ويجوز ابتداء خلاف لابن حبيب، (و) لو (أرضا غمر) أي كثر (ماؤها ونذر انكشافه) هو محل المبالغة إذ لو كان شأنها الانكشاف فلا نزاع في المنع إذا كانت لا تنكشف، (و) لو (شجراً لتجفيف) نحو ثياب (عليها)؛ لأن الانتفاع بها على هذا الوجه لا تتأثر به، وينقص قوتها فهي منفعة تتقوم، وقوله (على الأحسن) بغني عنه المبالغة، ثم أشار إلى محترز بعض ما تقدم من القيود فذكر محترز بلا استثناء عين قصدا بقوله (لا) استئجار شجر (لأخذ ثمرته أو) استئجار (شاة للبنها) أي لأخذه فلا يجوز إلا إذا اشترى لبن شاة، أو شاتين غير معينتين جزافا من شياه كثيرة عند البائع كعشرة فأكثر متساوية في اللبن عادة في إبان الحلاب مع معرفة وجه حلابها لأجل لا ينقص اللبن فيه، والشروع في الأخذ يوم العقد أو قبله

فيجوز وكذا إن وقع على الكيل ككل يوم رطلين من لبن شياهاك بكذا (واغتفر) اشتراط إدخال (ما في الأرض) المكترة وجيبة من الشجر المثمر (مالم يزد) ما فيها أي قيمته (على الثلث) أي ثلث الجميع فإن زاد لم يغتفر ، وتفسخ الإجارة ويعتبر الثلث (بالتقويم) ولا يعتبر ما أكرت به لأنه قد يزيد وينقص فيقال ما قيمة الأرض ، أو الدار إذا أكرت بلا شجر مثمر فيقال عشرة ، فيقال وما قيمة الثمرة في ذاتها بعد اسقاط كلفتها فيقال خمسة ، أو أقل فقد علم أنه الثلث ، أو أقل ، ولو قيل قيمتها ستة أو أكثر لم يجز ولا بد أن يكون طيب الثمرة في مدة الكراء ، وأن يكون شرط إدخالها لدفع الضرر ، وأما الزرع فلا يجوز إدخاله إلا إذا نقص عن الثلث فإن أكرت مشاهرة لم يجز إدخال شيء ، وذكر مفهوم لا حظر بقوله (و) لا (تعليم غناء) بكسر الغين والمد (أو دخول حائض لمسجد) أي لخدمته (أو دار لتتخذ كنيسة) أو مجمعا لفساق ، أو خمارة (كبيعها لذلك) ويفسخ متى اطلع عليه (وتصدق بالكراء) جميعه إن اطلع عليه بعد انقضاء مدة الإجارة للدار وبما ينوب الزمن الذي فسخت إليه إن اطلع عليه في الأثناء (وبفضلة الثمن) في بيعها لذلك (على الأرجح) أي بزائد على الثمن لو بيعت لمباح وكذا بزائد الكراء للأرض إذا أكرت لو أكرت لجائز ، وذكر محترز تعين بقوله (ولا) تجوز الإجارة على (مُتَعِينٍ) أي مطلوب من كل شخص بعينه ، ولا تصح فيه النيابة ولو غير فرض (كركعتي الفجر بخلاف الكفاية) كغسل ميت أو حمله فيصح الاستئجار عليه مالم يتعين بخلاف صلاة الجنازة عليها مطلقا (وَعَيْنٌ) في عقد الإجارة وجوبا (متعلم) لقراءة ، صنعة لاختلاف حاله ذكاء وبلادة (ورضيع) ؛ لاختلاف

حاله بكثرة الرضاع وقتله (و) عين (دار حانوت) ، و حمام ، وخان ونحوهما إذ لا يصح أن يكون العقار في الذمة^(١).

(١) الشرح: أشار المصنف إلى ركن المنفعة: وهي المعقود عليها في عقد الإجارة وهي المقصود الأول منها.

ويشترط فيها:

١- أن تكون لها قيمة شرعا لو تلفت، ومعنى ذلك أن تكون مملوكة ملكية خاصة، فلا تستأجر الروائح لمجرد الشم، وكذلك شم الرياحين؛ فإن صاحب الرياحين والروائح لا يمكنه منع رائحتها، أما الجلوس داخل البستان الذي فيه الرياحين فله استئجاره، وكذلك الاستدفاء بنار إذا كان إدفائها خارج ملكه، وكون شيء له قيمة أو ليس له قيمة مرجعه إلى العرف، فقد يكون الشيء له قيمة في بلد، وقد لا يكون له قيمة في بلد آخر.

٢- ويشترط فيها أن تكون مقدورا على تسليمها للمستأجر حسا، وشرعا، فلا يجوز استئجار حيوان شارد أو شيء مغصوب، أو غير مملوك للمؤجر، وكذلك لا يجوز استئجار شخص لقتل غيره بغير حق.

٣- ألا يترتب على استيفاء المنفعة استيفاء العين قصدا، فلا يجوز استئجار الشجر لأكل ثمرة.

٤- أن تكون المنفعة مباحة، فلا يجوز استئجار شخص على الرقص، أو عصر الخمر ونحو ذلك من كل منفعة محرمة، وكذلك لا تجوز إجارة الحائض، والجنب، والكافر لخدمة المسجد؛ لأنه يترتب على استيفاء المنفعة المعقود عليها الحظر، وكما يمنع تقرير النساء في الوظائف التي لا تتأتى شرعا إلا من الرجال كالإمامة، والخطابة، والأذان فتقريرهن فيه باطل؛ لأن شرط التقرير أن يكون المقرر أهلا لما قرر فيه.

وكذلك لا يجوز كراء دار لتتخذ كنيسة، أو مجمعا لفساق، أو خمارة، ويفسخ العقد متى اطلع عليه، ويتصدق بالكراء جميعه إن اطلع عليه بعد انقضاء مدة الإجار للدار، وبما ينوب من الزمن الذي اطلع عليه في الأثناء.

٥- ألا تكون من القربات المعينة على المكلف، فلا يجوز استئجار شخص ليصوم عن غيره، أو يؤدي الصلاة المفروضة عنه حتى ولو كانت نفلا كركعتي الفجر؛ لأن هذه العبادات متعينة على الشخص ولا تقبل النيابة، ويشترط في الفرض المتعين الذي لا يصلح محلا للنياحة فيه لعقد الإجارة ألا تجوز النيابة فيه، فإذا كان مما تجوز فيه النيابة كما هو

الحال في الزكاة، والحج فتجوز الإجارة عليه، وعليه فتجوز الإجارة على الفروض غير المتعين.

٦- يشترط في المنفعة أن تكون معلومة علماً ينفي الجهل بها إذا كانت الجهالة تؤدي إلى المنازعة، فلا تجوز الإجارة على التدريس لأي طالب، أو العمل في أي عمل، وتعيين المنفعة تكون بتعيين محلها، والعلم بها.

ما يجب تعيينه في الإجارة

قال المصنف: (و) عين (بناء على جدار) استؤجر للبناء عليه فيذكر قدره طولاً، وعرضاً وكونه بطوب، أو حجر أو غيرهما بخلاف كراء الأرض للبناء عليها فلا يشترط تعيين ما يبني فيها من كونه من حجر، أو طوب، (و) عين (محمل) بفتح أوله، وكسر ثالثه ما يركب فيه من شقة وشُقْدَفْ ، ومحفة لأنه يختلف باختلاف السعة والضيق ، والطول ، والقصر ، وأما بكسر أوله وفتح ثالثه فعلاقة السيف (أن لم توصف) المذكورات فإن وصفت وصفا شافيا كفى لكن البناء على الجدار لا يمكن فيه إلا الوصف لعدم وجوده حال العقد ، (و) عينت (دابة) اكرت (لركوب) عليها بالإشارة الحسية أو بأل العهدية ، ولا يكفي الوصف إذا لم تكن مضمونة في الذمة بأن قصد عينها (وإن ضمنت) في الذمة بأن لم يقصد عين دابة (فجنس) أي فاللزم تعيين جنسها كإبل ، أو بغال (ونوع) أي صنف كعراب وبخت (وذكورة) أو أنوثة فالوصف في هذا الباب يقوم مقام التعيين من حيث صحة العقد ، والحاصل أن الدابة وغيرها لركوب ، أو غيره لا بد في صحة الإجارة عليها من التعيين بالذات ، الوصف إلا أنها إذا عينت بالإشارة انفسخت الإجارة بتلفها وإلا فلا وعلى ربها بدلها ولو قال دابتك البيضاء ، أو الحمراء وليس له غيرها لاحتمال إبدالها ما لم يقل عليه ، أو التي رأيته معك بالأمس عينها ، وكلام المصنف لا يفيد ذلك فكان عليه أن يقول بعد قوله ومحل ودابة وسفينة ونحوها إن لم توصف بالإشارة وإلا فمضمونة^(١).

(١) الشرح: أشار المصنف إلى ما يجب تعيينه في الإجارة، يجب تعيين ما يلي:

البناء على جدار استؤجر للبناء عليه بأن يذكر طول مت بنى عليه وعرضه، وكونه من حجر أو لبن أو غير ذلك، بخلاف كراء الأرض للبناء عليها فلا يشترط وصف ما يبني عليها؛ لأنه لا يتعلق به غرض، بل يكفي علم المساحة.

ووجه الفرق بين الجدار يجب تعيين ما يبنى عليه، والأرض لا يجب ذلك فيها؛ أن الجدار يلحقه الضرر بكثرة البناء، بينما الأرض لا ضرر يلحقها بذلك وهذا الفرع مبني على جواز استئجار الحائط للبناء عليه.

- يجب تعيين المحمل المكترى للركوب فيه، وشقذف، ومحفة، وحجفة لأنه يختلف بحسب السعة والضيق، والطول، والقصر، والمتانة وغيرها.

- يجب تعيين المسكن، من دار أو غيرها، لاختلاف أحواله. وهذه المذكورات وحوها لا بد فيها من التعيين إن لم توصف وصفا شافيا، فالواجب إما التعيين، أو الوصف الشافي المفيد للمراد، وإلا كانت إجارة فاسدة.

- يجب تعيين الدابة المكترة للركوب أو الحمل، فيجب فيها التعيين ولا يكفي فيها الوصف، إلا الدابة المضمونة في الذمة ليتوصل بها إلى محل معين، وذلك إن لم تقصد عينها، فالواجب تعيين نوعها كإبل وبغال، وصنفها كعراب أو بخت، وذكرورة أو أنوثة لأن الوصف في هذا الباب يقوم مقام التعيين.

والحاصل أن الدابة وغيرها لركوب أو غيره: لا بد في صحة العقد عليها من التعيين بالذات أو بالوصف إلا أنها إذا عينت بالإشارة كدابتك هذه أو التي كانت معك بالأمس انفسخت الإجارة بتلفها، وإلا فلا تفسخ الأجرة وعلى ربها بدلها، فغير المعينة بالإشارة مضمونة، وعلى ربها بدلها إن تلفت، وإلا انفسخت بتلفها.

إجارة الأجير نفسه في عملين في وقت واحد

قال المصنف: (وليس لراع) استؤجر على غنم (رعي) غنم (أخرى) معها (إن لم يقو) على رعي الأخرى معها لغير ربها لكثرتها (إلا بمشارك) يعاونه فله رعي أخرى مع الأولى، (أو تقل) الأولى بحيث يقوى على رعي الأخرى معها (ولم يشترط) عليه ربُّ الأولى (خلافه) أي عدم رعي غيره فله رعي أخرى ومفهومه أنها إن قلت واشترط ربها عليه عدم رعي غيرها لم يجز له رعي الأخرى ، وإليه أشار بقوله (والا) بأن شرط خلافه أي عدم رعي غيرها معها (فأجرة) لما رعى من غيرها (لمستأجره) أي رب الغنم الأولى (كأجير لخدمة أجر نفسه) حتى فوت على المستأجر ما استأجره عليه ، أو بعضه فأجرته تكون لمستأجره الأول إن شاء أسقط عن نفسه أجرة ما فوته ، فإن لم يفوت عليه شيئا بأن وفى له بجميع ما استأجره عليه فلا كلام له ، وفهم من قوله فأجره لمستأجره ، وقوله أجر نفسه أنه لو عمل مجانا فإنه يسقط من كرائه بقدر قيمة ما عمل^(١).

(١) الشرح:

أجير الغنم، إذا استؤجر أجير لرعي بقر، أو بقر، أو إبل أو غيرها عينت له كهذه، أم لم تعين كعشرة من الغنم مثلا، فله أن يرعى غنما أخرى معها إن قوي على رعي الأخرى، ولو بمشارك يعينه على رعي الأخرى، وذلك إن لم يشترط رب الغنم الأولى عدم رعي غنم أخرى مع غنمه، فإن اشترط عليه ألا يرعى معها أخرى لم يجز له، فإن خالف الراعي ورعى معها غيرها فأجرة الذي أخذه في نظير الرعي الأخرى لمستأجرة الأول ولو قوي الأجير على رعي الجميع ولم يفوت شيئا.

فإن فوت عليه شيئا فالمستأجر مخير بين أن يعطيه الأجرة التي عينها له ويأخذ الأجرة التي في نظير رعي الأخرى، وبين أن يسقط أجرة ما فوته الأجير عليه بأن ينقصه من الأجرة التي سماها له، وهذا في أجير الغنم.

على من تكون رعاية ما تلده الغنم

قال المصنف: (ولا يلزمه) أي الراعي (رعي الولد) الذي تلده الغنم فعلى ربها أن يأتي لها براع آخر لرعيها ويجعل للأول أجرة في نظير رعي الأولاد (إلا لعرف) فإنه يعمل به^(١).

وأما أجير الخدمة إذا استؤجر في خدمة نفسه في خدمة أخرى معها حتى فوت على المستأجر الأول ما استأجره عليه، أو بعضه فإنه مخير كما في أجير الغنم، فإن لم يفوت عليه شيئاً بأن وفي بعمل كل ما طلب منه فلا كلام لمستأجره بخلاف أجير الغنم.

ومما تقدم يتعلق بإجارة الأجير نفسه في خدمة أخرى فلو عمل عملاً مجاناً بدون أجر فإن المستأجر يسقط من أجره بقدر ما فوته. أي فليس هناك تخيير، فإن لم يفوت شيئاً فلا يسقط من أجره شيء.

(١) الشرح: لا يلزم الراعي رعي ما تلده الغنم بعد الإجارة فعلى ربها أن يأتي لها براع آخر يقوم برعي الأولاد، أو يجعل للأجير الأول أجرة في نظير رعيه، إلا إذا وجد شرط أو عرف فيعمل به، والشرط مقدم على العرف إن وجد.

ووجه عدم لزوم رعي الراعي لما تلده الأمهات من الغنم عند عدم العرف والشرط، أن العقد لم يتناول ذلك، إذ الولد لم يكن موجوداً حين العقد، وفي ذلك مشقة على الراعي طرأت بعد ولادة الأمهات.

ويلزم الراعي الذي يأتي به أن يراعاها مع الأمهات؛ لئلا يتعب راعي الأمهات إذا فارقت أولادها، لا لمنع التفرقة لأنها خاصة بمن يعقل.

والفرق بين راعي الغنم لا يلزمه رعيه وولد المرأة الذي وضعته في السفر يلزم الجمال حمله، أن الحاصل من أولاد الغنم، وحين العقد لا يوجد أولاد حتى يتناولها العقد، والضرر الحاصل للجمال مشقة الحمل، والولد كان محمولاً قبل وضعه فيستصحب.

ما يُعمل فيه بالعُرف

قال المصنف: (وَعَمَلٌ بِهِ) أي بالعُرف أيضا (في الخيط) في كونه على الخياط، أو على رب الثوب، (و) في (نقش الرحي) المستأجرة للطحن في كونه على الملك أو المستأجر، (و) في (آلة بناء) فيقضى بما جرى به العرف في هذه الأشياء إذ العرف قاعدة من قواعد الفقه، (وإلا) يكن عُرف فيما ذكر (فعلى ربه) أي رب المصنوع من ثوب، ودقيق، وجدار وذلك (عكس إكاف) بكسر الهمزة ككتاب، وتضم كغراب، والمراد به ما يركب عليه من برذعة، أو شيء أصغر منها (وشبهه) كسرج وحويه ولجام ومقود فيعمل فيها بالعرف، وإلا فعلى رب الدابة على المذهب، وحينئذ فحكم الإكاف وشبهه حكم الخيط وما معه إذ هو على ربه في الموضعين لا عكسه، وأجيب بأن مرادة العكس في التصوير لا الحكم وهو أنه في الأول مكتر وهذا مكر، (و) عمل بالعرف (في) أحوال (السير والمنازل)، وقدّر الإقامة بها (والمعاليق) جمع معلوق بصم الميم كعصفور، وعصافير أي ما يحتاج له المسافر من نحو سمن، وزيت، وعسل (والزاملة) ما يحمل فيه المسافر حاجته من خُرج ونحوه فإن لم يكن عرف وجب التعيين في السير والمنازل، وإلا فسخ الكراء، وأما المعاليق والزاملة فلا يفسخ ولا يلزم المكري حملها (و) في (وطائه) أي فراشه وأولى غطائه (بمحمل) حملا أو اتيانا فإن لم يكن عُرف لم يلزم المكري (وبدل) نقص (الطعام المحمول) بأكل أو بيع فإن لم يكن عُرف فعليه وزن الحمل الأول، وأما عكسه كما إذا استأجره على قنطار إلى بلد كذا فأصابه مطر حتى زاد فلا يلزمه إلا حمل الوزن الأول (وتوفيره) أي الطعام المحمول إذا أراد ربه أن يوفره من أكل أو بيع وأراد المكري تخفيفه عُمَل بالعرف (كنزع الطيلسان) بفتح اللام، وقد تكسر، وتضم (قائلة) أو ليلا أي أن من استأجر قميصا ليلبسه فإنه يجب عليه

أن ينزعه في أوقات نزعه عادة فإن اختلف العرف في لبسه ونزعه لزمه بيان وقت نزعه أو دوام لبسه (وهو) أي من تولى المعقود عليه، أو من تولى العين المؤجرة من مؤجر بالفتح كراع ومستأجر كمكتري الدابة ونحوها^(١).

(١) الشرح: أشار المصنف إلى عدة مواضع يعمل فيها بالعرف منها:

يعمل بالعرف في كون الخيط على الخياط أو على رب الثوب، وفي كون نقش الرحي المستأجرة للطحن عليها على المالك أو المستأجر، وفي كون آلة البناء على البناء أو على رب الحائط. فإن لم يوجد عُرف فعلى رب الشيء المصنوع وهو الثوب والجدار. ووجه كونه على رب الشيء المصنوع إذا لم يوجد عرف، أن لفظ الخياطة والبناء لا يقتضي إلا العمل. وأما نقش الرحا فإنه عند عدم العرف لازم لرب الرحي سواء كان هو صاحب الدقيق أو كان الدقيق لغيره. (العرف الصحيح): هو ما تعارفه الناس، ولا يخالف دليل شرعي ولا يحل محرماً ولا يبطل واجباً، كتعارف الناس عقد الاستصناع، وتعارفهم تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر، وتعارفهم أن الزوجة لا تزف إلى زوجها إلا إذا قبضت جزءاً من مهرها، وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من حلي وثياب هو هدية لا من المهر. - كتاب علم أصول الفقه ص ٨٩، ط مكتبة الدعوة - الدليل السابع العرف - المكتبة الشاملة. (الذخرة للقرافي ج ٥، ص ٤٢٥، وجاء فيها "فإن فقدت العادة فعلى رب المال؛ لأن اللفظ لا يقتضي إلا العمل").

يعمل بالعرف في كراء الدابة في كون البرذعة والقنب والسرّج واللجام والمقود على رب الدابة أو المكتري. فإن لم يوجد عرف فعلى رب الدابة.

يعمل بالعرف في السير على الدابة المكترة ليلاً أو نهاراً، وفي باقي أحوال السير من كونه بالهويّنة أو حدر، أو متوسطاً، وفي المنازل التي ينزل بها في سير المسافة وقدر الإقامة بها ولا كلام لرب الدابة ولا المستأجر مع العرف.

فإن لم يكن عرف فلا بد في السير والمنازل من البيان وإلا فسد الكراء لعدم صحتها وفسخ لزيادة الغرر.

ويعمل بالعرف فيما يعلق بجانب الرجل مما يحتاج إليه المسافر في سفره من نحو سمن، وزيت، وعسل، وفي الزاملة. التي يضع المسافر فيها حاجته كخروج وكيس ونحوهما. الزاملة:

هي ما يحمل فيه، كالخرج ونحوه، الذخيرة ح ٥، ص ٤٢٧، وجاء فيها "قال صاحب التنبیهات: الزاملة ما يحمل فيها كالخرج ونحوه".

فإن لم يكن عرف فيما يعلق والزاملة فلا يلزم المكري حملها.
وقول المصنف وفي السير عطف على قوله وفي الخيط وكأنه أعاد الجار لبعده.

ويعمل بالعرف في فراش المحمل هل هو على رب الدابة أو على المكثري. فإن لم يكن عُرف لم يلزم المكري أي: رب الدابة الإتيان به.

ويعمل بالعرف في بدل الطعام نقص الطعام المحمول على الإبل إذا نقص بأكل أو بيع.
فإن لم يكن عرف فعليه وزن الحمل الأول.

ويعمل بالعرف في توفير الطعام المحمول بالكراء إذا أراد ربه أن يوفره من أكل أو بيع ونازعه رب الدابة . فإن لم يكن عُرف فلا كلام لرب الدابة وعليه حمله إلى غاية المسافة ولو زاد الطعام ثقلاً كنزول مطر عليه، فقال سحنون لم يلزم المكري إلا زنة الحمل المشترك.
شرح الخرشي على مختصر خليل ج ٧، ص ٢٥.

ويعمل بالعرف في نزع ثوب مكثري للبس مثل القميص والعمامة والشنال الذي يغطي به الرأس فيجب عليه نزعه في الأوقات التي جرى لعرف بنزعه فيها، كالليل والقائلة، فإن لم يكن عرف على عوام اللبس وإن اختلف العرف وجب البيان فإن لم يبين كانت الإجارة فاسدة.

الضمان في الإجارة

قال المصنف: (أمن فلا ضمان) عليه إن ادعى الضياع ، أو التلف كان مما يغاب عليه أولا ، ويحلف إن كان متهما لقد ضاع وما فرطت ولا يحلف غيره ، وقيل يحلف ما فرطت ، وبالع على عدم الضمان بقوله (ولو شرط) عليه (إثباته) أي الضمان (إن لم يأت بسمة الميت) فلا ضمان وإن لم يأت بها لكن كلامه يوهم صحة عقد الإجارة مع الشرط المذكور مع أنه يفسده لأنه شرط مناقض لمقتضى العقد فله أجره المثل سواء زادت على التسمية ، أو نقصت عند ابن القاسم إلا أن يسقط قبل الفوات ، وإلا صحت الإجارة ، والفوات هنا بانقضاء العمل فإسقاطه في أثناءه كإسقاطه قبله في إفادة الصحة (أو عشر) أجبر حمل أو عثرت دابته (بدّهن وطعام) أو غيرهما ، (أو) عشر (بأنية فانكسرت و) الحال أنه (لم يتعد) في فعله ولا سوق دابته فلا ضمان إلا أن يتهم بأن لم يصدقه ربه ولم يصاحبه ولم تقم له بينة فيضمن ، (أو انقطع الحبل) فتلف المتاع المشدود به ، (ولم يغر بفعل) بأن لم يغر أصلا ، أو غر بقول فلا ضمان له إذ لا أثر للغر القولي كأن يأتي بشقة لخياط يقول له هل تكفي ثوبا فيقول نعم فيفصلها فلم تكف فلا ضمان على الخياط ، وإن علم عدم كفايتها ، نعم إن شرط عليه بأن قال له إن علمت أنها تكفي ففصلها ، وإلا فلا فقال تكفي فيضمن ومثال القولي أيضا أن يقول الصيرفي في دينار ، أو درهم أنه جيد وهو يعلم أنه ردئ فلا ضمان ولو بأجرة ، وقيل بضمانه مطلقا ، أو قيل إن كان بأجرة واستظهر فإن غر بفعل ضمن كربطه بحبل رث أو مشيه بموضع زلق ، أو تعثر الدابة فيه وله الأجرة بحساب ما سار ككل متعد في المحمولات فإن لم يضمن فلا كراء له (كحارس) لدار أو بستان أو طعام ، أو ثياب أو غيرها لا ضمان عليه ؛ لأنه أمين ، إلا أن يتعدى أو يفرط ولا عبرة بما

شرط ،أو كتب على الخفراء في الحارث ، والأسواق من الضمان (ولو حماميا) فلا ضمان عليه فيما ضاع من الثياب مالم يفرط ، ومن التفريط مالم قال رأيت رجلا يلبسها فطننت أنه صاحبها ، (وأجير) لصانع لا ضمان عليه كأن يعمل بحضرة صانعة أم لا (كسمسار) يطوف بالسلع في الأسواق لا ضمان عليه (إن ظهر خيرُهُ) أي أمانته (على الأظهر) وإلا ضمن (ونوتي) وهو عامل السفينة (عُرقت سفينتهُ بعمل صانع) في سيرها وحملها وإلا ضمن المال أو الدابة مالم يعتمد القتل وإلا قُتل (لا إن خالف) راع (مرعى شُرط) عليه فهلك أو ضاعت فيضمن أو (أنزى) الراعي أي أطلق الفحل على الإناث (بلا إذن) من ربها فيضمن إن عطبت تحت الفحل أو من الولادة إلا لعرف بأن الرعاة تنزى (أو غر) المكثري (بفعل) كقول انضم له شرط كما تقدم (فقيمته) أي يضمن قيمته (يَوْمَ التلف) في موضع التلف وله من الكراء بحسابه طعاما كان أو غيره قامت بينة بتلفه بالعثار ونحوه أم لا (أو صانع) يضمن (في مصنوعة) فقط أي فيما له فيه صنعة كحلي يصوغه وكتاب بنسخه، وثوب يخيطة ، وخشبه يصنعها كذا ثم يدعي تلفه أو ضياعه (لا) في (غيره) أي لا ضمان عليه فيه (ولو محتاجا له عمل) أي ولو كان الغير يحتاج عمل المصنوع له فيضمن مصنوعه فقط ؛لأنه أمين في ذلك الغير لا صانع فمن دفع لطحان قمحا في قفة ليطحنه له ، أو دفع لناسخ كتابا لينسخ له منه آخر فادعى ضياع الكل ضمن القمح دون القفة ، والكتاب المسوخ دون المنسوخ منه فأحرى في عدم الضمان مالا يحتاج له العمل، وبالف في ضمان على الصانع مصنوعه بقوله على ضمان الصانع مصنوعه بقوله (وإن) عمله الصانع (ببيته أو) عمله (بلا أجر) وسواء تلف بصنعه أو بغيرها إلا أن يكون في صنعه تغيير^(١)..

(١) الشرح: أشار المصنف إلى الضمان في عقد الإجارة، ويكون المستأجر والأجير لا

ضمان عليهما على النحو التالي:

- إذا ادعى الضياع أو التلف وكان مما يغاب عليه أم لا. ويحلف إن كان متهما لقد ضاع وما فرطت، ولا يحلف غير المتهم، وقيل: يحلف غير المتهم فيقتصر في يمينه على قوله ما فرطت، ولا يحلف على الضياع.

والفرق: أن غير المتهم إذا وقع منه ضياع إنما يكون من تفريطه فيكفي حلفه ما فرطت، وهناك قول ثالث: إنه كالمتهم يحلف لقد ضاع وما فرطت.

ولا ضمان على المستأجر ولا الأجير المذكورين ولو شرط عليه إثبات الضمان في العقد، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله (ولو شرط) عليه (إثباته)، ويفسد عقد الإجارة بهذا الشرط.

ووجه الفساد أنه شرط يناقض مقتضى العقد. فإذا وقع فله أجره المثل زادت على المسمى أو نقصت قاله ابن القاسم.

ومحل الفساد: إن لم يسقط الشرط قبل الفوات، وإلا صحت، والفوات هنا يكون بانقضاء العمل. فإسقاطه في اثنا عشر كإسقاطه قبله في إفادة الصحة. والحاصل أنه شرط مفسد للعقد ما لم يسقط لكن لو عثر عليه بعد العمل فله أجر مثله ولا يعمل بالشرط.

ومثل التلف والضياع في عدم الضمان للأجير إذا عثرت دابته بدهن أو غيره استؤجر لحمله، أو عثر بآنية فانكسرت، أو انقطع الحبل الذي ربط به الأمتعة فتلفت، فلا ضمان عليه. ووجه عدم الضمان أن الأجير معه الإذن ويده يد أمانة، وعدم الضمان مقيد بأمرين هما:

الأول: ما لم يتعد في فعله أو سوق الدابة، فإنه يضمن لتعديه، فإن كذبه ربه - بعد م تعديه - فلا يصدق في الطعام والإدام إلا ببينة ويصدق في غيره.
وعلة التضمن في الطعام والإدام ما فيهما من قوة التهمة، لكون الطبع يحث على أخذ الطعام ويميل إليه.

وأشار المصنف إلى تلك العلة بقوله إلا أن يتهم فلا يصدق ربه. وعلق على ذلك الشيخ محمد عرفة الدسوقي بقوله يؤخذ من هذا أن المستأجر بالفتح ليس بأمين في الطعام. والسفينة كالدابة في التفصيل بين حمل الطعام وغيره.

الثاني: مالم يغر بفعله. فإن غر بفعله ضمن، كريطه الأمتعة بحبل رديء رث أو مشيه بالدابة بمكان زلق، فإنه يضمن؛ لأنه مفرط. فإن لم يفرغ بفعله وغر بقوله فلا ضمان عليه؛ لأنه لا أثر للغرور القولي، كأن يأتي أحد بشقة لخياط ويقول له كأن كانت تكفي ثوبا ففصلها، فقال له تكفي ففصلها فلم تكف فلا ضمان على الخياط وإن علم عدم كفايتها، إلا أن يشترط عليه بأن قال له: إن علمت أنها تكفي ثوبا ففصلها وإلا فلا، فقال تكفي مع علمه بأنها لا تكفي فيضمن.

وتعليل الضمان هنا أنه لم يؤذن له في قطعه إلا بشرط أن يكون فيه ثوب، فإذا قطعه وجب عليه الضمان؛ لأن ذلك خيانة. ومن الغرر القولي، قول الصيرفي في دنانير أو دراهم إنها جيدة مع عمله إنها رديئة فلا ضمان عليه ولو بأجرة. وقيل يضمن مطلقا، وقيل إن كان بأجرة، واستظهر هذا القول.

حارس الدار، أو البستان، أو الزرع، أو حارس طعام، أو عرض لا ضمان عليه؛ لأنه أمين. ولو كان حماميا إلا أن يتعدى أو يفرط. ومن التفريط ما لو قال الحمامي رأيت رجلا يلبس الثياب فظننت أنه صاحبها. ومن التفريط نوم الحارس في وقت لا ينام فيه. ووجه تضمين الحمامي عند التفريط بإعطاء الثياب لغير صاحبها، أنه أخطأ عليه متاعه فدفعه إلى غيره، وأموال الناس تضمن بالعمد والخطأ.

وأما الغفراء في الحارات والأسواق فلا ضمان عليهم، ولا عبرة بما يكتب عليهم من أنه إذا ضاع شيء في دار يضمنونه؛ لأن ذلك التزام ما لا يلزم، ولا ضمان حيث ما لم يفرطوا كما أفتى به الشيخ عبد الرحمن الأجهوري، ونقله عنه الشيخ كريم الدين.

وأعلم ان أصل المذهب عدم تضمين الخفاء، والحراس، والرعاة، واستحسن بعض المتأخرين تضمينهم نظرا لكونه من المصالح العامة.

أجبر الصانع لا ضمان عليه كأن يعمل بحضرة صانعه، وإلا ضمن؛ لأنه صار له حكم الصانع المشترك المنتصب للناس.

السمسار الذي يطوف بالسلع في الأسواق لبيعها، إذا كان خيرا ذا أمانه، لا ضمان عليه إذا ادعى ضياع شيء مما بيده بغير تعديه وبلا تفريط، وهذا في السلع قبل بيعها أوفي ثمنها إذا ضاع بعد البيع وفيما يحصل في السلع كالثوب من تمزيق، أو خرق بسبب نشر أو طي إذا لم يخرج عما أذن له فيه ويضمن كما إذا ادعى أنه باع سلعة لرجل وأنكر ذلك الرجل الشراء ولم يكن له برينة عليه لتفريطه بترك الإشهاد. وقيد بعضهم عدم الضمان من ظهر خيره بما إذا لم ينصب نفسه للسمسرة وإلا ضمن كالصانع وقد اعتبر ابن عرفة هذا القيد. وأمل من لم يظهر خيره فيضمن ن كذا افتى ابن رشد، وقيل: لا يضمن السمسار مطلقا قال عياض: وهو المعروف من قول مالك وأصحابه، قال: لأنهم وكلاء وليسوا صناع.

- النوتي إذا غرقت السفينة بفعل سائغ في تسييرها، وفي المشي بها في ربح أو موج بحسب المعتاد، وفي وسقها الوسق المعتاد فلا ضمان عليه في نفس ولا مال، وأولى إذا غرقت بغير فعل كهيجان البحر واختلاف الريح مع عجزه عن صرفها. وأن النوتي لا أجر له إذا غرقت أثناء المسافة، وكذا بعد تمامها، وقبل التمكن من إخراج الحمل، أما إذا غرقت بعد تمام المسافة، وبعد مضي مدة يمكن إخراج الأحمال منها فإنه لا ضمان على النوتي، وله الأجرة كاملة، ويجوز الطرح من السفينة عند خوف غرقها ويوزع ما طرح على مال التجارة فقط، ولا سبيل لطرح الأدمي ذكرنا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا، مسلما أو كافرا خلافا للخي القائل بجواز طرح الأدميين بالقرعة؛ لأن هذا كالخرق للإجماع على أنه لا يجوز إماته أحد من الأدميين لنجاة غيره.

- وإن غرقت بفعل لا يسوغ في سيرها أو حملها ضمن، وإن تعدد الفعل فالقصاص، والعلة في تضمين النوتي التعدي، فحيثما غابت العلة فلا ضمان.

- المستأجر لدابة إذا ضربها أو ساقها بالعصا على الناس بغير خرق فعطبت لم يضمن لأن العرف جارٍ بأنه لا بد للدابة من سوق وزجر على السير، والضرب على قدر الحاجة مأذونا فيه، فلم يضمن ما حدث عنه.

وفيما عدا ذلك يكون المستأجر والأجير ضامنا وذلك كما يلي:

- الراعي إذا خالف المرعى الذي شُـرط عليه، كأن يقال له لا ترعى إلا في المكان الفلاني فخالف ورعى في غيره أولا ترع في محل الجاموس فخالف ورعى فيه فتلفت فإنه يضمن.

ومحل الضمان إذا خالف مرعى شُـرط إذا كان بالغاً وإلا فلا ضمان لقول المصنف وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه.

- الراعي إذا أنزى الفحل على الإناث بلا إذن من ربها فعطبت، أو ماتت تحت الفحل أو عند الولادة فيضمن، إلا لعرف بأن الرعاة تنزي ولا تستأذن فلا ضمان اتفاقاً، أما إذا لم يجر عُرْف بشيء فقولان بالضمان وعدمه، والمعتمد الأول وعليه مشى المصنف، ومحل الخلاف إذا كان الفحل لرب الأنثى وإلا ضمن اتفاقاً.

- إذا غر بفعل فإنه يضمن كما تقدم، وكذلك إذا غر بقول انضم له شرط كما تقدم. وكل من الراعي وما بعده فالضمان يكون بالقيمة يوم التلف لا يوم التعدي ولا يوم الحكم. ويضمن الصانع في مصنوعة فقط لا غير، كثوب يخيطة، أو حلي يصوغه، أو خشبة ينشرها، أو حب يطحنه.

والفرق بين إيجاب الضمان على الصانع دون غيرهم من المستأجرين والأجراء لا يضمنون إلا بالتعدي؛ أن الأصل في قبض الصانع لأمتعة الناس هو على الضمان؛ لأنهم متهمون، بينما غيرهم الأصل فيهم ظانهم أمانة على ما يستأجرونه.

ولا ضمان على الصانع في غير مصنوعة، كما لو جعل الشيء المصنوع في ظرف فادعى الصانع ضياعها فإنه يضمن الصانع ما فيه الصنعة لا الظرف، ولو كان الصانع محتاجاً له في العمل فلا يضمنه، كقفة الطحين، والكتاب الذي يُنسخ منه، وهذا قول سحنون، وعمله بأنه لا عمل له فيه، وقال ابن حبيب: يضمن الصانع ما لا يستغني عنه سواء احتاج له الصانع أو المصنوع، وقال ابن المواز: يضمن الصانع ما يحتاج في عمله كالكتاب الذي

ينسخ منه دون ما يحتاج إليه المصنوع كظرف القمح والعجين، ووجه عدم تضمينه الظرف أنه باق عنده على حكم الوديعة.

ويضمن الصانع مصنوعه على ما تقدم ولو كان يصنعه في بيته دفعا لما يتوهم من عدم ضمانه في هذه الحالة ؛ لأنه لما عمل في بيته صار كأنه لم ينصب نفسه للعمل للناس. ودليل هذا القول المتوهم، هو ظان الأصل في الصانع عدم تضمينهم وأنهم مؤتمنون؛ لأنهم أجراء، وقد أسقط الشرع عن الأجير الضمان فأخرج أهل العلم الصانع من ذلك لنصيبهم أنفسهم لأعمال الناس وأخذ أمتعتهم، وإذا لم ينصب نفسه على الأصل، يسقط عنه الضمان. ويضمن الصانع أيضا ولو كان يصنعه بلا أجر، فأولى لو صنعه بأجر في حانوته.

شروط تضمين الصناع

قال المصنف: ... إلا أن يكون في صنعته تغير كثقب اللؤلؤ ، وتقش الفصوص وتقويم السيوف وكذا الختان والطب فلا ضمان إلا بالتفريط ، وأشار لشروط ضمان الصانع بقوله (إن نصب نفسه) لعموم الناس فلا ضمان على أجير خاص بشخص أو جماعة مخصوصة ، (وغياب عليها) أي على السلعة المصنوعة بأن صنعها بغير حضور ربها ، وبغير بيته ، فإن صنعها ببيته ولو بغير حضوره ، أو صنعها بحضوره لم يضمن ما نشأ من غير فعله كسرقة أو تلف بنار مثلاً بلا تفريط أو نشأ عن فعله مما فيه تغير كما مر ، ويشترط أيضاً أن يكون المصنوع مما يغاب عليه لا نحو عبد يرسله صيده للمعلم فيدعي هروبه فلا ضمان عليه ، وهذا غير قول المصنف وغياب عليها ، وإذا ضمن الصانع (فبقيته يوم دفعه) إلا أن يرى عنده بعده فلاخر رؤية إلا أن يقر الصانع أنه تلف أو ضاع بعد ذلك وكانت قيمته أكثر إذ ذاك من قيمته يوم الدفع ، أو الرؤية فيغرمها ؛ لأنه أقر على نفسه وبإلغ على الضمان بقوله (ولو شرط) الصانع (نفية) أي نفي الضمان ويفسد العقد بالشرط المذكور ، وله أجر مثله (أودعا) الصانع ربه (لأخذه) بعد فراغه من صنعه فتراخى ربه فادعى ضياعه فيضمن قال ابن عرفه إن لم يقبض الصانع أجرته فإن قبضها وصار بعد الفراغ وطلبه لأخذه وديعة عنده فلا يضمن إلا بتفريط (إلا أن تقوم بينة) بتلفه أو ضياعه بلا تفريط فلا ضمان سواء دعاه لأخذه أم لا ، وإذا لم يضمن (فتسقط الأجرة) من ربه ؛ لأنه لا يستحقها إلا بتسليمه لربه (وإلا أن يحضره) الصانع لربه (بشرطه) أي على الصفة التي شرطها عليه فتركه عنده وادعى ضياعه فإنه يصدق لأنه خرج من حكم الإجارة إلى الإيداع وهذا إذا كان قد دفع الأجرة وإلا كان رهناً فيها فحكمه حكم الرهن ، (وصدق) راع نحر بعيراً ، أو ذبح

شاة (إن ادعى خوف موت) لما نحره أو ذبحه (فنحر) أو ذبح ونازعه المالك وقال بل تعديت ، وحلف المتهم دون غيره كما يقتضيه ابن عرفه (أو) ادعى (سرقة منحوره) أي الراعي بأن قال ذبحتها خوف موتها ثم سرفت ، ومثلاً الراعي الملتقط (أو) ادعى الحجام (قلع الضرس) أذن له فيه ونازعه ربه وقال قلعت غير المأذون فيه، (أو) ادعى الصباغ (صبغاً) بأن قال أمرتني به ، وقال ربه بل بغيره ، أو قال أمرتني أن أصبغه بعشرة دراهم من الزعفران مثلاً ، وقال ربه بل بخمسه (فتوزع) أي نازعه ربه فيصدق الأجير في المسائل الأربعة^(١).

(١) الشرح: أشار المصنف إلى أن شروط تضمين الصانع خمسة وهي:

- ١- أن ينصب نفسه للصنة لعامة الناس، ويسمى الأجير المشترك. واحترزا عن الأجير لشخص خاص، أو جماعة مخصوصين فلا ضمان عليه.
- ٢- أن يغيب الصانع عن الشيء المصنوع بأن لا يعمل في بيت ربه وإن لم يكن حاضراً أو بحضوره ولو في غير بيته، وإلا فلا ضمان عليه.
- ٣- أن يكون المصنوع مما يغاب عليه أي: بأن يمكن إخفاؤه.
- ٤- ألا يكون في صنعته تغيير، أي: تعريض للإتلاف، كتقب اللؤلؤ، ونقش الفصوص، وتقويم السيوف، والختان، وقلع الضرس، وخبز العيش في الفرن، والطب، فلا ضمان إلا بالتفريط.

فإذا ختن الخاتن، أو سقى الطبيب المريض دواءً، أو قلع له شيئاً، أو كواه فمات من ذلك فلا ضمان على واحد منهما لا في ماله ولا على عاقلته؛ لأنه مما فيه تغيير فكأن صاحبه هو الذي عرضه لما أصابه، وهذا إذا كان الخاتن والطبيب من أهل المعرفة، ولم يخطئ في فعله فإذا كان أخطأ في فعله والحال أنه من أهل المعرفة فالدية على عاقلته، وإن لم يكن من أهل المعرفة عوقب، وكون الدية على عاقلته أو في ماله قولان الأول لابن القاسم، والثاني لمالك وهو الراجح؛ لأن فعله عمد والعاقل لا تحمل عمداً.

- ٥- ألا تكون له بينة بتلفه بلا تفريط.

وإذا ضمن الصانع يضمن قيمته يوم دفعه المصنوع للصانع، لا يوم تلفه ولا يوم الحكم إلا أن يرى المصنوع عنده بعد يوم الدفع فإن رئي بعده فبأخر رؤية.

وإذا كانت القيمة تعتبر يوم الدفع فلا أجره للصانع. وكذا إذا اعتبرت بآخر رؤية لم يكن مصنوعا، وعلى ربه الأجرة.

وإذا شرط الصانع نفي الضمان عن نفسه، فإنه يضمن ولا يفيد شرطه؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد كذا علله الشيخ محمد عرفة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير بهامش الشرح الكبير على مختصر خليل للشيخ أحمد الدريد، وأشار إلى تلك العلة الشيخ الخرشي في شرحه على مختصر خليل.

فإذا وقع العقد وعثر عليه ففيه أجره المثل قلت أة كثرت دون المسمى. وينتفي الضمان عن الصانع إذا كانت بينة تشهد بضياعة بلا تفريط فلا ضمان عليه. وهذا لأن ضمان الصانع ضمان تهمة ينتفي بإقامة البينة.

فإن أحضره الصانع لربه مصنوعا على الصفة المشترطة فتركه صاحبه عنده، فادعي ضياعه فلا ضمان عليه؛ لأنه خرج مخرج الإيداع، ولا تسقط الأجرة؛ لأنها تستحق بالتسليم وقد حصل. وهذا ما لم يتركه عنده رهنا في نظير الأجرة، وإلا كان حكمه حكم الرهن يضمنه ضمان الرهان، ولا تسقط الأجرة سواء ضمنه بالفعل أم لا.

ويصدق الراعي إن ادعى ضياح بعض الماشية بلا تفريط أو ادعى الخوف من موت بعضها فنحر أو ذبح وجاء بها مدكاه وخالفه ربه وقال له: بل تعديت كما يصدق إن ادعى سرقة ما نحر، وقال نحرتهما لخوف موتها فسرقت، وخالفه ربهما وقال: بل أكلتها، وفي كلا المسألتين يحلف الراعي إذا اتهم فقط، فإن خاف الراعي موتها وترك ذكاتها حتى ماتت ضمنها.

وإن قال: ذبحتها خوف الموت وأكلتها لم يصدق، إذا كان المحل قريبا، وذلك لقوة التهمة، وإلا صدق، ومحل عدم تصديقه مالم يجعل له ربهما أكلها وإلا صدق.

وأما المستأجر، والمستعير، والمرتهن، والمودع، والشريك فلا يصدق واحد منهم في دعوى التذكية لخوف الموت إلا بطلخ، أو بينة، وإن كانوا يصدقون في التلف والضياح، وذكر الشيخ محمد عرفة الدسوقي أن الفرق بين هؤلاء والراعي مع كون الجميع أمناء لتعذر الإشهاد من الراعي غالبا بخلاف هؤلاء فإنه لا مشقة عليهم في الإشهاد غالبا. (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ محمد عرفة الدسوقي بهامش الشرح الكبير ج ٤ ص ٢٩).

وأحرى من هذا في الضمان من مر على دابة شخص فذكاها وأدعى أنه فعل ذلك لخوف موتها، أو سلخ دابة غيره، وادعى أنه وجدها ميتة فلا يصدق إلا ببينة أو لطخ.

ويصدق الحجام إن ادعى قلع ضرس أذن له فيه، ونوزع في ذلك بأن المقلوع غير المأذون له فيه فالقول قول الحجام وله من الأجرة ما سماه إلا أن يصدقه الحجام على ما قاله فلا أجرة له، وعليه القصاص في العمد والعقل في الخطأ، وقول المصنف ضرر لا مفهوم له بل يشمل الضرر والسن والناوب، وإنما عبر به، وإنما خص الضرر بالذكر لأن الغالب أن الوجع يقع فيه.

ويصدق الصباغ أنه صبغ الثوب عصفرا بعشرة وادعى ربه أمره بخمسة منه، مع يمين الصانع إن أشبه أن يكون فيه بعشرة وإن أتى بما لا يشبهه صدق رب الثوب، فإن أتى بما لا يشبهه فله أجرة المثل.

فسخ الإجارة

قال المصنف: ثم شرع في بيان ما يطرأ على الإجارة فقال: (وَفُسِخَتِ) الإجارة (بِتَلْفٍ مَا يَسْتَوْفَى مِنْهُ لَا) بِتَلْفٍ مَا يَسْتَوْفَى (بِهِ) الْمُنْفَعَةُ أَشَارَ بِهَذَا إِلَى قَوْلِهِمْ أَنَّ كُلَّ عَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا فَيُهْلِكُهَا تَنْفُسُخُ الْإِجَارَةِ كَمَوْتِ الدَّابَّةِ الْمَعِينَةِ، وَكُلِّ عَيْنٍ تَسْتَوْفَى بِهَا الْمُنْفَعَةُ فَيُهْلِكُهَا لَا تَنْفُسُخُ الْإِجَارَةَ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَوْتِ الشَّخْصِ الْمُسْتَأْجَرِ لِلْعَيْنِ الْمَعِينَةِ وَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ وَأَرَادَ بِالتَّلْفِ التَّعْذِرَ أَيْ تَعْذِرَ اسْتِيفَاءِ مَا اسْتَوْجَرَ عَلَيْهِ كَأَسْرِ وَصْبِي، وَسُكُونِ وَجَعِ ضَرْسٍ، وَعَفْوِ قِصَاصٍ، وَاسْتِثْنَى مِنْ قَوْلِهِ لِأَبِهِ صَبِيَّيْنِ وَفَرَسَيْنِ بِقَوْلِهِ (إِلَّا صَبِيٍّ تَعْلَمُ) بِالإِضَافَةِ وَجَرَّ صَبِيٍّ لِأَنَّهُ مَسْتِثْنَى مِنْ ضَمِيرِ بِهِ الْوَاقِعِ بَعْدَ نَفْيِ بِهِ فَهُوَ بَدَلُ مِنْهُ وَلَوْ قَالَ لَا مَتَعْلَمَ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الْبَالِغَ مِنَ الْإِخْتِصَارِ (وَرَضِعٍ) مَاتَ كُلُّ قَبْلَ تَمَامِ مَدَةِ الْإِجَارَةِ أَوْ الشَّرُوعِ فِيهَا (وَفَرَسٍ نَزَوٍ) مَاتَتْ مِثْلًا قَبْلَ النَّزْوِ عَلَيْهَا وَأَمَّا مَوْتُ الذَّكَرِ الْمَعِينِ فَدَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ وَفُسِخَتِ بِتَلْفٍ مَا يَسْتَوْفَى مِنْهُ (و) فَرَسٍ (رَوْضٍ) أَيْ رِيَاضَةٍ أَيْ تَعْلِيمِهَا حَسَنَ الْجَرِيِّ فَمَاتَتْ، أَوْ عَطِبَتْ فَتَنْفُسُخُ وَلَهُ بِحِسَابِ مَا عَمِلَ وَالْحَقُّ بِهَذِهِ الصُّورِ الْأَرْبَعَةِ حَصْدُ زَرْعٍ مَعِينٍ، وَحَرْثِ الْأَرْضِ بِعَيْنِهَا وَبِنَاءِ حَائِطٍ بَدَارٍ فَيَحْصُلُ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِرَبِّهِ غَيْرُهُ فَتَنْفُسُخُ لَتَعْذِرَ الْخَلْفَ، وَقِيلَ لَا بَلْ يُقَالُ لِرَبِّهَا ادْفَعْ جَمِيعَ الْأَجْرَةِ، أَوْ أَنْتَ بَغِيرُهَا وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَصْنَفِ لِإِقْتِصَارِهِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا (و) فَسِخَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى (سَنِ) لِقَلْعٍ) أَيْ لِأَجْلِ قَلْعِهَا فَالْمُسْتَأْجَرُ عَلَيْهِ الْقَلْعُ وَلَوْ قَالَ وَقَلْعَ سَنِ (فَسَكَنْتِ) أَيْ أَلَمَهَا كَانَ أَوْضَحَ (كَعَفْوٍ) ذِي (الْقِصَاصِ) عَنِ الْمَقْتَصِ مِنْهُ فَتَنْفُسُخُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْقِصَاصِ لَتَعْذِرَ الْخَلْفَ وَهَذَا إِنْ عَفَا غَيْرَ الْمُسْتَأْجَرِ، وَأَمَّا إِنْ هَذَا الْمُسْتَأْجَرُ فَتَلَزَمَ حِينَئِذٍ الْأَجْرَةُ (و) فَسِخَتِ (بِغَضَبِ الدَّارِ) الْمُسْتَأْجَرَةِ (وِغَضَبِ مَنْفَعَتِهَا) إِذَا كَانَ الْغَاصِبُ لَا تَنَالُهُ الْأَحْكَامُ، (و) فَسِخَتِ بِ (أَمْرِ السُّلْطَانِ) أَيْ

من له سلطنة وقهر (بإغلاق الحوانيت) بحيث لا يتمكن مستأجرها من الانتفاع بها ، ويلزم السلطان أجرتها لربها إذا كان قصده غصب المنفعة فقط دون الذات ، (و) بظهور (حمل ظئر) أي مرضع (أو) حصول (مرض) لها (تقدر معه على رضاع) إن تحقق ضرر الرضيع وإلا كان أهله بالخيار كما تقدم، (و) بسبب (مرض عبد) لا قدرة له على فعل ما استؤجر عليه (وهربه لكعدو) بأرض حرب ، أو ما نزل منزلتها في البعد فإن هرب لقريب في أرض الإسلام لم تنفسخ لكن تسقط أجرته مدة هروبه (إلا أن يرجع) العبد أي يعود من مرضه أو هربه (في بقيته) أي العقد أي زمنه فلا تنفسخ ويلزمه بقية العمل ، كذا الظئر تصح فيلزمها بقية العمل ويسقط من الكراء مقدار ما عطل من زمن المرض أو الهرب ويحتمل رجوع الاستثناء لقوله الدار وما بعده كأنه قال إلا أن يرجع الشيء المستأجر على حالته التي كان عليها قبل المانع فلا فسخ أن له جميع المسمى بل يسقط منه بقدر ما عطل زمن المانع كما تقدم (بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح) فلا ترجع الإجارة بعد الفسخ لما يلحقه من الضرر في السفر بالصبر ، ومثل الدابة مرض العبد في السفر كما أن الدابة في الحضر مثل العبد فيه فحكمهما سواء ، وإنما اختلف جواب الإمام فيهما لاختلاف السؤال عن العبد في الحضر والدابة في السفر ولو العكس السؤال لكان الجواب ما ذكر (وخيّر) المستأجر في الفسخ وعدمه (إن تبين أنه) أي العبد مثلاً المستأجر ليعدمه في داره ، أو حانوته أو غيرها مما لا يمكن التحفظ منه فيه (سارق) أي شأنه السرقة ؛ لأنها عيب يوجب الخيار في الإجارة كالبيع ، وأما لو أكريته على شيء يمكن التحفظ منه فلا تنفسخ منه كما تقدم في المساقاة.

(و) فسخت الإجارة (برشد صغير عقد عليه) نفسه ، (أو على سلعة) كدأبته وداره (ولي) أب أو وصي أو مقام فبلغ أثناء المدة رشيداً فقلوه وبرشد معطوف على تلف بدليل الباء أي وفسخت بتلف ما ، وفسخت برشد ومعنى الفسخ إن شاء الصغير فهو مخير في الحقيقة ، وعطفه على إن تبين يبعده إعادة الباء ، وفي نسخة كرشد صغير بالكاف وهو تشبيه في التخيير وهي ظاهره ، والرشد يعتبر في العقد على نفسه ، أو على سلعة كما هو ظاهر وقد صرح به في التوضيح وقوله (إلا تظن عدم بلوغه) قبل انقضاء المدة (و) الحال أنه قد (بقى) منها اليسير (كالشهر) فيلزمه المدة ولا خيار له بأنه راجع للمسألتين وهو مذهب أشهب وهو ضعيف ، والمذهب أنه خاص بالأولى ، والحاصل أن محل خياره في العقد على نفسه أن يظن الولي حال العقد عليه بلوغه في مدة الإجارة أو لم يظن شيئاً مطلقاً ، أو ظن عدم بلوغه فيها فبلغ رشيداً وقد بقي منها كثير بأن زاد على كالشهر فإن ظن عدمه فيها فبلغ فيها وقد بقي اليسير كالشهر ويسير الأيام فلا خيار له ويلزمه البقاء لتمامها.

وأما في إجارة سلعة فإن بلغ سفيها فلا خيار له ولا يعتبر العقد على سلعة ظن رشد ولا عدمه، وكذا إن بلغ رشيداً، وقد ظن الولي عدم بلوغه في مدة الإجارة مطلقاً بقي اليسير أو الكثير فإن ظن البلوغ أولم يظن شيئاً فله الخيار فعلم أن الذي يخص المسألة الأولى هو قوله بقي كالشهر، وشبهه في الحكم المستثنى وهو اللزوم قوله (كسفيه) عقد وليه على سلعة، أو على نفسه لعيشه (ثلاث سنين) أو أكثر فرشد في أثناءها فتلزم الإجارة ولا خيار له حيث بقي من المدة الثلاث سنين فدون لأن الولي فعل ما يجوز له فإن عقد عليه لا لعيشه فله الفسخ لأن الولي لا تسلط له على نفسه بل على ماله وحينئذ فلو

اجر نفسه فلا كلام لوليه مالم يحاب وكذا لا كلام له إن رشد لأنه في نفسه كالرشيء.

(و) فسخت الإجارة (بموت مستحق وقف وآخر) ذلك الوقف في حياته مدة ، (ومات قبل نقضها) وانتقل الاستحقاق لمن في طبقته ، أو لمن يليه ولو ولده ولو بقى منها يسير (على الأصح) ولو كان المستحق المؤجر ناظراً بخلاف ناظر غير مستحق فلا تنفسخ بموته (لا) تنفسخ (بإقرار المالك) للذات المؤجرة بأنه باعها ، أو وهبها ، أو أجزها لآخر قبل الإجارة ونازعه المكتري ولا بينة لاتهامه على نقضها ويلزمه الإقرار فيأخذها المقر له بعد انقضاء المدة وله الأكثر من المسمى الذي أكرت به وكراء المثل على المقر، (أو خلف) بضم الخاء وسكون اللام اسم مصدر بمعنى تخلف أي لا تنفسخ الإجارة بتخلف (رب دابة) معينة أم لا (في) العقد على زمن (غير معين) كأن يكتريها ليلاتي بها رجلاً ، أو وفداً ، أو ليشيع بها رجلاً يوم كذا ، أو شهر كذا فتخلف ريثما عن الاتيان بها في ذلك اليوم أو الشهر بخلاف إذا عين الزمن كأكثرها يوم كذا ، أو على أن تخدمني ، أو تخيط لي في يوم كذا فتخلف فتفسخ ؛ لأنه أوقع الكراء على نفس الزمن (أو) في غير (حج) فلا تنفسخ بخلاف الحج إذا أخلف ربها حتى فات فيفسخ الكراء وإن قبض الكراء رده لزوال أيامه (وإن فات مقصده) من تشييع مسافر أو ملاقاته (أو) بظهور فسق مستأجر) لكدار لا تنفسخ ، وأمر (وآجر الحاكم) عليه (إن لم يكف) وهذا إن حصل بفسقه ضرر الدار أو الجار وهذا إن تيسر إيجارها عليه فإن تعذر أخرج حتى يؤجر عليه ولزمه الكراء ومن أكرى أو اشترى داراً لها جار سوء فعيب ترد به ، ومالك دار يضر فسقه بجاره يزجر ويعاقب فإن انتهى وإلا أخرج وبيعت عليه أجرت، (أو بعث عبد) مؤجر لا تصح إجارته (وحكمه على الرق) أي يستمر رقيقاً إلى تما

المدة في شهادته وقصاصه له وعليه وارثه لا فب وطاء السيد لها إن كانت أمة لتعلق حق المستأجر بالعين المؤجرة فإن أسقط حقه فما بقي من المدة مجاناً أو بشيء أخذ م العبد نجر عتقه (وأجرته) في باقي المدة بعد العتق (لسيده إن أراد أنه حر بعدها) لأنه بمنزلة من أعتقه، واستثنى منفعة مدة معينة فإن أراد أنه حر من يوم عتقه فأجرته للعبد مع بقاءه إلى تمامها فالشرط راجع لقوله وأجرته لسيده فقط لا لما قبله^(١).

(١) الشرح : ذكر المصنف قاعدة المذهب في فسخ الإجارة أن كل عين يستوفى منها المنفعة فيبطلها تنفسخ الإجارة كموت الدابة المعينة، وانهدام الدار المعينة.

ونوع ما في قول المصنف "بتلف ما يستوفى منه" ما موصولة، أي: الذي يستوفى منه، والموصول عند أهل اللغة من صيغ العموم، فكأنه قال بتلف كل ما يستوفى منه، لا نكرة بمعنى شيء، لأن النكرة في سياق الإثبات لا عموم لها، وقوله بتلف ما يستوفى منه إذا كان معيناً وأما إذا كان مضموناً في الذمة فلا تنفسخ بتلفه. (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤، ص ٢٩، شرح الخرشي على مختصر خليل ج ٧، ص ٣٠).

وقوله: "وانهدام الدار المعينة" لم يقيد ابن الحاجب الدار لكونها معينة قال في التوضيح: ولم يذكر المصنف التعيين لأن الدار لا تكرر إلا معينة. (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤، ص ٢٩).

تنبيه: وسوف اذكر الأمور التي تنفسخ بها الإجارة أولاً، ثم اذكر بعد الأمور التي لا تنفسخ بها الإجارة فلتنبيه إلى ذلك أيها القارئ الكريم، فالمصنف في الكتاب ذكر القاعدة التي تنفسخ بها الإجارة وذكر لها أمثلة، ثم بعد ذلك ذكر الأمور التي تستثنى من القاعدة، وساق بعد هذا الاستثناء أموراً تنفسخ بها الإجارة فلاحظ ذلك وفقك الله. ينبى على القاعدة التي ذكرها المصنف وهي كل عين يستوفى منها المنفعة فيبطلها تنفسخ الإجارة ما يلي:

- تنفسخ الإجارة إذا تعذر ما يستوفى منه المنفعة مثل الدار، والحانوت، والحمام السفينة ونحوها، وإن لم تعين حال العقد، ودابة عينت، والتفصيل بين المعينة وغيرها إنما في الدابة فقط، أما السفينة، والحمام ونحوهما متى تعذر ما يستوفى منه فسخت الإجارة. وأراد المصنف بقوله تلف التعذر-أي تعذر استيفاء ما استؤجر عليه-؛ لأن التعذر أعم من التلف، ويشمل الضياع والمرض، والغصب وغلق الحوانيت قهوا كما ذكره المصنف بعد ذلك.

وإذا فسخت الإجارة رجع إلى المحاسبة باعتبار ما حصل من المنفعة وما لم يحصل، وباعتبار المسافة طولا وقصرا، صعوبة وسهولة.

- وتنفسخ الإجارة ولو كان التعذر بغصب لما يستوفى منه دارا كانت، أو غيرها أو غصب منفعة لما يستوفى منه ولو لم يغصب الذات إذا كان الغاصب لا تتاله الأحكام.

كما تنفسخ الإجارة ولو بأمر ظالم لا تتاله الأحكام بإغلاق الحوانيت المكثرة بحيث لا يتمكن مستأجرها من الانتفاع بها، ويلزم الظالم أجرتها لربها إذا كان قصده غصب المنفعة فقط دون الذات.

ومحل فسخ الإجارة: بغصب العين المستأجرة، أو غصب منفعتها إن شاء المستأجر؛ وإن شاء بقي على اجارته، فإن فسخها كان لمالك الذات المغصوبة الأجرة على الغاصب، وإن أبقاها من غير فسخ صار ذلك المستأجر مع الغاصب بمنزلة المالك فتكون الأجرة له، ومعنى الفسخ في هذه المسائل أنها معرضة للفسخ، لا إنها تنفسخ بالفعل.

- وتنفسخ الإجارة بحمل الظئر-أي المرضع-سواء كان الحمل قبل عقد الإجارة وظهر بعده أو طرأ بعد عقد الإجارة إذا لم تقدر على الرضاع، فإن قدرت على الرضاع فلا تنفسخ الإجارة ما لم يضر بالرضيع.

- تنفسخ الإجارة إذا حدث مرض للأجير لا يقدر معه على عمل ما استؤجر عليه أو مرض الظئر-المرضع-لا تقدر معه على الرضاع فإن قدرت معه على الرضاع لم تنفسخ الإجارة إلا أن يضر.

- تتفسخ الإجارة بمرض الدابة لا تقدر معه على الفعل ما استؤجرت عليه وذلك لنفي الضرر الذي يدخل على المكري لو ألزمه ربها أن يقيم معه وينتظر شفاءها؛ لأن ذلك قد يؤخره عن الوصول إلى مقصده ويفوت عليه المصلحة، ونفي الضرر عن رب الدابة لو ألزمه المكري ورغب في الإقامة حتى تشفى؛ لأن السفر قد يجحف به ويقطعه عن عياله ويكلفه من النفقة الزائدة على نفسه وعلى الدابة.
- وإذا صح الأجير، أو صحت المرضع، أو الدابة في مدة الإجارة قبل الفسخ بالفعل فيلزم ببقية العمل ولا تفسخ الإجارة، وسقط من الأجرة عن المستأجر ما يقابل أيام المرض.
- وإذا حصل الفسخ قبل الصحة لم يلزم الأجير والظئر وصاحب الدابة عمل فيما بقي.
- وتتفسخ الإجارة إذا تبين للمستأجر أن الأجير شأنه السرقة؛ لأنها عيب يوجب الخيار في الإجارة والبيع، وبذلك علل الشيخ الدردير، فيخير المستأجر في الفسخ وعدمه، وهذا حيث كان استأجره للخدمة في بيته أو حانوته مما لا يمكن التحفظ فيه منه وأما لو إذا أجره دارا ليسكنها ونحو ذلك فلا تفسخ الإجارة بتبين سرقة لإمكان التحفظ منه.
- وتتفسخ الإجارة إذا تبين للمستأجر أن الأجير قد بلغ رشيدا، أي: حيث كان صغيرا وعقد عليه أو على سلعة وليه من أب أو وصي، أو حاكم كما إذا استأجره لخدمة مثلا ثلاث سنوات فبلغ رشيدا قبل انقضاء المدة، فإنه مخير بين الإبقاء لتمام المدة والفسخ.
- لكن يلزم في العقد عليه بقاء المدة بقيدين:
- الأول: أن يظن اليسير من المدة قبل تمام المدة وقت العقد فبلغ.
- الثاني: أن يبقى اليسير من المدة كالشهر.
- فبهذين القيدين لا خيار له. وإنما الخيار فيما إذا ظن وليه بلوغه فيهما أو لا ظن عنده مطلقا أي: بقي اليسير أو الكثير كان العقد عليه أو على السلعة أو ظن عدمه وبقي في العقد عليه الكثير.
- كما يلزم العقد إذا عقد ولي الصغير على سلع الصغير، كدابته وداره وغيرهما فيلزم فيما إذا ظن عدم بلوغه مطلقا، ولو بقي في المدة سنين بعد رشده على الأرجح.
- ومقابلة قول أشهب إن العقد على السلعة كالعقد عليه لا يلزمه إلا إذا ظن الولي عدم بلوغه وبقي مثل الشهر.

وأما سلع السفية إذا عقد وليه عليها فإنه لازم له إلا إذا رشد في أثناء مدة الإجارة بقي اليسير أو، ظن وليه رشده أم لا. إذ الرشد لا تعلم له غاية، وهو غير منضبط بالنسبة للسفيه.

وللسفيه أن يؤجر نفسه لعيشه، سواء ظن رشده أو ظن عدمه أو لم يظن شيء بقي اليسير أو بقي الكثير وهذا دون سلعة؛ لأنه محجور عليه بالنسبة لسلعة دون نفسه، ولا كلام لوليه في ذلك إلا أن يحابي، فلوليه الكلام من حيث المحابة. وكذلك لا كلام للولي إن رشد السفية؛ لأنه في نفسه كالرشيد، ولو آجره وليه لغير عيشه فله هو الفسخ لأن الولي لا تسلط له على نفسه. وإن آجر نفسه لعيشه فلا كلام له.

- وتتفسخ الإجارة بموت مستحق وقف أجر ذلك الوقف مدة معينة، ومات قبل تقضيها. وانتقل الاستحقاق فيه لمن في طبقته ولو ولده، وبقي يسير من المدة. فتتفسخ الإجارة ولو كان ذلك المستحق الذي آجر ناظرا-على الأصح-بخلاف نظرا غير المستحق أجر مدة معلومة بأجر المثل ثم مات فلا تتفسخ، ومقابل القول الأصح قول ابن شاش لا تتفسخ وهو قول ضعيف لأنه لا يعرف لغيره.

مالا تنفسخ به الإجارة

قال المصنف: ثم شرع في بيان ما يطرأ على الإجارة فقال: (وَفُسخت) الإجارة (بتلف ما يستوفى منه لا) بتلف ما يستوفى (به) المنفعة أشار بهذا إلى قولهم أن كل عين يستوفى منها فيهلاكها تنفسخ الإجارة كموت الدابة المعينة ، وكل عين تستوفى بها المنفعة فيهلاكها لا تنفسخ الإجارة على الأصح كموت الشخص المستأجر للعين المعينة ويقوم ورثته مقامه وأراد بالتلف التعذر أي تعذر استيفاء ما استؤجر عليه كأسر وصبي، وسكون وجع ضرر ، وعفو قصاص ، واستثنى من قوله لابه صبيين وفرسين بقوله (إلا صبي تعلم) بالإضافة وجر صبي لأنه مستثنى من ضمير به الواقع بعد نفي به فهو بدل منه ولو قال لا متعلم كان أولى ليشمل البالغ من الاختصار (ورضع) مات كل قبل تمام مدة الإجارة أو الشروع فيها (وفرس نزو) ماتت مثلاً قبل النزو عليها وأما موت الذكر المعين فداخل في قوله وفسخت بتلف ما يستوفى منه (و) فرس (روض) أي رياضة أي تعليمها حسن الجري فماتت ، أو عطبت فتنفسخ وله بحساب ما عمل وألحق بهذه الصور الأربعة حصد زرع معين ، وحرث الأرض بعينها وبناء حائط بدار فيحصل مانع من ذلك وليس لربه غيره فتنفسخ لتعذر الخلف ، وقيل لا بل يقال لربها ادفع جميع الأجرة ، أو انت بغيرها وهو ظاهر المصنف لاقتصاره على الأربعة التي ذكرها (و) فسخت الإجارة على (سنٍ لقلع) أي لأجل قلعها فالمستأجر عليه القلع ولو قال وقلع سن (فسكنت) أي ألمها كان أوضح (كعفو) ذي (القصاص) عن المقتص منه

فتفسخ الإجارة على القصاص لتعذر الخلف وهذا إن عفا غير المستأجر، وأما إن هذا المستأجر فتلزمه حينئذ الأجرة^(١).

(١) الشرح: بعد أن أشار المصنف إلى الأمور التي تنفسخ بها الإجارة وذكر قاعدة المذهب أن كل عين يستوفى منها المنفعة فبهلاكها تنفسخ الإجارة. وذكر عدة مسائل تتبني على هذه القاعدة - سبق ذكر هذه المسائل تحت عنوان فسخ الإجارة- و ذكر هنا أموراً لا تنفسخ بها الإجارة. (أخرت الحديث عن الأمور التي لا تنفسخ بها الإجارة إلى هذا الموضع حتى تكون جميع مسائل فسخ الإجارة في موضع واحد ويستطيع القارئ الإمام بها ، وقد نبهت إلى ذلك الأمور في بداية الكلام عن فسخ الإجارة).

وذكر المصنف قاعدة للأمور التي لا تنفسخ بها الإجارة وهي:

أن كل عين يستوفى بها المنفعة فبهلاكها لا تنفسخ الإجارة على الأصح كموت الشخص المستأجر للعين المعينة وقوم ورثته مقامه إلا في أربع مسائل: صبيان، وفرسان؛ وصبيا التعليم والرضاعة ، وفرسا النزو والرياضة. فحيث مات صبي التعليم والرضاعة انفسخت الإجارة ، ورجعا للمحاسبة ، وكذلك فرس النزو إذا استأجر الفحل على مدة معينة ثلاً، أو أربع سنوات مثلاً فحملت من مرتين ، أو ماتت قبل تمام المدة انفسخت الإجارة ورجعا للمحاسبة وكذلك إذا استؤجر لفرس يروضها ويعلمها كيفية الجري فماتت ، ويرجعان للمحاسبة وعلى القاعدة المذكور فإن الإجارة لا تنفسخ بموت الشخص المستأجر للعين المستأجرة، و يستثنى مما لا تنفسخ به الإجارة أربع مسائل تنفسخ الإجارة فيها بهلاك العين التي تستوفى بها المنفعة ، وهي: صبيان ، وفرسان ، صبيا للتعليم، والرضاعة، وفرسا فرس للنزو، والرياضة، فإذا استأجر شخصاً معلماً لتعليم صبي ويشمل البالغ، وقول المصنف "إلا صبي تعلم" أي لأن الصبي لا مفهوم له، وإنما خصه بالذكر؛ لأنه هو الذي شأنه التعليم. أو امرأة لترضع صبياً ، أو فحلاً للنزو على فرس أي استأجر صاحبها ذكراً ينزو عليها جمعة مثلاً، أو عشر مرات بدينار وحملت من مرة فتفسخ الإجارة ولرب الذكر من الأجر بحساب ما عمل ويشمل كل دابة نزو، أو مروضاً لترويض فرس، فإذا استأجر رب الفرس شخصاً يعلمها حسن السير فماتت قبل تعليمها فإن الإجارة تنفسخ وله بحساب ما عمل ؛ فإذا مات صبي التعليم أو الرضاعة انفسخت الإجارة ورجعا للمحاسبة.

هذه المسائل الأربع المستثناة عند سحنون ، وابن أبي زيد القيرواني ، وقال ابن عرفة له الأجرة لا تنفسخ في المسائل الأربع ، وله جميع الأجرة ؛ لأن المانع ليس من جهته .
وألحق بهذه الأربعة حصد من استأجر شخصا لحصد زرع معين ، أو وحرث أرض بعينها ليس لربها غيرهما ، أو بناء حائط بدار ، فيحصل مانع من جهة رب الأرض ، أو الزرع ، أو الحائط ، كأن تلف الزرع ، أو يبست الأرض ، أو تفقد مواد البناء ، وليس لرب الأرض غيرها فتتفسخ الإجارة لتعذر الخلف ، أما إن كان له خلف استأجره فيها ، أو يدفع له الأجرة بتمامها ولا تنفسخ الإجارة .

وقيل : لا تلحق هذه المسائل بالمسائل الأربعة المستثناة ، وقيل لا تنفسخ الإجارة ، ويقال لربها : ادفع الأجرة كاملة ، أو انت بغيرها إن كان له غيرها .
وعلى كل فالمسائل المستثناة والمسائل المختلف في إلحاقها بها ن مقيدة بكونها من جهة المستأجر ، فهي من قبيل ما يستوفى به . أما إذا كان المانع من جهة المؤجر على الحصد ، أو الحرث ، أو البناء ، كان ذلك من قبيل تعذر ما يستوفى منه ، وليس الكلام هنا فيه .

- لا تنفسخ الإجارة بإقرار المالك للذات المؤجرة بأن باعها أو وهبها أو أجرها لأخر ر قبل الإجارة المذكورة ، ونازعه المكثري ولا توجد معه بينة لاتهامه بنقضها ، ويلزمه الإقرار فيأخذها المقر بعد انتهاء المدة وله الاكثر من المسمى الذي أكرت به ، وكراء المثل على المقر .

- وقول المصنف "أو خلف" بضم الخاء ، وسكون اللام اسم مصدر بمعنى تخلف أي : لا ينفسخ الكراء بتخلف رب دابة معينة ، أو غير معينة عقد عليها شخص لملاقاة رجل أو ليشيع بها رجلا فتخلف ربا عن الاتيان بها في ذلك اليوم أو الشهر ، وإن فات ما يقصده ويروم إليه ، ما لم يكن الزمن معيناً ولم يكن حجا . ووجه عدم الفسخ عند عدم تعيين الزمن وعدم الحج أن المكثري يمكن أن يصل إلى غرضه في أي وقت في السنة .

- أما إذا كان الوقت معيناً أو حجا فلم يأت المكثري بالشيء المكثري إلى أن أنقضى الزمن المعين ، أو فات الحجب إن الكراء ينفسخ .

الدراسة الموضوعية

إعداد

أ.د/ طاهر معتمد خليفة السيسي (أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية

الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ)

د/ محمود محمد الشاعر (أستاذ مساعد متفرغ بكلية الشريعة

والقانون بطنطا)

د/ أبو اليزيد أبو اليزيد محمد (أستاذ مساعد ورئيس قسم الفقه بكلية

الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق)

- لا تنفسخ الإجارة بظهور فسق المستأجر للدار يضر بها أو بالجار ، وإنما يؤمر بالكف.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن الفقه الإسلامي عماد الحق، ونظام الخلق، ووسيلة السعادة الأبدية،
ولباب الرسالة المحمدية، من تحلى بلباسه فقد ساد، ومن بالغ في ضبط معالمه
فقد شاد، وهو الميزان الذي توزن به تصرفات الناس، والمرآة التي ترتسم فيها
أوضاع حياتهم، قويمة كانت أو سقيمة.

هذا والفقه المالكي شعاع نور يكتمل به صرح الفقه الإسلامي بصفة عامة،
ولا ينكر هذه الحقيقة إلا مكابر مخادع منكر للحقيقة.

ماضِرَّ شَمْسَ
الضَّحَى فِي الْأُفُقِ طَالِعَةً

أَنْ لَا يَرَى ضَوْعَهَا مَنْ لَيْسَ
ذَا بَصَرٍ

وقد اقتبسنا - في هذه الدراسة - جزءًا من الفقه المالكي جمعناه وأعدناه في صورة متفرقات من أبواب الفقه المختلفة، ليكون كالإشارة على الطريق يهتدي بها الدارسون والدارسات للمذهب المالكي في جامعتنا العريقة (جامعة الأزهر) - بالطريقة التي يسلكها المُحدِّثون من مدرسي الفقه الإسلامي - وتنقسم الدراسة إلى قسمين: دراسة موضوعية تمتاز بعباراتها السهلة ، وعرضها الشيق ، وصياغتها الدقيقة ، وأحكامها الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة النبوية وغيرهما من الأدلة المعتمدة ، والموثقة من كتب الفقهاء الأصيلة، وقد جاء ترتيب موضوعات الدراسة الموضوعية على النحو التالي:

الشركة - المزارعة - الإقرار - أحكام الدماء - البغى - الحراة.

هذا وقد اختص كل أستاذ بإعداد وكتابة بعض الأبواب الواردة في الكتاب ،
فقد أعد بابي الشركة والبغي أ.م/ محمود محمد الشاعر ، وأعد أبواب المزارعة
والإقرار وأحكام الدماء أ.د/ طاهر معتمد السيبي، وأعد باب الحراية، وكذا
الأهداف العامة من دراسة تلك الأبواب، والملخص الذي يعقب كل باب منها أ.م/
أبو اليزيد أبو اليزيد محمد.

والله نسأل أن ينفع به القارئ والدارس، وأن يلهمنا الصواب ويجنبنا الذلل،
إنه سميع مجيب.

الباب الأول
الشركة وأحكامها

الهدف من دراسة باب الشركة

يتوقع من الطالب والطالبة بعد دراسة باب الشركة أن يصل إلى الأهداف

التالية :

■ معرفة معنى الشركة بمدلولها العام ، والخاص ، وحكمها ، وأدلة مشروعيتها

■ الوقوف على الحكمة من تشريع الشركة.

■ معرفة أنواع الشركة ، وحقيقة كل نوع منها ، وما يجوز منها ، وما لا

يجوز .

■ العلم بكيفية اقتسام الربح ، أو تحمل الخسارة بين شريكين أو أكثر .

■ معرفة كيفية فض النزاع بين الشركاء ، وطريقة التقاضي فيما بينهم .

■ تطبيق الأحكام الشرعية التي تعلمها الطالب على الشركات الحديثة

لمعرفة صحتها من فاسدها .

■ إبراز سمو الشريعة الإسلامية على غيرها من الشرائع .

الشركة وأحكامها

الشركة: بكسر الشين المعجمة وسكون الراء على وزن نعمة، وبفتح الشين وكسر الراء (الشركة) على وزن نِقة، وبفتح الشين وسكون الراء (الشركة) على وزن رَحمة والأولى أفصح.

وهي لغة: الاختلاط: أي خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر.

واصطلاحاً: هي إذن في التصرف لهما مع أنفسهما.

ومعنى: " إذن في التصرف " أي يأذن كل واحد منهما أو منهم للآخر في أن يتصرف في مال، وهو كالجنس يشتمل الوكالة والقراض.

ومعنى " لهما " قيد أخرج الوكالة من الجانبين بأن يوكل صاحبه في أن يتصرف في متاعه لأنه لم يقع إذن كل منهما لصاحبه في التصرف له ولصاحبه بل إذن كل منهما لصاحبه أن يتصرف في الشيء الموكل فيه للموكل وحده.

ومعنى: " مع أنفسهما " قيد ثان أخرج القراض من الجانبين؛ لأن التصرف للعامل فقط دون رب المال ^(١).

والمعنى: أن الشركة هي إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في أن يتصرف في ماله له ولصاحبه مع تصرفهما لأنفسهما أيضاً.

فإن قيل: تصرف الإنسان في مال نفسه لا يحتاج فيه لإذن.

فالجواب: أن كل واحد باع بعض ماله ببعض مال الآخر على وجه الشيوخ فيحتاج في تصرفه في ماله للإذن لذلك.

مشروعية الشركة.

الشركة مشروعة ومشروعيتها ثابتة بالكتاب، والسنة، والإجماع

(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣ / ٣٤٨ .

أما الكتاب:

الأول: فقله تعالى: (فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) النساء: ١٢ .

فجعل الثلث شركة بين الإخوة لأم الإناث والذكور سواء .

الثاني: قوله تعالى: (وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ) ص: ٢٤ .

ومعنى الخطاء: الشركاء.

وأما السنة فمنها:

الأول: ما روي عن السائب المخزومي قال للنبي (ﷺ): " كنت شريكي في

الجاهلية فكنت خيرَ شريكٍ لا تُداريني ولا تُماريني" ^(١)

وقوله (لا تداريني) من درأ بالهمز إذا دفع ، وقوله (ولا تماريني) من المراء

وهو الجدل.

والمراد: أنه كان شريكا موافقا لا يخالف ولا ينازع.

الثاني: ما روي عن أبي هريرة . رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ

: قال الله تعالى: " أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانهُ

خرجت من بينهما" ^(٢) .

والمعنى: أن الله مع الشريكين أو الشركاء بالحفظ والإعانة يمددهما بالمعونة

في أموالهما، وينزل البركة في تجارتها، فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت البركة

والإعانة عنهما.

(١) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه. سنن ابن ماجه تحقيق محمود نصار ٨٧/٣ دار الكتب العلمية.

(٢) الحديث أخرجه أبو داود والحاكم. انظر الدليلين: فتح الرحيم على فقه الإمام مالك بالأدلة ١٣١/٢.

الثالث: وما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال "يد الله مع الشريكين ما لم يَتَخَاوُنَا" (١).

الرابع: وما روي أن النبي ﷺ شرك بين أصحابه في سهام خيبر، وفي الأزواد في السفر، واشترك رسول الله ﷺ وأبو بكر وعلي في أزوادهم يخلطونها بينهم .

وأما الإجماع :

فقد أجمع المسلمون من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا على جواز الشركة بين الناس في الجملة .

حكمة مشروعيتها:

تمكين الناس من التعاون في استثمار أموالهم وتتميتها، وإقامة المشاريع المختلفة سواء صناعية أو زراعية أو تجارية، والتي يتعذر على الفرد الاستقلال بالقيام بها.

أركان الشركة.

للشركة أركان ثلاثة نوضحها فيما يلي:

١- العاقدان ويشترط فيهما:

أن يكونا من أهل التصرف، وهو الحر البالغ الرشيد الذي يصح منه التوكل؛ لأن العاقدین للشركة كل واحد منهما وكيل عن صاحبه وموكل لصاحبه، فمن جاز له أن يوكل ويتوكل جاز له أن يشارك، ومن لا يجوز له أن يوكل ويتوكل فلا يجوز له أن مشاركة.

(١) الحديث أخرجه الدارقطني ٣٥/٣ بلفظ "يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما".

فلا تصح من عبد إلا بإذن سيده، أو كان العبد مأذوناً له في التجارة من قبل، ولا تصح من الصبي، ولا من المجنون، ولا من السفیه.

٢- المعقود عليه وهو المال والأعمال:

فتصح الشركة بالنقدين الذهب والفضة من كل من الشريكين أو من أحدهما ومن الآخر عوض، كما تصح بعرض من كل واحد منهما سواء اتفقا جنساً أو اختلافاً، كصوف وصوف أو صوف وحريز.

والعرض المشارك به من الجانبين أو أحدهما يعتبر رأس مال بالقيمة يوم أحضر للشركة أي يوم العقد، فإن استوت قيمة العرضين، أو قيمة العرض والعين المقابلة له فالشركة بالنصف، وإلا فبقدر الاختلاف كما لو كانت قيمة أحد العرضين عشرة والآخر عشرون، فتكون بالثلث والثلثين هذا إن صحت الشركة، فإن وقعت فاسدة فتعتبر القيمة يوم البيع.^(١)

٣- الصيغة: وهي اللفظ الدال على الشركة عرفاً من قول كأن يقولوا اشتركنا، أو يقول أحدهما ويسكت الآخر راضياً به، أو شاركني ويرضى الآخر، ومثال الفعل كخط أحد المالين معاً والعمل فيهما سواء انضم لذلك قول أم لا.

(١) الشرح الكبير ٣/٣٤٨، ٣٤٩، جواهر الإكليل ٢/١١٥، ١١٦، الشرح الصغير ٣/٤٥٧.٤٦٠، حاشية الخرشي ٦/٣٣٦.

أقسام الشركة

تنقسم الشركة إلى ثلاثة أقسام:

الأول : شركة الأموال.

الثاني: شركة الأبدان.

الثالث: شركة الوجوه.

واليك بيان كل قسم من هذه الأقسام.

أولاً: شركة الأموال.

وهي عقد مالكين لمالين أو أكثر على التجر فيهما معاً.

بمعنى أن كلا منهما يتاجر في المالين مع صاحبه ولو كان كل واحد في مكان منعزل عن الآخر؛ لأن ما حصل من ربح أو خسارة يكون بينهما، وتسمى شركة التجر، وتتنوع إلى أنواع خمسة:

شركة المفوضة، وشركة العنان، وشركة الجبر، وشركة الذم، وشركة المضاربة .

النوع الأول: شركة المفوضة.

وهي أن يفوض كل واحد منهما إلى الآخر التصرف والبيع والشراء حضر الآخر أو غاب، وتكون يده كيده، ولا يكونان شريكين إلا بقدر ما يعقدان الشركة عليه دون ما ينفرد أحدهما بملكه. (١)

وسميت بشركة المفوضة:

لتفويض كل منهما المال لصاحبه، أو لشروعهما في الأخذ والعطاء من قولهم تفاوض الرجلان في الحديث أي شرعا فيه. (١)

(١) المعونة ٢/١٣٩، التلقين: ٤١٤.

حكمها: جائزة على ما يتفاوضان عليه من الأجزاء.

وفي شركة المفاوضة إطلاق من الشريكين في التصرف بأن يجعل كل واحد منهما لصاحبه حق التصرف في حضوره وغيبته بالبيع والشراء والكرء والاكتراء وغير ذلك مما تحتاجه الشركة.

الأشياء التي يجوز لأحد شريكي المفاوضة فعلها من غير إذن شريكه.

١- التبرع بشيء من مال الشركة بغير إذن صاحبه كالهبة والخطيطة من الثمن بالمعروف إن كان في ذلك استئلاف قلوب الناس للشراء منه، وكذلك يجوز التبرع بشيء خفيف من مال الشركة ولو كان بغير استئلاف، كإعارة فأس وحبل وإناء ودلو ورحى، ونحو ذلك.

٢- الإبضاع من مال الشركة ومعناه: أن يدفع مالاً من مال الشركة لمن يشتري به بضاعة معلومة من بلد كذا ويرسلها، أو يقدم بها

للشريكين إن اتسع المال بأن يكون المال يحتاج فيه إلى مثل ذلك وإلا منع.

٣- الإيداع لمال الشركة أو بعضه عند أمين لعذر كهدم جدار أو حدوث جار سوء، فإن لم يكن الإيداع لعذر وضاع مال الشركة ضمن المودع نصيب شريكه مما أودعه.

٤- المضاربة بأن يدفع بعض المال لمن يعمل فيه مضاربة بجزء معلوم من الربح ويكون جزء الربح الآخر شركة، ويشترط فيه أيضاً اتساع المال وإلا منع.

٥- مشاركة أجنبي عن الشركة في شيء معين من مال الشركة، والمراد بالمعين أن يشارك ببعض مال الشركة بحيث لا تجول يد الأجنبي في جميع مال الشركة، سواء كانت الشركة في البعض المعين شركة مفاوضة أو غير مفاوضة.

(١) حاشية العدوي بهامش الخرشى ٣٤٤/٦.

٦- قبول المبيع المعيب إذا باعه هو أو شريكه في حالة رده بعيب قديم ظهر للمشتري بعد شرائه من أحد الشريكين أو منهما معاً سواء رضي شريكه أو أبى.

٧- قبول رد سلعة للشركة بثمنها الذي باعها به هو أو شريكه، وبيع سلعة مشتركة بمثل ثمنها إذا خاف كسادها أو خسرها.

٨- الإقرار بدين من مال الشركة، فإنه يلزم ما أقر به الآخر بشرط أن لا يكون إقراره لمن يتهم عليه بالكذب في إقراره له بأن كان أجنبياً أو بعيد القرابة، فإن أقر لمن يتهم عليه كأبويه، وأولاده، وصديقه فلا يقبل إقراره.

٩- بيع سلعة من مال الشركة بثمن إلى أجل معلوم، فإن باع بثمن إلى أجل معلوم وفلس المشتري، أو مات معسراً ضاع الثمن عليهما معاً لا على البائع وحده.

أما الشراء إلى أجل، فإما أن يكون بإذن من شريكه أولاً، فإن كان بإذن شريكه وكانت سلعة معينة جاز؛ لأنه صار بالإذن له وكيلاً عنه فيما يخصه فكان بمنزلة رجلين اشتريا سلعة بينهما بثمن إلى أجل وهذا جائز.

وإن كانت السلعة غير معينة بأن قال له شريكه كل سلعة وجدت وأعجبك فاشتريها وأجل الثمن فلا يجوز؛ لأنها من شركة الذمم وهي ممنوعة، وإن كان الشراء إلى أجل بغير إذن شريكه خير شريكه بين القبول والرد، فإن رد كان الثمن على المشتري وحده؛ لأن الربح له والخسارة عليه.

١٠- استقلال أحد الشريكين بأخذ مال من أجنبي ليعمل فيه قراضاً على أن الربح والخسارة له وعليه إن كان بإذن من شريكه؛ لأن مال القراض خارج عن الشركة، فكأنما أجر نفسه بجزء من الربح، ويشترط لهذا الجواز ألا يشغله ذلك عن العمل في الشركة، أو يأذن له شريكه.

١١- استقلال أحد الشريكين في التجارة بوديعة كانت عنده بالربح والخسارة دون الشريك الآخر، إلا إذا علم الشريك الآخر بتعديه في الوديعة فالربح لهما والضمان عليهما^(١).

يشترط لصحة شركة المفاوضة:

- ١- أن يكون العمل بينهما بقدر المالين .
- ٢- أن يكون الربح والخسارة أيضاً بقدر المالين سواء دخلا على ذلك أو سكتا.

يد الشريك يد أمانة.

اتفق الفقهاء على أن يد الشريك في المال يد أمانة كالوديعة؛ لأنه قبض المال بإذن صاحبه، لا لأجل أن يدفع ثمنه، كما في المقبوض على سوم الشراء، فإنه مقبوض لأجل أن يدفع الثمن، ولا لأجل التوثق به كما في الرهن، فإنه مقبوض لأجل التوثق بدينه .

وبناء عليه فإنه إذا هلك المال في يد الشريك من غير تقييد لم يضمن؛ لأنه نائب عن شريكه في الحفظ والتصرف، فكان الهالك في يده كالهالك في يد شريكه، ويقبل قوله بيمينه في مقدار الربح والخسران وضياح بعض المال أو كله، ولو من غير تجارة ويضمن بالتعدي أو التقصير، كما في سائر الأمانات.

ما تفسد به شركة المفاوضة.

تفسد شركة المفاوضة إذا وقتت بشرط التفاوت في الربح عند العقد ويفسخ العقد إن اطلع عليه قبل العمل .

(١) الشرح الكبير ٣/٣٥٢، الشرح الصغير وبلغه السالك ٣/٤٦٤-٤٦٨، الخراسي ٦/٣٤٥-٣٤٧، مواهب الجليل وبهامشه التاج والإكليل ٥/١٢٦-١٢٩، جواهر الإكليل ٢/١١٦، ١١٧.

أما إن اطلع عليه بعد العمل قُسم الربح على قدر المالين، ويرجع كل منهما على صاحبه بما يثبت له عند الآخر من أجر عمل أو ربح، كما لو أخرج أحدهما عشرين مثلاً، والآخر عشرة وشرطاً التساوي في الربح والعمل .
فيرجع صاحب العشرين على صاحب العشرة بسدس الربح ليكمل له ثلثي الربح، ويرجع صاحب العشرة على صاحب العشرين بسدس أجره عمله.
فإن شرطاً التساوي في الربح فقط، وكان العمل بقدر المالين، رجع صاحب العشرين على صاحب العشرة بسدس الربح، ولا رجوع لصاحب العشرة بشيء، وإن شرطاً التساوي في العمل فقط رجع صاحب العشرة بسدس أجره عمله، ولا رجوع لصاحب العشرين بشيء^(١).

كما تفسد الشركة إذا استوى المالان وشرطاً التفاوت في الربح .

التبرع من أحد الشركاء للآخر.

يجوز لأحد الشريكين أن يتبرع لشريكه بشيء من الربح أو العمل بعد وقوع العقد صحيحاً؛ لأنه من باب المعروف والصلة .

كما يجوز أن يسلفه شيئاً أو يهبه شيئاً بعد عقد الشركة الواقع صحيحاً، بناء على أن اللاحق للعقود ليس كالواقع فيها، أما قبل العقد فليس له ذلك .

لمن القول عند التنازع.

١- إذا ادعى أحد الشريكين تلف بعض مال الشركة الذي بيده أو خسره وكذبه شريكه فالقول لمدعي التلف؛ لأنه أمين ما لم يتهم أي يتهمه شريكه، فإن اتهم صدق بيمين ما لم يظهر كذبه بالبينة أو القرائن كدعواه التلف وهو في

(١) الشرح الكبير ٣/٣٥٢، ٣٥٣، الخرشي ٦/٣٤٥-٣٤٧، جواهر الإكليل ٢/١١٦، ١١٧،

مواهب الجليل وبهامشه التاج والإكليل ٥/١٢٦-١٢٩ .

رفقة لا يخفي عليهم ذلك ولم يعلم به أحد منهم، وكدعواه الخسارة في سلعة مرغوب فيها سعرها مشهور، فإن كان كذلك غرم .

٢- إذا ادعى أحدهما شراء شيء لنفسه خاصة أو لعياله وقال الآخر: بل اشتراه للشركة، فالقول لمن ادعى أنه اشتراه لنفسه إذا كان لائقاً به، فإن كان غير لائق، أو كان عروضاً أو حيواناً فالقول لمن ادعى أنه للشركة .

٣- إذا ادعى أحد الشريكين أن له ثلثي المال وادعى الآخر أن لكل النصف فالقول قول مدعي النصف فيقسم المال بينهما مناصفة بعد حلفهما نظراً لتساويهما في الحوز، والقضاء بالحوز لا يستقل الحكم به بدون يمين، وهذا قول أشهب .

وقال ابن القاسم: لكل ما سلم له وقسم السدس بينهما، وحينئذ فيأخذ مدعي الثلثين النصف ونصف سدس، ومدعي النصف الثلث ونصف سدس وهذا إذا كان التنازع من اثنين وإلا قسم المال على عدد الرؤوس، ويحمل هذا على ما إذا كانا حييين .

أما إذا مات أحد الشريكين فأراد الورثة المفاصلة من شريكه فقالوا: لموروثنا الثلثان، وقال الشريك: بل المال بيني وبين مؤرثكم على النصف فيحملان على النصف بعد حلف كل على ما ادعاه .

٤- إذا ادعى أحد الشريكين على شيء رآه بيد شريكه أنه للشركة، وأنه من جملة سلع التجارة، وادعى الآخر الاختصاص فالقول قول من ادعى أنه للشركة إذا شهدت البينة أنهما يتصرفان تصرف المتفاوضين سواء شهدت البينة على إقرارهما بالمفاوضة أولاً .

أما إن شهدت البينة لمدعي الاختصاص أنه ورثه أو وهب له فإنه يختص به ولا يكون للشركة؛ لأن الأصل عدم خروج الأملاك عن يد أصحابها سواء قالت البينة إن الإرث أو الهبة سابقان على المفاوضة ولم يدخلها فيهما، أو قالت:

لا نعلم هل المفاوضة سابقة على الإرث أو الإرث سابق عليها، أو قالت: إن الإرث متأخر على المفاوضة، أو لم تزد شيئاً على الشهادة بأنه قد ورثه أو وُهب له.

أما إن قالت: إن الإرث سابق على الشركة، ولم تشهد بعدم الدخول فيها، فإن تلك السلعة المتنازع فيها تكون على الشركة ^(١).

حكم النفقة والكسوة من مال الشركة .

إذا أنفق كل من المتفاوضين أو اكتسب الغيت نفقتهما وكسوتهما من مال الشركة بشرطين:

الأول: أن يتساوى المالان، فإن لم يتساويا فإن كل واحد ينفق على قدر حصته أي قدر ماله.

الثاني: أن يتساويا أو يتقاربا في النفقة والكسوة، ولا فرق بين أن يكونا في بلد واحد أو في بلدين مختلفي السعر، فإن لم يتساويا فكل واحد على قدر ماله .

كما تلغى النفقة والكسوة على عيالهما ^(٢) إن تقاربا عيالاً ونفقة والتقارب يكون في السن، والعدد بقول أهل المعرفة، ويشترط في هذه المسألة كون المال بينهما مناصفة.

فإن لم يتقاربا بان اختلافاً عدداً أو سناً اختلافاً بيناً أو كان المال بينهما على الثالث والثلثين حسب ما أنفقه كل واحد، ورجع ذو القليل على ذي الكثير بما يخصه لئلا يأكل من مال الشركة أكثر من حقه.

(١) الخرشي ٦ / ٣٤٩ - ٣٥١ ، الشرح الكبير ٣ / ٣٥٤ ، الشرح الصغير ٣ / ٤٦٩ - ٤٧١ .

(٢) المراد بعيال الرجل : من يعولهم ويمونهم فيشمل الزوجة والأولاد والخادم.

وقال الأجهوري: تلغى مطلقاً تقارب الإنفاق أولاً، تساوى المالان أو لا^(١).

النوع الثاني: شركة العنان.

العنان في اللغة: بكسر العين وتخفيف النون مأخوذ من عَنان الدابة وهو ما تقاد به .

واصطلاحاً: هي أن يشترط كل واحد من الشريكين على صاحبه أن لا يتصرف في شيء من مال الشركة إلا بإذن شريكه ومعرفته .
فكأنه أخذ بعنانه أي بناصيته أن لا يفعل فعلاً إلا بإذنه.
حكمها: جائزة بالإجماع ، والشرط لازم .

فلو تصرف أحد الشركاء بدون إذن الآخر كان له رده، وأما لو دخلا على أن لأحدهما التصرف المطلق دون الآخر، فهل تكون شركة مفاوضة في حق من أطلق له التصرف، وشركة عنان في حق من قيد له التصرف، أو تكون شركة فاسدة.

قولان الأظهر أنها فاسدة ؛ لأن الشركة يقتصر فيها على ما جاء فيها، ولأن هذه فيها تفاوت في العمل^(٢).

وهذا النوع من الشركات هو السائد بين الناس؛ لأن شركة العنان لا يشترط فيها المساواة لا في المال ولا في التصرف، فيجوز أن يكون مال أحد الشريكين أكثر من الآخر كما يجوز أن يكون أحدهما مسؤولاً عن الشركة والآخر غير مسئول .

ما يجوز في شركة العنان وما لا يجوز.

(١) الشرح الكبير ٣ / ٣٥٧ ، الشرح الصغير ٣ / ٤٧١ .

(٢) الشرح الكبير ٣ / ٣٥٩ ، الخرشي ٦ / ٣٥٥ .

- ١- يجوز لصاحبي طَيْرَيْنِ أن يتفقا على الشركة في الفراخ الحاصلة بينهما مناصفة لا في البيض، ونفقة كل على ربه إلا أن يتبرع أحدهما بها، ومحل جواز الاشتراك المذكور إن كان من الطير الذي يشترك في الحضن الذكر مع الأنثى كالحمام لا الدجاج والأوز حيث يحتاج للأم فقط، ولا غير الطير كحمر وخيل، ولا يجوز أن يأتي ببيض لشخص آخر ويقول اجعله تحت دجاجتك والفراخ بيننا. فإن حدث فالحكم أن الفراخ لصاحب الدجاجة ولصاحب البيض مثله، كمن أتى لآخر بقمح وقال: ازرعه بأرضك، فإن له مثله والزرع لصاحب الأرض.
- ٢- يجوز للرجل أن يقول لصاحبه اشتر السلعة الفلانية وانقد عني ما يخصني في ثمنها؛ لأنه معروف صنعه أحدهما مع صاحبه من غير عوض وهو تسليفه الثمن وكونه وكيلاً عنه في الشراء.
- ومحل الجواز إن لم يقل صاحبه (المنقود عنه) وأنا أتولى بيع حصتك، فإن قال ذلك منع؛ لأنه سلف جرّ نفعاً، ومثل قوله: (وأنا أتولى بيع حصتك) (أنا أجرها لك) لوجود علة المنع وهي السلف الجار منفعة، فإن وقع كانت السلعة بينهما ولا يتولى البيع، فإن تولاه كان له جُعل مثله.
- ٣- يجوز للرجل أن يقول لصاحبه اشترى هذه السلعة (لي ولك) وأنا أسلفك ما يخصك في ثمنها؛ لأنه معروف صنعه من غير عوض إلا أن يكون المشتري ذا خبرة ووجاهة وبصيرة بالبيع والشراء فإن كان كذلك فلا يجوز؛ لأنه سلف جر منفعة^(١).

صور تجتمع فيها الشركة والوكالة:

إذا قال الرجل لصاحبه اشترى السلعة الفلانية لي ولك والثمن بيننا فاشترها فهي لهما شركة، وكان المشتري وكيلاً عن صاحبه في نصف السلعة وكالة

(١) الخرشي ٦/ ٣٥٥-٣٥٨، الشرح الصغير وبلغة السالك ٣/ ٤٧١-٤٧٣.

قاصرة لا تتعدى لغير الشراء، فلا يصح له أن يبيع نصف شريكه إلا بإذنه له في ذلك.

وإذا كان وكيلًا في الشراء كان له طلبه بالثمن الذي أداه عنه لبائعها وليس له حبسها في نظير الثمن سواء قال له (وانقد عني) أو لم يقل، إلا إذا قال له: (اشترها لي ولك وانقد عني واحبس السلعة إلى أن تقبض ثمنها مني) فإن له حبسها حينئذ وتكون بمنزلة الرهن فيفرق فيها بين ما يغاب عليه فيضمنها إلا أن يقيم بينة على ما ادعاه، وما لا يغاب، عليه فالقول قوله بيمين، ويكون أحق بها في حالة الفلس أو الموت^(١).

النوع الثالث: شركة الجبر.

هي التي قضى بها عمر - رضي الله عنه - وقال بها مالك وأصحابه. ومعناها: أن من اشترى سلعة من سوقها طعاما أو غيره للتجارة، والحال أن غيره من تجار تلك السلعة حاضر لشرائها وهو ساكت لم يتكلم، وسواء كان هذا الحاضر الساكت من أهل ذلك السوق الذي بيعت به تلك السلعة أم لا، وأراد ذلك الحاضر الدخول في تلك السلعة، فإنه يجاب إلى ذلك.

شروط شركة الجبر.

يشترط فيها ستة شروط : ثلاثة في الشيء المشتري وهي :

- ١- أن يشتريه بسوقه المعد له ولو لم يكن الشاري من أهله .
- ٢- أن يكون شراؤه للتجارة احترازاً مما إذا اشتراه لا للتجارة بل للقنية أو إقراء ضيف أو عرس أو إهداء، فلا يشارك ويصدق المشتري بيمين.
- ٣- أن تكون التجارة به في البلد. احتراز مما إذا اشتراه ببيته أو بدكان ليس في سوقه .

(١) الخرشي ٣٥٦/٦، ٣٥٧، الشرح الصغير ٤٧٢/٣ .

وثلاثة في المشترك بفتح الراء وهي:

- ١- أن يكون حاضراً في السوق وقت الشراء، فإن اشتراها في غيبته أو كان حاضراً وزايد فيها فلا جبر .
 - ٢- أن يكون من تجار تلك السلعة التي بيعت بحضرته .
 - ٣- ألا يتكلم بمزايدة، فإن تكلم بمزايدة فلا جبر .
- ومحل الجبر مالم يبين المشتري للحاضرين من التجار أنه لا يشارك أحدا منهم، ومن شاء أن يزيد في ثمن السلعة فليفعل فإن بين فليس لهم جبره على المشاركة في السلعة.
- وإن توفرت الشروط وجب الجبر ولو طال الأمر حيث كان ما اشترى باقياً، فإن أبى المشتري أن يشارك غيره في السلعة، فإنه يوضع في السجن حتى يفعل رفقا بأهل السوق، وإن طلب المشتري المشاركة وأبى غيره أن يشاركه فإنه يقضي على من أبى الشركة مع المشتري في تلك السلعة إذا ظهرت الخسارة على المشتري^(١) .

(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣/٣٦٠، الخرشي ٦ / ٣٥٨، بلغة السالك بهامش الشرح الصغير ٣ / ٤٧٣.

النوع الرابع: شركة الذمم.

معناها: أن يتفقا اثنان أو أكثر على أن يشتريا شيئاً بينهما في ذمتها بلا مال يخرجانه من عندهما ثم يبيعان ذلك وما خرج من الربح فبينهما .

حكمها: فاسدة سواء اشتريا ذلك الشيء معاً أو اشتراه أحدهما دون صاحبه.

علة الفساد: أنها من باب تحمل عني وأتحمل عنك وأسلفني وأسلفك فهو من باب ضمان بجعل وسلف جر منفعة .

أما لو اشتريا شيئاً معيناً بثمن معلوم في ذمتها وتساويا في التحمل لجاز .

النوع الخامس : شركة المضاربة.

المعنى اللغوي للمضاربة:

المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة قال تعالى : (وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) المزمّل : ٢٠ .

ويحتمل أن يكون من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم .

والمضاربة والقراض اسمان لمسمى واحد، غير أن القراض لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق .

المعنى الاصطلاحي:

دفع مالك مال من نقد مضروب مسلم معلوم لمن يتجر به بجزء معلوم من ربحه قل أو كثر بصيغة .

حكمها: اتفق الفقهاء على جواز عقد المضاربة وأنه عقد غير لازم وأنه مستثنى من الغرر والإجارة المجهولة، وإن اختلفوا في أحكام أخرى تتعلق بفسخ العقد بعد العمل .

حكمة مشروعيتها:

التيسير على الناس أو تبادل المنافع التي أحلها الله، فرب ذي مال لا قدرة له على التجارة ورب قادر عليها لا مال له، فأجازت الشريعة الإسلامية هذا

اللون من التعامل ليتحقق التعاون على الخير بين صاحب المال وصاحب العمل.

دليل مشروعية المضاربة.

مشروعية المضاربة ثابتة بإشارات القرآن الكريم، وثابتة بالسنة، والآثار، والإجماع، والمعقول :

أما إشارات القرآن الكريم ففيما يأتي:

١- قوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ الْبَقْرَةَ : ١٩٨ .

٢- قوله تعالى: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

المزمل : ٢٠ .

وجه الدلالة :

أن في المضاربة ابتغاء من فضل الله ذلك أن صاحب المال حين يعطي المضارب - العامل - المال ليعمل فيه فإنما يبتغي فضلاً من الله والمضارب - العامل - حين يأخذ المال ويتجر به فإنما يسعى لتحصيل فضل الله.

وأما السنة فمنها:

١- ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: عامل النبي ﷺ

أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر أو زرع ^(١) .

٢- وما روي عن صهيب - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: ثلاث

فيهن البركة : البيع إلى أجل ، والمقارضة ، وخطط البر بالشعير للبيت لا للبيع ^(٢) .

وجه الدلالة:

أن الرسول ﷺ دفع الأرض إلى أهل خيبر على أن يعملوا فيها بأموالهم مساقاة ومزارعة ولم يدفع إليهم شيئاً وهذا من باب المشاركة، وهو نظير

(١) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه - سنن ابن ماجه رقم (٢٤٦٧) .

(٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : ٥ / ١٧ .

المضاربة؛ لأن الأرض نظير رأس المال في المضاربة، والمساقاة والمزارعة من جنس الشركة يستويان في المغنم والمغرم، والمضاربة كذلك ^(١).

وأما الآثار فمنها:

١- ما روي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرّا على أبي موسى الأشعري، وهو أمير البصرة فرحب وسهل ثم قال: بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماء فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، ثم تبعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما، فقالا: وددنا ذلك ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال فلما قدما باعا فأربحا فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما ؟ قالوا: لا، فقال عمر ابن الخطاب : ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما أديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه فقال عمر: أدياه فسكت عبد الله وراجع عبيدُ الله فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً فقال عمر: قد جعلته قراضاً، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه ، وأخذ عبد الله، وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال ^(٢).

٢- وما روي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضاً يعمل فيه على أن الربح بينهما ^(٣).

(١) سبل السلام تحقيق خليل هراس : ٣ / ١٠٢ دار الزهراء .

(٢) الأثر أخرجه مالك في الموطأ : المنتقى للباجي (١٣٧٧) .

(٣) الأثر أخرجه مالك في الموطأ - أوجز المسالك إلى موطأ مالك ١١ / ٤٠٦ .

٣- وما روي عن حكيم بن حزام أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد، ولا يبتاع به حيواناً، ولا يحمله في بحر فإن فعل شيئاً من ذلك فقد ضمن ذلك المال، قال: فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك^(١).

وأما الإجماع:

فقد أجمعت الأمة من لدن صحابة رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا على مشروعية المضاربة، ونقل هذا الإجماع ابن رشد، والنووي، وابن قدامة، وابن حزم وغيرهم.

وأما القياس:

فقياس المضاربة على المساقاة في أن كلا منهما فيه عمل من جانب ومال من جانب آخر والربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. والمساقاة مشروعة بما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قالت الأنصار للنبي - صلى الله عليه وسلم - أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال: لا فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا: سمعنا وأطعنا^(٢). فدل ذلك على أن المضاربة مشروعة أيضاً.

وأما المعقول:

فقالوا: الناس محتاجون إلى التعاون والتصرف في أموالهم بالتجارة فيها وليس كل واحد يقدر على ذلك بنفسه فاضطر فيه إلى استئابة غيره ممن له القدرة على ذلك فكان من الخير أن يتعاون من له مال مع من له الخبرة في العمل والتجارة ويكون الخير لهما وللناس.

(١) الأثر أخرجه البيهقي في السنن - السنن الكبرى : ٥ / ١١١ .

(٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه . فتح الباري : ٥ / ١١ .

أركان عقد المضاربة:

لعقد المضاربة أركان خمسة هي:

- ١- العاقدان: وهما رب المال والعامل ويشترط فيهما ما يشترط في الوكيل والموكل .
- ٢- رأس المال: ويكون من المالك.
- ٣- العمل: ويقوم به العامل.
- ٤- الربح: وهو المقدار المشترك بين العاقلين بعد إخراج رأس المال.
- ٥ - الصيغة: وهي اللفظ الدال على الإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامه.

شروط صحة عقد المضاربة.

عرفنا أن المضاربة عقد بين طرفين الأول صاحب رأس المال يقدمه للعامل ليعمل فيه ويستثمره على أن يكون الربح بينهما بحصة شائعة على ما يتفقان عليه، ويشترط لصحة هذا العقد شروط نجمل أهمها فيما يلي بما يكفي لتوضيح صورة هذا العمل دون الدخول في الكثير من التفاصيل الفقهية .

ولصحة عقد المضاربة لا يجوز أن يكون مع المضاربة عقد آخر مثل عقد البيع أو الإجارة أو غير ذلك . بمعنى أن لا يشتمل عليهما عقد واحد؛ لأن هذه عقود لازمة، وعقد الإجارة عقد جائز فلما تنافي مقتضاها لم يصح أن يجتمعا في عقد واحد ^(١) ، ويجوز للعامل في المضاربة أن يأخذ مالين من رجلين مختلفين، وله أن يجمعهما، وأن يفرقهما على ما اتفقا عليه ^(٢) ، ويجوز له أن يأخذ

(١) أوجز المسالك على موطأ مالك ٤٢٢/١١، الكافي في فقه أهل المدينة ٢/ ٧٧٥ ، ٧٧٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ / ٣٥٥ ، مراتب الإجماع لابن حزم : ١٠٨ .

مالاً من غيره ويخلطه بماله ويعمل في المالين ويكون له ربح ماله بحسابه وهو في مال غيره على ما اتفقا^(١).

هذا، ونذكر فيما يلي: أهم الشروط المتعلقة برأس المال، وتوزيع الأرباح، وتحمل الخسارة .

أولاً: بالنسبة لرأس المال:

١- أن يكون رأس المال من النقود الرائجة أما إن كان غير ذلك - كما لو عرضاً أو عقاراً - فلا يجوز دفعه رأس مال مضاربة وهذا قول جمهور الفقهاء^(٢).

إلا إذا قال رب المال للمضارب خذ هذه العروض ثم بعها وضارب بثمنها فقبل المضارب ذلك القول، فهذه مضاربة صحيحة عند الحنفية، والزيدية، والحنابلة، والظاهرية، وقول عند الإباضية^(٣)؛ لأنها مضاربة مضافة إلى ثمن العروض وليس إلى العروض نفسها .

وأيضاً المضاربة مضافة إلى زمن البيع وتجوز إضافة المضاربة؛

وأيضاً المضاربة تتعلق بالمجهول كشرط الربح وهو مجهول .

ومنعها المالكية، والشافعية، والإمامية، وقول عند الإباضية^(٤)؛ لأن رب المال استفاد أمراً فوق الربح المتفق عليه وهو بيع العروض فكأنه قراض ومنفعة، وما يبيع به السلعة مجهول، فكأنه قارض على رأس مال مجهول .

(١) المغني ٥ / ٢٨ .

(٢) بدائع الصنائع ٦ / ٨٢ ، المنتقى شرح موطأ مالك ٥ / ١٥٧ ، زاد المحتاج ٢ / ٣٤٢

(٣) اللباب في شرح الكتاب ٢ / ١٣١ ، حاشية رد المحتار ٥ / ٦٤٧ .

(٤) بداية المجتهد ٢ / ٣٠٣ ، الشرح الكبير ٣ / ٥١٩ ، الحاوي الكبير ٧ / ٣٠٩

وأرى ترجيح ما قاله الحنفية ومن معهم حيث إن فيه تحقيق مصلحة العامل ورب المال، وذلك لأن المضاربة نوعاً من الإحسان إلى العامل، وهو نوع من المعروف ولا بأس أن يكافئ الإنسان على المعروف، وأيضاً كون رب المال يشترط على المضارب أن يبيع العروض ثم يضارب بثمنها ويقبل المضارب ، فهذا شرط لصحة عقد المضاربة ولمصلحتها فلا مانع منه شرعاً .

٢- أن يكون رأس المال معلوماً للمتعاقدين قبل بدء العمل في المال، فإن كان مجهولاً فلا تصح، دفعاً لجهالة الربح .

٣- أن يكون رأس المال عيناً فلا يجوز المضاربة بدين على العامل أو على غيره بأمره ربه بقبضه ممن عليه ثم المضاربة به على الراجح ^(١) ؛ لأنها مضاربة فاسدة.

٤- أن يكون رأس المال مُسَلَّماً للمضارب ليتمكن من العمل، فلا تصح المضاربة بالمال مع بقاء يد المالك عليه ، كما لا تصح إذا شرط أن يعمل فيه معه؛ لأن ذلك يخل بكمال التسليم، ولأن شرط عمله معه شرط بقاء يده على المال وهو شرط فاسد.

وأما إعانة رب المال، المضارب بدون شرط فجائز وهذا قول جمهور الفقهاء ^(٢) .

وقال أحمد والخرقي: إذا اشترك بدنان بمال أحدهما، وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل منهما، مثل أن يخرج أحدهما ألفاً ويعملان فيه معاً والربح

(١) بدائع الصنائع ٦/ ٨٣ ، أوجز المسالك ١١ / ٤١ ، ٤٧ ، الحاوي الكبير ٧ / ٣٠٩ .

(٢) بدائع الصنائع ٦ / ٨٤ ، أوجز المسالك ١١ / ٤٠٧ ، الشرح الكبير ٣ / ٥٢٠ ، الجامع للشرائع : ٣١٧ .

بينهما، فهذا جائز وتكون مضاربة؛ لأن غير صاحب المال يستحق المشروط له من الربح بعمله من مال غيره وهذا هو حقيقة المضاربة^(١).

وتأولوا قول أحمد والخرقي: على أن رب المال عمل من غير شرط.

ثانياً: بالنسبة لتوزيع الربح:

الربح في المضاربة لا يظهر إلا بعد أن ينض مال التجارة كله - أي يصير نقداً - ولا يتم ذلك إلا بعد أن يبيع المضارب كل ما تحت يده من عروض التجارة، ويشترط فيه أن يكون معلوم القدر لكل من رب المال والمضارب حتى لا يدع مجالاً للمنازعة.

كما يشترط فيه أن يكون مشاعاً كالنصف، أو الثلث، أو السدس ونحو ذلك مما يتفقان عليه، فلو جعل الربح كله لرب المال ولا شيء للعامل كان ذلك إبطاعاً، ولو جعل الربح كله للعامل كان العامل مقترضاً للمال من صاحبه وليس ذلك مضاربة، فلا يصح اشتراط دراهم معلومة لأحدهما كألف ريال، أو مائة جنية في الشهر، أو كخمس رأس المال لصاحبه ونحو ذلك.

فإذا شرط أحدهما أو كلاهما نقوداً معلومة بطلت المضاربة^(٢).

وتوزيع الربح يكون بعد حساب النفقة للمضارب إذا اشترطت، أو كان

العرف بها على الراجح من أقوال الفقهاء^(٣) مع اختلاف بينهم هل في السفر، أو في الحضر، أو فيهما معاً، أو لا ؟

(١) المغني ٥/ ٢٨، ٢٩ .

(٢) الباب في شرح الكتاب ٢/ ١٣٢، أوجز المسالك ١١/ ٤١٧، زاد المحتاج ٢/ ٣٤٥، المغني ٥/ ٢٣، المحلى لابن حزم ٨/ ٢٤٧ .

(٣) حاشية رد المحتار ٥/ ٦٥٧، الشرح الكبير ٣/ ٥٣٠، الحاوي الكبير ٧/ ٣١٨، المغني ٥/ ٤١، المحلى لابن حزم ٨/ ٣٤٧، شرائع الإسلام : ٣١٤ .

ثالثاً: بالنسبة لتحمل الخسارة:

يتولى العامل في المضاربة كل ما جرت العادة أن يتولاه، ويكاد الفقهاء يتفقون على أن من الواجب على المضارب في المضاربة المحافظة على المال، وعدم التفريط وتعريضه للضياع، أو التلف، أو الإلتلاف فإذا تحققت خسارة كانت على رب المال وحده واحتسب أولاً من الربح إن كان قد ربح، فإن لم يربح احتسب الزائد من رأس المال، ولا يرجع رب المال على المضارب بشيء؛ لأن المضارب أمين مقبول قوله فيما يدعيه من خسارة أو ضياع أو هلاك إلا أن يتبين كذبه.

أما إذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له فعله، أو تعدى ما أمره به رب المال ضمن من المال ما تسبب فيه من خسارة أو تلف^(١).

أنواع المضاربة.

للمضاربة نوعان: مطلقة، ومقيدة.

فالمطلقة: هي أن يدفع رجل المال إلى آخر بدون قيد، ويقول دفعت هذا المال إليك مضاربة على أن الربح بيننا كذا مناصفة، أو ثلاثاً، أو نحو ذلك، ويقول المضارب قبلت.

والمقيدة: هي أن يدفع شخص إلى آخر عشرة آلاف من الجنيهات المصرية مثلاً مضاربة على أن يعمل فيها في بلدة معينة، أو سوق معين، أو بضاعة معينة مما لا تُعدم التجارة فيها، ولا تُعدم هي في وقت من الأوقات، كالحيوان والطعام، ويقبل الآخر فهذا جائز^(٢).

(١) الباب في شرح الكتاب ٢/ ١٣٧، الشرح الكبير ٣/ ٥٣٨، روضة الطالبين ٥/ ١٣٥

(٢) بدائع الصنائع ٦/ ٨٧.

أما إن أُقِّت المضاربة بوقت معين كسنة أو أقل أو أكثر، أو خصصها بشيء معين كثوب بعينه أو عبد بعينه، أو شخص معين كأن لا يبيع إلا من فلان أو لا يشتري إلا من فلان، أو أضافها إلى المستقبل، كخذ من العشرة آلاف من الجنيهاً المصرية وضارب بها عند حلول شهر رجب ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: ذهب الحنفية، والحنابلة، والظاهرية، والزيدية إلى جواز ذلك (١).

القول الثاني: ذهب المالكية، والشافعية، والإمامية في غير التخصيص إلى عدم الجواز (٢).

أدلة أصحاب القول الأول.

استدل أصحاب القول الأول القائلون بجواز التخصيص بالآتي:

١- عقد المضاربة عقد مبناه الوكالة، والوكالة تجوز مؤقتة وتجوز إضافتها إلى الزمان المستقبل، فكذاك المضاربة (٣).

٢- عقد المضاربة عقد يصح تخصيصه بنوع فصح تخصيصه برجل بعينه وسلعة بعينها (٤).

٣- عقد المضاربة يتعلق بالمجهول فلأن يضاف إلى المستقبل أولى، أما إضافته إلى المجهول، فهو أننا نشترط للعامل جزءاً من الربح منسوباً إليه - الربح - والربح قد يأتي وقد لا يأتي، وإن أتى قد يكون قليلاً لا يكافئ العمل.

(١) الباب في شرح الكتاب ٢/ ١٣٢ ، ٣٤٥ ، المغنى: ٩٦ ، المحلى ٨/ ٢٤٧ .

(٢) الشرح الكبير ٣/ ٥١٩ ، الحاوي الكبير ٧/ ٣١١ .

(٣) بدائع الصنائع ٦/ ٩٩ .

(٤) بدائع الصنائع ٦/ ١٠٠ .

أدلة أصحاب القول الثاني.

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم الجواز بالآتي :

- ١- عقد المضاربة عقد يقع - يصح - مطلقاً ، فلا يجوز مؤقتاً ولا مضافاً قياساً على النكاح .
- ٢- التأقيت ليس من مقتضى عقد المضاربة، فأشبهه ما لو شرط أن لا يبيع، وبيان أنه ليس من مقتضى العقد: أنه يقتضي أن يكون رأس المال ناضاً - نقداً - فإذا منعه من البيع لم يُنْضَ^(١) .
- ٣- التأقيت والإضافة ليسا من مقتضى عقد المضاربة فلا يصح، والدليل على أنه ليس من مقتضى عقد المضاربة أنه فيه تحجير على العامل، والتحجير خارج عن سنة القراض، ومن مقتضى عقد المضاربة تحصيل الربح ، وقد يكون الربح في تبقية المتاع وبيعه بعد مضي المدة فيمتنع ذلك بمضيها^(٢) .
- ٤- لا يصح تخصيص رجل بعينه للبيع أو الشراء في عقد المضاربة؛ لأنه لو فعل ذلك لم تكن مضاربة بل يصير العامل لرب المال أجيراً بأجر موصوف، ولأن فلاناً قد يموت قبل مبايعته، وقد لا يرغب في مبايعته^(٣) .
- ٥- عقد المضاربة من العقود الجائزة، يبطل باشتراط المدة كالشركة^(٤) .

مناقشة أدلة القول الثاني.

نوقش أصحاب القول الثاني بالآتي :

-
- (١) الحاوي الكبير ٧/ ٣١١ ، المغني ٥/ ٦٩ ، ٧٠ .
 - (٢) المغني ٥/ ٧٠ .
 - (٣) أوجز المسالك ١١/ ٤٢٨ ، الحاوي الكبير ٧/ ٣١٤ .
 - (٤) أوجز المسالك ١١/ ٤٢٥ ، الحاوي الكبير ٧/ ٣١١ .

١- القياس على النكاح لا يسلم، فعقد النكاح أشبه بالعبادات، وعقد المضاربة من المعاملات، والمعاملات الأمر فيها أوسع من العبادات والنكاح ليس عقداً مالياً بينما المضاربة عقد مالي، بل عقد المضاربة أشبه بعقد الوكالة وبعقد الوديعة، وكلاهما يجوز مؤقتاً فبطل القياس.

٢- الاستدلال بأن التأقيت والإضافة ينافيان مقتضى العقد، وأن فيهما إضرار بالعامل فيبطل بتخصيصه بنوع من المتاع؛ لأن لرب المال منعه من البيع والشراء في كل وقت إذا رضي أن يأخذ ماله عرضاً ، فإذا شرط ذلك فقد شرط ما هو مقتضى العقد فصح كما لو قال: إذا انقضت المدة فلا تشتري شيئاً (١)

الراجح: بعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة وأدلة كل قول ما أمكن يظهر لي رجحان القول الأول القائل بجواز المضاربة إن أقتت بوقت معين، أو خصت بشيء معين، أو بشخص، أو أضيفت إلى المستقبل وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها، ولأن الإضافة، أو التوقيت، أو التخصيص كلها أمور مرتبطة بمصلحة المتعاقدين وتحقق مراد كل منهما وذلك ما يتحقق به الرضا، ويدفع الضرر مع عدم المانع الشرعي.

أفضلية المضاربة كأسلوب للاستثمار والتنمية.

سبق القول بأن عقد المضاربة يصح إذا عمل المضارب في مال فرد، أو عدد من الأفراد وفقاً لما يتفق عليه، ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والعمل بالمضاربة كأسلوب لاستثمار الأموال في العديد من المشروعات المختلفة - تجارية وصناعية وزراعية - هو البديل الإسلامي الذي يؤدي إلى تنمية الاقتصاد القومي واستثمار الأموال في المشروعات الكبرى التي تفي بحاجات المسلمين

(١) المغني ٥ / ٧٠ .

فيعود الخير على صاحب رأس المال، وعلى العامل في المضاربة، وعلى المجتمع بما يقدمونه من خدمات ومنافع .

وتظهر أفضلية المضاربة في عدد من الأمور منها :

١- صاحب المال الذي يودع ماله في بنك إسلامي - على أساس شركة المضاربة - سوف يحصل على الربح العادل الذي يتكافأ مع الدور الذي أداه ماله في التنمية الاقتصادية، وفي تشجيع المسلمين لإيداع أموالهم لدى البنك الإسلامي، ودوام استثمارها بواسطته وفي ذلك ربط المسلمين بعملية تكوّن رأس المال كركن أساسي في تدعيم اقتصاد العالم الإسلامي وإقبالهم على استثمار ما لديهم من أموال، بدلاً من الاكتناز المنهي عنه .

٢- البنك الإسلامي في تعامله بنظام المضاربة لا يعتمد على الفرق بين سعر الفائدة الدائنة والمدينة في تغطية نفقات ومصاريف الأجهزة العاملة به، وكذلك عائد المودعين، وهذا يؤدي إلى تنشيط عمليات التنمية في المجتمع عن طريق تجنيد المصرف كل طاقاته وإمكانياته الفنية في استخدام الأموال التي لديه، بخلاف البنوك غير الإسلامية فهي تعتمد على الفرق بين سعر الفائدة الدائنة والمدينة في تغطية نفقات ومصاريف الأجهزة العاملة، وكذلك فوائد المودعين ، وبذلك تقوم بإيداع الأموال المتجمعة لديها لدى بنوك أخرى، وهذه الأموال تصب في النهاية في الأجهزة التي تقوم بعملية الاستثمار .

٣- يضمن نظام المضاربة النهوض بالاقتصاد الإسلامي وذلك؛ لأن البنك الإسلامي لا ينظر إلى الفائدة على أنها المؤشر الأساسي لتحديد الكفاية الحدية لرأس المال ولتوجيه الاستثمارات دائماً، بل المؤشر الأساسي لديه هو الربح بجانب العمالة ورفاهية المجتمع واحتياجاته من الإنتاج .

٤- في العمل بالمضاربة عدالة في توزيع العائد بما يساعد في عدم تركيز الثروة في يد فرد أو جماعة من ناحية، وبحول دون إهدار الطاقات البشرية من

ناحية أخرى، وقد تؤدي ظروف اجتماعية واقتصادية خارجة عن إرادة الفرد إلى أن تتضاعف أرباح مشروع معين، وينشأ عن ذلك - في حالة الإقراض بفائدة - أن ينتفع من لا يستحق بأكثر مما يستحق، وأن يتحمل غير المتسبب غرماً لا دخل له فيه، ويحول أسلوب المضاربة دون أي من الأمرين؛ لأنها قائمة على الغنم والغرم .

وفي ظل نظام المشاركة ينتفي الكسب المضمون الذي يحصل عليه المرابي دون تحمله لأي خسارة، كما أنه وفي ظل نظام المشاركة - المضاربة - ينتفي إضافة أسعار الفائدة كتكاليف للإنتاج، وما ينتج عن ذلك من غلاء أسعار السلع والخدمات يتولد عنه إما قصور في الطلب يؤدي إلى ظاهرة الانكماش والكساد، وإما نشوء احتكار في سوق العمل يؤدي إلى ظاهرة التضخم، وفي كلتا الحالتين فإن التعامل بالربا يؤدي إلى وجود خلل في درجة التناسب بين كمية النقود وبين حجم السلع والخدمات .

وبذلك يعد من أهم الأسباب المنشئة لتقلبات الأسعار وما يتبعها من تغير في قيمة النقود .

أحكام مخرجة على شروط صحة القراض (المضاربة)

أولاً: حكم القراض بالدين والوديعة:

إذ قال رب الدين لمن له دين عليه: اتجر بالدين الذي عليك قراضاً على أن الربح بيننا كذا، فإن أحضر المدين الدين وقبضه الدائن وأشهد على قبضه، صح ذلك وكان قراضاً، وإلا فالدين باق على حاله، ويختص العامل بالربح وعليه الخسر.

قال مالك في الموطأ: "إذا كان لرجل على رجل دين، فسأله أن يقره عنده قراضاً، أن ذلك يكره حتى يقبض ماله، ثم يقراضه بعد أو يمسه، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله، فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه"^(١). والكره هنا كراهة منع كما قال الزرقاني^(٢)، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد^(٣).

ومثل الدين، الوديعة عندنا، فإذا قال المودع للمودع: قارض بالدرهم التي عندك وديعة، فإن ذلك لا يصح.

قال في المدونة: "الوديعة مثله - يعني الدين - لأنني أخاف أن يكون أنفق الوديعة فصارت عليه ديناً" نقله المواق^(٤).

وقال الأئمة الثلاثة: يصح ذلك في الوديعة.

جاء في المغني: "وإن كان في يده وديعة، جاز له أن يقول: ضارب بها، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي"^(٥).

(١) الموطأ ٢ / ٦٨٩.

(٢) شرح الزرقاني على الموطأ ٣ / ٣٤٨.

(٣) الباب ٢ / ١٣١، مغني المحتاج ٢ / ٣١٠، المغني ٥ / ٧٣.

(٤) التاج والإكليل ٥ / ٣٥٨.

(٥) المغني ٥ / ٧٥.

ثانيًا: حكم القراض إذا لم تحدد نسبة الربح:

إذا قال رب المال للعامل: اعمل في المال ولك جزء من الربح، بدون تعيين، أو أبهم القراض بأن قال: اعمل فيه قراضًا وأطلق، فإن كان أهل بلدهما لهم عادة في قدر ما يأخذه العامل من الربح من نصف، أو أقل، أو أكثر، صح القراض، وعمل بما جرت به العادة، وإن لم يكن هناك عادة لأهل البلد، فإن ذلك لا يجوز، وفيه بعد العمل قراض مثله^(١).

ثالثًا: ما لا يجوز في شركة القراض:

- ١- لا يجوز أن يشترط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف بلا تفريط، وإذا حدث فللعامل قراض مثله، والشرط باطل.
 - ٢- ولا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل أن يعمل معه في المال، كما لا يجوز له أن يشترط على العامل أن لا يبيع ولا يشتري إلا بعد مشاورته، أو مشاوره فلان من الناس، لما في ذلك من التحجير على العامل، فإن وقع ذلك فللعامل أجر مثله، لأنه أصبح بمنزلة الأجير.
 - ٣- ولا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل أن يكون التجار في محل معين، أو زمن معين، أو لشخص معين، كأن يقول له: لا تبع إلا في الشتاء، أو تعامل مع فلان من الناس، فإن وقع بطل القراض، وللعامل أجر المثل، والربح لرب المال والخسارة عليه.
- وخالفنا في هذا الحنفية والحنابلة فجوزا أن يشترط صاحب المال على العامل أن لا يتعامل إلا في زمن معين، أو محل معين، أو لشخص معين^(٢).

(١) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٥١٩.

(٢) المغني ٥/ ٦٨، ٦٩.

رابعًا: ما يجوز في شراكة القراض:

١- يجوز لعامل القراض أن يخلط مال القراض بمال غيره، حتى وإن كان الخلط بمال العامل نفسه، إن لم يشترط عليه ربه عدم الخلط، فله التجارة بمال غيره، وبماله الخاص مع مال القراض، ويكون الربح بينهما حسب مال كل منهما.

٢- يجوز للعامل السفر بمال القراض إن لم يحجر عليه رب المال قبل الشغل في المال، فإن حجر قبل شغله في المال ولو بعد العقد لم يجز.

خامسًا: المسائل التي يضمن فيها العامل مال القراض:

١- إن عمل العامل بالمال بعد علمه بموت ربه، فإنه يضمن المال إن كان عينًا، لأنه صار لغيره، ولا يضمنه إن كان عرضًا، لأن الورثة ليس لهم أن يمنعوه من التصرف في العرض، كما لا يضمن مطلقًا إن تصرف في المال قبل علمه بموته.

٢- إذا نهى رب المال العامل عن السفر بالقراض قبل العمل فيه فسافر به وتلف، فإنه يضمن، لأن السفر مظنة الخطر، وقد نهاه عنه.

٣- إذا شارك العامل في مال القراض غيره، ولو عاملاً آخر لصاحب مال الشركة بغير إذن رب المال؛ فإنه يضمنه، لأن صاحبه لم يستأمن غيره فيه.

٤- إذا باع سلعة من سلع القراض بدين بلا إذن.

٥- إذا دفع العامل مال الشركة كله، أو بعضه لغيره قراضًا بلا إذن

رب المال، فإن العامل يضمن إذا خسر المال، أو تلف، وإذا ربح، يكون لرب المال ما اتفق عليه من الربح في المسائل الخمس كلها^(١).

(١) تبين المسالك ٤/ ١٧٣.

سادساً: الربح يجبر الخسارة:

إذا حصل في مال القراض خسر، وربح، فإن الربح يجبر الخسر، كأن يكون رأس المال ألفاً، فيشتري به سلعةً ويبيعهها بثمانمائة، ثم يشتري بها سلعةً أخرى، ويبيعهها بألف ومائتين، فإن خسر البيعة الأولى جبره ربح البيعة الثانية، وما زاد بعد الجبر يكون بين العامل ورب المال على ما اشترطوا. كما يجبر الربح أيضاً كل ما تلف، أو فقد من مال القراض، ولو كان فقده أو تلفه قبل الشروع في العمل، وإذا لم يحصل ربح يجبر ما تلف، فرب القراض خلف التالف.

سابعاً: حكم نفقة العامل من مال القراض:

يجوز للعامل النفقة بالمعروف من مال القراض إن سافر به للتجارة أو التنمية، ولو كانت المسافة دون مسافة القصر بشروط:

الأول: إن لم يكن بالبلد الذي سافر إليه زوجة مدخول بها.

الثاني: وكان المال يحتمل الإنفاق، بأن كان كثيراً، أما اليسير فلا نفقة فيه، وحد اليسر: أربعون ديناراً، وخصوصاً مع الغلاء.

الثالث: ولم يكن السفر لقربة، كحج، أو صلة رحم، فإن كان لقربة فلا نفقة له في الذهاب ولا الإياب، لأن ما كان قربة لا يشرك معه غيره^(١).

وفي حالة جواز النفقة للعامل في السفر، تكون له في الذهاب والإياب إلى أن يعود لوطنه، ويتضمن ذلك الأكل، والشرب والمسكن، وما يتعلق بذلك، كغسل ثياب ونحوه على وجه المعروف. وإذا كان أهلاً للإخدام استأجر خادماً من مال القراض، كما أن له الكسوة إن طال سفره طويلاً يُخلق ثيابه، كما أن له أن يستأجر من القراض على الأعمال التي لا يتولاها مثله.

(١) تبين المسالك ٤ / ١٧٥.

وإن سافر للتجارة، ولقضاء حاجة أخرى غير الحج، والأهل، وزعت النفقة على مال القراض والحاجة، حسبما ينفقه على كل منهما منفردًا. ففي الموطأ "قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فخرج به وبمال نفسه، قال: يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال"^(١).

ثامناً: حق الشريكين في فسخ الشركة:

حكى ابن رشد الإجماع على أن لكل من العامل ورب المال فسخ الشركة قبل الشروع في العمل، كما حكى ابن حزم الإجماع على أن لكل منهما فسخ الشركة بعد العمل ونضوض المال (أي بيع السلع كلها بالنقود)^(٢). ولرب المال فقط فسخ شركة القراض إن تزود العامل من مال القراض ولم يشرع في السفر، إلا أن يلتزم العامل لرب المال غرم ما اشترى به الزاد. أما الأئمة الثلاثة فقالوا: إن لكل من رب المال والعامل فسخ القراض، ولو كان المال عرضاً^(٣).

قال ابن رشد في بداية المجتهد - بعد أن حكى الإجماع على أن لكل منهما فسخ القراض قبل الشروع في العمل: واختلفوا إذا شرع العامل، فقال مالك: هو لازم. ثم قال: وقال الشافعي وأبو حنيفة: لكل واحد منهما الفسخ إن شاء^(٤).

تاسعاً: هل يفسخ القراض بالموت؟

لا يفسخ القراض عندنا بموت العامل بعد شروعه في العمل، فلوارثه الأمين أن يحل محله على حكم ما كان لمورثه، فإن لم يكن أميناً، أتى بأمين كالأول، وإلا فعليه أن يسلم المال لربه بدون ربح ولا أجر^(٥).

(١) الموطأ ٢/ ٦٩٦.

(٢) بداية المجتهد ٢/ ٢٤٠، مراتب الإجماع ص ٩٢.

(٣) المغني ٥/ ٦٤، ٦٥.

(٤) بداية المجتهد ٢/ ٢٤٠.

(٥) حاشية الصاوي ٢/ ٢٥٤.

وخالفنا الأئمة الثلاثة ورأوا: أن القراض يفسخ بموت العامل، أو رب المال، ومثله: الجنون والإغماء.

جاء في الكتاب "وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة". وقال في المنهاج: "ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ القراض". ومثله في المغني^(١).

عاشراً: اختلاف عامل القراض ورب المال:

عامل القراض أمين لا ضمان عليه فيما لم يفرط فيه، فإن ادعى تلف المال، أو خسره، صدق بيمين، وكذلك إن ادعى أنه رده لربه، صدق في دعواه ذلك، إن أخذه بلا بينة، أو ببينة لم يقصد بها التوثق، أما إن قصد بها التوثق فلا يبرأ إلا إذا أقام بينة على رده المال لربه^(٢).

كذلك يكون القول قول عامل القراض إذا قال: أنه أخذ المال على وجه القراض، وقال رب المال: إنه أرسله معه بضاعة ليشتري سلعة معينة بأجر معلوم، والعكس، فالقول قول العامل بيمين إن كان مثله يعمل في القراض، ومثل المال يدفع قراضاً، وكانت المنازعة بعد العمل الموجب للزوم القراض. وأما إن ادعى أن المال الذي دفعه صاحبه إليه قراض، أو وديعة، وادعى رب المال أنه دفعه له قرضاً، فالقول لرب المال بيمين، لأن الأصل تصديق المالك في كيفية خروج ماله من يده.

وكذلك إذا كان نزاعهما في قدر جزء الربح قبل الشروع في العمل، فإن القول لرب المال بلا يمين، لأن لكل منهما فسخه قبل العمل كما تقدم.

(١) اللباب ٢/ ١٣٥، مغني المحتاج ٢/ ٣١٩، المغني ٥/ ٦٦.

(٢) منح الجليل ٣/ ٧٠١، ٧٠٢.

وإن اختلفا في صحة عقد القراض وفساده، فإن قال أحدهما: إن رأس مال القراض عرض، ويقول الآخر: إنه عين، فالقول لمدعي الصحة، وهو الذي قال: إنه عين، لأن هذا الباب ليس من الأبواب التي يغلب فيها الفساد.

وأما مذاهب الثلاثة في اختلاف العامل ورب القراض، فقال أبو حنيفة: القول لرب المال في ادعاء القراض والبضاعة والقرض والوديعة، والبينة على المضارب، لأن المضارب يدعي عليه التملك، وهو ينكر^(١).

وقال الشافعي: القول للعامل فيما يدعي من تلف المال، وفيما يدعي عليه من خيانة، لأنه أمين، والقول له في قدر رأس المال، أما في رد المال فقليل: إن القول له، وقيل لرب المال، وإن اختلف في قدر الربح المشروط تحالفًا، فإن حلفا صار الربح كله لرب المال، ويرجع العامل بأجرة المثل^(٢).

وقال أحمد: القول للعامل فيما يدعيه من هلاك وخسران، وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للقراض، والقول لرب المال مع يمينه في رد المال إليه، وفي تحديد الجزء المشروط للعامل، والقول للمالك أيضًا بيمين إذا دفع للعامل مالاً يتجر فيه فربح، وادعى العامل أنه قرض، ربحه له، وادعى المالك أنه قراض، ربحه بينهما، فإذا حلف، قسم الربح بينهما، وقيل: يتحالفان، وللعامل أكثر الأمرين مما شرط له من الربح، أو أجرة مثله. قاله في المبدع^(٣).

(١) الهداية مع فتح القدير ٧ / ٨٦.

(٢) المهذب ١ / ٣٨٩.

(٣) المبدع في شرح المقنع ٥ / ٣٥ - ٣٧ وانظر: تبیین المسالك ٤ / ١٧٩.

ثانياً: شركة الأبدان.

تعريفها: وهي عقد شخصين أو أكثر على عمل والريح بينهما على كسب مال كل أو عمله بما يدل عرفاً^(١).

ويقال لها شركة العمل فهي تلزم بكل ما دل عرفاً على الشركة سواء كان قولاً فقط، أو فعلاً فقط ، وأولى إذا اجتمعا، وهي شركة في الصنائع والأعمال .

حكمها: الجواز .

دليلها: استدلوا على جواز شركة الأبدان بحديث عبد الله بن مسعود حيث قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما نصيب، فلم أجيء أنا ولا عمار بشيء وجاء سعد برجلين^(٢) .

فهذه شركة فيما يصيبون من سلب في الحرب، وقد أقرهم النبي (ﷺ) على الشركة فدل على جوازها .

قال الصنعاني: الحديث فيه دلالة على صحة الشركة في المكاسب.

وقال الشوكاني: هو حجة في شركة الأبدان .

وقال السندي: فيه دليل على جواز الشركة في المباح الذي يملكه الإنسان بالإحراز كالصيد والحطب^(٣) .

شروطها :

(١) الشرح الصغير وبلغة السالك ٣ / ٤٥٦ .

(٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه : سنن ابن ماجه ٣ / ٨٧ ، ٨٨ ، النسائي ٧ / ٦٠ ، ٣٤٠ .

(٣) سبل السلام ٣ / ٨٤ ، نيل الأوطار ٥ / ٣٩٢ .

١- أن يتحد العمل كنساجين لا نساج ونجار، أو يتلازم العمل بأن يتوقف أحد العاملين على الآخر، كأن يصوغ أحدهما ويسبك له الآخر أو أحدهما يغوص لطلب اللؤلؤ والثاني يمسك عليه ويقذف بالمقذاف .

٢- أن يدخل على أن كلا منهما يأخذ من الربح بقدر عمله ولا يضر التبرع بعد العقد .

٣- أن يحصل التعاون بينهما، وإن بمكانين بحيث تجول يد كل منهما على ما بيد صاحبه كخياطين في حانوتين يأخذ كل منهما ما بيد صاحبه .

٤- أن يشتركا في الآلة التي بها العمل كآلة الخياطة والفأس والقنطرة وغير ذلك إما بملك أو إجارة لهما من غيرهما، أو كان أحدهما يملكها واستأجر شريكه منها نصفها، فإن كانت الآلة من أحدهما دون الآخر لم يجز .

من هذا الشرط يعلم أن الصور ست : المتفق على جوازها ثلاث والمختلف فيها بين الجواز والمنع ثلاث .

أما الثلاث المتفق على جوازها فهي:

الأولى: أن تكون الآلة مملوكة لهما معاً بشراء أو إرث .

الثانية: أن تكون الآلة مكتراة منهما معاً .

الثالثة: أن يُخرج كل منهما آلة، ويبيع نصف آله بنصف آلة صاحبه.

وأما الثلاث المختلف فيها فهي:

الأولى: إخراج كل واحد آلة مساوية لآلة الآخر، ولم يستأجر كل واحد

نصيب آلة صاحبه .

الثانية: إخراج أحدهما الآلة كلها من عنده، وأجر نصفها لصاحبه

الثالثة: إخراج كل منهما آلة مساوية لآلة الآخر، وأجر كل منهما نصف

آله بنصف آلة الآخر .

والمعتمد في الصورة الأولى عدم الجواز، وفي الأخيرتين الجواز .

وإذا كنا قد عرفنا الصور الجائزة والصور الممنوعة لشركة العمل فيمكن التمثيل لشركة العمل الجائزة بالآتي :

١- اشتراك طبيبين اتحد طبهما ككحاليين وجراحين، أو تلازم، أي دخلا على الطبيب والدواء، فإن اختلف طبهما لم يحصل اتحاد ولا تلازم، كجراح وكحال فإنه لا يجوز اشتراكهما للغرر؛ لأنه قد تروج صنعة أحدهما دون صنعة الآخر .

٢- اشتراك صائدين في بازين (نوع من الصقور) مثلاً بملك أو استتجار، أو بازٍ لأحدهما وكلب معلم للآخر لوجود التلازم بينهما .

واختلف في محل الجواز هل إن اتفقا في المصيد والمكان وفي ملك ذاتهما، أو الجواز وإن افترقا في المصيد، كأن يصطاد أحدهما الغزال والآخر بقر الوحش، أو في المكان أو في الملك بأن يملك أحدهما بازه والثاني منفعة الآخر، والحاصل أن الأحوال ثلاثة :

أ- إن اتحد طلبهما بأن اتفق البازان في المصيد والمكان وحصل الاشتراك في ملك ذاتهما جازت الشركة اتفاقاً .

ب- وإن لم يحصل الاشتراك في ذاتهما ولم يتحد طلبهما بأن كان مصيد أحدهما الطير، والآخر الوحش منعت اتفاقاً .

ج- وإن حصل اشتراك في ذاتهما واختلف طلبهما أو اتحد طلبهما ولم يحصل اشتراك في ذاتهما فهذا محل خلاف فقيل: تجوز الشركة، وقيل: لا تجوز .

٣- اشتراك حافرين على الركاز والمعادن والآبار والبنيان بشرط اتحاد الموضوع، فلا يجوز أن يعمل هذا في غار من المعدن وهذا في غار سواه .
وإذا مات أحد الحافرين في المعدن بعد العمل، فإن وارثه لا يستحق بقية عمل مورثه في المعدن وللإمام أو الحاكم أن يقطعه لمن يشاء .

وقيد القابسي : عدم استحقاق الوارث بقية عمل مورثه في المعدن بما إذا لم يَبْدُ النيل (أي المسافة أو القدر) فإن بدا أي ظهر بعمل المورث ولم يخرج منه شيئاً، أو قارب بدوه بعمله فإنه يستحق الوارث بقية العمل إلى أن يفرغ النيل الذي بدا أو قارب البدو، والراجح عدم التقييد .

وإذا مرض أحد شريكي العمل أو غاب، فإن كان يوماً أو يومين أو ثلاثة، فإن ذلك يلغى، وما فعله الحاضر الصحيح شاركه في غلته المريض أو الغائب . أما إن كثر زمان المرض أو زمان الغيبة بأن زاد على خمسة أيام فعلى الحاضر (الذي لم يغب عن العمل) والصحيح (الذي لم يصبه مرض) أن يرجع عليه بأجرة مثله، والأجرة الأصلية بينهما والضمان منهما .

مثال ذلك: لو تعاقد شخصان على خياطة ثوب مثلاً بعشرة دراهم وغاب أحدهما أو مرض كثيراً فخاطه الآخر، فإن العشرة دراهم بينهما، ويقال ما أجرة مثله في خياطته لهذا الثوب، فإن قيل أربعة دراهم مثلاً رجع على صاحبه بدرهمين، فكأنه أخذ أجرة مثله أربعة دراهم وقسمت الستة عليهما بالسوية .

ثالثاً: شركة الوجوه .

وهي أن يبيع الوجيه مال الرجل الخامل ^(١) بجزء من ربحه .

حكمها: فاسدة لأمرين:

الأول: أن فيها إجارة مجهولة .

الثاني: لما فيها من الغش والتدليس على الناس، وأكل أموال الناس بالباطل؛ لأن كثيراً من الناس يرغبون في الشراء من أملياء السوق ظناً منهم أن الأملياء يتجرون في جيد السلع، وأن الفقراء على العكس وإذا وقع ذلك أي باع الوجيه سلعة الخامل، كان للوجيه أجرة مثله بالغة ما بلغت.

(١) الخامل : الساقط الذي لا يلتفت إليه .

وأما من اشترى من الوجيه فإن كانت السلعة قائمة فله الخيار بين الرد والتماسك بالثمن، وإن فاتت لزم المشتري بالأقل من الثمن والقيمة.

وقال بعض الفقهاء: إن شركة الوجوه هي مثال ثان لشركة الذمم الممنوعة؛ لأنها قائمة على غير مال ولا صناعة، وهذا قول ضعيف، والأوجه أن شركة الوجوه نوع مستقل عن شركة الذمم^(١).

مسائل يقع فيها النزاع بين الشركاء وغيرهم.

كثيراً ما يقع نزاع بين الشركاء على أشياء بينهم الأمر الذي يتطلب الحكم والقضاء في هذا النزاع، وهناك مسائل ذات أهمية كبيرة غالباً ما يقع النزاع فيها نتعرض لأهمها فيما يلي:

١- إذا كان بين الشريكين على سبيل الشركة عقار لا ينقسم كالحمام والطاحون والحانوت والفرن ونحوها فاحتاج إلى الإصلاح وأبى أحدهما أن يصلح ففي ذلك أقوال ثلاثة :

الأول: الحاكم يأمر الممتنع أن يُعَمَّر مع من أراد التعمير، فإن امتنع قال له: إن لم تُعمر حكماً عليك بالبيع، فإن استمر على الامتناع حكم عليه بالبيع، ولو كانت حصته يزيد ثمنها على التعمير.

والثاني: الحاكم يحكم عليه ببيع قدر ما يحصل به التعمير؛ لأن البيع الجبري إنما أبيح للضرورة فيقتصر على قدرها للقاعدة الفقهية التي تقول : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها .

وأجيب عن هذا القول: بأن دفع ضرر كثرة الشركاء إنما يكون ببيع الكل.

الثالث: الحاكم يأمره بالتعمير إن كان غنياً، وبالبيع إن كان فقيراً .

(١) الشرح الكبير ٣/ ٣٦٤ ، بلغة السالك بهامش الشرح الصغير ٣/ ٤٧٧ ، الخرشي ٦/ ٣٦٦

، المعونة ٢/ ١٤٢ ، بداية المجتهد ٢/ ٤٩٩ ، القوانين الفقهية : ٢٩٠ .

هل تأخذ العيون من الآبار نفس الحكم السابق باعتبار أنها لا تنقسم إذا احتاجت إلى التعمير والإصلاح ؟

العيون والآبار إذا احتاجت إلى التعمير والإصلاح لا تأخذ الحكم السابق وإنما فيها قولان:

الأول: لابن القاسم وهو أن الممتع من التعمير لا يقضي عليه بالبيع وإنما يقال لمن أراد التعمير : عمر إن شئت ولك ما حصل من الماء بعمارتك وهو إما كل الماء أو ما زاد منه بالعمارة ، وليس لمن لم يعمر شيء مما حصل بالعمارة إلا أن يدفع ما يخصه من النفقة سواء كان على البئر زرع أو شجر فيه ثمر مؤبر أم لا .

والثاني: لابن نافع وهو أن الشريك يجبر على التعمير إذا كان عليها زرع أو شجر فيه ثمر مؤبر، والراجح الأول .

ما الفرق بين العيون والآبار وغيرهما كالحمام حتى يفرق في الحكم بينهما ؟

الفرق أن في الحمام ونحوه نفع الشريك محقق؛ لأن البنيان ممكن بخلاف العين والبئر فإن ماءهما غير محقق فقد يوجد، وقد لا يوجد^(١).

٢- البناء المكون من طابقين سفلي وعلوي فإذا وهى (أي ضعف) السفلي، فإنه يقضى على صاحبه بالتعمير، فإن امتنع حكم عليه بالبيع لمن يعمر وذلك لدفع ضرر البناء الأعلى .

وكذلك إذا سقط البناء الأعلى على الأسفل^(٢) فهَدَمَهُ جُبِرَ رب الأسفل على أن يبنيه، فإن امتنع حُكِمَ عليه أن يبيع لمن يبنى حتى يبنى صاحب العلو علوه، فإن باع ممن يبنيه فامتنع من بنائه جُبِرَ المشتري أيضاً على البناء فإن امتنع حكم عليه بالبيع لمن يبنيه .

وكذلك إذا وهى السفلى وخيف على الأعلى أن يسقط فإنه يقضى على صاحب الأسفل أن يعلق الأعلى وذلك بالأعمدة والمسمار ونحو ذلك حتى يفرغ صاحب الأسفل من إصلاحه، لأن التعليق بمنزلة البنيان، والبناء على صاحب الأسفل، وكذلك يقضى على صاحب الأسفل بالسقف لبيته؛ لأنه أرض للأعلى.

٣- نزح بئر المرحاض الذي يلقي فيه صاحب الأعلى مع صاحب الأسفل سقطاته قيل على صاحب السفلى وهو قول ابن القاسم وأشهب؛ لأنه بمنزلة سقف الأسفل، وقيل على الجميع بعدد رؤوسهم وهو قول ابن وهب وأصبغ، وهو الذي ينبغي الفتوى به؛ لأنه الأصلح.

(١) حاشية الخرشي ٣٦٨/٦ ، وبهامشه حاشية العدوي ، الشرح الصغير ٤٧٩/٣ .

(٢) المراد بالأسفل : ما نزل عن الطول لا الملاصق للأرض؛ لأنه قد يكون طوابق متعددة .

ومحل الخلاف: إذا لم يجر العرف بشيء أما إذا جرى العرف بشيء عمل به اتفاقاً، واختلف في كنس كنيف الدار المكثرة فقليل: "على ربها، وقيل: على المكثري، والقولان لابن القاسم في كتابه المدونة، ومحل الخلاف أيضاً عدم جريان العرف بشيء وإلا عمل بالعرف قطعاً.

٤- إذا دخلت دابة في دار وماتت فيها فعلى من إخراجها؟ قولان: **الأول:** على رب الدار إخراجها؛ لأن ربها إنما كان يملكها حال حياتها، فإذا ماتت لم يملك منها شيئاً، فيلزم رب الدار إخراجها.

الثاني: على ربها إخراجها؛ لأنه أحق بجلدها وجنينها وبلحمها إذا أراد إطعامه لكلابه، وموتها لا ينقل ملك ربها عنها وهو الصواب والعرف يقضي بذلك حتى عند عدم ما ذكر.

٥- السلم الذي يصعد عليه صاحب الأعلى على علوه يقضي به صاحب الأعلى على المشهور؛ لأن حكمه حكم البلاط الذي فوق سقف الأسفل يكون على صاحب الأعلى.

ومقابلته: ما حكى ابن أبي زمنين عن بعض القرويين أن السلم على صاحب الأسفل كالسقف.

٦- طين المطر الذي ينزل في الأسواق والطرقات ويضر بالمارين لا يجب على أصحاب الحوانيت كنسه لأنه ليس من فعلهم، ما لم يجمعه أصحاب الحوانيت أو أهل البيوت في وسط السوق وأضر بالمارة فإنه يجب عليهم كنسه.

٧- صاحب العلو إن أراد أن يزيد في البناء على علوه الذي دخل عليه فإنه يمنع من ذلك ويقضى عليه بعدم فعله لأنه يضر ببناء الأسفل إلا أن يزيد زيادة خفيفة لا يحصل منها ضرر ويرجع في ذلك لأهل المعرفة.

٨- لمن يقضى بالدابة عند التنازع؟

يقضى بالدابة عند التنازع لراكبها لا لمن تعلق بلجامها ولا سائق لها إلا لقرينة أو بينة، فإن وجدت القرينة أو البينة قضى بها، فإن كانا راكبين عليها فإنه يقضى بها للمقدم، وإن كانا في كل جنب فهي لهما وإن كان معهما ثالث كراكب على ظهرها قضى بها بينهم.

٩- إذا اشترك ثلاثة في رchy فتعطلت واحتاجت إلى الإصلاح فعمرها أحدهم بعد أن أبيا شريكاه من تعميرها معه - قبل حكم الحاكم عليهما بالبيع أو التعمير - فالمشهور أن الغلة الحاصلة لهما بالسوية بعد أن يستوفي المعمر من غلتها ما أنفقه عليها في عمارتها إلا أن يعطوه نفقته فلا غلة له .

واعترض على هذا القول : بأن استيفاء ما أنفقه من الغلة فيه ضرر عليه لأنه دفع جملة وأخذ مفرقاً .

وأجيب عنه: بأنه هو الذي أدخل نفسه في ذلك إذ لو شاء لرفع الأمر للحاكم فيجبرهما على الإصلاح أو البيع ممن يعمر .

مقابل المشهور: قول ابن القاسم : وهو أن الغلة كلها لمن عمر وعليه لشركائه كراء المثل على تقدير أن لو أكرت لمن يعمر .

ويتفرع على هذه المسألة سبعة فروع :

الفرع الأول: إذا استأذنهما في العمارة وأبيا واستمرا على المنع إلى أن تم الإصلاح .

الفرع الثاني: إذا استأذنهما فيسكتا ثم أبيا حال الإصلاح .

الفرع الثالث: إذا استأذنهما فأبيا ثم سكتا عند رؤيتهما للإصلاح .

فالحكم في الفروع الثلاثة واحد وهو أنه يرجع بما عمر في الغلة.

الفرع الرابع: إذا عمر قبل علم شريكه ، والحال أنهما لم يطلعهما على

التعمير إلا بعد تمامه ، سواء رضوا بما فعل أو لا .

الفرع الخامس: إذا عمر بإذنهم ، ولم يحصل منهم ما ينافي الإذن حتى تمت العمارة .

الفرع السادس: إذا سكتوا حين التعمير عالمين به سواء استأذنهم أم لا فالحكم في الفروع الثلاثة أيضاً واحد وهو أنه يرجع بما أنفقه في ذمتهم لقيامه عنهم بما لا بد منهم .

الفرع السابع: إذا أذن له في التعمير ثم منعه بعد ذلك ، فننظر إن كان المنع قبل شراء مؤن التعمير ثم قام بالتعمير ، فالحكم أنه يرجع بما أنفقه في الغلة .

وإن كان المنع بعد شراء مؤن التعمير ، فالحكم أنه يرجع عليهم بما عمر في ذمتهم ولا عبرة بمنعهم له .

١٠ - دخول دار الجار لأجل الإصلاح :

يقضى على الجار أن يأذن لجاره في الدخول لأجل إصلاح جدار أو غرز خشبة أو نحو ذلك ، ويكون هذا من باب ارتكاب أخف الضررين وهما دخول دار الجار ، وضرورة الإصلاح ، ودخول دار الجار أخف .

١١ - البناء في طريق يمر به الناس :

من بنى في طريق الناس بنياناً ولو لم يضر بهم ، فإنه يؤمر بهدمه؛ لأنه لا حق له في ذلك مع كون البناء في طريق الناس شأنه الضرر . وهذا الأمر قد كثر في زماننا ، فكل من بنى أو جدد له بيتاً يخرج ببناؤه بسكة الناس حتى صارت الطرق ضيقة تضر بالناس، وللمجالس المحلية في هذا الشأن دور ملموس ومشاهد .

١٢ - جلوس الباعة بأفنية^(١) الدور :

يقضى بجلوس الباعة بأفنية الدور بشروط أربعة :

إن خف الجلوس، وكان لا يضر بالمارة لاتساع الطريق، وأن تكون الطرق نافذة، وأن يكون جلوسهم للبيع .

١٣ - الطاقة في البناء الذي بين الجارين :

إذا تنازع جاران على فتح أحدهما طاقة أو شباكاً أو باباً، فإما أن يكون فتح ذلك مستحدثاً، أو قديماً .

فإن كانت مستحدثة فإنه يقضى على من فتحها بسدها جميعاً لا سد خلفها فقط، كما يقضى عليه بإزالة الواجهة والشباك والخشب الموجود بجوانب الفتحة خوفاً من إطالة الزمن فيريد من أحدثها أو غيره فتحها بحجة قدمها لدلالة ذلك عليها .

وإن كانت قديمة فلا يقضى بسدها، وإنما يقال للجار استر على نفسك إن شئت .

كما لا يقضى بسدها إن كانت عالية لا يمكن التطلع منها على الجار إلا بما يصعب .

ونقل عن ابن القاسم: أن من أحدث عليه ضرر من فتح كوة أو غيرها وسكت عشر سنين بلا عذر، ولم ينكر جبر عليه ولا مقال له بعد ذلك .

١٤ - المنبعث من الحمامات، والأفران، والمدابغ، والأكلمة والحصير:

(١) الأفنية جمع فناء ، وهو ما امتد من جوانب الدار ، قال ابن عرفة : فناء الدور ما بين بنائها فاصلاً عن ممر الطريق المعد للمرور غالباً كان بين يدي بابها أو غيره ، حاشية العدوي بهامش الخرشي ٦/ ٣٧٥ ، معجم لغة الفقهاء : ٣١٩ .

يقضى بمنع إحداث ما ينبعث منه دخان كالحمام والفرن إذا تضرر الجيران به بسبب تسويد الثياب والحيطان ونحو ذلك .

كما يقضى بمنع إحداث ما ينبعث منه رائحة كريهة كالمذبغة ، والمذبح ، والمسمط ^(١) ، والمصلق ^(٢) ، والمجيرة إذا تضرر بها الجيران

كما يمنع الشخص من تنفيض الأكلمة والحصير ونحوهما على باب داره إذا أضر الغبار بالمارة، ولا حجة له في أنه يفعل ذلك على باب داره، أما إن لم يحدث ضرر فلا مانع .

١٥- إحداث جرين، ومُضَر، واصطبل، ودكان، وأغصان شجرة يقضى بمنع إحداث جرين قرب بيت أو دكان؛ لأن صاحب البيت أو الدكان يتضرر بتبن التذرية .

كما يقضى بمنع إحداث ما يضر بجدار جاره من هدمه أو وهنه كحفر بئر ونحوه .

كذلك يقضى بمنع إحداث اصطبل لخليله لما فيه من الضرر ببول الدواب وزيلها وحركتها ليلاً ونهاراً .

كما يقضى بمنع إحداث دكان قبالة باب شخص؛ لأن إحداثه بهذه الصفة يلزم منه أن يطلع من في الدكان على عورات جاره، ولأن فتح الدكان أشد ضرراً من فتح الباب لملازمة الجلوس به .

كذلك يقضى بقطع أغصان شجرة بجوار إنسان أضرت بالجدار، كما يقضى بقطع الشجرة نفسها إذا صارت سلباً للصوص يصعدون عليها لبيت

(١) المسمط: هو الإناء الذي يوضع فيه مصارين البهيمة ورأسها وكرشها ويسمط ذلك في الماء الحار لإزالة ما فيها من الأقدار والشعر .

(٢) المصلق: هو الإناء الذي يطبخ فيه المصارين والرعوس بعد إخراج قدرها في المسمط ، حاشية الدسوقي ٣/٣٦٩ .

الجار، هذا إن كان الجدار أقدم من الشجرة أما إن كان الجدار أحدث من الشجرة من حيث النشأة فيقضى بقطع الأغصان، ولا يقضى بقطع الشجرة وهو ما رجحه ابن رشد .

مسائل لا يترتب على إحداثها ضرر:

١- من رفع بناءه على بناء جاره حتى منع عنه الضوء أو منع عنه الشمس أو الريح، فلا يمنع من البنيان وهذا هو المشهور.

ومقابلته: يمنع من رفع البنيان إن ترتب على رفعه منع ضوء أو شمس أو ريح وهو قول ابن نافع^(١).

٢- من أحدث على جاره أصواتاً لا تضر به ضرراً قوياً كصوت الكمد وهو دق القماش لتحسينه، والخياط، والحداد، وصانع الآلات المباحة - كالدف - عند تجربتها، ومعلم الصبيان عند رفع أصواتهم فلا يمنع من ذلك لخفتها، ما لم يشتد ويدوم وإلا منع .

٣- من أحدث بلكونة يخرج بها جهة السكة في علو حائطه لتوسعة العلو فلا يمنع من ذلك لعدم الضرر ما دام ملتزماً بالضوابط المقيدة لذلك .

٤- من أحدث ساباطاً - وهو جعل سقف على حائطين له - بسكة نافذة فلا يمنع من ذلك لأنه لا يترتب على ذلك ضرر بالمارين.

٥- من أراد صعود نخلة في داره أو شجرة لأخذ ثمرها أو تقليمها أو إصلاحها فلا يمنع من ذلك لكن يجب عليه أن ينذر جاره بطلوعه إياها خوف أن يشرف على عورة جاره، وقيل: الإنذار مندوب.

(١) مواهب الجليل ٥/ ١٦٥، الخرشي ٦/ ٣٧٨.

هذا بخلاف المنارة التي يشرف من صعد عليها للأذان على الجار فإنه يمنع، لأن الأذان يتكرر في اليوم خمس مرات فيتكرر الضرر بخلاف النخلة أو الشجرة فإن الصعود عليها نادر.

أمور يندب فعلها مع الجار وغيره:

١- يندب للإنسان أن يعير جداره ليغرز فيه جاره خشبة لما في الموطأ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره " ^(١)، ولأنه من المعروف ومكارم الأخلاق.

وحمل الإمام مالك ذلك على الندب لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ".

وحمل الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وداود وأبو ثور ^(٢) ذلك على الوجوب إذا لم يكن في ذلك مضرة على صاحب الجدار.

واستدلوا على ذلك بقول أبي هريرة - رضي الله عنه - "والله لأرmin بها بين أكتافكم" .

وأبو هريرة أعلم بمعنى ما سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما كان ليوجب عليهم غير واجب.

وبأن هذا من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالموافق. وأما قوله عليه الصلاة والسلام " لا يحل مال امرئ مسلم " إنما هو على التملك والاستملاك وليس الموافق ذلك، وكيف يكون منه والنبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بين ذلك فأوجب أحدهما ومنع الآخر.

(١) الموطأ كتاب الأقضية حديث رقم (٣٢).

(٢) الحاوي ٤٠٩/٨، المغني ٣٨/٥.

كما احتجوا بأن عمر بن الخطاب قضى بذلك، وقال لابن مسلمة والله ليمرن ولو على بطنك، وقال له لم تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضره فلو لم يكن ذلك واجباً عند عمر ما جبره على ذلك.

٢- اختلف في جاز المسجد هل له غرز خشبة في حائط المسجد أو ليس له ذلك؟ على قولين:

الأول: له غرز خشبة في حائط المسجد إن لم يضر به، وبه أفتى ابن عتاب.

الثاني: ليس له ذلك، وإليه ذهب ابن ناجي، وهو الذي أميل إليه.

٣- يندب للجار أن يدفع لجاره أو لقريبه أو لغيرهما ماء في بئر أو في عين أو في غيرهما فضل عن حاجته ليرتفق به في شرب أو في سقي زرع، ويتأكد ذلك في القريب، والجار لقوله تعالى (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا) النساء: ٣٦.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " يا نساء المسلمين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه " ^(١) أي ولو أن تهدي إليها الشيء الحقير الذي هو كرجل شاه .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " خير الأصحاب عند الله خيرهم نصيحة، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره " ^(٢) .

(١) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأدب

(٢) رواه أحمد في مسنده والترمذي والحاكم في مستدركه وقال حديث حسن.

واختلف في حد الجيرة فقليل: أربعون داراً من كل ناحية، وقيل: ستون داراً عن يمينه وستون عن يساره وستون خلفه وستون أمامه.

والجار على ثلاثة أقسام:

- جار له عليك حقان وهو الجار المسلم الأجنبي.
- وجار له عليك ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم الذي بينك وبينه قرابة.
- وجار له عليك حق واحد وهو الجار الذمي.

٤- يندب للمسلم أن يعين غيره في مهم كموت وعرس وسفر^(١) لما في حديث مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه "^(٢).

(١) مواهب الجليل وبهامشه التاج والإكليل ١٦٠/٥ - ١٧٥، الشرح الكبير ٣/٣٦٨ - ٣٧١، الشرح الصغير وبهامشه بلغة السالك ٣/٤٩١، حاشية الخرشي وبهامشه حاشية العدوي ٦/٣٦٨ - ٣٨١.

(٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه.

ملخص ما سبق دراسته في باب الشركة:

- ١- الشركة : إذن من أحد الشريكين للآخر في أن يتصرف له ولصاحبه .
- ٢- الشركة مشروعة في الجملة بالكتاب والسنة والإجماع .
- ٣- أركان الشركة : عاقدان (الشريكان) - معقود عليه (المال الذي تجوز به الشركة) - صيغة (كل ما يدل على الاشتراك من قول أو فعل أو إشارة مفهومة لمن لا يحسن النطق و الكتابة) .
- ٤- تصح الشركة من أهل التوكيل والتوكل ، أي ممن كان أهلا لأن يوكل غيره ويتوكل لغيره .
- ٥- تجوز مشاركة المسلم للذمي ، ومن في حكمه بشرط : أن يتولى المسلم أمر إدارة الشركة .
- ٦- المال الذي تجوز به الشركة يشترط فيه ما يشترط في المعقود عليه في باب البيوع بأن يكون طاهرا ، منتفعا به شرعا ، مقدورا على تسليمه ، معلوما للمتعاقدين ، موجودا وقت التعاقد يقينا أو ظنا .
- ٧- تتنوع الشركة إلى ستة أنواع : مفاوضة - عنان - جبر - عمل - ذمم (وجه) - مضاربة .
- ٨- التصرف الحاصل من أحد الشريكين تتصرف آثاره إليه ولصاحبه ، لأن كلا منهما وكيل عن صاحبه .
- ٩- نفقة الشريكين على أنفسهما وأولادهما من مال الشركة بشرطين : التقارب في الأولاد ، وعدم الزيادة على نفقة المثل .
- ١٠- الربح والخسارة في مال الشركة ، وكذا العمل يقسم على كل من الشريكين بقدر المالين من تساو وتفاوت إن شرطاً ذلك ، أو سكتا عنه .

أسئلة على باب الشركة :

س ١ : بين معنى الشركة ، واذكر حكمها ودليله من الكتاب والسنة والإجماع .

س ٢ : من أنواع الشركة : شركة الجبر . فما معناها ؟ وما حكمها؟
س ٣ : ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة ، و كلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة ؛ مبينا السبب:

- كل من جاز له أن يوكل جاز له أن يشارك .
- تصح الشركة بطعامين .
- ما يفعله أحد الشريكين من معروف يكون من مال الشركة.
- لكلا الشريكين الإقرار بدين في مال الشركة لشخص لا يتهم في محاباته.
- س ٤ : أكمل العبارات الآتية :
 - شركة العنان هي :.....
 - نفقة الشريكين من مال الشركة إذا تقاربا
 - ولم يخرجوا لأنهماويقتسمان الربح على قدر
 -جائزة بشروط : أنويتساويا في
 - ويحصل التعاون ويشتركان في الآلة التي تنتج لهما .

الباب الثاني
المزارعة وأحكامها

الهدف من دراسة باب المزارعة

يتوقع من الطالب بعد دراسة باب المزارعة معرفة الآتي :

- ١- معنى المزارعة، وحكمها، ودليل مشروعيتها .
- ٢- معرفة أنها أحد بل أهم مصادر الإنتاج الرئيسية، وأن الرسول حث الناس عليها .
- ٣- العلم بكيفية اقتسام الناتج بين مالك الأرض والعامل (المزارع) .
- ٤- معرفة طرق فض النزاع بين طرفيها إذا حدث ، ومعرفة أسباب فسخ عقدها .

المزراعة وأحكامها

أولاً: تعريف المزارعة:

المزراعة مأخوذة من الزرع وهو ما تنبته الأرض، وصيغة المفاعلة شأنها أن تكون من اثنين يفعل كل واحد منهما بصاحبه مثل ما يفعل الآخر به، مثل المضاربة لذا عبر اللخمي عنها بالشركة في الحرث.

وهي في اللغة: علاج ما تنبته الأرض.

وفي الشرع: إعطاء الأرض لمن يزرعها، ويعمل بها مقابل جزء من الزرع.

ثانياً: حكمها:

المزراعة مشروعة على خلاف الأصل ؛ لحاجة الناس إليها وقيام أمرهم عليها، فهي رخصة مستثناة من أصول ممنوعة، منها الإجارة بجزء مجهول، وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها - كما سيأتي.

وخالفنا أبو حنيفة فمنعها مطلقاً وإن خالفه أصحابه.

ثالثاً: دليل مشروعيتها:

وقد دل على مشروعية المزارعة السنة وفعل الصحابة والقياس.

من السنة: فما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنه) أن النبي (ﷺ) عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها، ولفظه: أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها^(١).

وجه الدلالة من الحديث:

أن رسول الله (ﷺ) أذن لأهل خيبر في زراعة الأرض على شطر ما يخرج منها، ولم يقتصر الإذن على السقي وعلاج الأصول القائمة فقط، بل امتد ليشمل

(١) حديث رقم ٢٣٣١.

كل ما يحتاج إليه الزرع من حرث وتسوية ومعالجة شاملة، وهذا دليل المشروعية.

وأما فعل الصحابة: فقد عامل عمر بن الخطاب الناس في المزارعة على: إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر والبقر والحرث من عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث.

وفي البخاري عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والرابع، وزارع على وسعد بن مالك وعبدالله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين^(١). ولم يُنقل عن الصحابة خلاف في جوازها.

أما القياس، فقياس المزارعة على القراض، فكما أنه يجوز لصاحب المال إعطاء ماله لمن يضارب به لحاجته إلى ذلك، يجوز لصاحب الأرض أن يعطي أرضه لمن يزرعها ويعمل بها مقابل جزء من الزرع، لحاجته إلى ذلك، فالعلة هي دفع الحاجة في كل منهما، بل هي أولى بالجواز من القراض، لأن الغرر والخطر فيها أقل.

وأما المنهي عنه في هذا الباب فهو المحاقلة والمخابرة.

والمحاقلة: هي كراء الأرض بكيل طعام.

وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالتمر، أو بيع الزرع قبل بدو صلاحه^(٢).

والمحاقلة منهي عنها، فقد روى مسلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله

قال: نهى رسول الله (ﷺ) عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى بدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا^(٣).

(١) فتح الباري حديث رقم ٢٣٢٨.

(٢) الموطأ بشرح الباجي ٤ / ٢١٩.

(٣) حديث رقم ١٥٣٦.

وعليه : ينبغي أن تحمل الروايات المطلقة التي عرفت المحاقلة بكراء الأرض على كرائها بالطعام خاصة، حملاً للمطلق على المقيد، لأن كراءها بالدينار والدرهم جائز كما في الحديث.

والمخابرة : هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها على أن يكون البذر من العامل.

وهي منهي عنها، لما رواه أبو داود بسنده قال: نهى رسول الله (ﷺ) عن المخابرة، فقال الراوي: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع^(١).

فالبذر يكون من العامل، ثم يأخذ من الثمر، فيؤدي إلى طعام بطعام نسيئة.

فالمخابرة والمزارعة والمحاقلة ألفاظ متقاربة، وهي إن سلمت من المخاطرة، أو استبدال طعام بطعام نسيئة فهي مزارعة مشروعة، وإن أدت إلى الغرر والمخاطرة أو إلى الطعام بالطعام نسيئة فهي مخابرة ومحاقلة منهي عنها^(٢).

رابعاً: صفة عقد المزارعة:

عقد المزارعة له شبه قوي بعقد القراض والمضاربة من حيث إنه عقد بين رب الأرض والعامل على اقتسام الثمرة والغلة، وله شبه قوي أيضاً بالإجارة والكراء، لذا اختلف في لزومها بالعقد وحده إذا لم يصحبه عمل.

ف قيل: تلزم بالعقد تغليباً للإجارة ، وهو قول سحنون وابن الماجشون ورواية

عن ابن القاسم.

(١) حديث رقم ٢٩٠٧.

(٢) مدونة الفقه المالكي وأدلته د/ الصادق الغرياني ٣ / ٥٦٤.

وقيل: لا تلزم بمجرد العقد بل بالبذر ونحوه، أي إلقاء الحب على الأرض لينبت أو وضع الزريعة بالأرض مما لا بذر لحبه، كالبصل والقصب، وهو قول ابن القاسم في المدونة.

وقيل: إنها تلزم بالعقد إن انضم إليه عمل كحرث الأرض وتقليبها^(١).
قياساً على الجعالة إذا أن الجاعل يلزمه الجعل بشروع المجعل له في العمل^(٢).

فالأقوال ثلاثة، لكن مسائل الباب مبينة عند علمائنا على أن المزارعة من قبيل الشركة، لذا اشترطوا فيها شرطين:

الشرط الأول: أن يكون الربح فيها على قدر ما أسهم به كل واحد من الشريكين، كأن يجعل للأرض قيمة مثلاً، وللعمل قيمة، وللآلات قيمة، والنفقات الأخرى قيمة، ويكون ربح كل واحد بقدر ما أسهم به، وما قد يكون في ضمانهما معاً.

فمن أسهم بثلاث التكاليف كان له من الربح الثلث، ومن أسهم بالربع كان له الربع وهكذا.

الشرط الثاني: السلامة من كراء الأرض بما يخرج منها، فلا يصح أن يجعل البذر مقابل الأرض، لأن ذلك محاقلة - كما سبق - وهي فاسدة للغرر. وبناء على ما تقدم فإن لكل واحد من الشريكين أو الشركاء فسخ المزارعة إن لم يبذر، ترجيحاً لمن غلب جانب الشركة في المزارعة على جانب الإجارة^(٣).

خامساً: شروط المزارعة:

اشترط العلماء لصحة المزارعة شروطاً أربعة:

(١) حاشية الصاوي ٢/ ١٧٨، الشيخ الصادق ٣/ ٥٧٠.

(٢) مواهب الجليل للخطاب ٥/ ١٧٧.

(٣) حاشية الرهوني ٦/ ١٠١.

أولها: السلامة من كراء الأرض بأجر ممنوع كراؤها به، وهو الطعام، ولو لم تنبت الأرض كعسل، وما تنبته ولو غير طعام كقطن وكتان، إلا الخشب فيجوز، لأنه ليس مما يزرع، كما يجوز كراؤها بالبوص الفارسي والصندل والشب والكبريت ونحوهما من المعادن، لأنها ملحقة بالخشب.

ومعنى هذا الشرط: أن لا تقع الأرض أو بعضها في مقابلة بذر، كأن يكون كراؤها بذهب أو فضة أو عرض أو حيوان، فإن قابلها بذر كأن يكون البذر من أحدهما والأرض للآخر فسدت على المشهور^(١).

وذهب الشافعية على أن محل منع كراء الأرض بما يخرج منها: إذا اشترط الأخذ من عين ما يخرج من خصوص تلك البقعة صريحاً ولم يكتفوا بالجنس. والدليل على منع فساد المزارعة عند انتفاء هذا الشرط: حديث رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول الله (ﷺ) حتى روي لنا عنه أنه قال: من كانت له أرض فيلزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها بثلاث ولا بربع أو بطعام مسمى^(٢).

ولأنه بيع للطعام بطعام متأخر ومجهول.

وأما الدليل على فساد المزارعة إذا كانت بكتان أو قطن أو بعض ما يخرج منها وإن لم يكن طعاماً فمنهيه (ﷺ) عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها^(٣).

ثانيها: أن يكون الربح مطابقاً للمخرج، أي أن يقابل الأرض ما يساويها من غير البذر على قدر الربح الواقع بينهما، كأن تكون أجرة الأرض مائة، والبقر والعمل خمسين، ودخل على أن لرب الأرض الثلثين ولرب البقر والعمل الثلث، أو يكون أجرتها مائة كالأرض، ودخل على النصف فتجوز فيها، وإلا فسدت

(١) حاشية الدسوقي ٣/ ٣٧٣.

(٢) سنن الإمام أحمد ٢٩ حديث رقم ١٧٥٣٩.

(٣) سبق تخريجه.

لأنها شركة فوجب أن يكون الربح مطابقاً للمخرج، فإذا دخلا على شرط التفاوت فسدت^(١).

ويجوز أن يتبرع أحدهما للآخر بزيادة من عمل أو ربح بعد لزوم عقد المزارعة بالبذر، لأن التبرع لا يكون إلا بعد العقد، أما ما كان في العقد فليس يتبرع ولو صرحوا به، لأنه حينئذ مدخول عليه فهو مشترط^(٢).

ثالثها: تماثل البذرين جنساً وصنفاً من الشريكين إن أخرجاه من عندهما، كما لو كانت الأرض بينهما، وأخرج كل منهما حصته في البذر، فلا بد من تماثلها كقمح أو شعير أو فول أو نحو ذلك، فإن أخرج أحدهما قمحاً والآخر فولاً أو شعيراً لم تصح، ولكل واحد ما أنبته بذره، ويتراجعان في الأكرية. وقيل: بالصحة أيضاً.

رابعها: خلط البذرين إن كان منهما معاً خلطاً حقيقياً أو حكماً، بأن يحمل كل بذره إلى الأرض ويبذره بها من غير تمييز لأحدهما عن الآخر، فإن تميز بذر كل بجهة فلا شركة بينهما، ولكل واحد ما أنبته حبه، ويتراجعان في الأكرية ويتقاصان، وهذا ما ذهب إليه سحنون في أحد قولييه.

واشترط الخلط لأن المزارعة شبيهة بالإجارة، والبذر فيها أشبه بالأجرة المعينة، وهي لا بد من تعجيلها في الجملة، فطلب هنا الخلط لأنه بمثابة التعجيل^(٣).

وذهب الإمام مالك وابن القاسم إلى أنه لا يشترط الخلط حساً ولا حكماً، فلو بذر كل منهما بجهة غير الآخر صحت. وهو القول الآخر لسحنون، وهو الراجح الذي به الفتوى^(١).

(١) شرح الخرشي ٦٣ / ٣.

(٢) حاشية الدسوقي ٣٧٣ / ٣.

(٣) حاشية الخرشي ٦٤ / ٣.

مسألة متفرعة على قول مالك^(١):

وتفريعاً على ما ذهب إليه الإمام مالك من عدم اشتراط خلط البذرين بصحة المزارعة: فإن الشريكين إذا لم يخلطا البذر، وإنما حمل كل واحد منهما بذره إلى جهة من الأرض بنية الشركة وبذر كل بذره على حدة وتميز موضع كل منهما، ولم ينبت بذر أحدهما، فإن الذي لم ينبت بذره لا يخلو حاله من أمرين:

الأول: أن يغر صاحبه، الثاني: أن لا يغره.

فإن غر صاحبه بأن علم أنه لا ينبت، بأن كان قديماً أو مسوساً، فإنه لا يحتسب به في الشركة، والشركة باقية بينهما، ويغرم الذي لم ينبت بذره مثل نصف النابت، ونصف كراء الأرض، ونصف قيمة العمل فيه.

وإن لم يغر شريكه، بأن لم يكن عنده علم أنه لا ينبت، أو يعلم ذلك وبينه لشريكه، فإن الشركة بينهما أيضاً ثابتة، لكن يغرم كل واحد لصاحبه مثل نصف بذره، فيغرم الذي نبت بذره للذي لم ينبت بذره مثل نصف بذره الذي لم ينبت أي قديماً مسوساً، ويغرم الذي لم ينبت بذره للذي نبت بذره مثل نصف بذره أي صحيحاً جديداً. وهذا إذا فات الإبان في الصورتين، فإن لم يفت، بأن كان وقت الزراعة ما زال باقياً، فعلى الغار الإتيان ببذر جيداً فيزرعه. وفي حالة عدم الغرور يخرج كل واحد منهما قدر حصته منه، ويزرعانه إن أحبا ذلك.

سادساً: صور المزارعة الجائزة:

تجوز المزارعة في الصور الخمس الآتية التي سلمت من جعل الأرض أو جزء منها مقابل البذر، وذلك على الوجه الآتي:

الصورة الأولى: أن يتساوى الشريكين في جميع ما أخرجاه، بأن تكون الأرض بينهما، والعمل بينهما، والآلة كذلك بكراء أو ملك منهما، أو من أحدهما.

(١) الشرح الصغير ٢ / ١٧٩.

(٢) الشرح الكبير ٣ / ٣٧٤، شرح الخرشي ٣ / ٦٥.

فالشركة بهذا تكون صحيحة، ويأخذ كل واحد منهما من الربح بقدر ما أخرج.

والعمل الذي يجوز اشتراطه هو الحرث دون الحصاد والدراس، فلا يجوز اشتراطهما على مذهب ابن القاسم، لأنهما مجهولان لا يدري كيف يكونان، وشأن ذلك قد يقل ويكثر^(١).

الصورة الثانية: أن يقابل البذر من أحدهما عمل من الآخر، والأرض بينهما بملك أو كراء، بشرط أن تكون قيمة العمل مثل قيمة البذر. فالشركة صحيحة أيضاً.

الصورة الثالثة: أن يقابل الأرض والبذر عمل من الآخر، بمعنى أن تكون الأرض والبذر من جانب أحد الشريكين، والعمل بيد أو بقر أو آلة من الجانب الآخر، فتصح الشركة بهذا أيضاً.

الصورة الرابعة: أن تكون الأرض من جانب، والعمل من الجانب الآخر والبذر بينهما بشرط أن لا ينقص ما يأخذه العامل من الزرع عن نسبة بذره، بأن زاد أو ساوى، كما لو أخرج ثلث البذر وأخذ النصف، أو أخرج النصف وأخذ النصف.

وأما إن نقص ما يأخذه العامل من الزرع عن نسبة بذره، كما لو أخرج مع عمله ثلثي البذر، وأخرج صاحب الأرض ثلث البذر على أن الزرع بينهما مناصفة فسدت الشركة، لأن زيادة البذر هنا كراء الأرض وهو لا يجوز - كما سبق.

الصورة الخامسة: مسألة الخمّاس، وهي أن يكون العمل مقابل الأرض والبذر والآلة، وله من الزرع جزء، كربع أو غيره من الأجزاء، فهي صحيحة اتفاقاً

(١) شرح الخرشي ٦٥ / ٣.

إن عقداها بلفظ الشركة، لأن الشركة على جزء مشاع من الربح جائزة، وإن عقداها بلفظ الإجارة فسدت، لأنها إجارة بجزء مجهول.

وإن أطلقا بأن لم يذكر شركة أو إجارة، فقد حملها ابن القاسم على الإجارة فتكون فاسدة، لأن من خاصية الشركة أن يخرج كل مالا، ولا يشترط فيها معرفة ما ينوبه من الخارج، وفاسدة لأن من شروط الإجارة كونها في مقابلة عوض معلوم، وهنا لا يعرف الخارج. وحملها سحنون على الشركة فجوزها، لأنه يرى أن عمل العامل كالمال في الشركة^(١).

والمراد بالعمل الحرث لا الحصاد والدراس لأنه مجهول، فمتى شرط عليه أزيد من الحرث فسدت، والعرف كالشرط، وأما لو تطوع بأزيد من الحرث بعد العقد كالسقي والتنقية والحصاد ونحوها فذلك جائز.

سابعًا: الصور الممنوعة في المزارعة:

تفسد المزارعة إذا اختل شرط من شروط صحتها، كما تفسد إذا كانت صورتها واحدة من الصور الآتية:

- ١- أن يقع التفاوت بين ما يخرج من يد الشريك وما يعود عليه من الربح فيها - كما تقدم.
- ٢- أن يقابل الأرض من أحد الشريكين البذر من الشريك الآخر، كأن تكون أرض وعمل من جانب، وبذر من الجانب الآخر، فتفسد اتفاقًا.
- ٣- إذا أخرج أحدهما أرضًا لها قدر وبال، فألغاهما لصاحبه وتساويا فيما عداها من البذر والعمل، فإنه لا يجوز، لما فيه من كراء الأرض بما يخرج منها، إلا أن يدفع له صاحبه نصف كراء الأرض، فتصح حينئذ.

(١) شرح الزرقاني على المختصر ٦/ ٧٠، حاشية الدسوقي ٣/ ٣٧٥.

وأما إذا كانت الأرض لا قدر لها، فإنه يجوز إلغاؤها، لأن مالا بال له كالعدم^(١).

٤- إذا أخرج أحدهما أرضاً ولو رخيصة لا بال لها وعمل، وأخرج الآخر البذر، ففاسدة لمقابلة جزء من الأرض بالبذر.

ثامناً: حكم المزارعة إذا فسدت:

المزارعة إذا وقعت فاسدة، بأن اختل شرط من شروط صحتها أو وجد مانع فإنها تفسخ قبل العمل، فإن فاتت بالعمل وتساويا فيه، فإن الزرع يكون بينهما على قدر عملهما، لأنه نشأ عنه، وبترادان غير العمل، كما لو كانت الأرض من أحدهما، والبذر من الآخر فيرجع صاحب البذر على صاحب الأرض بمثل نصف بذره، ويرجع صاحب الأرض على صاحب البذر بأجرة نصف أرضه، ولا خفاء في فساد هذه الصورة، لمقابلة الأرض بالبذر.

وأما إذا لم يتكافأ في العمل، بل كان العامل أحدهما فقط، فالزرع كله يكون للعامل، لأنه نشأ عن عمله، وعليه أجرة الأرض لصاحبها، وأجرة الآلة لصاحبها، فإن كانت الأرض للعامل فعليه ثمن البذر لصاحبه، لكن شرط اختصاص العامل بالزرع: أن يكون له مع العمل إما بذر، والأرض للآخر، أو أرض والبذر للآخر. وفسادها كان لمقابلة البذر جزءاً من الأرض.

وإذا كان الشركاء ثلاثة فأكثر فالزرع لمن له شيئان منها، سواء تعدد من له الشيئان أو انفرد.

فإن انفرد فظاهر، وإن تعدد كان بينهما، أو بينهم، وأعطى لمن انفرد بشيء مثل بذره، إن كان ما انفرد به بذراً، أو أجرته إن كان غير بذر.

(١) الشرح الصغير ٢ / ١٨٠.

فلو انفرد كل واحد منهم بشيء واحد من الأصول الثلاثة وهي البذر، والأرض، والعمل، ففيه أقوال ستة:

القول الأول: الزرع بينهم أثلاثاً، كما لو كان لكل منهم شيئان. وهو مذهب ابن القاسم.

القول الثاني: أن الزرع لصاحب البذر، وعليه لأصحابه أجر ما أخرجوه.

القول الثالث: أن الشركة إن فسدت للمخابرة - أي كراء الأرض بما يخرج منها - فالزرع لرب البذر، وإن فسدت لغيرها كان بينهم على ما شرطوا وتعادلوا فيما أخرجوه، وهو لابن حبيب.

القول الرابع: أن الزرع لصاحب عمل اليد ولو انفرد به، وعليه لأصحابه ما أخرجوه من بذر أو أرض.

القول الخامس: لمن اجتمع له شيئان من أربعة أشياء: أرض، وبذر، وعمل، ويقر.

القول السادس: لمن له شيئان من ثلاثة أشياء: أرض، وبقر، وعمل^(١).

(١) الشرح الصغير ٢ / ١٨٠.

ملخص ما سبق دراسته في باب المزارعة :

- ١- المزارعة : عقد بين مالك الأرض ومن يقوم بزراعتها على جزء من الخارج .
- ٢- يشترط في الأرض أن تكون صالحة للزراعة .
- ٣- المزارعة مشروعة على الخلاف ، ومقيدة بشروط عند القائل بها.
- ٤- تلزم المزارعة بالبذر للحب وما في معناه ، كوضع الزريعة في الأرض مما لا بذر له ، كالبصل والقصب .
- ٥- الزارع الحقيقي للأرض هو الله سبحانه وتعالى ، وفعل الإنسان حرث ، قال تعالى " أفرايتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون " .

أسئلة على باب المزارعة:

- س ١ : بين معنى المزارعة ، واذكر حكمها ودليله .
- س ٢ : من شروط المزارعة : أن يسلم من كراء الأرض بممنوع. اشرح ذلك.
- س ٣ : ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة ، وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة مبينا السبب:
- المزارعة عقد يلزم بتقليب الأرض .
 - الربح يكون بين صاحب الأرض والزارع بنسبة الخارج .
- س ٤ : أكمل العبارة الآتية :
- تصح المزارعة بشروط أولها والثاني : أن يدخل على أن الربح والثالث : البذران ، وجاز من أحدهما للآخر من أو ربع " .

الباب الثالث
الإقرار

الهدف من دراسة باب الإقرار.

يتوقع من الطالب بعد دراسة باب الإقرار أن يصل إلى الأهداف الآتية :

- ١- الوقوف على معنى الإقرار ، وأدلة اعتباره، وشروط العمل به .
- ٢- الحكمة التشريعية من الأخذ بالإقرار .
- ٣- العلم بأن الاعتراف سيد الأدلة .
- ٤- العلم بأن للإقرار تأثيره في التقاضي، والحكم الصادر من القضاة ، مما يكون له أكبر الأثر في طمأنينة الأفراد والمجتمع .
- ٥- بالإقرار يتحلل الإنسان من تبعات الدنيا ، حتى يلقي الله طاهرا محررا في الآخرة .

الإقرار

أولاً: تعريف الإقرار:

الإقرار لغة: الإثبات، مأخوذ من قولهم: قر الشيء يقر قراراً إذا ثبت.
وشرعاً: الاعتراف بما يوجب حقاً على قائله بشرط، سواء كان ذلك يتضمن مالاً أو عقوبة كحد وقصاص^(١).

ثانياً: حكم الإقرار:

ظهور ما أقر به المقر، لا ثبوت الحق وإنشاؤه من أول الأمر، لأنه خبر، كالدعوى والشهادة، ولا يتوهم من إيجابه حكماً على المقر أنه إنشاء، والإقرار حجة قاصرة على المقر، لا يتعدى أثره إلى غيره، وهو سيد الأدلة، لانتفاء التهمة فيها^(٢).

ثالثاً: دليل حجته:

والأصل في مؤاخذة المكلف بإقراره الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

(١) تبين المسالك ٤ / ٧٨، الشرح الصغير للدردير ٢ / ١٩٠.

(٢) المبسوط ١٧ / ١٨٤، الفقه الإسلامي وأدلته د/ وهبة الزحيلي ٦ / ٦١٢.

أولاً: الكتاب:

الأول: قوله تعالى: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾^(١).

قال ابن العربي: فيها دليل على قبول إقرار المرء على نفسه، لأنها شهادة منه عليها، قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢) ولا خلاف فيه، لأنه إخبار على وجه تنفي التهمة عنه، لأن العاقل لا يكذب على نفسه^(٣).

الثاني: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾^(٤) قال ابن عطية: وشهادة المرء على نفسه إقراره بالحقائق وقوله الحق في كل أمر، وقيامه بالقسط عليها كذلك^(٥).

ثانياً: السنة النبوية:

ومنها:

١- عن أبي ذر (رضي الله عنه) قال: قال لي النبي (ﷺ): "قل الحق ولو كان مرّاً". قال الصنعاني: وفيه دلالة على اعتبار إقرار الإنسان على نفسه في جميع الأمور، وهو أمر عام لجميع الأحكام، لأن قول الحق على النفس هو الإخبار بما عليها مما يلزمها التخلص منه بمال أو بدن أو عرض^(٦).

(١) الآية ١٤، ١٥ سورة القيامة.

(٢) الآية ٢٤ سورة النور.

(٣) أحكام القرآن لابن العربي ٤ / ٣٤٤.

(٤) من الآية ١٣٥ سورة النساء.

(٥) المحرر الوجيز ٤ / ٢٥٥.

(٦) سبل السلام ٣ / ٨٩٧.

٢- ما روي عن أبي هريرة مرفوعاً في قصة العسيف "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"^(١) فاعتبر الرسول (ﷺ) الاعتراف كطريق لإثبات الحد عليها.

ثالثاً: الإجماع:

فإن الأمة الإسلامية أجمعت على صحة الإقرار وأنه طريق من طرق الإثبات الشرعية، كما أنه لا خلاف عند جميع الأئمة أن المكلف غير المحجور عليه مؤاخذ بإقراره طائعاً في صحته^(٢).

رابعاً: القياس:

فهو أننا إذا قبلنا الشهادة على الإقرار، فلأن نقبل الإقرار أولى^(٣).

رابعاً: أركان الإقرار:

أركان الإقرار أربعة: مقر، ومقر له، ومقر به، وصيغة.

الركن الأول: المقر، وهو الشخص الذي أقر بحق عليه، ويشترط فيه حتى يصح إقراره الشروط الآتية:

١- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً، فلا يقبل إقرار الصبي والمجنون لقوله (ﷺ) "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق" ويلحق بالمجنون السكران فلا يؤاخذ بإقراره في المعاملات.

٢- أن يكون طائعاً، فلا يصح إقرار المكره ولا يلزم، لأنه غير مكلف، ولقوله (ﷺ) "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

(١) رواه البخاري ٦/ ٢٥٠٣، ومسلم ٣/ ١٣٢٥.

(٢) تبیین المسالك ٤/ ٧٩.

(٣) الفقه الإسلامي د/ وهبة الزحيلي ٦/ ٦١١.

٣- أن يكون غير محجور عليه في المعاملات، فلا يقبل إقرار السفية المحجور عليه والرقيق بالنسبة للمال، فكل منهما وإن كان مكلفاً، لكنه محجور عليه بالنسبة للمال، أما إقرار السفية والرقيق في الجنايات والحدود فمقبول. كذلك يقبل إقرار السفية المهمل، والرقيق المأذون له في التجارة والمكاتب مطلقاً أي في الجنايات والحدود والأموال، فيلزم كلاً منهم ما أقر به لعدم الحجر^(١).

وذهب ابن القاسم إلى أن السفية المهمل والمحجور عليه سواء في عدم المؤاخذه بالإقرار في المعاملات المالية، لأن المانع عنده من التصرف السفه لا الحجر^(٢).

٤- أن يكون غير متهم في إقراره، فإن اتهم بإقراره لملاطفة أو صداقة أو نحوهما بطل، لأن التهمة تخل برجحان الصدق على الكذب في إقراره، وهذا الشرط إنما يعتبر في المريض والحامل والحاضر صف القتال والمحبوس لقتل أو قطع، وكذا يعتبر في الصحيح المفلس بالنسبة لما فلس فيه، فلا يقبل إقراره لأحد حيث كان الدين الذي فلس فيه ثابتاً بالبينة، لأنه يتهم على ضياع مال الغرماء، أما ما تجدد له في المستقبل من المال فيقبل إقراره فيه لتعلق الإقرار بذمته.

٥- أن يكون المقر معلوماً، فلو قال رجلان "فلان على واحد منا ألف درهم" لا يصح الإقرار، لأن المقر إذا لم يكن معلوماً لا يتمكن المقر له من المطالبة بالمقر به، فلا يكون فيه فائدة.

الركن الثاني: المقر له، ويشترط فيه حتى يصح القرار له شرطان:

١- أن يكون أهلاً للإقرار له، والمراد بالأهل، القابل لأن يملك ما أقر به ، ولو باعتبار المآل كالحمل بأن يقول: إن لهذا الحمل عندي الشيء الفلاني

(١) الشرح الكبير للدريدر ٤/ ٣٩٧.

(٢) حاشية الصاوي ٢/ ١٩٠، حاشية الدسوقي ٤/ ٣٩٧.

من ميراث أبيه مثلاً، فالحمل قابل لملك ذلك باعتبار المآل، أو قابل لأن يملك ما أقر به باعتبار ما يتعلق به من إصلاح لبقاء عينه أو استحقاق، كالوقف والمسجد، فالوقف قابل لملك المقر به من حيث أخذ المستحقين له، والمسجد قابل لملك المقر به باعتبار ما يتعلق به من الإصلاح.

فإذا كان المقر له ليس أهلاً لملك ما أقر به، فلا يؤخذ المقر بإقراره له. فلو أقر شخص لحجر أو دابة، فإن إقراره غير لازم فلا يؤخذ به لهما، بل هو باطل، اللهم إلا أن يقر للحجر لأجل أن يوضع في كسبيل، أو للدابة من حيث علفها في جهاد، فيصح إقراره، وحينئذ يرجع للحبس (الوقف)^(١).

٢- أن يصدق المقر له المقر في إقراره، فإن كذبه بأن قال للمقر: ليس لي عليك شيء أو قال: لا علم لي بما أقررت به لي، بطل الإقرار ولكن بشرطين:

(أ) أن يستمر التكذيب من المقر له للمقر، فإن رجع المقر له إلى تصديق المقر صح الإقرار ولزم ما لم يرجع المقر، فإن رجع المقر في صيغة التكذيب الأولى (ليس لي عليك شيء) عقب تصديق المقر له، فهل يلزم إقراره أو يبطل؟ قولان:

القول الأول: هو الذي عزاه ابن رشد للمدونة، **والقول الثاني:** هو الذي في النوادر وعليه اقتصر ابن الحاجب^(٢).

وأما إنكار المقر عقب تصديق المقر له في صيغة التكذيب الثانية (لا علم لي بما أقررت) فلا عبرة به، والإقرار صحيح باتفاق.

(ب) أن يكون التكذيب من المقر له البالغ الرشيد، أما تكذيب المقر له الصبي أو السفیه فلغو، لا يعتبر وحينئذ يلزم المقر ما أقر به لهما وإن كذباه^(١).

(١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٢/ ١٩٠.

(٢) حاشية الدسوقي ٣/ ٣٩٨.

الركن الثالث: المقر به:

وهو نوعان: المال، ويشترط فيه ألا يتعلق به حق الغير، فإن تعلق به حق الغير، فلا يصح الإقرار، كإقرار المريض مرض الموت بدين لوارثه، فلا يصح إقراره إلا بإجازة الورثة إلا إذا ثبت الدين ببينة.

العقوبة: وهو الإقرار بجناية تستلزم عقوبة، كالإقرار بالقتل أو الزنا، أو القذف، أو السرقة، فيقام عليه بالإقرار العقوبة المحددة للجناية التي ارتكبها، ويصح في هذا النوع من الإقرار الرجوع قبل إقامة الحد عليه، لاحتمال صدقه، سواء كان الرجوع بشبهة أو غير شبهة على الراجح، أما الرجوع عن الإقرار في النوع الأول، فغير مقبول، والفرق، أن المال حق العبد، والحد حق الله^(٢).

وهناك نوع ثالث من الإقرار، وهو إقرار الأب ببنة طفل، ويسمى استلحاقاً وسأعقد له مبحثاً في نهاية الباب نقف فيه على أحكام هذا النوع من الإقرار.

الركن الرابع: الصيغة، وهي اللفظ الدال على الإقرار، كأن يقول المقر: على لفلان ألف جنيه، أو في ذمتي له ألفاً، أو أعطيتني ألفاً، أو أخذت منك ألفاً، فإن هذا وشبهه صريح في هذا الباب، ويكون إقراراً^(٣).

هذا ويشترط في اللفظ أن يكون بيئاً حتى يلزم المقر ما أقر به من مال أو حد أو قصاص، فإن كان لفظاً محتملاً؛ حمل على أظهر معانيه، وفي هذا الباب فروع كثيرة اختلف الفقهاء فيها لاختلاف معانيها نذكر بعضاً منها تحت هذا العنوان الآتي في "خامساً".

(١) الشرح الكبير للدردير ٤ / ٣٩٨.

(٢) القوانين الفقهية ص ٢٧١.

(٣) الشرح الكبير للدردير ٣ / ٤٠٢.

خامساً: أحكام مخرجة على شروط صحة الإقرار:

أ- تقيد الإقرار بالمشيئة:

إذا عقب المكلف إقراره بإن شاء الله، أو إن قضى الله، بأن قال: لفلان علي ألف إن شاء الله أو إن قضى الله، فإن ذلك لا يضر في الإقرار، ويلزمه لأنه لما نطق بالإقرار علمنا أن الله قد شاء وقضاه، ولأن الاستثناء لا يفيد في غير الحلف بالله، بخلاف إن شاء فلان، كأن يقول: عندي مائة جنيه لفلان إن شاء فلان، فلا يلزمه شيء ولو قال فلان: شئت ذلك، لأنه خطر، لأنه حين قال ذلك كان مجوراً أن يشاء وأن لا يشاء وقد يقول المقر: ظننت أنه لا يشاء^(١).

ب- دعوى المقر أن المقر به ملكه بهبة أو بيع:

إذا ادعى شخص على شخص بحق، فقال المدعى عليه: نعم كان له حق عندي لكن وهبه لي، فإن الإقرار يلزمه، ويثبت أنه وهبه له، وهل يحلف المقر له أنه ما وهبه أو لا؟ خلاف، مبني على الخلاف في اليمين هل تتوجه في دعوى المعروف أو لا؟ وكذلك يلزمه الإقرار إن ادعى عليه بحق فقال: بعته لي، ويثبت أنه باعه له، لأنه أقر بالملك للمدعي وادعى خروجه عنه، فإذا طلب المدعي عليه يمين المدعي، فإنه يحلف بلا خلاف، وكذلك يلزم الإقرار من طلب منه دين فقال: وفيته لك ويبين أنه وفاه له.

ومحل كون دعوى الهبة أو البيع إقرار بالشيء: إذا لم تحصل الحيابة

المعتبرة شرعاً، فإن مضت مدة الحيابة المعتبرة، وقال المدعى عليه إنه باع لي أو وهب لي، فإنه يصدق في ذلك بيمينه، ولا يكون هذا إقراراً بالملك للمدعي^(٢). ومدة الحيابة المعتبرة شرعاً عشرة أعوام^(١).

(١) شرح الخرشي ٩١ / ٦.

(٢) حاشية الدسوقي ٤٠٢ / ٣.

ج- الإقرار بصيغة الاستفهام:

إذا قال شخص لآخر: أما أقرضتني الألف جنيه، أو قال له: ألم تقرضني الألف، فإنه يلزمه الإقرار بشرط: أن يصدقه المقر له في إقراره بقوله بلى أو بقوله نعم أو أجل، فإن ادعى الطالب المال فإنه يلزم المقر، ولا ينفعه الجحد بعد ذلك.

وتصديق المقر له المقر في إقراره إنما يحتاج إليه إذا وقع هذا اللفظ من المقر ابتداءً، وأما إذا وقع قوله أما أقرضتني وما بعده جواباً لقول الطالب: لي عندك كذا، فلا يحتاج لإجابة الآخر، لأن هذا اللفظ إقرار مطلقاً قال نعم أو لا.

د- حكم من قال لمدعي الحق ساهلني أو ليس لي ميسرة:

إذا قال شخص لآخر: أليس لي عندك عشرة دنانير؟ فقال الآخر: ساهلني فيها أو اتزنها مني، أو لا قضينك اليوم، أو قال له: نعم أو بلى أو أجل، فإنه يلزمه الإقرار بذلك.

لكن اللزوم في بلى ظاهر، لأنها توجب الكلام المنفي، أي تصيره موجباً بعد أن كان منفيّاً، وأما قوله نعم بعد قول المدعي له: أليس لي عندك كذا؟ فإنما لزم بها الإقرار على عرف الناس، لأن الإقرارات مبنية على ذلك، لا على مقتضى اللغة على الصحيح، لأنها تقرر الكلام الذي قبلها، نفيّاً كان أو إيجاباً، ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ لو قالوا نعم لكفروا، أي لأنهم قالوا لست ربنا^(٢).

(١) انظر رسالتنا الدكتوراه نظرية الإجازة وأثرها في العقود والتصرفات في الفقه الإسلامي ص ٢٤٠.

(٢) شرح الخرشي ٦ / ٩١.

وكذلك يلزمه الإقرار لو قال بعد قول المدعي: أليس لي عندك كذا؟ ليس لي ميسرة، لأنه بمنزلة من قال نعم، وطلب المهلة في ذلك^(١).

هـ- حكم الإقرار مع المناكرة:

إذا عقب المقر إقراره بما يوهم أنه رافع لحكمه، لا ينفعه ذلك، ويلزمه ما أقر به، فإن قال له: علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو نحوهما مما لا يصح بيعه، وناكره المقر له، أي كذبه، وقال له: بل الألف من ثمن عبد أو بر أو شبهه، فإنه يلزمه ما أقر به، لأنه لما قال له علي ألف، أقر بعمارة ذمته، وبعد قوله بعد ذلك من ثمن خمر ندمًا، ويحلف المقر له أنها ليست من ثمن خمر إن كان مسلمًا، فإن كان ذميًا، فإن ناكراً المقر في ذلك، فكذلك، وإن لم يناكر فلا يلزمه ما أقر به من الثمن، لأنه شراء فاسد، ويلزمه قيمة الخمر أو الخنزير إن فوته^(٢).

كذلك يلزمه الإقرار لو قال: علي ألف من ثمن عبد ولم أقبضه منك، وقال البائع: بل قبضته مني، وكذلك لو قال عقب إقراره: هي من ربا، أو أقام بينة بذلك، فإن الإقرار يلزمه، ولا تنفعه البينة لاحتمال أنه ربا في غير هذه المعاملة، إلا إذا أقام البينة على إقرار المدعي أي المقر له أنه لم يقع بينهما إلا الربا، فلا يلزمه القدر الزائد على رأس المال، ويرد رأس المال قولاً واحداً لعدم إمكان الشروع^(٣).

سادسًا: صيغ لا يلزم بها الإقرار:

هناك صيغ كثيرة لا يلزم بها الإقرار ولا يثبت بها حق للمقر له منها:

(١) الشرح الكبير للدردير ٤٠٣/٣.

(٢) حاشية الدسوقي ٤٠٣/٣، شرح الخرشي ٩٢/٦.

(٣) الشرح الكبير ٤٠٣/٣.

■ إذا أقر شخص بأنه اشترى من فلان خمراً بألف، فلا يلزمه شيء، لأنه لم يقر بشيء في ذمته.

■ وكذلك لو قال: اشتريت منك عبداً بألف ولم أقبضه، لأن الشراء لا يوجب عمارة الذمة إلا بالقبض ولم يقر به، لكن هذه المسألة فيها بحث، لأن الضمان من المشتري بمجرد العقد، فلا يعتبر القبض إلا أن يفرض في عبد غائب، ليكون الضمان فيه من البائع.

■ وكذلك لا يلزم الإقرار بقوله لمن ادعى عليه بأنه أقر بشيء: أقررت بكذا وأنا صبي أو مجنون، لأنه لم يقر على نفسه بما يلزمه بشيء.

سابعاً: الإقرار على وجه الاعتذار:

إذا جاء شخص يسأل شخصاً شيئاً على وجه الإعارة أو الشراء أو الصدقة أو نحو ذلك، فقال المسئول: هذا الشيء لفلان، فإن المقر له لا يأخذه إلا ببينة تشهد له بملكه قبل الإقرار بشرط: أن يكون السائل ممن يعتذر له، فإن كان ممن لا يعتذر له لرذالته، فإن المقر له يأخذه بغير بينة.

وذهب بعض الفقهاء: أن المقر له لا يأخذ المقر به إلا ببينة تشهد له بملكه قبل الإقرار، كان السائل ممن يعتذر له أم لا^(١).

ثامناً: الإقرار على وجه الشكر أو الذم:

إذا أتى بالإقرار على غير وجه الإقرار، بل على وجه الشكر كأن يقول: جزى الله فلاناً خيراً أقرضني مائة وقضيتها له، أو على وجه الذم، كأن يقول: قبح الله فلاناً أقرضني مائة، وضيق علي حتى وفيتها، فقام المقر له أو ورثته إن كان قد مات يطلبون المقر بما أقر به ويدعون أنه لم يقض ما اقترض،

(١) حاشية الدسوقي ٣/ ٤٠٤.

فالأصح: أنه لا يلزمه شيء، لأنه لم يورده على وجه الإقرار، وإنما أورده على وجه الشكر أو الذم، ولفظ الإقرار مفتقر إلى القصد في كونه إقراراً.

ومقابل الأصح: يلزمه ما أقر به، لأنه معترف بأن الرجل دفع إليه المال على وجه القرض، ومدح للبراءة منه، فلا يقبل منه إلا ببينة^(١).

وأما إذا لم يقصد بإقراره شكراً ولا ذمّاً بأن قال: أقرضني فلاناً الميت مالاً وقضيته إياه على وجه الإخبار فحسب، ففيه تفصيل بين القرب والبعد، فإن لم يطل الزمان من يوم المعاملة ليوم الموت، لم ينفعه قوله قضيته، إلا أن تقوم له بينة، وإن كان زمان ذلك طويلاً، حلف المقر وبرئ.

تاسعاً: حكم من أقر بمال وادعى تأجيله:

إذا أقر بمال ادعاه شخص عليه، ولكن ادعى تأجيل هذا المال، فإن كان المال الذي اعترف به من بيع، فالقول قول المقر بيمينه إن كان العرف والعادة جارية بالتأجيل له، وإن كانت العادة عدم التأجيل أصلاً، كان القول قول المقر له بيمينه، وإن لم يكن عرف بشيء فإن ادعى المقر أجلاً قريباً يشبه أن تباع السلعة له، كان القول قول المقر بيمينه، وإن ادعى أجلاً بعيداً مستكراً، فإنه لا يصدق، والقول قول المقر له بيمينه.

هذا إذا فانت السلعة، فإن كانت قائمة تحالفا وتفاسخا، ولا ينظر لشبه ولا لعدمه^(٢).

عاشراً: حكم تفسير ما أبهمه المقر في إقراره:

إذا أقر شخص بأن عليه لفلان: ألف ودرهم، أو ألف وعبد، أو ألف ثوب، ونحو ذلك، فإنه يقبل تفسيراً الألف بأي شيء أراده، ولو لم تجر العادة به، ولا يكون المعطوف تفسيراً للمعطوف عليه.

(١) المعونة ٢/ ١٢٥٩.

(٢) حاشية الصاوي ٢/ ١٩٣.

ويحلف على ما فسر به إن خالفه المدعي.

ودليلنا على قبول تفسير المقر بأي شيء أراد: أن كل ما لزم به حق بنفسه لم يكن تفسيراً لما تقدمه، ولأن العطف قد يكون عطفاً على الجنس، وعلى غير الجنس، فلا يقضي بالاحتمال، ووجب الرجوع في تفسيره إلى المقر^(١). كذلك يقبل قول المقر إذا قال للمقر له: عندي خاتم لك وفصه لي، أو أمة ولدها لي، أو جبة بطانتها لي، وكذا باب مسماره لي مما صدق الاسم فيه على المجموع بشرط: أن يقول المقر ذلك نسقاً بلا فصل، فإن قال: فصه لي، أو ولدها لي بعد مهلة فإنه لا يصدق في أن الفص أو الولد له، ويأخذ المقر له الخاتم بفصه، والجارية مع ولدها^(٢).

حادي عشر: حكم الإقرار بمال غير محدد:

إذا أقر شخص بمال - سواء قال عظيم أم لا - فإن المقر يلزمه للمقر له نصاب الزكاة على الأشهر، وقيل: نصاب السرقة. وعلى الأول يلزمه أقل ما يسمى نصاباً من جنس مال المقر، فيلزمه عشرون ديناراً إن كان من أهل الذهب، ومائتا درهم إن كان من أهل الفضة، وخمس من الإبل، إن كان من أهل الإبل، وثلاثون من البقر إن كان من أهل البقر، وأربعون من الضأن أو المعز إن كان من أهل الضأن أو المعز، وخمسة أوسق من الحب إن كان من أهل الحرث.

والأحسن: أن يفسر المقر قوله: له عندي مال، ويقبل قوله فيما فسر به ولو بحبة أو درهم مع يمينه، فإن فسر فلا كلام، وإن أبى فإنه يحبس حتى يفسر، وهو قول الشافعي أيضاً^(٣).

(١) المعونة ٢/ ١٢٥٠.

(٢) الشرح الكبير ٣/ ٤٠٥.

(٣) الأم ٣/ ٢٣٧، مختصر المزني ص ١١٣.

وجه هذا القول: قول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ وقوله ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ ولا خلاف أن هذا ينتظم القليل والكثير، ولأن هذا الاسم لجنس ليس له تقدير في شرع ولا لغة، فوجب أن يلزم الاسم لقليله وكثيره.

وجه القول بمراعاة نصاب السرقة: إنه لما عدم المقدار من جهة المقر، وكان لنا سبيل إلى تقديره، وجب تقديره، ووجدنا المقادير تعلم من ثلاثة أوجه: اللغة والشرع والعادة، وقد انتفت من طريق اللغة والعادة، وثبت من طريق الشرع في مواضع منها نصاب الزكاة، ومنها تقدير المهور، ومنها نصاب القطع في السرقة، فأخذنا بأقل المقادير، لأنه المتيقن، وأول ما يتناوله الاسم.

وجه القول بمراعاة نصاب الزكاة: أن اسم المال لما كان لا يكفي فيه الجنس، ووجدنا العادة تمنع إطلاق الاسم على ثلاثة دراهم أو ربع دينار، وهي إن تكن فيها تقدير، فإنها لا تثبت الاسم إلا في حد من الكثرة، فكان أولى المقادير ما اتفق عليه العادة من طريق الجملة، والشرع من طريق التفضيل، وهو مائتا درهم، وعشرون ديناراً^(١).

ثاني عشر: حكم الإقرار المتعدد:

الإقرار إما أن يكون موثقاً بالكتابة أو يكون مجرداً عنها، فإن أقر شخص في وثيقتين بأن لفلان كذا من المال، وأشهد على ما فيهما ولم يبين سبب هذا الدين، أو بينه وكان متحدًا في الوثيقتين، فالمعتمد أنه يلزم المقر ما في الوثيقتين، سواء اتحد القدر أو اختلف.

(١) المعونة ٢/ ١٢٤٦.

وأما إن كان الإقرار مجرداً عن الكتابة وكان متعدداً، فإن كان المقر به أولاً وثانياً متحد القدر. لزم المقر أحد الإقرارين، وإن كان المقر به مختلف القدر، لزمه الأكثر منهما على المعتمد^(١).

ثالث عشر: حكم الإقرار بالظرف والمظروف معاً:

إذا أقر شخص لآخر بأن له عنده ثوب في صندوق أو زيت في جرة، فإنه يلزمه الثوب والزيت بلا خلاف ويقبل تفسيره في الثوب والزيت، وأما الظرف وهو الصندوق والجرة فقولان في لزومه المقر وعدم لزومه. ومحل الخلاف في لزوم الظرف وعدم لزومه: إذا كان الظرف ينتقل، أما إذا كان لا ينتقل كما لو قال له: عندي دابة في إصطبل، فلا يلزمه اتفاقاً، وإنما تلزمه الدابة، ويقبل تفسيره لها^(٢).

رابع عشر: حكم الإقرار المبهم أو غير المعين:

إذا أقر شخص لآخر بأن له أحد هذين الثوبين، أو العبدین مثلاً، فإن المقر يؤمر بتعيين ما أقر به، لأن إقراره يحتمل الإبهام والشك، وله دعوى زوال الشك، وعلى كل حال له التعيين، فإن عين له أجودهما، أخذه المقر له، وكذلك إذا عين له أدناهما وصدقه المقر له على ذلك، فإن لم يصدقه، حلف المقر ودفعه له، فإن نكل حلف المقر له على ما ادعاه من الأعلى وأخذه، وإن لم يعين المقر ما أقر به، بل قال: لا أدري أيهما له، فإن المقر له يعين أحدهما، فإن عين أدناهما أخذه بغير يمين إذ لا تهمة حينئذ، وإن عين أعلاهما حلف عليه، لأنه يتهم حينئذ.

وإن قال المقر له أيضاً: لا أدري أيهما متاعي حلفاً على نفي العلم، ويبدأ المقر باليمين، ويشتركان حينئذ في ذلك بالنصف، لا بالثلث والثلثين، لأن

(١) حاشية الدسوقي ٣/ ٤٠٨، ٤٠٩.

(٢) شرح الخرشي ٦/ ٩٧.

المتبادر من الاشتراك التساوي، والتصريح بنفي العلم، تصريح بما علم التزاماً، إذ دعواهما عدم الدراية.

هذا إذا كان المقر لا يدري أيهما حق المقر له، أما إذا كان يعلم ما للمقر له عنده وامتنع عن التعيين فإنه يحبس حتى يعين أو يموت، بخلاف المقر له، فإنه إذا امتنع من التعيين مع معرفته، فإنه لا يحبس بل يعطي الأدنى^(١).

خامس عشر: حكم الاستثناء في الإقرار:

الاستثناء في الإقرار كالاستثناء في غيره من الأبواب التي يستثنى منها، كباب العتق، وباب الطلاق، وباب النذر، وما أشبه ذلك، فيصح الاستثناء هنا بشروط:

- ١- الاتصال، إلا لعارض كسعال ونحوه.
- ٢- وعدم الاستغراق كأن يقول لك على عشرة إلا تسعة، فيلزمه واحد. وإذا تعدد الاستثناء، فكل واحد مخرج مما قبله، فإذا قال: له علي عشرة إلا أربعة، إلا اثنين إلا واحداً، فالواحد مستثنى من الاثنين، يبقى منهما واحد مستثنى من الأربعة يبقى منها ثلاثة مستثناة من العشرة يبقى سبعة هي المقر بها.
- ٣- وأن ينطق بالاستثناء.
- ٤- وأن يسمع به غيره، لأنه حق لمخلوق، وهذا الشرط خاص بالاستثناء في الإقرار.
- ٥- وأن يقصد الاستثناء^(٢).

سادس عشر: حكم الاستثناء من غير الجنس:

يصح الاستثناء من غير الجنس، فإذا قال: له على ألف درهم إلا عبداً، أو إلا ثوباً، وما أشبه ذلك، فإن ذلك يكون إقراراً صحيحاً، وكان المعنى له على

(١) شرح الخرشي ٩٨ / ٦، حاشية الدسوقي ٤١٠ / ٣.

(٢) حاشية الصاوي ١٩٤ / ٢.

ألف درهم إلا قيمة عبد، أو قيمة ثوب، وتسقط قيمة ما ذكر من الشيء المقر به بشرط: أن لا تستغرقه القيمة، فإن استغرقت القيمة المقر به، بطل الاستثناء، والإقرار صحيح^(١).

والدليل على جواز الاستثناء من غير الجنس، ورود اللغة به، قال الله تعالى ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. إِلَّا إِبْلِيسَ﴾^(٢). وقال الشاعر:

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير^(٣) وإلا العيس^(٤)

ولا يقال لشيء من هذا أنيس^(٥).

سابع عشر: حكم الإبراء من الحق المقر به:

إذا أبرأ شخص شخصاً معيناً مما له قبله براءة مطلقة، بأن قال: أبرأت ذمة فلان مما لي قبله، أو قال: أبرأته من كل حق، أو قال: أبرأته فقط وأطلق، فإنه يبرأ من كل حق في الذمة أو تحت اليد من الأمانات، معلومة أو مجهولة، ويبرأ أيضاً من المطالبة بحد القذف، مما لم يبلغ الإمام، وإلا فلا يجوز له البراءة، إلا أن يريد المقذوف الستر على نفسه، فله ذلك بعد البلوغ، ويبرأ أيضاً من المطالبة بالمال المسروق، وأما حد السرقة فهو حق الله، فلا يجوز لأحد أن يسقطه مطلقاً. وإذا أبرأه من الحق الذي عليه، برأ من المطالبة به في الآخرة على أحد القولين، وقيل: لا تسقط عنه مطالبة الله^(٦).

(١) انظر المرجع السابق.

(٢) سورة الحجر ٣٠، ٣١.

(٣) اليعافير تيوس الظباء (الصحيح ٢/ ٧٥٢).

(٤) العيس: إبل بيض في بياضها ظلمة خفيفة والواحدة عيساء (الصحيح ٣/ ٩٥٤).

(٥) المعونة ٢/ ١٢٥٣.

(٦) شرح العدوي على الخرشي ٦/ ٩٩.

وإذا برئ من عليه الحق بصيغة من الصيغ المتقدمة، ثم قام صاحب الحق، وادعى على من أبرأه بحق، فلا يقبل دعواه عليه بنسيان أو جهل، أو أنه أراد بعض متعلقات الإبراء ولو أتى بصك يثبت حقه عند المدعى عليه، إلا أن يأتي ببينة تشهد له أن الحق الذي في الصك صدر التعامل بما فيه بعد البراءة، فحينئذ يعمل به.

ثامن عشر: الإبراء مما معه هل يستلزم الإبراء مما عليه؟

إذا أبرأ شخص آخر مما له معه، أو مما له عنده، فإنه يبرأ من الأمانات، فقط، كالودائع والقراض وما أشبه ذلك، ولا يبرأ من الديون لأنه لا يقال في عرف التخاطب لما يتعلق بالذمة معه، ولا عنده، بل عليه، لأن معه وعنده تقتضي الأمانة، ولفظة عليه تقتضي الذمة.

هذا إذا لم يكن عرف بخلاف ذلك، فإن كان العرف جريان هذا اللفظ في الأمانة والدين برئ منهما جميعاً^(١).

تاسع عشر: حكم إقرار الأخرس:

يلزم إقرار الأخرس بالإشارة، لأن إشارة الأخرس تنزل منزلة العبارة، فلو انطلق لسانه ورجع عن إقراره لم يعتبر رجوعه، كما أنه لو لاعن زوجته بالإشارة ثم انطلق لسانه وادعى أنه لم يلاعن لم يعتبر رجوعه.

عشرون: حكم إقرار المريض:

المريض مرضاً مخوفاً إذا أقر بشيء إما أن يقر لوارث قريب أو بعيد، أو لقريب غير وارث أصلاً، أو لصديق ملاطف، أو لمجهول حاله، لا يدري هل هو قريب أو ملاطف أو أجنبي، أو يقر لأجنبي غير صديق.

(١) الشرح الكبير للدريير ٣/ ٤١١.

فإذا أقر لوارث قريب مع وجود الأبعد أو المساوي، كان الإقرار باطلاً، لأنه متهم في هذا الإقرار أنه أراد صرف ماله كله إلى هذا القريب.

وإن أقر لوارث بعيد، كان الإقرار صحيحاً إن كان هناك وارث أقرب منه، سواء كان ذلك الأقرب حائزاً للمال أم لا، إذ لاتهمة حينئذ لأنه لا يتهم أنه منع القريب ووصل من هو أبعد منه، ولا يشترط أن يكون ذلك الأقرب ولداً.

وإن أقر لقريب غير وارث كالخال، أو لصديق ملاطف، أو مجهول حاله، صح الإقرار إن كان لذلك المقر ولد أو ولد ولد، لعدم التهمة، لأنه لا يتهم أنه منع ولده ووصل غيره ممن هو أبعد منه إليه، فإن لم يكن له ولد فلا يصح إقراره، لوجود التهمة وهي: أنه أراد وصل هؤلاء.

وإن أقر لأجنبي غير صديق، كان الإقرار صحيحاً ولازماً، كان له ولد أم لا.

هذا حكم إقرار المريض أما الصحيح فيلزمه الإقرار بلا قيد، سواء أقر لوارث بعيد أو قريب أو لملاطف، أو لمجهول حاله، أو لقريب غير وارث، أو لأجنبي غير ملاطف، سواء قام المقر له في الصحة، أو في المرض أو بعد الموت، لأن الصحيح لا تلحقه في إقراره تهمة، ولا يظن فيه إدخال شيء بالكذب^(١).

حادي وعشرون: حكم إقرار الزوج لزوجته:

الزوج إذا أقر في حالة مرضه لزوجته بدين في ذمته، أو أنه قبض منها ديناً، فإنه يؤخذ بإقراره إن كان يبغضها وعلم ذلك من حاله، وإن لم يرثه ولده.

وأما إن كان يحبها ويميل إليها، فإنه لا يقبل إقراره لها، لأنه يتهم في ذلك إلا أن يجيزه الورثة، فعطية منهم لها.

(١) حاشية الدسوقي ٣ / ٣٩٩.

وإن جهل حال الزوج معها من حب أو بغض، فإن الزوج يؤخذ بإقراره لها بشرطين:

- ١- أن يرثه ابن واحد منها أو من غيرها، أو بنون متعددون.
- ٢- ألا تتفرد الزوجة بالولد الصغير، فإن انفردت به، أي بكونه منها، وبقية الورثة كبار، منها أو من غيرها، فإن إقراره حينئذ لا يصح اتفاقاً لقوة التهمة.

وإن كان مع الزوجة المجهول حاله معها بنات للزوج المقر منها أو غيرها - وعصبة كأب وأخ، ففي إقراره لها قولان: بالصحة نظراً إلى أنها أبعد من البنت، وعدمها نظراً إلى أنها أقرب من العاصب، والموضوع: أنها لم تتفرد بصغير، وإلا منع قطعاً^(١).

ثاني وعشرون: حكم إقرار الوالد لولده العاق:

إذا أقر المريض لولده العاق مع وجود البار، ولو اختلفا بالذكورة والأنوثة، فقولان في جواز الإقرار ومنعه، فمن نظر إلى عقوقه، أجاز وكأنه أقر لأبعد مع وجود أقرب، ومن نظر إلى الولدية منع، لأنه أقر للمساوي مع مساويه.

واقرار المريض لأم ولده العاق فيها أيضاً قولان:

قيل: يصح، نظراً لمساواة ولدها لغيره في الولدية، وقيل: لا يصح، نظراً إلى أن وجود العاق كالعدم، فكأنه أقر لها، وليس لها ولد، والموضوع: أنه جهل بغضه لها، فإن علم بغضه لها، صح إقراره لها قولاً واحداً.

ثالث وعشرون: حكم الإقرار للحمل:

(١) الشرح الصغير للدردير ٢ / ١٩١، شرح الخرشي ٦ / ٨٩.

إن أقر شخص لحمل، بأن قال في ذمتي كذا حمل فلانة، فلا يخلو إما أن يكون لأم الحمل زوج أو سيد مسترسل عليها^(١) حين الإقرار أم لا، فإن كان لها زوج أو سيد مسترسل عليها حين الإقرار، لزم الإقرار للمقر إن ولدته حياً لدون أقل أمد الحمل من يوم الإقرار، للعلم بأنه كان موجوداً يوم الإقرار، وإن ولدته لأقل أمد الحمل من يوم الإقرار، وأولى لأكثر من أقل أمده، كان الإقرار باطلاً، لاحتمال وجوده بعد الإقرار وعدم وجوده حينئذ، وهذا كله إذا كان الحمل حين الإقرار خفياً، فإن كان ظاهراً حينه، لزم الإقرار ولو أتت به لأكثر من ستة أشهر من يوم الإقرار.

وأما إن كانت أم الحمل ليس لها حين الإقرار زوج أو سيد مسترسل عليها، كان الإقرار لازماً إن ولدته لأقصى أمد الحمل فدون من يوم انقطاع الاسترسال عليها، فإن ولدته بعد أكثر أمد الحمل بطل الإقرار^(٢).

رابع وعشرون: الاستلحاق " وحكمه:

الاستلحاق لغة: الادعاء، يقال: استلحقه أي ادعاه، والملحق: الدعي الملتصق، واللق: الدعي الموصل بغير أبيه.

وفي الحديث: أن النبي (ﷺ) قضى أن كل مستلحق استلحق بغير أبيه الذي يدعى له، فقد لحق بمن استلحقه.

قال ابن الأثير: قال الخطابي هذه أحكام وقعت في أول زمان الشريعة، وذلك أنه كان لأهل الجاهلية إماء بغايا، وكان سادتهن يلمون بهن، فإذا جاءت إحداهن بولد ربما ادعاه السيد والزاني، فألحقه النبي (ﷺ) بالسيد، لأن الأمة

(١) المراد به: أنه ليس به مانع من وطنها، بأن كان حاضراً غير مسجون.

(٢) حاشية الدسوقي والشرح الكبير ٣/ ٤٠١.

فراش كالحرة، فإن مات السيد ولم يستلحقه ثم استخلفه ورثته بعده لحق بأبيه، وفي ميراثه خلاف^(١).

وشرعاً: إقرار ذكر مكلف أنه أب لمجهول نسبه.

شرح التعريف:

قوله: "إقرار ذكر" قيد في التعريف يخرج به إقرار الأنثى، فلا استلحاق لأم اتفاقاً، لأن الاستلحاق من خصائص الأب لأن الولد ينسب لأبيه دون أمه، فغيره لا يصح استلحاقه، ولذلك لا يصح الاستلحاق من الجد على المشهور، لأن الرجل إنما يصدق في إلحاق ولد بفراشه لا في إلحاقه بفراش غيره.

وقال أشهب: يستلحقه الجد، وجمعاً بين الرأيين قال ابن رشد: إذا قال الجد: هذا ابن ولدي، فلا يصدق ولا يكون هذا استلحاقاً، وإن قال: أبو هذا ابني، أو والد هذا ابني، فإنه يصدق ويكون استلحاقاً.

قوله: مكلف: أي بالغ عاقل ولو سفيهاً، وهو قيد خرج به إقرار الصبي والمجنون والمكره، فلا يثبت بإقرارهم نسب لعدم تكليفهم وعدم الاعتداد بعبارتهم. وقوله "أنه أب" قيد احترز به عن إقرار رجل بأنه جد لهذا الولد، أو عم أو خال، أو أخ فلا يستلحق.

قوله "مجهول النسب" قيد احترز به عن معلومه أي الثابت النسب، ويحد من استلحقه حد القذف، كما احترز به عن مقطوع النسب كولد الزنا لأن الشرع قطع نسبه عن الزاني، واحترز به أيضاً عن اللقيط، فإنه لا يصح استلحاقه إلا ببينة أو وجه.

(١) لسان العرب لابن منظور ٢٥٢ / ١٢ (مادة لحق).

وإنما خص الشرع استلحاق مجهول النسب دون مقطوعه وغيره لتشوف الشارع للحقوق النسب، ولولا أن الشرع خصه بالأب، لكان استلحاق الأم أولى، لأنها اشتركت مع الأب في ماء الولد، وزادت عليه الحمل والرضاع^(١).

حكم الاستلحاق ودليله:

الاستلحاق جائز شرعاً بشروطه، والأصل فيه: ما أخرجه الشيخان ومالك، واللفظ لمالك (عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان عتبة بن أبي وقاص، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص، أن ابن وليدة زمعة منى، فاقبضه إليك، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي، قد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله (ﷺ) فقال سعد: يا رسول الله: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، وقال عبد بن زمعة، أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال رسول الله (ﷺ) هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال رسول الله (ﷺ) الولد للفراش، وللعاشر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه، لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص، قالت: فما رآها حتى لقي الله (ﷻ)^(٢).

قال عياض: سبب هذا الاختصاص أنهم كانوا في الجاهلية يثبتون النسب بالزنا ويبتاعون الجواري، ويستأجروهن للوطء، فإن ألحقته المزني بها بأحد، أو ادعاه الزاني ولم ينازعه فيه أحد لحق به، فلما جاء الإسلام أبطل ذلك وألحق الولد بالعقود الصحيحة والأفرشة الثابتة^(٣).

وأيضاً حديث (أن النبي (ﷺ) قضى أن كل مستلحق استلحق بغير أبيه الذي يدعي له، فقد لحق بمن استلحقه).

(١) شرح الخرشي ٦ / ١٠١.

(٢) الموطأ ٢ / ٧٣٩، صحيح البخاري ٦ / ٤٨١، صحيح مسلم ٢ / ١٠٨٠.

(٣) إكمال الإكمال ٤ / ٧٨.

شروط صحة الاستلحاق:

يشترط في الاستلحاق حتى يصح، ويستلحق به الولد شروطاً ثلاثة:

- ١- أن يكون المقر به مجهول النسب، فإن كان معلوم النسب من غيره لم يصح استلحاق وعلى المستلحق حد القذف - كما سبق.
- ٢- أن يكون المقر به محتمل الثبوت من نسب المقر، فلا يكذبه العقل، أو العادة، فإن كذبه العقل، كما لو استلحق الصغير الكبير فلا يلحق به، لأن ذلك يحيله العقل، لما فيه من تقدم المعلول على عليته.
- وإن كذبه العادة، كما لو استلحق ولداً ولد ببلد بعيد، علم أنه لم يدخله فلا يلحق به، وكذا لا يلحق به ولد ادعاه، لو علم أنه لا يقع منه نكاح ولا تسر أبداً.
- ٣- ألا يكون المستلحق (بالفتح) رقاً، أو مولى لمن يكذب الأب في استلحاقه، لأن المستلحق (بالكسر) يتهم على إخراج الرقبة من رق مالكها، أو على إزالة الولاء عن أعتقه، فلا يلحق الولد به إلا إذا تقدم للمستلحق ملك على أم المستلحق، فيلحق نسبه به فقط، ويستمر المستلحق (بالفتح) ملكاً أو مولى للمكذب، يتصرف فيه تصرف الملاك، فإذا لم يتقدم للمستلحق (بالكسر) ملك على أم الولد المستلحق فلا يلحق به أصلاً لا في الظاهر ولا في الباطن.

حكم استلحاق الولد الكبير أو الميت وميراثه:

يصح الاستلحاق وإن كان المستلحق (بالفتح) كبيراً أو ميتاً، لأنه لا يشترط تصديقه لمستلحقه، وسواء كان المستلحق (بالكسر) صحيحاً أم مريضاً، أحاط الدين بماله أم لا.

وورث الأب المستلحق الابن المستلحق بعد موته إن ورث المستلحق (بالفتح) ولد، فيكون للأب منه السدس إن كان الولد ذكراً، وله النصف إن كان الولد أنثى فقط، فإن لم يكن له ولد، فلا يرثه الأب المستلحق، لأنه يتهم بأنه إنما

استلحقه ليأخذ ماله، ما لم يكن المال قليلاً لا بال له، فإنه يرثه أيضاً^(١). وعليه
فإرث الأب لابنه الذي استلحقه مشروط بأحد شرطين:

١- أن يكون للابن المستلحق ولد يرثه.

٢- أو يكون المال الذي خلفه قليلاً لا بال له، وإن لم يكن له ولد.

هذا الشرط يعتبر إذا استلحقه ميتاً، وأما إن استلحقه حياً، فإنه يرثه وإن لم
يكن للمستلحق (بالفتح) ولد، وكان المال كثيراً^(٢).

حكم من استلحق ولدًا ثم أنكره:

من استلحق ولدًا، فإنه يلحق به، فإن أنكره بعد ذلك، بأن قال: ما هو
ولدي، ثم مات الولد، فإن الأب لا يرثه، لأنه نفاه، ويوقف ماله، فإن مات الأب
المقر، أعطى الموقوف لورثة الأب، لأن إنكاره للولد لا يقطع حق ورثة الأب.
وقضى بمال الولد دين الأب إن كان عليه دين، وإن قام غرماء الأب عليه
وهو حي أخذوا ديونهم من مال الولد، وما بقي يوقف حتى يموت الأب.
فإن مات الأب قبل الولد ورثه الولد بالاستلحاق الحاصل أولاً، ولا يسقط
نسبه بإنكاره بعد استلحاقه، ثم إن مات الولد بعد ذلك ورثه عصبته من قبل أبيه
المستلحق له.

واعلم أن هذه المسألة يلغز بها من أربعة أوجه^(٣):

الأول: ابن يرث أباه ولا عكس وليس بالأب مانع.

الثاني: مال يرثه الوارث ولم يملكه مورثه.

الثالث: مال يوقف لوارث الوارث دون الوارث.

الرابع: مال يقضي منه دين الشخص ولا يأخذه هو.

(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣/ ٤١٢، حاشية الصاوي ٢/ ١٩٥.

(٢) شرح الخرشي ٦/ ١٠٢.

(٣) حاشية الدسوقي ٣/ ٤١٩.

حكم استلحاق غير الولد:

إن استلحق شخص إنساناً وارثاً غير ولد، من أخ أو عم أو نحوهما، فإن المستلحق (بفتح الحاء) لا يرث المقر إن كان للمقر وارث ثابت النسب حائز للمال من الأقارب والموالي، لأنه المقر يتهم حينئذ على خروج الإرث لغير من كان يرثه.

فإن لم يكن لهذا المقر وارث أصلاً، أو له وارث غير حائز للمال، فخلاف بالإرث وعدمه، والراجع إرث المقر به من المقر جميع المال إن لم يكن للمقر وارث، والباقي إن كان له وارث غير حائز للمال، وهذا بناء على أن بيت المال ليس كالوارث المعروف، بل هو حائز يحوز المال لأجل صرفه في مصالح المسلمين.

ومقابل الراجع: وهو عدم إرث المقر به من المقر، مبني على أن بيت المال كالوارث المعروف.

هذا ومحل الخلاف المذكور: إذا لم يطل زمن إقرار المقر بالأخوة ونحوها، أما إن طال إقراره بذلك فإنه يرثه قولاً واحداً ؛ لأن قرينة الحال دلت على صدقه في ذلك.

والطول يكون بمضي ثلاث سنين فما فوقها.

هذا حكم إرث المستلحق (بفتح الحاء) من المستلحق (بالكسر) أما العكس فيجري فيه التفصيل السابق، فلا يرث المستلحق (بالكسر) المستلحق (بفتح الحاء) إن كان للمستلحق (بفتح الحاء) وارث يأخذ جميع المال، وإلا فخلاف، وذلك لأن المستلحق (بالكسر) مستلحق (بفتح الحاء) حيث صدقه الآخر، والمستلحق (بفتح الحاء)

مستلحق (بالكسر) فكل منهما مستلحق ومستلحق فيجري في إرث كل منهما من حيث كونه مستلحقاً (بالفتح) التفصيل السابق^(١).

فإن كذب المستلحق (بالفتح) المستلحق (بالكسر) في دعوى الإلحاق فلا إرث لأحدهما من الآخر، كان له وارث حائز أم لا.

وإن سكت، فهل هو كالتصديق، أو يرث المستلحق (بالفتح) فقط، تردد^(٢).

هذا وإطلاق الاستلحاق على هذه المسألة تجوز، لأن الاستلحاق لا يكون إلا من الأب لولده، وأما غيره فيسمى إقراراً.

(١) انظر شرح الخرشي ٦ / ١٠٤.

(٢) حاشية الدسوقي ٣ / ٤١٥.

ملخص ما سبق دراسته في باب الإقرار:

- ١- الإقرار: هو الاعتراف بما يوجب حقا على قائله ، سواء كان ذلك يتضمن مالا ، أو عقوبة كحد أو قصاص .
- ٢- الإقرار حجة شرعية منذ القدم إلى وقتنا المعاصر ، حتى أصبح سائدا بين الناس أن الإقرار سيد الأدلة .
- ٣- الإقرار مشروع بالكتاب والسنة والإجماع .
- ٤- أركان الإقرار أربعة : مقر - ومقر له - ومقر به - وصيغة .
- ٥- يشترط في المقر حتى يصح إقراره الشروط الآتية :
 - أن يكون المقر بالغا عاقلا .
 - أن يكون طائعا .
 - أن يكون غير محجور عليه في المعاملات .
 - أن يكون غير متهم في إقراره .
 - أن يكون المقر معلوما .
- ٦- شروط المقر له :
 - أن يكون أهلا للإقرار له .
 - أن يصدق المقر له المقر في إقراره .
- ٧- إذا عقب المقر إقراره بما يوهم أنه رافع لحكمه لا ينفعه ذلك ، ويلزمه ما أقر به .
- ٨- يصح الاستثناء في الإقرار بشروط :
 - أن يتصل الاستثناء بالإقرار .
 - عدم الاستغراق .
 - أن ينطق المقر بالاستثناء .
 - أن يسمع به غيره .

■ أن يقصد المقر الاستثناء .

٩- يلزم إقرار الأخرس بالإشارة المفهمة ، لأن إشارة الأخرس تنزل منزلة العبارة .

أسئلة على ما سبق دراسته في باب الإقرار .

س ١ : بين معنى الإقرار ، واذكر حكمه ودليله .

س ٢ : بين الحكم فيما يأتي :

■ الإقرار مع المناكرة .

■ الإقرار على وجه الشكر أو الذم .

■ الاستثناء في الإقرار .

■ الإقرار للحمل .

س ٣ : ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة ، وكلمة خطأ أمام العبارة

الخاطئة مبينا السبب :

■ يصح الإقرار لصديق قريب ملاطف .

■ قال شخص : لفلان على ألف جنيه إن شاء الله .

■ لا يلزم إقرار الأخرس بإشارته .

■ لا يصح الإقرار من الصبي والمجنون .

س ٤ : أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

■ الأثر المترتب على ظهور ما أقر لا الحق

و لأنه كالدعوى و

■ يشترط في المقر له أن وأن

■ المقر به نوعان ويشترط فيه حق للغير

..... فإن تعلق فلا إذا ثبت ببينة ،

والنوع الثاني كالإقرار

■ يشترط في حتى يرفع حكم الإقرار شروط إلا

لعارض والاستغراق وأن ينطق وأن

الاستثناء وأن غيره .

الباب الرابع

أحكام الدماء

الهدف من دراسة أحكام الدماء

يتوقع من الطالب بعد دراسته لأحكام الدماء والقصاص أن يعرف الآتي:

- ١- حرمة النفس البشرية أيا كان لونها ، أو جنسها ، أو دينها .
- ٢- لا يحل قتل النفس إلا بحق .
- ٣- الإنسان معصوم النفس والطرف .
- ٤- حفظ النفس من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية .
- ٥- القصاص من الجاني يكون بمثل ما فعل بالمجنى عليه .
- ٦- شرع القصاص في الإسلام من الجاني ليكون سببا في إحياء النفوس واستقرار الحياة .
- ٧- أن يستطيع الطالب تطبيق الأحكام الشرعية المتعلقة بالقصاص على نوازل العصر ومستجداته إذا ما عين في الفصل بين منازعات الناس وخصوماتهم .

أحكام الدماء

تمهيد:

الجنايات الموجبة للعقوبة ثلاثة عشر وهي: القتل، والجرح، والزنى، والقذف، وشرب الخمر، والسرقعة، والبغي، والحاربة، والردة، والزندقة، وسب الله، وسب الأنبياء، والملائكة، وعمل السحر، وترك الصلاة والصيام.

ومحل الدراسة في هذا الكتاب هي الجنايات على النفس وما دونها (وهي القتل والجرح)، وكذلك البغي والحاربة، وإن شاء الله سوف أتناول الجنايات الأخرى بالبحث والدراسة وذلك في مقررات دراسية أخرى.

والكلام عن الجناية على النفس وما دونها طويل ومتشعب، لذا رأيت أن أضع خطة أسير عليها في بحث ودراسة هذا الموضوع المهم، حتى أحيط بكل جوانبه دون أن يخفي علي منه شيء، أو أنسى مقصدًا من مقاصده وأنا مستغرق في بحث فروعه ومسائله، وما ذلك إلا لأن الجنايات من أؤكد الضروريات التي يجب مراعاتها في جميع الملل بعد حفظ الدين، وهي حفظ النفوس، ويجب أن تكون أول ما ينظر فيه القاضي، ففي الصحيح "أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء" ولا يعارضه حديث "أول ما ينظر فيه من عمل العباد الصلاة" لأن هذا في خاصة أعمال العبد نفسه، وذلك فيم بينه وبين غيره.

خطة الموضوع:

الفصل الأول: الجناية على النفس وفيه مبحثان.

الفصل الثاني: الجناية على ما دون النفس.

الفصل الثالث: الجناية على نفس غير مكتملة.

الفصل الأول

الجناية على النفس

الجناية: هي الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة^(١).

وعرفها **الماوردي**: بأنها محظورات شرعية زجر الله عنه بحد أو تعزير، ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية.

ومن هذا التعريف يفهم أنه لا بد في الجريمة من توافر أمور ثلاثة:

١- أن يكون من المحظورات الشرعية، أي مما نهى الشرع الإسلامي عنه نهى تحريم لا نهى كراهة.

٢- أن يكون تحريم الفعل أو الترك من قبل الشريعة الإسلامية، فإن كان من غيرها فلا يعتبر المحذور جريمة.

٣- أن يكون للمحذور عقوبة من قبل الشرع الإسلامي، سواء كانت هذه العقوبة مقدرة وهي التي يسميها الفقهاء بالحد، أم كان تقديرها مفوضاً إلى رأي القاضي، وهي التي يسميها بالتعزير، فإذا خلا الفعل أو الترك من عقوبة لم يكن جريمة^(٢).

هذا والجناية على النفس اثنان: عمد، وخطأ ولا ثالث لهما، لأن الله لم يذكر في كتابه غيرهما، قاله في المقدمات^(٣).

هذا وسيكون بحث الجناية على النفس ثلاثة مباحث:

الأول: القتل العمد. الثاني: القتل الخطأ. الثالث: بم يثبت القتل بنوعيه؟

(١) لسان العرب لابن منظور مادة جنى ٢/ ٢٩٣.

(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٤٥١.

(٣) المقدمات لابن رشد ٣/ ٣٨٧.

المبحث الأول

القتل العمد

وفيه مطالب:

المطلب الأول: في تعريفه وحكمه

تعريفه: القتل العمد هو: أن يقصد القاتل إلى القتل بضرب محدد أو مثقل، أو بإحراق، أو تغريق، أو خنق، أو سم، أو نحو ذلك^(١).

أو هو: قصد الفعل والشخص بما يقتل قطعاً أو غالباً^(٢).

حكمه: أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، بل ليس بعد الشرك بالله أعظم منه، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.

أولاً: الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾^(٣)، وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾، وقوله: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾^(٤).

ثانياً: السنة:

فما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله (ﷺ) "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" متفق عليه.

ثالثاً: الإجماع:

(١) القوانين الفقهية ص ٢٩٥.

(٢) مغني المحتاج ٤ / ٥.

(٣) الإسراء ٣٣.

(٤) النساء ٩٢، ٩٣.

ولا خلاف بين الأمة في تحريمه.

فإن فعله إنسان متعمداً فسق، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه وتوبته مقبولة في قول أكثر أهل العلم.

وقال ابن عباس: إن توبته لا تقبل للآية التي ذكرناها، وهي من آخر ما نزل، ولم ينسخها شيء، ولأن لفظ الآية لفظ الخبر، والأخبار لا يدخلها نسخ، ولا تتغير، لأن خبر الله - تعالى - لا يكون إلا صدقاً وهو مذهب الإمام مالك لقوله: لا تجوز إمامته^(١).

ولكن الراجح أن توبته مقبولة لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^(٢) فجعله داخلاً في المشيئة، ولأن التوبة تصح من الكفر، فمن القتل أولى، والآية محمولة على من لم يتب، أو على أن هذا جزاؤه إن جازاه، وله العفو إذا شاء، فضلاً عن أحاديث وردت في ذلك، كحديث الرجل الذي قتل مائة نفس.

وتحريم الله للقتل، وتشديد عقوبة من يرتكبه، إنما كان لما في القتل من تعديّة على خلقه الله وصنعتة في الأرض، ولما فيه من تهديد للناس وزعزعة للأمن وإفساد في الأرض وإنهاء للحياة عليها، لذا حرمه الله (ﷻ) بل جعله من السبع الموبقات التي يترتب عليها استحقاق أشد العذاب في الأولى والآخرة.

(١) شرح ابن الناجي على الرسالة ٢ / ٢٢١.

(٢) النساء ٤٨.

المطلب الثاني

أنواع القتل العمد

القتل عمد نوعان^(١):

أحدهما: القتل بالمباشرة، وهو أن يقصد المكلف غير الحربي ضرب المعصوم بما يقتل غالباً، كالمحدد والمثقل، بل وإن كان بما لا يقتل غالباً كالقضيب والسوط ونحوهما، قصد بالضرب قتله أو لم يقصد قتلاً، وإن قصد مجرد الضرب، وسواء قصد المضروب أو قصد غيره، بشرط أن يكون فعله هذا لعداوة أو غضب لغير تأديب، وأما إن كان على وجه اللعب أو التأديب، فهو من الخطأ إن كان بنحو عصا لا بنحو سيف.

والأصل في ذلك: عمل أهل المدينة في الموطأ: قال مالك "الأمر المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيه عندنا - أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا، أو رماه بحجر، أو ضربه عمداً فمات من ذلك، فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص". قال مالك "فقتل العمد عندنا، أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تقيض نفسه"^(٢).

وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى: أن القتل بالعصا والسوط ونحوهما مما لا يقتل غالباً، شبه عمد، تجب فيه الدية المغلظة، ولا قصاص فيه^(٣).

للقتل المباشر صور كثيرة منها:

- ١- خنق المعصوم.
- ٢- ومنعه من الطعام والشراب حتى يموت إن قصد قتله، أو لم يقصده وعلم أنه يموت بالخنق ومنع الطعام والشراب منه.

(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٤٢، شرح الخرشي ٨ / ٧.

(٢) الموطأ ص ٧٧٨.

(٣) الباب ٣ / ١٤١، ١٤٢، مغني المحتاج ٤ / ، الروض المربع ٢ / ٣٣١.

٣- ومنع فضل مائه عن مسافر، عالمًا بأنه لا يحل له منعه، وأنه يموت إن لم يسقه، فيقتل به، وهذا كله، إن لم يكن له عذر من تأويل وغيره.

٤- وطرح إنسان لا يحسن العوم في نهر ونحوه، لعداوة أو غيرها، ومثله من يحسن العوم، وكان الغالب عدم النجاة لشدة برد أو طول مسافة، فغرق، فالقصاص في المسألتين.

وإذا جهل كونه يحسن العوم، وطرح في نهر وغرق، فإن كان فعل ذلك عداوة، فالقصاص، وإن كان فعله لعبًا فالدية، ولا قصاص^(١).

ثانيهما: القتل أو الإيتلاف بالسبب، وهو أن يفعل فعلًا يكون سببًا للإيتلاف، فمن حفر بئرًا في موضع لا يجوز له حفرها فيه كطريق المسلمين، أو حفرها في موضع يجوز له فيها حفرها كبيته، وقصد بذلك الضرر، كهلاك شخص معين، وهلك فيه ذلك المعين، فإنه يقتل به، فإن هلك فيه غير المعين، فعليه ديته إن كان حرًا أو قيمته إن كان عبدًا، وأما لو حفر بئرًا في بيته لضرورة اقتضت ذلك، فهلك فيها إنسان أو غيره، فلا ضمان عليه فيه، بل هو هدر.

أو وضع ما يزلق في طريق المسلمين كماء أو قشر بطيخ، أو ربط دابة بطريق، أو اتخذ كلبًا عقورًا وقد أُنذر عن اتخاذه لشخص معين، فإنه يقتص منه، لكن بشروط ثلاثة:

- ١- أن يقصد الفاعل بفعله الضرر.
- ٢- وأن يكون من قصد ضرره معينًا.
- ٣- وأن يهلك ذلك المعين، فإن لم يقصد الضرر أصلًا، أو قصد معينًا فهلك غيره فالدية، وليس القصاص.

(١) حاشية البناني على الزرقاني ٨/٨.

والأصل في ذلك: عمل أهل المدينة، ففي الموطأ قال مالك: والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق، أو يربط الدابة، أو يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره، فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو في ماله خاصة، وما بلغ الثلث فصاعداً فهو على العاقلة، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين، فلا ضمان عليه فيه ولا غرم^(١).

يؤيد ذلك حديث جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار وفي الركاز الخمس^(٢).

ومن صور القتل بالسبب أيضاً الإكراه وهو نسبة بين المكره والمكره، فيقتل المكره (بكسر الراء) لتسببه والمكره (بفتح) لمباشرته إن لم يمكنه مخالفة الأمر خوف قتله.

ومن صورهِ أيضاً تقديم مسموم من طعام أو غيره لإنسان معصوم غير عالم بأنه مسموم فتناوله فمات، فيقتص ممن قدمه إن كان عالماً بأنه مسموم، وإلا فلا.

والأصل في ذلك: حديث أبي سلمة قال (كان النبي ﷺ) يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، فأهدت له يهودية بخير شاة مصلية (مشوية) سمتها، فأكل رسول الله ﷺ) منه، وأكل القوم، فقال: ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة، فمات بشر بن البراء بن المعرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي

(١) الموطأ ص ٧٧٥، ٧٧٦.

(٢) أخرجه مالك في الموطأ ص ٧٧٥، والبخاري في صحيحه ٢ / ٥٤٥، ٥٤٦.

صنعت؟ قالت: إن كنت نبيًا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكًا أرحمت الناس منك، فأمر بها رسول الله (ﷺ) فقتلت^(١).

ومن صورهِ أيضًا: أن يرمي على شخص معصوم حية من شأنها أن تقتل، فيموت فالقصاص سواء مات من لدغها أو من الخوف، رماها على وجه العداوة أو اللعب، وإن كانت الحية صغيرة ليس شأنها أن تقتل، أو كانت ميتة ورماها عليه فمات من الخوف، فإن كان الرمي على وجه اللعب فالدية، وإن كان على وجه العداوة فالقصاص.

ومن صورهِ أيضًا: أن يشير عليه بآلة القتل سيف أو رمح أو نحو ذلك. فيهرب، فيطلبه فيموت، فإذا أن يموت بدون سقوط، أو يسقط وفي كل إما أن يكون بينهما عداوة أو لا، فإن لم تكن بينهما عداوة فالدية، سقط حال هروبه أو لا، وإن كان بينهما عداوة، فإن لم يسقط فالقصاص بدون قسامة، وإن سقط فالقصاص بقسامة.

ومن صورهِ أيضًا: أن يمسك شخصًا ليقطله آخر، ولولا إمساكه ما أدركه القاتل، مع علمه بأنه قاصد قتله، فقتله الطالب، فيقتص من الممسك لتسببه كما يقتص من القاتل لمباشرته، وكذا الدال الذي لولا دلالته ما قتل المدلول عليه، قياسًا على الممسك.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقتل الممسك مطلقًا، وإنما يقتل المباشر وحده، لما روي عن رسول الله (ﷺ) قال (إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك)^(٢).

(١) مختصر سنن أبي داود ٦/ ٣١٠، السنن الكبرى للبيهقي ٤٦١٨.

(٢) رواه الدارقطني وصححه ابن القطان بلوغ المرام شرحه سبل السلام للصنعاني ٣/ ١٢٠١.

المطلب الثالث

عقوبة القتل العمد

العقوبة هي: الجزاء المترتب على الجناية، وعقوبة القتل هي الجزاء المترتب على قتل النفس، وهي ثلاثة أنواع أصلية، وبدلية، وتبعية، فضلاً عن وقوعه في معصية كبيرة وإثم عظيم يستحق عليه الخلود في نار جهنم، قال تعالى ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾^(١).

النوع الأول: العقوبة الأصلية:

العقوبة الأصلية للقاتل عمداً هي القصاص بنص حديث رسول الله (ﷺ) "العمد قود"^(٢). والكلام عن القصاص سيكون في الفروع التالية:

- ١ - تعريف القصاص.
- ٢ - شروطه.
- ٣ - مسقطات القصاص.
- ٤ - لمن يكون حق استيفاء القصاص.
- ٥ - حق القصاص.
- ٦ - وقت استيفاء القصاص.

الفرع الأول: تعريف القصاص

القصاص لغة: يطلق على معان عدة منها اتباع الأثر يقال: خرج فلان قصصاً في أثر فلان، وقصاً إذا اتبع أثره.
ومنها: الحفظ يقال: تقصصت الكلام أي حفظته.

(١) النساء ٩٣.

(٢) وسمي القتل قصاصاً قوداً لأن الجاهلية كانوا يقودون الجاني المستحق بحبل ونحوه.

ومنها الاستبانة، يقال: أقصت الفرس والشاة، وهي مقص، استبان ولدها أو حملها ومنها، القود وهو القتل بالقتل^(١).

وشرعاً: مجازاة الجاني بمثل فعله^(٢).

والأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع:

أولاً: الكتاب: قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾^(٣) وقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾^(٤) وقوله تعالى ﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾^(٥).

ثانياً: السنة: قوله (ﷺ) (العمد قود كله إلا أن يعفو ولي المقتول)^(٦). وقوله (من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية)^(٧).

ثالثاً: الإجماع: أجمعت الأمة على وجوب قتل القاتل عمداً، والعقول تقتضي بمشروعيته استتباباً للأمن، وحفظاً للنفس الإنسانية التي كرمها الله سبحانه وزجراً لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة، فإن من يعلم أنه لو قتل يقتل ما أقدم على ارتكابها.

وقد اختلف أهل العلم: هل القصاص من الجاني يكفر عنه إثم القتل أم لا؟ فمنهم من ذهب إلى أنه يكفره لقوله عليه الصلاة والسلام "الحدود كفارات لأهلها" فعمم ولم يخص قتلاً من غيره، ومنهم من ذهب إلى أنه لا يكفرها لأن المقتول

(١) لسان العرب مادة قصص ١١ / ١٩٢.

(٢) الفقه الإسلامي وأدلته د/ وهبة الزحيلي ٦ / ٢٦١.

(٣) البقرة ١٧٨.

(٤) البقرة ١٧٩.

(٥) المائدة ٤٥.

(٦) أخرجه الدارقطني ٣ / ٩٤ وابن أبي شيبة ٩ / ٣٦٥.

(٧) أخرجه البخاري كتاب الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ٨ / ٣٨.

المظلوم لا منفعة له في القصاص وإنما منفعته للأحياء لينتهي الناس عن القتل
قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ ويخص الحديث بالحدود التي الحق فيها
لله فقط^(١).

(١) حاشية الصاوي ٢ / ٣٨٢.

الفرع الثاني: شروط القصاص

يشترط لوجوب القصاص شروط في الجاني، وشروط في المجني عليه،
وشروط في الجناية.

شروط الجاني:

يشترط في الجاني ليقام عليه عقوبة القصاص شروط^(١).

١- أن يكون مكلفاً أي بالغاً عاقلاً، ذكراً أو أنثى، مسلماً أو كافراً، ولو كان رقيقاً، فيقتل العبد بمثله، وبحرّ إن شاء الولي، وله استحيائه كما سيأتي.
وأما الصبي والمجنون فلا يقتص منهما، لأن عمدهما وخطأهما سواء، والدية على عاقلتهما، على أنه لا عمد للمجنون، ولذا لو كان يفيق أحياناً، وجنى حال إفاقته، اقتص منه حال إفاقته فإن جن بعد الجناية، انتظرت إفاقته، فإن لم يفيق فالدية في ماله.

والسكران بحلال كالمجنون، وأما السكران بحرام، فإنه يقتص منه، لأنه هو الذي تسبب في زوال عقله، وسدّاً للذرائع أما المفسدين، فلو لم يقتص من السكران مطلقاً، لشرب من يريد قتل إنسان خمرًا ثم قتله لأنه بمأمن من العقوبة، ولأن أحكام السكران بحرام أحكام الصاحي في وقوع طلاقه، ولزوم قضاء الصلاة له، وحده في الزنا والقذف فكذلك القود.

الإكراه على القتل:

من أكره غيره على قتل رجل ظلمًا فإن كان المأمور ممن يمكنه مخالفة الأمر، ولا تلزمه طاعته، قتل المأمور المباشر للقتل لأنه قاتل لغيره ظلمًا، فوجب أن يقاد به، وإن كان مكرهًا لا يمكنه مخالفته، كالسلطان الذي يخاف من يخالفه أن يقتله أو يجري عليه مكروه لمخالفته، قتلًا جميعًا، وكذلك العبد مع سيده، لأن

(١) حاشية الدسوقي في الشرح الكبير ٢٣٧/٤، وما بعدها، شرح الخرشي ٣/٨، الشرح الصغير ٢/٣٨١.

المكره (بكسر الراء) ألجأ المكره (بفتح الراء) إلى قتله، فوجب أن يتعلق الحكم بالقتل كالشاهدين زورًا بالقتل، وأما المباشر، فلأنه قتله لاستبقاء نفسه منه ظلمًا فأشبهه إذا جاع فقتله وأكله^(١).

وقال أبو حنيفة وابن حنبل يقتص من الأمر دون المأمور.

٢- أن يكون معصومًا، والعصمة تكون بالإيمان أو الأمان فتشمل المسلم والذمي، أما الحربي فلا يقتل قصاصًا إذا قتل مسلمًا أو ذميًا، بل يهدر دمه، لذا لو أسلم أو دخل عندنا بأمان لم يقتل.

٣- أن يكون مكافئًا (مساويًا) للمجني عليه، أو أنقص منه، فيقتل الحر المسلم بمثله، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى والذكر المماثل لها وعكسه ويقتل العبد بالحر والذمي بالمسلم ولو رقيقًا، فإن كان زائدًا عن المجني عليه بحرية أو إسلام لم يقتص منه، فلا يقتل حر مسلم برقيق ولا بذمي ولا يقتل رقيق مسلم بذمي حر، لأن الإسلام أعلى من حرية الذمي، والأعلى لا يقتل بالأدنى. والظرف الذي يجب أن تتوافر فيه هذه الشروط الثلاثة هو: وقت القتل فلو قتل معصومًا وهو حربي، أو زائد حرية، أو إسلام، أو غير مكلف فلا قصاص ولو بلغ أو أسلم الحربي بأثر ذلك، ولو رمى عبد أو جرح مثله، ثم عتق الجاني فمات المجني عليه، لم يقتص من الجاني لأنه حين الموت زائد حرية، وكذا لو رمى ذمي مثله، أو جرحه وأسلم قبل موت المجني عليه.

وهذه الشروط التي اشترطت في الجاني محلها إذا كان القتل لغير أخذ المال، أما إذا كان القتل لأخذ المال، وهو ما يسمى بقتل الغيلة، فلا يشترط فيه الشروط المتقدمة، بل يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالكافر، كما أنه لا عفو فيه ولا صلح، وصلاح الولي مردود، والحكم فيه للإمام^(٢).

(١) المعونة ٣/ ١٣١١، القوانين الفقهية ص ٢٩٥، بداية المجتهد ٢/ ٤٧٠.

(٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير ٢/ ٣٨٢.

شروط المجني عليه:

يشترط في المجني عليه حتى يقتص من قاتله شروط ثلاثة:

- ١- أن يكون معصومًا إلى حين التلف في النفس، وإلى حين الإصابة في الجرح، فيعتبر في النفس من حين الضرب إلى حين الموت، وفي الجرح من حين الرمي إلى حين الإصابة، أي لا بد من اعتبار الحالين معًا، حالة الرمي وحالة الإصابة في الجرح، وحالة الموت في النفس، فإذا رمى كافر مرتدًا، وقبل وصول الرمية إليه أسلم، اعتبر حال الرمي، فلا يقتل به إن مات، وكذا لو جرحه، ثم أسلم ونزا ومات، فإنه لا يقتل به لمراعاة حالة الجرح. والعصمة - كما سبق - تكون بإيمان لقوله (ﷺ) (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها). وتكون بأمان لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾^(١).

حكم أطراف القاتل:

القاتل إذا تعدى عليه رجل أجنبي أو ولي الدم، فقطع يده مثلاً عمداً أو خطأ فله القصاص على من فعل به ذلك عمداً، سواء كان الفاعل أجنبياً أم ولي الدم، وسواء فعله بعد أن أسلم إليه من الحاكم أو قبله، ثم يقتلونه بعد ذلك لأن أطراف القاتل معصومة حتى بالنسبة لولي الدم، وللقاتل أخذ الدية في الخطأ.

جناية القاتل قبل القود:

إذا قتل المكلف مسلماً عمداً عدواناً، فعدا عليه مكلف آخر فقتله عمداً عدواناً، فإن دم هذا القاتل يستحقه ولي المقتول الأول، إن شاء قتله، وإن شاء عفا عنه، وكذلك إذا قطع شخص يد شخص عمداً، فعدا على القاطع شخص

(١) التوبة ٦.

فقطعه يده، فإن المقطوع يده أولاً يستحق قطع يد القاطع، إن شاء قطع وإن شاء عفا عنه.

وكذلك لو استحق شخص دم شخص لكونه قتل أباه مثلاً عمداً عدواناً، فقتل شخص القاتل خطأ، فمستحق الدم يستحق الدية من القاتل خطأ على عاقلته، وليس لأوليائه مقال معه، لأنه لما استحق دمه صار كأنه الولي، وكذا لو قطع شخص يد آخر عمداً فقطع أجنبي يد القاطع خطأ، فلمستحق القطع دية يده من القاطع خطأ لقاطع يده^(١).

٢- أن لا يكون المجني عليه أنقص من الجاني، فإن كان أنقص لم يقتص من الجاني، كما لو كان المجني عليه عبداً والجاني حراً، أو المجني عليه ذمياً، والجاني مسلماً، فلا يقتص من الجاني لعدم التكافؤ بينهما، وإنما يعتبر التكافؤ بين الجاني والمجني عليه لقوله (ﷺ) "المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم"^(٢) وللاجماع على منع قتل المسلم بالمعاهد والمستأمن.

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى قتل الحر بالعبد إلا من قتل عبد نفسه، فلا يقتل به.

وذهب النخعي إلى: قتل الحر بالعبد مطلقاً، سواء كان عبد القاتل، أو عبد غيره.

واحتجوا بقوله (ﷺ): "من قتل عبده قتلناه به"^(٣).

(١) الشرح الكبير للدردير ٤/ ٢٤٠، شرح الخرشي ٨/ ٥، ٦.

(٢) أخرجه أبو داود في الجهاد - باب في السرية على أهل العسكر ٣/ ١٨٣، وابن ماجه في الديات باب المسلمون تتكافأ دماؤهم ٢/ ٨٥٩، والنسائي في القسامة باب القوديين الأحرار والمماليك ١٩١٨.

(٣) أخرجه أحمد ٥/ ١٠، ١١/ ١٢، وأبو داود (٤٥١٥) والنسائي ٨/ ٢٠، والترمذي (١٤١٤) وغيرهم.

وقالوا: لما كان قتله محرماً كقتل الحر، وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص في الحر^(١).

٣- ألا يكون المجني عليه جزء القاتل، وإلا فلا قصاص، فإذا قتل الأب ولده، أو الأم ولدها، فلا قصاص، لقوله (ﷺ): "لا يقاد الوالد بالولد"^(٢) ولأن النبي (ﷺ) قال: "أنت ومالك لأبيك" فهذه الإضافة تقتضي تملكه إياه، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص، لأنه يدرأ بالشبهات، ولأن الأب سبب وجوده، فلا ينبغي أن يتسلط بسببه على إعدامه. والجد وإن علا كالأب في هذا.

واستثنى الإمام مالك حالة واحدة يقاد فيها الوالد بولده وهي: أن يضجع الوالد ولده فيذبحه، أو يقتله قتلاً لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه، فيقاد به لعموم القصاص بين المسلمين، لكن إن رماه بسيف أو عصا فقتله لم يقتل به^(٣).

وإذا قلنا بعدم القصاص من الوالد لولده، فإنه يجب عليه الدية.

قتل أحد الأبوين صاحبه:

إذا قتل أحد الأبوين صاحبه، ولهما ولد، لم يجب القصاص؛ لأنه لوجب لوجب، ولا يجب للولد قصاص على والده، لأنه إذا لم يجب بالجنابة عليه فلائ لا يجب له بالجنابة على غيره أولى، وسواء كان الولد ذكراً أو أنثى، أو كان للمقتول ولد سواه أو من يشاركه في الميراث، أو لم يكن، لأنه لو ثبت القصاص

(١) انظر بداية المجتهد ٢/ ٤٧٤.

(٢) ذكره ابن عبد الله وقال: وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، ويستغنى شهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفاً.

(٣) بداية المجتهد ٢/ ٥٧٧، المغني لابن قدامة ٩/ ٣٦٠، وأما إذا قتل الولد أحد والديه فإنه يقتل به، لأن الأب أعظم حرمة وحقاً من الأجنبي فإذا قتل بأجنبي فالأب أولى.

لوجب له جزء منه ولا يمكن وجوبه، وإذا لم يثبت بعضه سقط كله؛ لأنه لا يتبعض، وصار كما لو عفا بعض مستحق القصاص عن نصيبه منه.

شروط الجناية:

الجناية هي فعل الجاني الموجب للقصاص، وهو ضربان: مباشرة وسبب، وقد تقدم ذكرهما، ويشترط في الجناية حتى يقام على الجاني القصاص أن تكون عمداً عدواناً، أي يتعمد الجاني الفعل الذي سبب القتل، وإن لم يكن يقتل غالباً، كضرب بسوط أو عصا ونحوهما - كما تقدم - إن كان الفعل غير جائز، بأن كان لعداوة أو غضب، لا إن كان الفعل جائزاً كأدب ولعب، فلا قود فيه. وقد تقدم ذكر الدليل على ذلك.

وذهب أبو حنيفة إلى: أن العمد هو ما تعمد ضرب بسلاح أو ما أجرى مجرى السلاح كالنار والمحدد من الخشب.

قتل الجماعة بالواحد:

إذا اجتمع جماعة على قتل شخص عمداً من غير تمالؤ على قتله، فإنهم يقتلون جميعاً به بشرط: ألا تتميز ضرباتهم، أو تميزت وتساوت، أو اختلفت ولم يعلم صاحب الضربة التي أزهقت روحه أو أنفذت مقاتله.

فإن تميزت الضربات وعلم موته من إحداها، فإنه يقتص ممن علم أنه مات من ضربته، واقتص من الباقي مثل فعله.

هذا إذا حدث القتل منهم من غير تمالؤ، أما لو تمالؤوا على قتله أي اتفقوا وتعاقدوا على قتله وحضروا موقع الجريمة قتلوا به جميعاً وإن كان الضرب بآلة شأنها عدم القتل غالباً كاليد والسوط، بل ولو لم يل القتل إلا واحد منهم بشرط: أن يكونوا بحيث لو استعين بهم أعانوا.

والأصل في ذلك: ما جاء في الموطأ^(١) عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قتل نفراً خمسة أو سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً واحداً قتل غيلة وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً.

وروي عن علي (رضي الله عنه) أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلاً، وعن ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعاً.

ولأنها عقوبة تجب للواحد على الواحد، فوجب للواحد على الجماعة كحد القذف، ويفارق الدية فإنها تتبع بعض، والقصاص لا يتبع بعض، ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى التسارع إلى القتل به، فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر^(٢).

اشتراك جماعة يمتنع القصاص في حق أحدهم لمعنى فيه:

إذا اشترك مكلف وصبي في قتل شخص عمداً عدواناً بتمالؤ واتفاق منهما على قتله قتل المكلف وحده دون الصبي لعدم تكليفه، وذلك لأن العقوبة تجب عليه جزاء لفعله، فمتى كان فعله عمداً وعدواناً وجب القصاص عليه دون النظر إلى فعل شريكه.

ويجب على عاقلة الصبي نصف الدية، لأن عمده كخطئه.

هذا إذا تمالأ على قتله، فإن لم يتمالأ على قتله، وإنما تعمداً قتله فقط دون الاتفاق على ذلك، فلا قصاص على المكلف المشارك للصبي في القتل، لاحتمال كون رمي الصبي هو القاتل، وإنما عليه نصف الدية في ماله، ونصفها الآخر على عاقلة الصبي، إلا أن يدعي أولياء المقتول أنه مات من فعل المكلف فإنهم يقسمون عليه ويقتلونه، فيسقط نصف الدية عن عاقلة الصبي.

(١) الموطأ ص ٧٧٧ رقم (١٥٢٣).

(٢) المغني ٩ / ٣٦٨، بداية المجتهد ٢ / ٤٧٦.

وإذا اشترك مع المكلف المتعمد للقتل مخطئ أو مجنون، فلا يقتص من المكلف المتعمد للشك، لاحتمال أن يكون الموت من رمي المخطئ أو المجنون، ولو أقسم الأولياء على أن القتل منه، لأنه لا صارف لفعل المخطئ أو المجنون، فيمكن حصول الموت من فعلهما معاً، لشدة فعل المخطئ والمجنون بخلاف فعل الصبي.

ويكون على المكلف نصف الدية في ماله، والنصف الآخر على عاقلة المخطئ أو المجنون هذا إن تعمد، فإن كان المكلف هو الآخر مخطئاً فالنصف على عاقلته أيضاً^(١).

الموت بالتصادم أو التجاذب:

إذا تصادم مكلفان معصومان أو تجاذبا حبلاً أو غيره عمدًا، سواء كانا راكبين أو ماشيين أو مختلفين ولو بسفينتين على الراجح، فالقصاص على من بقي منهما، وإن ماتا معاً، فلا دية ولا قود، لفوات محله، وإن كان تصادمهما أو تجاذبهما على وجه الخطأ وماتا، فدية كل واحد منهما على عاقلة الآخر، وإن مات أحدهما فديته على عاقلة من بقي.

ففي المدونة: "قلت: رأيت إذا اصطدم فارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه قال: قال مالك: عقل كل واحد منهما على قبيل صاحبه، وقيمة فرس كل منهما في مال صاحبه"^(٢).

ويلاحظ أن الإمام مالك قال بلزوم القصاص في حال تعمد المصادمة، بل إنه عند جهل القصد والخطأ، يحمل المتصادمان على القصد في غير السفينتين، أما السفينتان فعند جهل الخطأ والعمد، يحمل تصادمهما على الخطأ والعجز لأن

(١) الشرح الصغير للدردير ٢ / ٣٨٦.

(٢) المدونة الكبرى ٤ / ٥٠٦.

جريها بالريح، وليس من أعمال أربابهما، وحينئذ يكون التالف فيهما هدرًا، وإن كان ذلك عن عمد أو تقصير ضمن ملاحوها^(١).

ففي المدونة "قلت: أرأيت لو أن سفينة صدمت سفينة أخرى فكسرتها فغرق أهلها، قال: مالك: إذا كان ذلك من الريح غلبتهم، ومن شيء لا يستطيعون حبسها منه، فلا شيء عليهم، وإن كانوا لو شاءوا أن يصرفوها صرفوها فهم ضامنون"^(٢).

وتصادم السيارتين كتصادم الفارسين، لأن السائق الماهر أقدر على كبح سيارته والسيطرة عليها من الفارس.

موانع القصاص:

مما تقدم يمكن أن نستنبط الموانع التي تحول دون إقامة القصاص على الجاني وهي:

- ١- الأبوة، إلا حالة واحدة وهي قتل الأب ابنه قتلاً لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه، فيقتص من الأب في هذه الحالة.
- ٢- عدم التكافؤ بين الجاني والمجني عليه.
- ٣- إذا كان التمالؤ والاتفاق على القتل دون حضور القتل، فإن حضر ولم يباشر اقتص منه بشرط: أن يكون بحيث لو استعين به أعان.
- ٤- إذا تمالؤوا واشتركوا في القتل، وميزت الضربة التي أزهدت روح المجني عليه، فإنه يقتص من صاحب هذه الضربة فيقتل دون غيره ممن اشتركوا، وإن كان يقتص منهم بقدر أفعالهم بالمجني عليه إن ميزت الضربات جميعاً.

(١) تبين المسال ٤/ ٤٠٧، ٤٠٨، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٢٤٧، ٢٤٨.

(٢) المدونة الكبرى ٤/ ٥٠٦.

الفرع الثالث: مسقطات القصاص

يسقط القصاص بأحد الأسباب الآتية:

١- فوات محل القصاص، وذلك بأن يموت الجاني، أو يقتل من غير المستحق للدم، لأن محله هو نفس القاتل، ولا يتصور بقاء الشيء مع فوات محله، وإذا سقط القصاص بفوات محله، فلا تجب الدية في مال الجاني ولا على العاقلة، لأن القصاص واجب عيناً، فإذا مات سقط الواجب، ولا تؤخذ الدية إلا برضا الجاني^(١).

وخالفنا الحنابلة والشافعية فذهبوا إلى: أن للولي أخذ الدية لأنها بدل عن القصاص عند سقوطه^(٢).

٢- العفو عن القاتل ممن له استيفاء القصاص بشرط: أن يكون في درجة الباقي في الاستحقاق، أو أعلى منه درجة، كعفو أحد ابنين أو أحد أخوين شقيقين، أو عفو شقيق مع أخ لأب، لا إن كان الذي عفا أنزل درجة، كعفو أخ مع ابن.

وإذا كان استيفاء القصاص لنساء كبنت وأخت، فإن البنت - وإن سفلت - أولى بالعفو أو ضده من الأخت، وإن كانتا سواء في الإرث. وإذا لم يكن للقتيل عاصب، وله بنات أو أخوات، وعفت إحداهن وطلب باقيهن القصاص، نظر الحاكم العدل في الأصلح، فأمضاه، فإذا أمضى عفو بعض البنات، فلمن بقي منهن الدية، أما إن عفون كلهن أو طلبن القصاص كلهن، فليس للحاكم النظر في ذلك، وإنما ينجز ما أردن^(٣).

(١) شرح الخرشي ٥١٨، الشرح الكبير للدريز ٢٣٩ / ٤.

(٢) كشاف القناع ٦٣٣ / ٥، المهذب للشيرازي ١٨٨ / ٢.

(٣) منح الجليل ٣٨٦، ٣٨٧، شرح الخرشي ٢٦ / ٨.

وإذا كان المستحقون للقصاص رجالاً ونساءً، والنساء أعلى درجة من الرجال، كبنت وأخت وعصبة، وكان للرجال كلام لكونهم وارثين ثبت القتل ببينة أو إقرار أو قسامة - أو كانوا غير وارثين، ولكن ثبت القتل بقسامة، لم يسقط القصاص إلا بعفو الفريقين جميعاً، أو ببعض الفريقين، فإن عفا فريق، وطلب الفريق الآخر القصاص، فإنه يجاب إلى ذلك.

أما لو كان الرجال مساوين للنساء، فلا كلام للنساء، والاستيفاء للعاصب وحده.

وحيث أسقط بعض المستحقين للدم القصاص، فإنه يسقط، ولكن لمن لم يعف نصيبه من دية العمد، وكذا إذا عفا جميع من له التكلم مترتباً، كما إذا وقع العفو من البعض، ثم بلغ عفوه من بقى من الأولياء فعفي، فإنه لا يضر بقية الورثة من أخت وزوج وزوجة، لأنه مال ثبت بعفو الأول، لأنه بمجرد عفو الأول ترتب لها الحق على الجاني، فلا يسقط بعفو الثاني، فيكون لمن بقي نصيبه من الدية، بخلاف ما لو وقع العفو من الجميع ممن له التكلم في فور واحد فلا شيء لمن لا تكلم له، كما لو كان للمقتول بنون وبنات وزوجة، فعفا البنون في فور واحد، فيسقط حق البنات والزوجة من الدية.

وهذا كله محمول على ما إذا وقع الإسقاط مجائاً، أما إذا وقع على مال، فلمن بقي من الورثة نصيبه من الدية، وإن لم يكن له تكلم، سواء وقع الإسقاط من بعضهم أو من كلهم مترتباً أم لا^(١).

٣- إذا ورث القاتل دم نفسه كله أو بعضه، كأن يقتل أحد ابنين أباهما، ثم مات غير القاتل، ولا وارث له سوى القاتل، فقد ورث القاتل دم نفسه كله، ولو كان الأبناء ثلاثة، وقتل أحدهم الأب، ومات أحدهم غير القاتل، فإن القاتل ورث

(١) الشرح الكبير حاشية الدسوقي ٤/ ٢٦١، ٢٦٢.

بعض دم نفسه، فيسقط القصاص لأن إرثه له كلاً أو بعضاً كالعفو، ولمن بقي نصيبه من دية العمد^(١).

٤- من مسقطات القصاص أيضاً: الصلح من الجاني لولي الدم سواء كان مجاناً أو على مال من الدية، أو أكثر منها حالاً، أو كان على مال من جنس الدية كالعين، أو من غير جنسها كالعرض، لأن العمد لا عقل فيه مسمى والصلح مشروع بقوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾. وقول النبي (ﷺ) "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً".

وحكم الصلح حكم العفو، فمن يملك العفو يملك الصلح، وأثر الصلح كأثر العفو في إسقاط القصاص^(٢).

الفرع الرابع: لمن يكون حق استيفاء القصاص؟

استيفاء القصاص في النفس من الجاني يكون لعاصب المقتول، فلا دخل فيه لغيره من الورثة كالزوج والأم والأخ لأم والجد لأم، فالمقصود به هو العاصب بنفسه وهم الجهات الأربع: البنوة والأبوة والأخوة والعمومة، فلا دخل فيه للعاصب بغيره، ولا للعاصب مع غيره.

وترتيب العاصب هنا كترتيبه في ولاية النكاح، فيقدم الابن فابنه، فالأب، فالأخ فابنه، فالجد، فالعم، فابنه... إلخ (انظر ترتيب الأولياء في النكاح).

ولكن يستثنى من الترتيب في ولاية النكاح تقديم الأخ فابنه على الجد، فيتساويا هنا في القتل والعفو، فلا يقدم الأخوة على الجد، وعليه فإن الجد يحلف بثلاث أيمان القسامة (الآتي ذكرها) إن كان معه أخوان، وإن كان معه أخ واحد، حلف النصف.

(١) المرجع السابق، تبين المسالك ٤/ ٤٢٧.

(٢) الفقه الإسلامي وأدلته ٦/ ٢٩٣.

وانتظر غائب من العصابة عن بلد المقتول إن قريت غيبته أو توسطت، بحيث تصل إليه الأخبار، إن كان مساوياً للحاضر في الدرجة، إلا إذا عفا الحاضر عن القصاص فإن الغائب لا ينتظر، بل له إذا حضر نصيبه من دية العمد.

وأما بعيد الغيبة جداً، فلا ينتظر بالقصاص، كما لا ينتظر مجنون مطبق بخلاف من يفيق أحياناً فتنتظر إفاقته، كما لا ينتظر صغير لم يتوقف ثبوت الدم عليه، بأن يكون من العصابة اثنان فأكثر ولو أبعد منه، أو واحد مساو له أو أبعد منه، ويستعين بعاصب له، فلهم القسامة والقصاص بلا انتظار الصغير ولو تعدد.

وأما لو توقف القصاص على بلوغ الصبي، بأن لم يوجد من العصابة غيره انتظر.

ويحبس القاتل مدة الانتظار، ويقيد بالحديد، لأن العادة الفرار في مثل هذا، ولا يطلق بكفيل، إذ لا تصح الكفالة في القود^(١).

وخالفنا أبو حنيفة والشافعي وأحمد فذهبوا إلى: أن كل وارث يعتبر قوله في إسقاط القصاص، وفي إسقاط حظه من الدية، وفي الأخذ به، فينتظر الصغير والغائب، ويعتبر قول النساء إذا كن وارثات^(٢).

ودلينا على استيفاء القصاص في القتل يكون للعاصب الذكر، قوله تعالى: **﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾**^(٣). والولي هو العاصب الذكر، ونقل القرطبي أن إسماعيل بن إسحاق

(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٢٥٦، ٢٥٧، بداية المجتهد ٢/ ٤٨٠، تبين المسالك ٤/ ٤١٩.

(٢) بدائع الصنائع ٧/ ٣٦٠، مغني المحتاج ٤/ ٥٠، الإنصاف ٩/ ٤٨٢.

(٣) الإسراء ٣٣.

ذكر في قوله تعالى ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيَّهِ﴾ ما يدل على خروج المرأة عن مطلق لفظ الولي، فلا جرم أنه ليس للنساء حق في القصاص لذلك، ولا أثر لعفوها، وليس لها الاستيفاء^(١).

فاستيفاء القصاص عندنا لا يكون للنساء إلا بثلاثة شروط

أحدها: أن يكن وارثات، احترازًا عن العمة والخالة ونحوهما.

ثانيها: أن لا يساويهن عاصب في الدرجة، بأن لم يوجد عاصب أصلاً، أو جد ولكنه أنزل رتبة منهن، كعم مع بنت أو أخت.

ثالثها: أن يكن عصابة لو كن ذكوراً، فلا كلام للجدة من الأم والأخت للأم والزوجة.

الفرع الخامس: صفة القصاص

المشهور من المذهب أن القاتل يقتل بالذي قتل به ولو كان ناراً، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾^(٢). وقوله تعالى ﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾^(٣) ولما روي عن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان؟ حتى ذكروا يهودياً، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله (ﷺ) أن يرض رأسه بين حجرين "

(١) تفسير القرطبي ١٠ / ٢٥٤، ٢٥٥.

(٢) النحل ١٢٦.

(٣) البقرة ١٩٤.

وأيضاً لما روي عن النبي (ﷺ) قوله "من عرض عرضنا له، ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه" ومعنى عرض أي عرض بالقذف، ومعنى: عرضنا له، أي بتأديب لا يبلغ الحد^(١).

وأما الجراح فيطلب فيها القصاص من الجاني بأرفق ما جنى به، فإذا أوضح بحجر أو عصا اقتص منه بالموسى.

لكن لا يقتل الجاني بمحرم قتل به، كخمر أكره شخصاً معصوماً على شربها حتى مات، أو لواط فعله به كرهاً فمات، فلا يقبل بالخير، ولا يجعل نحو خشبة في دبره حتى يموت، كما أن القاتل لا يقتص منه بما يطول الموت به، كأن يمنع طعاماً أو ماء عن شخص حتى يموت، فلا يقتل بذلك، بل يقتل بالسيف في هذه المسائل التي لا يقتص بها، لأن ذلك معاصي، ولا يجوز لأحد أن يأمر بمعصية، لأنه فسق^(٢).

تداخل الجنايات:

إذا جنى القتال عمداً على طرف وإن لغير المقتول عمداً، كما لو قطع يد شخص، وفقاً عين آخر بعد قتله للمجني عليه أو قبله ولم يستوف، فإن الطرف يندرج تحت القتل، فلا تقطع يده، ولا تفقأ عينه، بل يكفي القتل وحده، إلا إذا قصد الجاني مثله، بالمجني عليه المقتول، حيث كان القطع والفقاً لمن قتله عمداً، فإنه يقتص منه للطرف ثم يقتل^(٣).

لمن يكون الحق في مباشرة القصاص؟

القصاص إذا وجب فإنه يشترط في مباشره شرطان: أحدهما: أن يكون من أهل المعرفة بالقصاص.

(١) تبیین المسالك ٤/٢٩٤.

(٢) شرح الخرشي ٨/٢٩، بداية المجتهد ٢/٤٢٨.

(٣) الشرح الكبير للدردير ٤/٢٦٦.

ثانيهما: أن يكون من أهل العدالة.

فإن كان القصاص في النفس، فالحاكم بالخيار إن شاء اقتص بنفسه، وإن شاء رد القتل إلى مستحق الدم، لكن لما كان يخاف من الجور في القصاص وجب على الحاكم أن ينهيه عن العبث بالجاني، فلا يمثل به. وإن كان القصاص في جرح، فإن الذي يتولاه الحاكم، لأن الأصل عدم تمكين غير الإمام في استيفاء الحدود والقصاص، فورد النص بأنه (ﷺ) أسلم القاتل لولي الدم، وقال: دونك صاحبك، فبقي ما عداه على أصله^(١).

(١) شرح الخرشي ٨ / ٢٤.

الفرع السادس: وقت استيفاء القصاص

استيفاء القصاص يكون بعد ثبوت موجباته، والإعذار إلى القاتل في ذلك إن لم يكن مقرراً، ولكن إن كان القصاص فيما دون النفس فإنه يؤخر وجوباً في الحالات الآتية:

١- في الحر والبرد المفرطين، خوف الهلاك على الجاني، فيؤدي إلى أخذ نفس فيما دونها.

٢- إذا كان الجاني مريضاً، فلا يقام القصاص حتى يبرأ الجاني، وتبرأ أطراف المجني عليه أيضاً، لاحتمال أن يأتي الهلاك على النفس، فتستحق تلك النفس بقسامة.

٣- إذا كان الجاني امرأة حاملاً، فإنها تؤخر وجوباً إلى الوضع ووجود مرضع.

٤- إذا كان الجاني امرأة مرضع وكان الجرح مخيفاً يخاف عليها الموت إن اقتص منها.

٥- إن اجتمع عليه قطع أكثر من طرف، وخيف عليه الهلاك من قطعهما أو قطعهم في فور واحد فإنه يقام عليه أكبرها، ثم يؤخر حتى يبرأ.

وإن كان القصاص في النفس، فإنه يؤخر وجوباً في حالتين:

الأول: الحمل حتى الوضع، والثاني: الرضاعة إذا لم تجد للولد من يرضعه حتى يستغني بالطعام عن اللبن^(١).

النوع الثاني من أنواع عقوبة القتل العمد: العقوبة البديلة:

إذا سقط القصاص من الجاني بموته أو بوراثته دمه كله أو بعضه، أو بالصلح على الدية طبقت عقوبتان أخريان هما:

(١) شرح الخرشي ٨/ ٢٥، تبیین المسالك ٤/ ٤٢٢، بداية المجتهد ٢/ ٤٨٢.

١ - الدية.

٢ - التعزير.

وإذا سقط القصاص بالعفو عن الجاني من ولي الدم، فلا تجب الدية إلا برضا الجاني، لأنه لا يجب للولي في القتل العمد إلا أن يقتص من الجاني أو بعفو عن غير دية، أما العفو على الدية، فلا يجوز إلا برضا الجاني، وقد يرضى بأقل منها أو أكثر، أو من جنسها، أو من غير جنسها، وعليه: فإن الذي يجب على الجاني بسقوط القصاص بالعفو عنه على الدية أو ما اتفق على دفعه هو التعزير، بعد دفع ما اتفق عليه إن كان بينهما اتفاق على شيء^(١).

أولاً العقوبة البدلية الأولى - الدية:

تعريفها: الدية مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه، مقدراً شرعاً لا باجتهاد^(٢).

وهي مأخوذة من الودى بوزن الفتى، وهو الهلاك، وسميت بذلك لأنها مسببة عنه، فسميت باسم سببها.

وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع.

أولاً: الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾^(٣). وهذه الآية وإن كانت في القتل الخطأ إلا أن العلماء أجمعوا على وجوب الدية في القتل العمد إذا سقط القصاص بأحد المسقطات التي سبق ذكرها.

(١) بداية المجتهد ٢/ ٤٧٨، ٤٨١، الشرح الكبير ٤/ ٢٣٩.

(٢) حدود ابن عرفة ص ٤٨٠.

(٣) النساء ٩٢.

ثانياً: السنة: حديث عمرو بن حزم في الديات وهو: أن رسول الله (ﷺ) كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات، وكان في كتابه "أن في النفس الدية مائة من الإبل..."^(١).

ثالثاً: الإجماع: فقد أجمع العلماء على وجوبها.

شروط وجوب الدية:

ويشترط لوجوب الدية شرط واحد فقط وهو العصمة، والعصمة - كما سبق - تكون بإسلام أو أمان، فتجب للمسلم والذمي والكتابي المعاهد، والمجوسي المعاهد، والمرتد على المشهور، ولا تجب للحربي لأنه غير معصوم الدم، ولا للمجوسي غير المعاهد^(٢).

نوع الدية ومقدارها:

الدية ثلاثة أنواع: إبل، وذهب، وفضة، فالإبل على أهل البادية، فإن لم يكن عندهم إبل، بل خيل مثلاً، كلفوا بما في حاضرتهم، وقيل: يكلفون قيمة الإبل.

والذهب والفضة على أهل الحضر، وينظر فيها إلى حال الناس، فإن غلب فيهم الذهب كان الدية منه، وإن غلب فيهم الفضة كانت الدية منها. فالدية عندنا منحصرة في هذه الثلاثة - الإبل والذهب والفضة - فلا يؤخذ في الدية بقر ولا غنم ولا عرض، فإذا لم يوجد في البلد غير ذلك فالذي استظهره بعضهم أنهم يكلفون ما في أقرب البلاد إليهم الموجود فيها شيء من الأصناف الثلاثة، ولا يؤخذ مما وجد عندهم^(٣).

(١) الموطأ مع تنوير الحوالك ص ٧٦١.

(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٢٦٧، ٢٦٨.

(٣) حاشية الدسوقي ٤/ ٢٦٧.

وكذا لا يؤخذ من أهل بلد إلا ما ثبت في حقهم، وما يكون به تعاملهم، وعلى ذلك إجماع أهل المدينة، قال مالك في الموطأ "الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق، ولا من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب"^(١).

وخالفنا الحنابلة فذهبوا إلى: أن الدية تجب من ستة أجناس، وهي الإبل وهي أصل الدية بالإجماع، والذهب والفضة، والبقر، والغنم، والحلل، وقدر الحل عندهم مائتا حلة من حلل اليمن كل حلة بردان، إزار ورداء جديان^(٢). وأما مقدارها، فمن الإبل مائة، ومن الذهب ألف دينار، ومن الورق والفضة اثني عشر ألف درهم.

والأصل في ذلك: قوله (ﷺ) في الكتاب الذي كتبه لعمر بن حزم في العقول: "أن في النفس مائة من الإبل"^(٣).

وأن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قوم الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم^(٤).

وذهب أبو حنيفة إلى أن الدية من الفضة عشرة آلاف درهم، وذهب الشافعي إلى أن الدية على أهل الذهب والورق قيمة المائة من الإبل بالغة ما بلغت من غير اعتبار بألف دينار، ولا باثني عشر ألف درهم، لأن الواجب الأصلي في الدية هو مائة من الإبل، فيرجع إلى قيمتها عند فقد الأصل^(٥).

(١) الموطأ ص ٧٦٢.

(٢) المغني ٩ / ٤٨٢.

(٣) رواه مالك في الموطأ ص ٧٦١.

(٤) المرجع السابق.

(٥) مختصر القدوري مع شرح الميداني ٣ / ١٥٣، الأم ٦ / ١٠٥ مختصر المزني ص ٢٤٤.

هذه دية المسلم الذكر، وأما اليهودي والنصراني والذمي فديته نصف دية المسلم، لنقصان حرمتهم عن حرمة المسلم، وكذلك المرأة المسلمة ديتها نصف المسلم لقوله (ﷺ) دية المرأة على النصف من دية الرجل^(١).

هذا هو مقدار الدية في القتل العمد إذا عفا عليها ولي الدم، بأن قال: عفوت على الدية، ولم يذكر قدرًا محددًا، وإلا بأن عفي على قدر محدود من المال، كان أقل من الدية أو أكثر، فإنه يصار إليه ولا يلتفت إلى المقدار الأصلي للدية، فيجب دفعه لولي الدم، لأن دية العمد غير محدودة، فيجوز ما يتراضون عليه من قليل أو كثير، فإن أبهت كانت مثل دية الخطأ.

كيفية أداء الدية في القتل العمد:

الأصل أن جناية العمد لا دية فيها، وإنما للولي القصاص أو العفو لقوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ...﴾ إلى قوله تعالى: فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴿﴾ فلولي القتل العفو مجانًا، وله الصلح مع الجاني بما اتفقا عليه مقابل تنازله عن القصاص كما تقدم، لذا فإن الكيفية التي تؤدي عليها الدية في القتل العمد تخضع لما اتفق عليه ولي الدم والجاني، فإن اتفقا على دفعها حالة، دفعت حالة، وإن اتفقا على دفعها منجمة، دفعت منجمة، وإن لم يتفقا على شيء من ذلك دفعت من مال الجاني حالة، ولا تكون على العاقلة مطلقًا، سواء دفعت منجمة أو حالة، لما روي عن ابن عباس أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدًا، ولا اعترافًا ولا صلحًا في عمد ولا مخالف له من الصحابة، لأن الأصل يقتضيه وهو: أن بدل المتلف على المتلف يجب وأرش الجناية على الجاني، قال النبي (ﷺ): لا يجني جان إلا على نفسه،

(١) أخرجه البيهقي ٨ / ٩٥.

وقال لبعض أصحابه حين رأى معه ولده "ابنك هذا؟ قال نعم. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه.

ولأن موجب الجناية أثر فعل الجاني، فيجب أن يختص بضرره كما يختص بنفعها.

وإنما خولف هذا الأصل في قتل المعذور فيه لكثرة الواجب وعجز الجاني في الغالب عن تحمله مع وجوب الكفارة عليه، وقيام عذره تخفيفاً عنه ورفقاً به، والعامد لا عذر له، فلا يستحق التخفيف ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ^(١).

ودية العمد في الإبل أربع، خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. ولا تغلظ إلا في قتل الأب لابنه فتكون أثلاثاً ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون خلفه، وهي الحوامل^(٢).

ولا تغلظ الدية على أهل الذهب والورق، لأن الصحابة لم تقوم دية التغليظ على أهل الذهب والورق، ولأن التغليظ في الإبل بالسن، وهذا لا يتصور إلا في الإبل.

ثانياً: العقوبة البدلية الثانية - التعزير:

التعزير لغة: التأديب، لأنه يمنع عن معاودة الذنب، ويمنع من تعاط القبح. واصطلاحاً: عقوبة غير مقدرة تجب حقاً لله - تعالى - أو لآدمي في كل معصية لا حد فيها^(٣). ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله.

(١) المغني ٩ / ٤٩٠.

(٢) بداية المجتهد ٢ / ٤٩٣، ٤٩٤، المعونة ٣ / ١٣١٩.

(٣) الأحكام السلطانية ص ٤٧٧.

وحكم تعزيز القاتل في القتل العمد واجب عندنا إذا لم يقتص، وتعزيزه يكون بضربه مائة جلدة، وحبس سنة، سواء كان القتل لحر أو عبد، وكذلك إن كان القاتلون جماعة، فقتل واحد منهم قصاصًا، فإن بقيتهم يضربون مائة ويحسبون عامًا^(١).

النوع الثالث: العقوبة التبعية للقتل العمد:

هناك عقوبة أخرى للقاتل في القتل العمد وهي الحرمان من الميراث، والدية إن عفي عنه، لأن الدية موروثة كسائر التركة كانت عن خطأ أو عمد، لأنها مال للمقتول، إذ هي بدل عن نفسه، ألا ترى أنه يقضي منها ديونه وتنفذ وصاياه.

وقد نص على هذه العقوبة الرسول (ﷺ) فقال: "ليس للقاتل شيء"^(٢) وعملاً بالقاعدة الفقهية التي تنص على أن من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه".

والقتل الذي يمنع من الميراث هو القتل العمد، ولو كان القاتل صبيًا أو مجنونًا، مباشرًا أو متسببًا، وحتى لو كان قتله له بشبه تدرأ عنه القتل، كقتل والد ولده بحديدة شأنها عدم القتل.

وأما القتل الخطأ، فلا يحرم القاتل من الميراث، وإن كان يحرم من دية من قتله^(٣).

والأصل في ذلك: ما جاء عن مالك في الموطأ "الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتله شيئًا، ولا من ماله، ولا يحجب أحدًا

(١) القوانين الفقهية ص ٢٩٦.

(٢) رواه مالك في الموطأ ص ٧٧٤.

(٣) تبين المسالك ٤ / ٦٠٤، ٦٠٥، شرح الخرشي ٨ / ٢٢٣.

وقع له ميراث، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئاً، ويرث من ماله، لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه"^(١).

(١) الموطأ ص ٧٧٥.

المبحث الثاني

القتل الخطأ

سبق وأن ذكرت أن الجناية على النفس نوعان: عمد وخطأ، وقد سبق الحديث عن جناية القتل العمد وعقوبته، وفي هذا المبحث سيكون الحديث عن الجناية الأخرى على النفس وهي القتل الخطأ، من حيث تعريفه وعقوبته.

تعريف القتل الخطأ:

القتل الخطأ هو: أن لا يقصد الجاني الضرب ولا القتل، مثل لو سقط على غيره فقتله، أو رمى صيداً فأصاب إنساناً^(١).

وهذا النوع من القتل لا قصاص فيه باتفاق، وإنما فيه عقوبتان:

العقوبة الأولى: الدية، والعقوبة الثانية: الكفارة:

ودليل ذلك: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ والدية - كما سبق - مال مقدر شرعاً، وهي من الإبل مائة، ومن الذهب ألف دينار، ومن الفضة اثني عشر ألف درهم.

كيفية أداء الدية في القتل الخطأ:

دية القتل الخطأ تجب لولي الدم مخففة، ومظاهر التخفيف في الآتي:

- ١ - أنها تدفع لولي الدم منجمة في ثلاث سنين، ثلثها أولها يوم الحكم لا يوم القتل، ويحل النجم الثالث بآخر السنة الثالثة، وكذلك كل نجم غيره.
- وسواء كانت دية النفس، أو دية الطرف، كدية الأذنين، أو قطع الذكر أو الأنثيين.

هذا إذا كانت الدية كاملة فإن كانت ناقصة، كنصف دية، أو ثلث دية، أو

ثلثين، فقد اختلف في تنجيمها على قوين:

(١) القوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٩٥.

أحدهما: أنها تؤخذ حالة، ولا تتجم إلا الدية الكاملة.

والثاني: أنها تتجم، لأنها أرش جناية خطأ بلغ الثلث، فأشبهه الكاملة.

وفي كيفية التجيم روايتان:

الأولى: النصف في سنتين، لأنه أقرب إلى التخفيف، والثلث في السنة،

والثلثان في السنتين.

والثانية: أنه يجتهد فيه على ما يرى^(١).

٢- أنه تكون لولي الدم على الجاني والعاقلة، والجاني كواحد من

العاقلة.

٣- والمظهر الثالث من مظاهر التخفيف في دية القتل الخطأ هو أنها

إن كانت من الإبل فإنها تكون خمسة على النحو التالي:

عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون

حقه، وعشرون جذعة.

وقد سبق أن دية القتل العمد إذا قبلت تكون مربعة، خمس وعشرون بنت

لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون

جذعة.

وأما دية خطأ العمد، وهي حالة قتل الوالد لولده دون قصد القتل، كما لو

رماه بحديدة فقتله، فإنها تكون مثثة، ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون خلفه

في بطونها أولادها، وتكون مغلظة، فتكون في مال الوالد حالة^(٢).

وعليه: فالديات ثلاثة، خمسة ومربعة ومثثة، فالمخمسة للخطأ المطلق،

والمربعة للعمد إذا قبلت، فهي لا تجب إلا أن يصطلحوا عليها - كما تقدم،

(١) التقرير ٢/ ٢١٣، المعونة ٣/ ١٣٢٦، شرح الخرشي ٨/ ٤٧، ٤٨.

(٢) شرح زروق على الرسالة ٢/ ٢١٣.

والمثلثة وهي المغلظة ولا تكون عندنا إلا في صورة واحدة، وهي الرجل، يرمي ولده بحديدة فيقتله.

العاقلة

العاقلة هي التي تتحمل العقل أي الدية، وهي عدة أمور: العصبه، وأهل الديوان، والموالي، وبيت المال.

ولكن أهل الديوان يقدمون على العصبه إن كان القاتل منهم، وأهل الديوان هم الجيش أو العسكر الذين دونت أسماؤهم في دفتر يضبط عددهم وعطاؤهم، فينزل ضبط عددهم وعطائهم بدفتر منزلة النسب، لما جبلوا عليه من التعاون والتناصر، ولكن يعقلون عن الجاني منهم إذا كانوا يعطون أرزاقهم المعينة لهم في الدفتر من بيت المال.

وإن لم يكن ديوان، أو كان وليس الجاني منهم، أو منهم ولم يعطوا بدئ بالعصبه، الأقرب فالأقرب، وترتيبهم كترتيب الولاية في النكاح.

فإن لم يكن للجاني عصبه فمواليه الأعلون، وهم المعتقون (بكسر التاء) الأقرب فالأقرب، ثم مواليه الأسفلون وهم المعتقون (بفتح التاء) ويقدم الأقرب فالأقرب فإن لم يكن للجاني عصبه ولا موالي، فإن الدية تدفع من بيت المال إن كان الجاني مسلماً، وإن لم توجد عصبه ولا موال ولا بيت مال للمسلمين، أو لهم وتعذر الوصول إليه، تكون الدية على الجاني في ماله منجمة^(١).

هذا ولا تضرب الدية على كل فرد من العاقلة إلا بقدر حاله، فلا يجوز التغليظ عليهم بالزيادة، لأن الأخذ منهم على وجه الصلة والتبرع تخفيفاً على القاتل، وإذا ضربت على العاقلة بقدر حال كل واحد، ثم بعد ذلك أعسر أحدهم

(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٨٣، تبين المسالك ٤ / ٤٥٤، ٤٥٥.

أو مات، فإنه لا يسقط عنه شيء مما ضرب عليه على المشهور، وتحل بالموت والفلس.

وتضرب الدية على من حضر وغاب من القبيلة، ولو بعدت غيبته إن لم تكن غيبة انقطاع، وإلا فلا يضرب عليه.

من الذي يؤدي الدية من العاقلة؟

لا يؤديها إلا الذكور البالغين العقلاء الموسرين الموافقين للجاني في الدين والدار، وتوزع عليهم حسب حالهم في المال، فيؤدي كل واحد منهم ما لا يضر به كما سبق.

وعليه، فلا يطالب بها الصبي والمجنون والمرأة والفقير والكافر، لأنه ليس منهم تناصر، ولعجز الفقير واحتياجه^(١).

والمعتبر في الفقر والصبا والجنون وقت توزيع الدية على العاقلة، فإذا أيسر فقير، وبلغ صبي، وعقل مجنون بعد التوزيع، فلا شيء عليهم. ويعقل عن الصبي والمجنون والمرأة والفقير إذا جنوا.

عدد العاقلة:

أقل العاقلة سبعمائة، فإن تحملها أهل الديوان وكانوا أقل من هذا العدد ضم إليهم عصبة الجاني الذين ليسوا معه في الديوان^(٢).

شروط تحمل العاقلة الدية:

تؤدي العاقلة الدية بأربعة شروط، وهي:

- ١- أن تكون الدية الثلث فأكثر، وإلا فعلى الجاني في ماله حالة .
- ٢- وأن تكون الدية عن دم حر، احترازًا عن قيمة العبد، فعلى الجاني في ماله.

(١) المرجع السابق، القوانين الفقهية ص ٢٩٨.

(٢) حاشية الدسوقي ٤ / ٢٨٣.

- ٣- وأن تكون الدية عن قتل خطأ، وإلا كانت على الجاني في ماله.
- ٤- وأن يثبت القتل بغير اعتراف الجاني، بأن يثبت ببينة وما في معناها من لوث وقسامة.
- ٥- وأن يكون القتل للمقتول من غيره، فإن قتل نفسه، عمداً أو خطأ، فلا تحمل العاقلة شيئاً من الدية، لأنه ليس له دية أصلاً، بل هو هدر.
- وخالفنا الأوزاعي قائلًا: من أخذ يضرب بسيفه في العدو، فأصاب نفسه، فعلى عاقلته الدية، وهذا مروى عن أحمد بن حنبل أيضاً^(١).

العقوبة الثانية: الكفارة:

الكفارة في القتل الخطأ واجبة ومرتبة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، كعتق الرقبة في كفارة الظهار، فما يطلب هناك يطلب هنا، وما يمتنع هناك يمتنع هنا، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا إطعام فيها لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾^(٢) ومن لم يستطع الصوم فإنه ينتظر القدرة على العتق أو الصيام، ولا يجزئه الإطعام.

والكفارة واجبة في القتل الخطأ بالشروط الآتية^(٣):

- ١- أن يكون القاتل حرًا، وكذلك المقتول، فإن كان القاتل رقيقًا فلا تجب عليه الكفارة بالعتق، لعدم صحة عتقه، لأنه لا ولاء له، ويجوز تكفيره بالصوم، وإن كان المقتول رقيقًا، فلا تجب الكفارة أيضًا، لأنه مال مقوم، فلم تجب بإتلافه كفارة كالبهائم.

(١) شرح ابن ناجي على الرسالة ٢/ ٢٤٠، شرح زروق ٢/ ٤٠، شرح الخرشي ٨/ ٤٤.

(٢) النساء ٩٢.

(٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٢٨٦.

٢- وأن يكون القاتل والمقتول مسلمين، فإن كان القاتل كافرًا فلا يجب عليه كفارة لأنه ليس من أهل القرب، وإن كان المقتول كافرًا، فلا تجب على القاتل كفارة أيضًا، لأن الكفارة وجبت في قتل المؤمن لحرمة دمته، وتحريم دمه، وذلك غير موجود في الكافر، ولأنها لم تجب في قتل المؤمن عمدًا، فكانت بأن لا تجب في قتل الكافر أولى.

٣- أن يكون المقتول معصوم الدم، فلا تجب الكفارة على قاتل الزنديق^(١)، أو الزاني المحصن.

٤- أن يكون القتل خطأ، فلا تجب في عمد عفي عنه، بل تندب.

لماذا وجبت الكفارة في القتل الخطأ، ولم تجب في القتل العمد؟

وجبت الكفارة في القتل الخطأ دون العمد، لأن القتل العمد أعظم من أن تكفره الكفارة، ألا ترى أن الكبائر لا كفارة فيها كعقوق الوالدين، واليمين الغموس، ولأن العمد معنى يوجب القتل، فلم يوجب كفارة، وفي الحديث "ومن أظلم ممن هدم بنيان الله، لهدم الكعبة ورمىها في البحر حجرًا حجرًا أيسر عند الله من قتل نفس مؤمنة"^(٢).

على من تكون الكفارة؟

الكفارة واجبة على الجاني في ماله، ولو كان صبيًا أو مجنونًا، لأن الكفارة من خطاب الوضع بالنسبة للقسم المالي، فقد جعل الشارع القتل خطأ سببًا لوجوب الكفارة في مال الجاني، ولو حدث القتل من صبي أو مجنون، والوجوب على الولي، فإن أعسر كل منهما، انتظر للبلوغ والإفاقة لأجل أن يصوما.

(١) وهو من يسر الكفر ويظهر الإسلام. شرح ابن ناجي ٢/٢٤٨.

(٢) شرح زروق على الرسالة ٢/٢٤٨.

وكذلك تجب الكفارة على الجاني في ماله ولو كان شريكاً لصبي أو مجنون أو غيرهما، ويكون على كل منهما كفارة كاملة لأنها لا تتبع بعض^(١).

ولا تتحمل العاقلة عن الجاني من الكفارة شيئاً، لأنها شرعت للتكفير عن الجاني، ولا يكفر عنه بفعل غيره، وتفارق الدية من وجوه:

١- أن الدية شرعت لجبر المحل، وذلك يحصل بها كيفما كان، والكفارة شرعت للتكفير عن الجاني - كما سبق -.

٢- أن الدية مال كثير، فأيجابها على القاتل يحفف به، والكفارة بخلافها.

٣- أن الدية وجبت مواساة للقاتل، وجعل حظ القاتل من الواجب الكفارة، فأيجابها على غيره يقطع المواساة، ويوجب على غير الجاني أكثر ما وجب عليه، وهذا لا يجوز^(٢).

القتل الذي تندب فيه الكفارة:

تندب الكفارة للحر المسلم في حالات القتل الآتية^(٣):

- ١- في قتله رقيقاً، سواء كان مملوكاً له، أو مملوكاً لغيره.
- ٢- وفي قتل الجنين.
- ٣- وفي قتل الذمي، سواء وقع القتل خطأ أو عمداً.
- ٤- وفي القتل العمد الذي لا يقتل به، إما لكونه عفي عنه، وإما لعدم التكافؤ، وأما لو قتل به، فلا يتوهم فيه كفارة، بل يجزم بعدمها.

بم يثبت القتل؟

يثبت القتل بثلاثة أشياء:

(١) حاشية الدسوقي ٤ / ٢٨٦.
(٢) الشرح الكبير للمقدسي ٩ / ٤٨٥.
(٣) شرح الخرشي ٨ / ٥٠.

١ - باعتراف القاتل أنه قتل فلاناً المجني عليه.

ويشترط في الاعتراف أن يكون واضحاً مفصلاً قاطعاً بارتكاب الجناية عمداً أو خطأ، فلا يصح الإقرار المجمل الغامض، أو المشتغل على شبهة، حتى يتحدد نوع العقاب، إذ لا عقاب -مثلاً- على القاتل دفاعاً عن النفس أو المال^(١).

ويشترط لصحة الإقرار من المقر: أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً غير متهم في إقراره^(٢).

فلا يصح إقرار المتهم في إقراره لملاطفة صديق ونحوه، لأن التهمة تخل برجحان جانب الصدق على الكذب في إقراره، وكذا لا يلزم إقرار الصبي والمجنون والمكره والسكران.

ويكفي في الإقرار مرة واحدة، فلا يشترط تعدده.

٢ - **البينة**، وهي شهادة عدلين، فلا تقبل فيه شهادة النساء كما لا تقبل في الحدود كلها، وذلك لخطورتها، وضرورة التأكد من ثبوتها، ولأن في شهادة المرأة بدلاً من الرجل شبهة البدلية، لقيامها مقام شهادة الرجال، فلا تقبل فيما يندرى بالشبهات^(٣).

(١) الفقه الإسلامي وأدلته ٦ / ٣٨٦.

(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣ / ٣٩٧.

(٣) الفقه الإسلامي ٦ / ٣٨٩.

٣ - القسماء، وفيها مسائل:

المسألة الأولى: صفتها:

القسماء في اللغة: الأيمان^(١).

وفي الاصطلاح: حلف أولياء الدم خمسين يمينًا أو جزءها على إثبات الدم^(٢).

وتغلظ اليمين في القسماء بالزمان والمكان والكيفية، فالزمان كونه بعد العصر ويوم الجمعة، والمكان بأن يكون في الأماكن المعظمة، فيجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس، وإلا ففي المسجد الأعظم بعد الصلاة، والهيئة أن يحلف قائمًا لكونها أردع للحالف وأهول في حقه، لعله يرجع للحق إن كان مبطلًا، فإن لم يحلفوا قيامًا، فهل يكون كالنكول أو لا؟ قولان.

فإن حلف الأولياء وجب بها القصاص في العمد، والدية في الخطأ.

وخالفنا الشافعي وأبو حنيفة فقالا، تجب بها الدية ولا يراق بها دم^(٣).

وعمدة مالك ومن قال بقوله وهم الحنابلة: ما روي عن بشير ابن يسار أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحبيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر، فتفرقا في حوائجهما، فقتل عبد الله بن سهل، فقدم محبيصة، فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي (ﷺ) فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه، فقال رسول الله (ﷺ) كبر كبر، فتكلم حويصة ومحبيصة، فذكرا شأن عبد الله بن سهل، فقال لهم رسول الله (ﷺ) أتخلفون خمسين يمينًا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر، فقال لهم رسول الله "قتبرئكم يهود

(١) المصباح المنير ص ٥٠٣.

(٢) شرح زروق على الرسالة ٢ / ٢٢٢.

(٣) القوانين الفقهية ص ٢٩٨، بداية المجتهد ٢ / ٥١٤.

بخمسين يمينًا؟ فقالوا: يا رسول الله: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فوداه رسول الله (ﷺ) من عنده^(١).

هذا وسنة القسامة سنة منفردة بنفسها مخصصة للأصول كسائر السنن المخصصة، والعلة في ذلك: حوطة الدماء، وذلك أن القتل لما كان يكثر، وكان يقل قيام الشهادة عليه، لكون القاتل يتحرى بالقتل مواضع الخلوات، جعلت هذه السنة حفظاً للدماء.

ولهذه العلة أيضاً جوز مالك شهادة المسلوبين على السالبين من قطاع الطريق والسراق^(٢).

وكانت القسامة على العصبة فقط في دعوى العمد، لأنه ليس طريقها الميراث، لأنها مستحقة بالنصرة والولاية كالنكاح.

المسألة الثانية: من يجوز قسامته في العمد من ولادة الدم؟

لا يحلف في العمد أقل من رجلين من عصبة المقتول، لقوله (ﷺ) "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟" فجمعهم في الأيمان، ولأن الدم لما كان لا يستحق بأقل من شاهدين لم تصح القسامة إلا باتنين، والنصاب شرط، فإن لم يكن الولي غير واحد فلا قسامة إلا أن يجد من يحلف معه من العصبة أو العشيرة الذين يجتمعون معهم في أب واحد معروف، فيقسم كل واحد منهما خمسة وعشرين يمينًا، وإن كانوا أكثر قسمت الأيمان على حسبهم، فإن نكلوا عن الأيمان، ردت الأيمان على المدعى عليه، فيحلف خمسين يمينًا أنه ما قتل، فإن نكل بعض الأولياء ففيها قولان: قيل: يحلف من بقي منهم ويأخذ نسيبه من الدية، لأن القود

(١) رواه مالك في الموطأ ص ٧٨٣.

(٢) بداية المجتهد ٢/ ٥١٣، ٥١٤.

قد سقط بالنكول. وقيل: ترد اليمين على المدعى عليه، فإن نكل حبس حتى يحلف، فإن طال حبسه ترك، وعليه جلد مائة وحبس عام^(١). ولا يحلف في القسامة في العمد النساء لأن استحقاق الدم بالقسامة شرطه الذكورية، وكذا لا يحلف الصبيان لأنه لا حكم لقولهم، ولا يقتل بدعواهم، ولا يحلف في القسامة رجل واحد.

المسألة الثالثة: كم يقتل بالقسامة من الجناة؟

لا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد، فإن انفرد أقسموا عليه وقتلوه، وإن تعدد المدعى عليهم، فإنهم يختارون واحداً، فيقسمون عليه، ثم يقتل. وقال سحنون: إن كان الضرب واحداً حلفوا على الجميع، ثم قتلوا واحداً، وإن افترقوا في الضرب، لم يحلفوا إلا على واحد، ثم يقتل. قال مالك في الموطأ: لم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد^(٢). وذلك لأن القسامة أضعف من الإقرار والبيئة، ولأن الردع يحصل بقتل واحد منهم^(٣). وإذا قتل منهم واحد، فلا دية على الباقيين، لأنهم لم يثبت عليهم الدم لا بقسامة ولا بغيرها، فلا وجه لإلزامهم الدية.

المسألة الرابعة: شروط وجوب القسامة في القتل العمد:

القسامة لها شروط لا تجب إلا بها وهي سبعة^(٤):

- ١- أن يكون المدعى عليه بالغاً عاقلاً (مكلفاً).
- ٢- أن يكون المقتول عمداً عدواناً.
- ٣- أن يكون القتل غير ثابت ببيئة ولا اعتراف.

(١) القوانين الفقهية ص ٢٩٩.

(٢) موطأ مالك ص ٧٨٥.

(٣) المعونة ٣ / ١٣٥٠.

(٤) شرح زروق على الرسالة ٢ / ٢٢٢.

- ٤- أن يثبت القتل باللوث.
- ٥- أن تكون الدعوى بين مسلمين يصح قتل أحدهما بالآخر، ومن مسلم حر على ذمي ونحوه.
- ٦- أن يتحد المطلوب بالدم ويتعدد الحالفون.
- ٧- أن يكون الحالفون عصابة ، واثنين فصاعداً.

المسألة الخامسة: موجب القسامة:

لا تجب القسامة إلا بلوث، فهو شرط في ثبوتها، وهو: أمانة على القتل غير قاطعة، ولكن يغلب على الظن صدقها^(١). ويقال له اللطخ، وعرفه العلامة زروق في شرحه على الرسالة بأنه: القرينة المقوية للتهمة^(٢).

واللوث أن يقول شخص بالغ عاقل وإن أنشئ قتلني فلان، أو دمي عند فلان أو يدعي ولد على والده أن دمه عنده، أضجعه وذبحه، أو زوجة على زوجها، ولكن يشترط حتى يكون قول المجني عليه لوثاً أربعة شروط:

- ١- أن يكون به جرح، ويسمى التدمية الحمراء، وينزل منزلته الضرب أو السم.

- ٢- أن يتمادى على إقراره.
- ٣- أن يكون بالغاً عاقلاً مسلماً.
- ٤- أن يشهد على قوله عدلان.

وإنما قلنا إن قول المقتول في العمد دمي عند فلان لوث، لأن حال الموت حال تقرب إلى الله - تعالى - وإقلاع عن المعاصي وتوبة من الذنوب، هذا هو

(١) القوانين الفقهية ص ٢٢٩، المعونة ٣ / ١٣٤٣.

(٢) ص ٢٢٣ / ٢.

الظاهر من المسلمين والعادة فيهم، فلا يتهمون بتزوير ونحوه من كذب وتدليس حال ورودهم على الله^(١).

ومن اللوث أيضاً: أن يشهد شاهدان بجرح أو ضرب للمقتول، أو يشهدا بإقرار المقتول بأن فلاناً جرحه أو ضربه عمداً أو خطأ ثم يتأخر الموت، فيحلف الأولياء ويستحقون القود في العمد والدية في الخطأ، أما إذا لم يتأخر الدم، بل مات على الفور، فإنهم يستحقون الدم أو الدية بغير قسامة.

ومن اللوث: شهادة الشاهد العدل على معاينة القتل.

ومن اللوث: أن يحصل على المقتول في دار مع قوم فيوجد مقتولا بينهم، أو يكون في محله قوم أعداء له.

وفي شهادة الشاهد الواحد والجماعة غير العدول والنساء، روايتان: إحداهما: أن شهادتهما لوث، والأخرى: أنها ليست بلوث^(٢).

المسألة السادسة: القسامة في قتل الخطأ:

أيمان القسامة في الخطأ تفارق العمد في أمور^(٣):

الأول: في دخول النساء فيها، وعدم تقيدها بالعصبة.

الثاني: في أنه إذا لم يكن للمقتول وارث إلا رجل واحد، فإنه يحلف الخمسين يميناً ويأخذ نصيبه من الدية، ويسقط ما على الجاني من الدية.

الثالث: أن من له نصيب من الإرث يحلف على قدر نصيبه، فتوزع الأيمان على الأنصباء، بخلاف القسامة في العمد، فإنها تقسم بين العصبة على عددهم.

(١) المعونة ٣/ ١٣٤٧.

(٢) الشرح الكبير للدردير ٤/ ٢٨٧، وما بعدها، وشرح زروق ٢/ ٢٢٣.

(٣) شرح زروق ٢/ ٢٢٥.

كيفية حلف الأيمان في القتل الخطأ:

إذا كان ورثة المقتول جماعة، فإن الأيمان توزع على المكلفين منهم على قدر الميراث، ومن لا يرث لحجب أو منع لا يحلف، لأن القسامة سبب في حصول الميراث، فإذا كان محجوباً أو محروماً فلا يحلف، فإن كان في الأيمان كسور إذا قسمت بينهم، نظر إلى الذي يكون عليه أكثر، ذلك المكسور فتجبر عليه تلك اليمين، وإن كان أقلهم نصيباً، كما لو كان الورثة ابن وبنت، على الابن ثلاثة وثلاثون يميناً وثلاث، وعلى البنت ستة عشر وثلثان، فيجبر كسر اليمين على البنت، لأن كسر يمينها أكثر من كسر يمين الابن وإن كانت البنت أقل نصيباً، فتحلف سبعة عشر يميناً، فلو تساوى الكسر، كثلاثة بنين على كل ستة عشر وثلثان، فتكمل على كل، فيحلف كل منهم سبعة عشر.

وإذا غاب بعضهم أو كان صغيراً، فإن غيره يحلف جميع الأيمان، ويأخذ حصته من الدية، لأن العاقلة لا يخاطبون بالدية إلا بعد ثبوت الدم، وهو لا يثبت إلا بعد حلف جميع أيمان القسامة، ثم إذا حضر من كان غائباً، أو بلغ الصغير يحلف حصته فقط من أيمان القسامة ويأخذ ما يخصه من الدية.

وإن نكلوا كلهم عن أيمان القسامة أو بعضهم، فإن الأيمان ترد على عاقلة الجاني فيحلف كل واحد منهم يميناً واحدة، ولو كانوا عشرة آلاف رجل، فمن حلف منهم برئ، ولا يلزمه غرم، ومن نكل منهم، فإنه يغرم ما وجب عليه، والقاتل كواحد منهم، فإن لم تكن عاقلة، حلف الجاني خمسين يميناً ويبرأ، فإن نكل غرم حصته.

وإن كان وارث المقتول واحداً، رجلاً أو امرأة حلف خمسين يميناً وأخذ حصته من الدية، والباقي يسقط من على الجاني - كما سبق^(١).

(١) شرح الخرشي ٨ / ٥٦، الموطأ ص ٧٨٥.

المسألة السابعة: ما لا قسامة فيه من القتل:

ليس كل قتل تصح فيه القسامة، وإنما القسامة لا تكون إلا إذا توافر في

القتل شروط ذكرناها سابقاً، منها يتبين لنا القتل الذي لا تكون فيه قسامة وهو:

١- قتل العبد، فلا قسامة فيه، لأنه مال، وحرمة دون حرمة الحر، فلا يستباح له ما يستباح للحر، ولكن إذا أصيب العبد عمداً أو خطأ، ثم جاء سيده بشاهد، حلف مع شاهده يميناً واحدة، ثم يأخذ قيمة عبده^(١).

٢- قتل الذمي، فلا قسامة فيه إذا قتله مسلم، أو قتله ذمي مثله وتحاكموا إلينا، وذلك لأنه أنقص حرمة من المسلم، وهذا بخلاف ما إذا قتلوا منا قتيلاً، فإن القسامة متوجهة.

٣- القتل بين الصفين، فلا قسامة فيه على إحدى الروايتين، وديته على الفئة التي نازعت إن كان من الفئة الأخرى، وإن كان من غيرها فديته عليهما معاً.

والرواية الأخرى: إن وجد بينهما معاً فهو لوث يوجب القسامة لولاته فيقسمون على الذي عليه الدعوى ويقتلونه.

وهذا كله إذا كان القتال على غير تأويل دين، فإن كان بخلاف ذلك، فلا قسامة ولا دية ولا قود.

٤- القتل يوجد في محلة قوم ولا يدري من قتله، لم يؤخذ به أحد، وتبطل ديته، فلا تكون في بيت المال ولا غيره، ومحل هذا: إذا لم يوجد معه أحد، أما لو وجد معه رجل وعليه أثر القتل، قتل به مع القسامة^(٢).

(١) الموطأ ص ٧٨٦.

(٢) المعونة ٣/ ١٣٤٤، شرح زروق ٢/ ٢٢٨.

ولا قسامة أيضًا في الجراح، لأن الجراح يتسع فيها النظر ويتوجه
الاحتمال، بخلاف القتل فإنه متحد لا يقع به الجزم إلا بعد التحقيق، ولأن حرمة
الجراح أخفض من حرمة النفس، ألا ترى أنه لا كفارة فيها^(١).

(١) المرجعين السابقين.

الفصل الثاني

الجنابة على ما دون النفس

الجنابة على ما دون النفس: هي كل اعتداء على جسد إنسان من قطع عضو، أو جرح أو ضرب مع بقاء النفس على قيد الحياة، فهي على نوعين:

الأول: الجرح

الثاني: قطع عضو وإزالة منفعة.

النوع الأول: الجرح وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في أسماء الجراح:

وهي عشرة^(١):

١- الموضحة (بكسر الضاد) وهي التي أظهرت عظم الرأس أو الجبهة أو الخدين.

٢- الدامية، وهي التي أضعفت الجلد حتى يرشح منه شيء كالدم، من غير أن ينشق.

٣- الخارصة، وهي التي شقت الجلد.

٤- السمحاق (بكسر السين المشددة) وهي التي كشطت الجلد، أي إزالته عن اللحم.

٥- الباضعة، وهي التي شقت اللحم.

٦- المتلاحمة، وهي التي غاصت في اللحم في عدة مواضع منه، ولم تقرب من العظم.

٧- الملطاة (بكسر الميم) وهي ما قاربت العظم، ولم يبق بينها وبين العظم إلا ستر رقيق.

(١) القوانين الفقهية ص ٣٠٠، الشرح الكبير ٤ / ٢٥١، ٢٥٢.

- ٨- المنقلة، وهي ما ينقل بسببها فراشن العظم (أي العظم الرقيق الكائن فوق العظم كقشر البصل) للدواء ليلتئم الجرح، ولا تكون إلا في الرأس أو الوجه، وتسمى أيضاً بالهاشمة، أي التي تهشم العظم.
- ٩- الآمة، وهي ما أفضت لأم الدماغ، وأم الدماغ جلدة رقيقة مفروشة على الدماغ، متى انكشفت عنه مات صاحبها.
- ١٠- الدامغة، وهي ما خرقت أم الدماغ ولم ينكشف، بل أحدث فيها ثقباً قدر مغرز الإبرة، وإلا مات.

المسألة الثانية: في الواجب في الجرح:

الجرح لا يخلو من أن يكون خطأ أو عمدًا، فإن كان عمدًا ففيه القصاص، والجرح الذي فيه القصاص حكمه حكم النفس في الفعل، بحيث يقصد به العدوان، وفي الفاعل بأن يكون الجاني مكلفًا معصومًا، وفي المفعول بأن يكون المجني عليه معصومًا بإيمان أو أمان، ومكافئًا للجاني في الحرية ويزاد شرط آخر على شروط القصاص في النفس وهو: أن يكافأ الجاني المجني عليه في الإسلام والحرية، فلا قصاص في جرح ناقص لكامل، كأن يجرح كافر مسلمًا، أو عبد حرًا مسلمًا فلا قصاص في ذلك على المشهور، وإنما فيه الدية، وذلك لأنه كجناية ذي يد شلاء على صحيحة، وإن كان يقتص منه في النفس - كما تقدم.

جاء في الموطأ: قال مالك: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح، والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدًا، ولا يقتل الحر بالعبد إن قتله عمدًا، وهو أحسن ما سمعت^(١).

(١) الموطأ ص ٧٧٩.

شرط القصاص في الجراح:

يشترط حتى يقتص من الجراح للمجروح تحقق المماثلة قال تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ أي مساواة، يؤخذ الجاني بمثل ما جنى به إن أمكنته المماثلة، ولم يخف سريانه للنفس، وإلا فالواجب هو العقل لا القصاص. والأصل في وجوب القصاص في الجروح العمد قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾^(١).

وعن أنس أن الربيع بن النضر، (عمته) كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو، فأبوا، فعرضوا الأرش، فأبوا، فأتوا رسول الله (ﷺ) فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله (ﷺ) بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله: أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتهما. فقال رسول الله (ﷺ): يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله (ﷺ): "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" متفق عليه.

وعليه الإجماع وعمل أهل المدينة، جاء في المغني "وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن، ولأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص، فكان كالنفس في وجوبه"^(٢).

وفي الموطأ "الأمر المجتمع عليه عندنا أن من كسر يداً أو رجلاً عمداً أنه يقاد منه ولا يعقل"^(٣).

والجراح التي يقتص من الجاني فيها هي:

(١) المائدة ٤٥.

(٢) المغني ٩ / ٣١٩.

(٣) الموطأ ص ٧٨٠.

- ١- الموضحة، وهي ما أوضحت عظم الرأس أو الجبهة، أو الخدين،
- كما سبق ولا يشترط في الموضحة - قصاصاً أو دية- أن يكون الجرح له بال
واتساع، بل يقتص منه وإن كان ضيقاً كقدر مغرز الإبرة.
- ٢- ما دون الموضحة من الجراحات، وهي التي لا يظهر بها العظم
وهي ست، ثلاث متعلقة بالجلد، وثلاث متعلقة باللحم، فالثلاث المتعلقة بالجلد
هي: الدامية، والخارصة، والسحاق، وأما الثلاث المتعلقة باللحم فهي: الباضعة،
والمتلاحمة، والملطاة.
- ٣- المنقلة إن كانت في غير الرأس، أما المنقلة في الرأس فلا
قصاص فيها، لعظم الخطر، وإنما فيها العقل.
- ٤- باقي جراح الجسد ما لم يعظم، كعظام الصدر والعنق والصلب
والفخذ وشبه ذلك، فإنه لا قصاص فيها، وإنما فيها العقل.
- ٥- ضربة السوط، فإنه يقتص منها، لأن السوط جرح، يحصل من
الضرب به الجرح^(١).

كيفية القصاص في الجراح:

يقيس أهل الطب والمعرفة الجرح طولاً، وعرضاً، وعمقاً، ثم يشقون مقداره
في الجراح - فقد تكون الجراح نصف عضو المجني عليه، وهي جل عضو
الجاني أو كله، بشرط: أن يكون ذلك في العضو الواحد، وعليه: لو عظم عضو
المجني عليه حتى كان القدر الذي جرح منه يزيد على العضو المماثل له من
الجاني، فإنه لا يكمل من غيره، بلا خلاف.

(١) الشرح الكبير للدريدر ٤/ ٢٥١، تبين المسالك ٤/ ٤١١.

واعتبار القصاص بالمساحة يكون: إن اتحد المحل، ولم يحصل بالجرح إزالة عضو، أما إذا حصل به إزالة عضو، فلا ينظر للمساحة، بل يقطع العضو الصغير بالكبير المماثل له، وعكسه^(١).

الحكم إذا زاد المباشر للقصاص أو نقص:

إذا زاد الطبيب أو المباشر للقصاص في القصاص من الجاني على القدر المطلوب المأذون فيه عمدًا، اقتصر منه بقدر مساحة الزيادة، وإن لم يعتمد فلا يقتصر منه، وإنما اللازم الدية فيما زاد به، وإن نقص الطبيب من القدر المطلوب فعله بالجاني عمدًا أو خطأ، فلا يقتصر من الجاني ثانيًا لأنه قد اجتهد.

وإذا قطع الطبيب أو المباشر في الموضع المعتاد، فمات الجاني، لم يكن عليه شيء، وإن زاد على ذلك يسيرًا ووقع القطع فيما قارب كان خطأ وعلى عاقلة الطبيب الدية، وإن زاد على ذلك فيما لا يشك فيه أن ذلك عمد، كان فيه القصاص، وإن تردد بين الخطأ والعمد، كانت عليه الدية مغلظة.

والأصل في ذلك: عمل أهل المدينة، ففي الموطأ "قال مالك، الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة أن عليه العقل، وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يعتمد ذلك ففيه العقل"^(٢).

وقت استيفاء القصاص:

لا يقتصر من الجراح حتى تتدخل وتبرأ جراح المجروح، فيقاد من الجراح، وذلك لأنه ربما ينتهي الجرح بالمجروح إلى الموت، فيحصل القصاص بالنفس لا بالجرح، فإن جاء جرح الجراح مثل جرح المجروح حين يصح فهو القود، وإن زاد فليس على المجروح شيء.

(١) حاشية الدسوقي ٤ / ٢٥١، شرح الخرشي ٨ / ١٥، القوانين الفقهية ص ٣٠٠.

(٢) الموطأ ص ٧٦٤.

وإن شلت يد المجرور بسبب الجرح، أو برأت وبها عيب أو نقص، فإنه يقاد من الجرح بمثل الجرح الذي جرحه للمجرور، ويكون عليه عقل ما نقص من يد المجرور.

سراية القصاص فيما دون النفس:

السراية هي: سراية الجرح الحاصل بالقصاص من العضو إلى النفس أو إلى عضو آخر.

ولا شيء على المقتص -كما سبق- بسريان القصاص إلى النفس أو العضو، لأن السراية حصلت من فعل مأذون فيه بخلاف سراية الجناية، فإنها مضمونة لأنها أثر الجناية^(١).

فوات محل القصاص:

إذا فات المحل الذي سيقام فيه القصاص، كأن يفوت العضو، أو تفوت النفس كلها بالموت قبل أن يقتص منه، فلا شيء للمجني عليه، لا من القصاص، لفوات محله، لأنه إنما تعلق حقه بالعضو المماثل، وقد ذهب ولا من الدية، لأن الواجب في العمد إنما هو القصاص.

والأصل في ذلك، ما في الموطأ "قال مالك في الرجل يقتل الرجل عمداً أو يفتق عينه عمداً، فيقتل القاتل أو تفتق عين الفاقئ قبل أن يقتص منه: أنه ليس عليه دية ولا قصاص، وإنما كان حق الذي قتل أو فقت عينه في الشيء بالذي ذهب"^(٢).

الجراح التي لا يقتص من الجاني فيها:

- ١- المنقلة التي تكون في الرأس.
- ٢- الآمة، وهي التي وصلت لأم الدماغ.

(١) القوانين الفقهية ص ٣٠١.

(٢) الموطأ ص ٧٧٩.

٣- الدامغة: وهي ما خرقت خريطة الدماغ ولم تنكشف.

٤- الجائفة، وهي التي وصلت إلى الجوف.

٥- شفر العين، وشعر الحاجب، وشعر اللحية، لا قصاص فيه، وفيه الحكومة إذا لم ينبت.

٦- اللطمة على الخدين بباطن الراحة، فلا قصاص فيها ولا عقل، بل في عمدتها الأدب، ما لم ينشأ عنها جرح، وإلا اقتص منه، وتصير كما إذا ذهب بها معنى كسمع ونحوه فلا يقتص بالضرب، بل إن أمكن ذهاب المعنى بغير فعل، وإلا فالعقل.

٧- ما يعظم فيه الخطر، ككسر العظم والعنق ونحو ذلك^(١).

والعلة في عدم وجوب القصاص في هذه المسائل: خطره على النفس، والأصل في ذلك قوله (ﷺ) "لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة". ما تقدم في الجرح العمد، أما الجرح الخطأ فلا قصاص فيه ولا أدب، وإنما فيه الدية، ففي الموضحة نصف عشر الدية، وهي خمس من الإبل، ويعتبر به في الذهب والورق.

وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها، وفي المأمومة والجائفة ثلث الدية، وفي الدامية والخارصة والسحاق والباضعة والمتلاحمة، والمطاة حكومة، وليس فيها دية معلومة، والحكومة هي: أن يقوم المجني عليه لو كان عبدًا سليمًا، ثم يقوم بالجناية، فما نقص من ديته جعل من قيمته بالغًا ما بلغ.

الخلاصة:

جراح البدن إما في الرأس فتسمى شجاجًا، وإما في البدن فتسمى جراحًا، فكل شجاج جراح، وليس كل جراح شجاجًا، فالشجاج كله على الاجتهاد - أي

(١) الشرح الكبير للدريدر ٤/ ٢٥٢، ٢٥٣، تبين المسالك ٤/ ٤١٣، ٤١٤.

فيه حكومة- إلا ثلاثة الموضحة والمنقلة والمأمومة، وجراح الجسد كلها كذلك إلا الجائفة، فهذه الأربع فيها أمر مقرر من الشارع وهو ما ذكر.

النوع الثاني: قطع العضو، وإزالة المنفعة:

قطع العضو إن كان عمداً ففيه القصاص إلا أن يخاف منه التلف، وإن كان خطأ ففيه الدية، وهي تختلف، ففي كل زوج من البدن دية كاملة، وفي الفرد نصف الدية، وذلك العينان والأذنان والشفتان واليدين والرجلان والأنثيان والإليتان، وثديا المرأة، وفي الأنف واللسان والذكر دية كاملة، وفي السن خمس من الإبل، وفي كل إصبع عشر من الإبل.

وفي إزالة العقل والسمع والبصر والشم والنطق والصوت والذوق وقوة الجماع والقدرة على القيام والجلوس الدية كاملة.

فإن أزال بعض هذه المنافع فعليه بحساب ما نقص، فإن أزال سمع الأذن الواحدة أو بصر العين الواحدة، فعليه نصف الدية، وفي عين الأعور دية كاملة.

من يتحمل دية الخطأ في الجراح؟

إذا كان العقل المدفوع أقل من ثلث الدية فعلى الجاني في ماله، فإن كان الثلث فأكثر فهي على العاقلة.

وأما جراح العمد إذا لم يقتص من الجراح فيها فالدية على الجراح، لأن العاقلة لا تحمل عمداً ولا اعتراقاً^(١).

دية جراح المرأة:

دية جراح المرأة كدية جراح الرجل فيما دون ثلث الدية الكاملة، فإذا بلغت الثلث أو زادت عليها رجعت إلى نصف دية الرجل، وعليه: ففي ثلاثة من أصابعها ثلاثون من الإبل، وفي أربعة عشرون من الإبل.

(١) القوانين الفقهية ص ٣٠١.

العقوبة الثانية للجناية على ما دون النفس:

أوجب المالكية^(١) عقوبة ثانية للجاني على الأطراف بقطعها عمدًا، أو بالاعتداء على الجسد بجرح أو ضرب وهي الأدب باجتهاد الحاكم، وهو ما يسمى بالتعزير، سواء كان الواجب في الجناية القصاص أو الدية لتعذر القصاص، وذلك مبالغة في الردع.

الفصل الثالث

الجناية على نفس غير مكتملة (الجنين)

الجناية على الجنين جناية على نفس إنسانية معصومة، ومن ثم وضع المشرع عقوبة لمن يتسبب في الجناية عليه بالموت بعد اكتماله، أو الإلقاء وإن كان علقه، بلا فرق بين كون الجناية عمدًا أو خطأ، من أجنبي أو من أب أو أم، كانت الجناية بسبب ضرب، أو تخويف لغير وجه شرعي، أو شم ريح كحقة أو فتح كنيف أو شم رائحة مسك أو سمك أو نحو ذلك، فإذا شمت ذلك من الجيران مثلاً، فعليها أن تطلب منهم أن يجنبوها الروائح التي تؤذيها، فإن لم تطلب ولم يعلموا بحملها حتى ألقته، فعليها الغرة لتقصيرها وتسببها، فإذا طلبت منهم فلم يجنبوها هذه الرائحة مع علمهم أن ذلك مسقط لحملها فإنهم يضمنون، وإن كان حفظ حملها يكون بتعاطي رائحة المسك أو الطعام وجب عليهم أن يعطوها منه^(٢).

(١) الشرح الكبير للدردير ٢٥٣/٤، الشرح الصغير وحاشية الصاوي ٣٨٩/٢.

(٢) حاشية الصاوي ٣٩٧/٢.

وعقوبة الجاني على الجنين تختلف باختلاف الأم الحامل، فإن كانت الأم حرة، فالواجب في الجناية على جنينها غرة عبد^(١) أو وليدة^(٢)، أو عشر دية أمه، والتخيير للجاني لا لمستحقها .

وشرط وجوب الغرة أو عشر دية الأم: أن انفصل الجنين عن أمه ميتاً وهي حية، فلو انفصل كله بعد موتها أو بعضه في حياتها وبعضه بعد موتها فلا شيء فيه لاندراجها في الأم^(٣).

والدليل على هذه العقوبة أحاديث كثيرة منها: ما رواه أبو هريرة (رضي الله عنه) "أقتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختموا إلى رسول الله (ﷺ) فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها"^(٤).

كيفية دفع دية الجنين:

دية الجنين تجب على الجاني في ماله حالة عمدًا كانت الجناية أم خطأ، إلا أن تبلغ ثلث دية الجاني فعلى العاقلة، كما لو ضرب مجوسي حرة مسلمة فألقت جنينًا، فدية المجوسي ستة وستون دينارًا أو ثلثا دينار، وعشر دية الحرة المسلمة خمسون دينارًا، ولا شك أن الخمسين أكثر من ثلث دية الجاني، فحينئذ تحمل العاقلة عنه، ويكون واحدا منها.

حكم ما لو استهل الجنين صارخًا:

سبق وأن ذكرت أن شرط وجوب الغرة، أو عشر دية الأم أن انفصل الجنين عن أمه ميتاً وهي حية، وأما لو ضرب الجاني الأم فانفصل الجنين عنها

(١) غرة كل شيء: أوله وأكرمه، وأفضله.

(٢) الوليدة الأمة الصغيرة التي بلغت سبع سنين وعدمها لئلا يتوهم اشتراط كبرها.

(٣) الشرح الكبير للدريدر ٢٦٥ / ٤.

(٤) متفق عليه نيل الأوطار ٦٩ / ٧.

حيًا حياة مستقرة بأن استهل صارخًا، أو رضع كثيرًا، ونحو ذلك، سواء انفصل منها وهي حية أو ميتة، ثم مات بعد ذلك ففيه الدية كاملة على العاقلة، لأن حياته قد ثبتت، فقاتله قاتل خطأ بشرط. أن يقسم أولياء الجنين أنه مات من فعل الجاني، فإن لم يقسموا فلا دية ولا غرة ولو مات عاجلاً بعد تحقق حياته، لأن الجنين إذا استهل صارخًا صار من جملة الأحياء فلم يكن فيه غرة، وعدم الدية لتوقفها على القسامة، وقد امتنع الأولياء منها^(١).

حكم تعمد ضرب الجنين:

إن تعمد الجاني الجنين بضرب بطن أمه أو ظهرها أو رأسها فنزل حيًا ثم مات ففيه أقوال ثلاثة.

الأول: يقتص من الجاني بقسامة.

الثاني: الواجب فيه الدية في مال الجاني بقسامة.

والثالث: إن تعمد الضرب في البطن أو الظهر فالقصاص، وإن تعمد الضرب في الرأس فالدية في ماله كتعمده ضرب يدها أو رجلها وهو الراجح^(٢). ومحل القصاص في تلك المسائل: إن لم يكن الجاني الأب، وإلا فلا يقتص منه؛ إلا إذا قصد قتل الجنين بضرب البطن خاصة^(٣).

تعدد الواجب بتعدد موجهه:

الواجب في الجناية على الجنين وهو الغرة أو العشر إن نزل الجنين ميتًا، والدية مع القسامة إن نزل حيًا ثم مات، يتعدد بتعدد الجنين، فإن قتل جنينين ففيهما غرتان أو خمس دية الأم إن نزلا ميتان، وديتان إن نزلا حيان ثم ماتا.

(١) حاشية الدسوقي ٢٦٩/٤.

(٢) الشرح الصغير وحاشية الصاوي ٣٩٨/٢، شرح الخرشي ٣٣/٨.

(٣) المعونة ١٣٥٨/٣، حاشية الدسوقي ٢٧٠/٤.

ورثة دية الجنين:

تورث الواجبات في الجناية على الجنين من عشر وغرة ودية ولو تعددت بتعدد الجنين على فرائض الله - تعالى - فرضاً وتعصيياً، لأنها دية نفس آدمي مقتولة، فكانت لجميع ورثتها. وإذا كان الجاني على الجنين من الأبوين أو الإخوة كان كالقاتل، فلا يرث من الواجب المذكور شيئاً^(١).

(١) المعونة ٣/ ١٣٥٨، حاشية الدسوقي ٤/ ٢٧٠.

ملخص ما سبق دراسته في باب الدماء

- ١- الجناية : اسم لفعل جرمه الشارع ، سواء وقع على نفس أو مال أو غيرهما .
- ٢- الجريمة : محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير .
- ٣- العقوبة : الجزاء الذى قرره الشرع وينال الإنسان على فعل شر .
- ٤- الحد : عقوبة مقدرة شرعا وجبت حقا لله تعالى .
- التعزير : عقوبة غير مقدرة شرعا لجرائم لم يرد بشأنها نص .
- ٦- القصاص في الإسلام يقتضى المماثلة بين العقوبة والجناية.
- ٧- حفظ النفس من الكليات الخمس المجمع عليها في كل ملة ، وإزهاق النفس بغير وجه شرعي كبيرة ليس بعد الشرك أعظم منها .
- ٨- أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق ، والقصاص مشروع في الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع .
- ٩- أركان القصاص ثلاثة : جان - ومجنى عليه - وجناية (الفعل الموجب للقصاص).
- ١٠- يشترط في الجاني حتى يقتص منه ثلاثة شروط : أ- التكليف ب - العصمة بإيمان أو أمان ج -المكافأة للمجنى عليه .
- ١١- يشترط في المجنى عليه حتى يستحق القصاص : أ- أن يكون معصوما ب - أن يكون مكافأ للجاني ، أو زائدا عليه .
- ١٢- الجناية التي يثبت بشأنها قصاص يشترط فيها : أ- أن تكون عمدا ب- أن تكون عدوانا .
- ١٣- يقتل القاتل بالذي قتل به ، من ضربة بحديدة ، أو حجر ،أو..... يكرر ذلك عليه حتى يموت ؛ إذا كان موجبا للموت غير معذب تعذيباً يطول ؛ فإن كان مما لا يؤمن معه تعذيب الجاني قتل بالسيف .

١٤- تقتل الجماعة بالواحد بشرطين : أ- إن تعمدوا ضربه ولم تتميز الضربات ، أو تميزت وتساوت . ب- إن تمالؤا على قتله ، بأن قصد الجميع قتله ، وانفقوا عليه .

١٥- يسقط القصاص بأحد الأسباب الآتية:

أ- فوات محل القصاص .

ب- العفو عن القاتل ممن له استيفاء القصاص .

ج- إذا ورث القاتل دم نفسه كله أو بعضه .

د- الصلح بين الجاني وأولياء الدم ، سواء كان على دية أم مجانا .

١٦- الدية : مبلغ من المال أو ما في معناه يدفع إلى المجنى عليه أو أوليائه .

١٧- مقدار الدية من الإبل : مائة على تفصيل في ذلك ، ومن الذهب ألف دينار من الذهب ، واثنًا عشر ألف درهم من الفضة ، أو ما قيمته ذلك كله بالعملة المتداولة الآن .

١٨- الجرح الذي لا قصاص فيه ولا مقدار له من الشرع فيه حكومة (مال غير مقدر يحكم به أهل الخبرة) .

١٩- وقت استيفاء القصاص يكون بعد ثبوت موجباته ، والإعذار إلى القاتل .

٢٠- إن كان القصاص فيما دون النفس فإنه يؤخر وجوبا في الحالات التي يخاف فيها هلاك الجاني ، كالحر والبرد المفرطين ، أو كان الجاني امرأة حاملا أو مرضعا .

أسئلة على ما سبق دراسته في أحكام الدماء

س ١ : بين معانى المصطلحات الآتية :

الجناية - الحد - التعزير - الدية - القسامة .

س ٢: اذكر شروط قتل الجماعة بالواحد ، مبينا مسقطات القصاص.

س ٣ : أكمل العبارات الآتية :

- الجناية التي يثبت بشأنها القصاص يشترط فيها :

١- ٢- ٣-

- القصاص في يقتضى بين

.....و.....

- عصمة الدم تكون بأحد أمرين :

١- ٢-

- يقتل بالأنثى ، والصحيح

.....و..... بالناقص عضوا ، والمتسبب مع

س ٤ : من له حق استيفاء القصاص ؟ وهل تستحقه النساء ؟

س ٥: ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة

الخاطئة مبينا السبب:

أ- يقتل الصبي إذا قتل شخصا مكلفا .

ب- السكران بحلال لا يقتص منه .

ج - لا يقتص من الأم إذا منعت وليدها من الرضاع حتى لو قصدت قتله

.

د- إذا سقط القصاص بفوات محله وجبت الدية .

الباب الخامس
البغي

الهدف من دراسة حد البغي والحاربة

يتوقع من الطالب بعد دراسة حدى البغي والحاربة أن يصل إلى الأهداف

التالية :

- ١- حقيقة معنى البغي والحاربة، وأنها محرمان في الإسلام .
- ٢- كيفية التعامل مع الفرقة الباغية، والتدرج في التعامل معها.
- ٣- معرفة الآثار المدمرة لجريمة الحاربة، حيث إنها من الإفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد.
- ٤- بيان كيف تحدث القرآن الكريم والسنة النبوية عن جريمة قطع الطريق ، والوقوف على العقوبات التي قررها الإسلام لقطاع الطريق.
- ٥- بيان الحكمة الإلهية من تشريع العقاب لكل من جريمتي البغي والحاربة .
- ٦- معرفة المقاصد والغايات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية الغراء، صيانة للأنفس والأعراض والأموال .
- ٧- الوقوف على نعمة الأمن والأمان المترتبة على محاربة الرزائل وكافة الجرائم التي تؤدي إلى نشر الخوف والاضطراب في صفوف المجتمع .

البغي

تعريف البغي.

البغي لغة: التعدي، يقال بغي الرجل على الرجل استطال وتعدى عليه.
قال الفراء: البغي الاستطالة على الناس، وقال الأزهري: معناه الكبر والظلم والفساد^(١).

والبغي شرعاً: هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأويلاً^(٢).

والشيخ خليل استغنى عن تعريف البغي بتعريف الباغية حيث قال: "الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو خلعه"^(٣)، وذلك لأن الباغي مشتق من البغي ومعرفة المشتق تستلزم معرفة المشتق منه؛ لأن المشتق ذاتٌ سبق لها المشتق منه، فالمشتق منه جزء من مفهوم المشتق ومعرفة الكل تستلزم معرفة الجزء^(٤).

شرح تعريف ابن عرفة.

قوله (الامتناع): جنس في التعريف يشمل جميع أنواع الامتناع سواء كان الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته أو من لم تثبت، وسواء كان بمقاتلة أو بغير مقاتلة.

(١) لسان العرب ١ / ٣٢٣.

(٢) الشرح الكبير ٤ / ٢٩٨.

(٣) مختصر الشيخ خليل بن إسحاق المالكي إشراف الشيخ أحمد نصر ٢٨٢ مطبعة مصطفى حجازي القاهرة.

(٤) حاشية الدسوقي ٤ / ٢٩٨.

وقوله (من طاعة من تثبت إمامته) : قَيِّدُ يخرج به الامتناع من طاعة من لم تتعقد له الإمامة، فإنه لا يعد باغياً كخروج الإمام الحسين وأتباعه عن طاعة يزيد بن معاوية، فإنه لا يعد باغياً؛ لأن يزيد لم تثبت إمامته من جميع الناس فأهل الحجاز لم يسلموا له لظلمه.

وقوله (في غير معصية) : إما حال أو متعلق بطاعة، وهذا يقتضي أن من خرج عن طاعة الإمام في مكروه يكون باغياً.

وقال القرطبي: لا تجب طاعة الإمام في المكروه ^(١) أي المجمع على كراهيته وعلى هذا الممتنع لا يكون باغياً وهذا هو الأظهر؛ لأنه من الأمور المحدثه من الدين أي ليست منه، وهي غير مقبولة من فاعلها لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " .

وقوله: (بمغالبة) جار وجرور متعلق بالامتناع وهو قيد يخرج به الامتناع من طاعة من تثبت إمامته في غير معصية من غير مغالبة فلا يكون باغياً.
مثال ذلك: ما وقع لبعض الصحابة أنه مكث أشهراً لم يبايع الخليفة ثم بايعه.

وقوله (ولو تأويلاً) قيد لبيان أن الامتناع عن طاعة من تثبت إمامته يكون باغياً سواء كان الممتنع متأولاً بأن كان عنده شبهة لخروجه عن طاعته أو لم يكن متأولاً بأن كان خروجه للعناد والهوى.

لذا اعتبر أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - من امتنع عن دفع الزكاة بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - باغياً وقاتلهم مع أنهم كانوا متأولين، حيث إن بعضهم زعم أن أخذ الزكاة قاصر على النبي - صلى الله عليه وسلم -

(١) الخرشي على مختصر خليل ٨ / ٢٤٨ دار صادر.

استناداً إلى قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)
التوبة: ١٠٣.

والبعض الآخر زعم أن الخلافة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت
لعلي لا لأبي بكر^(١).

فأهل البغي هم الخارجون على الإمام يريدون خلعه، أو يمتنعون من
الدخول في طاعته على سبيل التأويل لا الجحود.

حكم البغي.

البغي حرام لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " من نزع يده من طاعة
إمامه فإنه يأتي يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه
يموت ميتة جاهلية "^(٢).

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : " من حمل علينا السلاح فليس منا
"^(٣).

ويجب الحض على الالتزام بالطاعة ووحدة الجماعة وعدم الخروج على
الإمام المسلم فقد روى ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال
من كره من أمره شيئاً، فليَصْبِرْ، فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة
جاهلية "^(٤).

الأمور التي تثبت بها الإمامة:

(١) حاشية العدوي على هامش الخرشبي ٨ / ٢٤٨.

(٢) سبل السلام ٣ / ٢٥٧.

(٣) نيل الأوطار ٧ / ١٧١، ١٧٣.

(٤) أخرجه البخاري بإسناد عن ابن عباس ٩ / ٥٩.

لما كان الخروج عن طاعة من ثبتت إمامته يُعدُّ بغياً فوجب أن نعرف الأمور التي تثبت بها الإمامة وهي:

١- البيعة من أهل الحلِّ والعقد، وهم أصحاب الرأي والكلمة في الدولة الإسلامية.

ويشترط أن تجتمع فيهم ثلاث صفات: العدالة، والرأي، والعلم بشروط الإمامة وهي:

أ- أن يكون مستجمعاً لشروط القضاء (العدالة، ومستلزماتها^(١)، والذكورة، والفطنة، والفقه).

ب- أن يكون قرشياً.

ج- أن يكون ذا نجدة وكفاية في المعضلات ونزول الدواهي^(٢).

وتحصل المبايعة من أهل الحل والعقد بالقول والمباشرة بصفقة اليد، لمن كان حاضراً، وبالقول والإشهاد عليه لمن كان غائباً.

ويكفي العامي اعتقاد أنه تحت أمره فإن أضمر خلاف ذلك فسق^(٣) ودخل تحت قوله - صلى الله عليه وسلم - : " من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " .

(١) العدالة تستلزم: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية وعدم الفسق. الشرح الصغير مع بلغة السالك لأقرب المسالك ٢٦ / ٣.

(٢) حاشية البناني على هامش شرح الزرقاني على مختصر خليل ٨ / ٦٠، بلغة السالك ٤ / ٤٢٦.

(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ٢٩٨.

٢- إيصاء الخليفة لشخص متأهل للإمامة كما فعل أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - حين عهد إلى عمر بن الخطاب بالخلافة وإن كان بعد استشارة الصحابة والتعرف على آراء أهل الحل والعقد. وليس للخليفة الأول عزله بعد عهده إليه، إلا أن يتغير حاله، كما لا يجوز له عزله لوجود من هو أفضل منه.

٣- القهر والغلبة: فإذا تغلب شخص بقوة عصبية أو عشيرته على الخلافة أصبح بحكم الأمر الواقع إماماً ووجب على الناس طاعته حقناً للدماء ومنعاً للفساد؛ لأن من اشتدت وطأته بالتغلب وجبت طاعته، ولا يراعى في هذا شروط الإمامة إلا الإسلام؛ لأن المدار على درء المفسد وارتكاب أخف الضررين.

حكم الخروج عن طاعة الإمام الذي ثبتت إمامته:

لا خلاف بين الفقهاء في أن الإمام إذا كان عدلاً يعمل بكتاب الله وسنة نبيه لا يجوز الخروج عليه، ومن أظهر الملامح في وحدة المسلمين؛ أن يلتحم المسلمون في بنیان راسخ من حول الإمام بعد أن يبادروه بالبيعة على السمع والطاعة، وأن لا يَشُقُّوا عليه بعدها عصا الطاعة، وأن لا يخرجوا عليه في أمر يدعوهم إليه ما أقام فيهم كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - لقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) النساء: ٥٩ .

وأن من خرج عليه يعد باغياً يجب قتله وعلى المسلمين مساندة الإمام في ردعه وصدده.

وأما إن كان غير عدل فجمهور أهل السنة من المحدثين والفقهاء على أنه إن لم يأمر بالمعصية ولم يُرَ منه الكفر صريحاً، فلا يجوز الخروج عليه ولو

كان جائراً أو ظالماً أو فاسقاً حقناً للدماء ومنعاً للفساد، وتعطيل الحقوق، بل
الواجب على جميع المسلمين وعظه وتذكيره حتى يرجع.
وذكر الدسوقي في حاشيته: إذا كان الإمام غير عدل لا يجوز الخروج
عليه تقديماً لأخف المفسدتين^(١).

(١) حاشية الدسوقي ٤ / ٢٩٩.

حكم قتال الإمام للبغاة:

للإمام العدل مقاتلة البغاة، وإن تأوّلوا الخروج عليه لشبهة قامت عندهم حتى يرجعوا إلى حظيرة الإسلام كما يجب على الناس معاونّة الإمام في مقاتلتهم.

أما إذا كان غير عدل فلا يجوز له قتل البغاة لاحتمال أن يكون خروجهم من أجل جوره وفسقه بل يجب عليه أن يتوب أولاً ثم يقاتل.

وإن كان يحرم الخروج عليه شرعاً وإن جار وفسق، فإن أصر الإمام غير العدل على مقاتلتهم فلا تجب معاونته، قال الإمام مالك - رضي الله عنه - دعه وما يُراد منه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما^(١).

الواجب على الإمام نحو البغاة:

يجب على الإمام قبل أن يقاتل البغاة دعوتهم لطاعته وموافقة جماعة المسلمين، وإنذارهم عاقبة المخالفة، وأنهم إن لم يطيعوه قاتلهم، فإن عاجلوه بالقتال أو لم يطيعوه قاتلهم.

ويقاتلهم بالسيف والرمي بالنبل، والمنجنيق^(٢)، والتغريق، والتحريق، وقطع الميرة^(٣) والماء عنهم إلا أن يكون فيهم نساء وذرية فلا يرميهم بنار.

(١) الشرح الكبير ٤ / ٢٩٩.

(٢) هذا هو المعتمد خلافاً لابن شاس القائل لا تنصب عليهم الرعادات أي المجانيق وهي التي تنصب لهدم الأسوار والقلاع والبيوت أثناء الحرب أو هي آلة حربية تستعمل لقذف الحجارة وكل ما يمكن قذفه من الأجسام. حاشية الدسوقي ٤ / ٢٩٩.

(٣) أي الطعام.

ويحرم على الإمام: سبي ذراريهم، ونسائهم؛ لأنهم مسلمون، كما يحرم عليه إتلاف أموالهم وأخذها بدون احتياج لها، ورفع رعوسهم بعد قتلهم بمحل قتلهم وأولى في غير محل قتلهم^(١)؛ لأنه مثله بالمسلمين.

فإن أمن الإمام والناس جانبهم بالظهور عليهم مع عدم الخوف أو بعدم انحيازهم إلى فئة تركهم ولا يتبع منهزمهم ولا يجهز على جريحهم، فإن خيف منهم انحازوا إلى فئة أتبع منهزمهم وأجهز على جريحهم.

ما يمتاز به قتال البغاة عن قتال الكفار^(٢):

يمتاز قتال البغاة عن قتال الكفار بأحد عشر وجهاً:

- ١- أن يقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم بخلاف الكفار فالمقصود القتل.
- ٢- وأن يكف عن مدبرهم بخلاف الكفار.
- ٣- ولا يجهز على جريحهم.
- ٤- ولا تقتل أسراهم.
- ٥- ولا تغنم أموالهم.
- ٦- ولا تسبي ذراريهم.
- ٧- ولا يستعان على قتالهم بمشرك.
- ٨- ولا يوادعهم (يصالحهم) على مال.
- ٩- ولا تُنصب عليهم الرعادات (أي المجانيق).

(١) قال البناني هذا محل نظر بل إنما يمنع حمل رعوسهم لمحل بلد آخر كبلد أو وائل وأما رفعها على الرماح في محل قتلهم فقط فجائز كالكفار فلا فرق بين الكفار والبغاة في هذا، ولهذا لم يذكر في الأمور التي يمتاز فيها قتال البغاة عن قتال الكفار. بلغة السالك لأقرب المسالك ٤ / ٤٢٨.

(٢) حاشية الدسوقي ٤ / ٢٩٩، بلغة السالك ٤ / ٤٢٩، حاشية العدوي بهامش الخرشي ٨ / ٢٤٨، القوانين الفقهية: ٣٨٦.

١٠- ولا تُحَرَّق مساكنهم.

١١- ولا يُقَطَّع شجرهم^(١).

(١) القوانين الفقهية: ٣٨٦.

فروع:

الأول: جاز للإمام وغيره أن يستعين بمال البغاة - كالسلاح والخيول وما أشبه ذلك من آلات الحرب - على قتالهم إن احتاج إليه، فإن استغنى عنه رده إليهم، كما يرد غير ما يستعان به من أموالهم؛ لأنهم مسلمون فلم يزل عن ملكهم.

الثاني: يكره للرجل أن يقتل أباه الباغي^(١) مسلماً كان أو كافراً بارزه الأب أو لم يبارز، ومثل الأب الأم بل هي أولى لما جلبت عليه من الحنان والشفقة ولضعف مقاتلتها عن مقاتلة الرجال.

الثالث: الباغي المتأول في خروجه على الإمام إذا أتلّف نفساً أو طرفاً أو مالا لا ضمان عليه ولا إثم عليه لتأوله سواء كان الإمام عدلاً أو غير عدل.

الرابع: إذا خرج ذمي مع الباغي المتأول طائعاً رد لذمته، ولا يعد خروجه مع الباغي المتأول نقض للعهد، فإذا أتلّف الذمي نفساً أو طرفاً أو مالا فلا ضمان عليه.

وإذا خرج طائعاً مع الباغي المعاند أي غير المتأول فيعد ناقضاً للعهد ويكون هو وماله فيء، فإذا أتلّف نفساً أو طرفاً أو مالا فعليه الضمان.

فإن خرج معه مكرهاً فلا يكون ناقضاً للعهد ما لم يقاتل، فإن قاتل كان ناقضاً^(٢).

(١) هذا هو المشهور، وروى ابن عبد السلام جواز قتل الأب الباغي. مواهب الجليل ٦/ ٢٧٩.

(٢) لامتناع تعلق الإكراه بقتال من لا يحل. حاشية البناني بهامش الخرشبي ٨/ ٦٢، بلغة السالك ٣/ ٤٤٥.

الخامس: الباغي المتأول إذا أقام قاضياً وهو خارج عن طاعة الإمام فحكم بشيء ثم رجع المتأول للحق ودخل تحت طاعة الإمام مضى حكمه ولا يتعقب ويرفع الخلاف، فإن أقام حداً من الحدود فلا يُعاد إن كان غير قتل، ولا دية على القاضي إن كان قتلاً.

وأما غير المتأول فأحكامه التي قضى بها قاضية تُتَعَقَبُ فما وجد منها صواباً مضى وإلا رد.

السادس: المرأة إذا كانت مع البغاة وقاتلت بسلاح فإن ظُفِرَ بها حال المقاتلة قتلت ولو لم تَقْتُلْ أحداً سواء كانت متأولة أو غير متأولة، فإن قاتلت بغير سلاح فلا تقتل ما لم تقتل أحداً.

وإن ظُفِرَ بها بعد انقضاء القتال، فإن كانت متأولة فلا ضمان عليها فيما أتلقت من نفسٍ أو طرفٍ أو مالٍ.

وإن كانت غير متأولة فعليها الضمان إن كانت مسلمة، ورقت إن كانت ذمية لنقضها العقد.

الباب السادس
الحراية

الحرابة

الحرابة في اللغة:

من حارب يحارب حرباً وحرابة ومحاربة: قطع الطريق وإشهار السلاح، وهي مأخوذة من الحرب؛ لأن هذه الطائفة الخارجة على النظام تعتبر محاربة للجماعة من جانب، ومحاربة للتعاليم الإسلامية التي جاءت لتحقيق أمن الجماعة وسلامتها من جانب آخر^(١).

والحرابة في اصطلاح الشرع معناها:

الخروج لإخافة سبيل، لأخذ مال محترم، بمكابرة قتال، أو خوفه أو إذهاب عقل أو قتل خفية، أو لمجرد قطع الطريق، لا لإمرة، ولا نائرة ولا عداوة^(٢).

شرح التعريف:

الخروج: جنس في التعريف، يشمل كل خروج، سواء كان خروجاً مشروعاً أو غير مشروع، وسواء كان الخروج لأخذ مال أو لا، أو لإمرة وعداوة أو لا، وقوله: الخروج مناسب للمحدود، لأنه مصدر.

لإخافة سبيل: علة لقوله خروج، أي خروج لإخافة سبيل الله، فليس السبيل الذي هو الطريق يكون خائفاً^(٣).

وقوله لإخافة سبيل: قيد أخرج به الخروج لغير إخافة سبيل.

لأخذ مال: قيد خرج به الخروج لغير أخذ مال، كما لو خرج لإخافة عدوه فليس المراد منه الخروج لمجرد قطع الطريق.

(١) المصباح المنير ١/ ١٩٨، مادة: حرب، معجم لغة الفقهاء د/ محمد رواس قلعة جي، د/

حامد صادق قتيبي - ص ١٧٧ - ط ١ - ١٩٨٥م، دار النفائس بيروت.

(٢) التعريف المذكور لابن عرفة من المالكية - يراجع: شرح الخرشي على مختصر خليل ج ٥ ص ٣٤٥ - ٣٤٦.

(٣) حاشية العدوي على شرح الخرشي ٥ / ٣٤٥.

محترم: صفة لمال، وسواء كان المال لمسلم، أو ذمي، وخرج به مال الحربي فماله ليس محترماً.

والبضع^(١) أخرى من المال:

فمن خرج لإخافة السبيل، قاصداً الغلبة على الفروج فهو محارب، لأن الغلبة عليها أقبح من الغلبة على المال.

قال ابن العربي: "رفع إلى في ولايتي القضاء قوم خرجوا محاربين إلى رفقة، فأخذوا منهم امرأة فاختلوها، فأخذت، فسألت من كان ابتلانا الله - تعالى - بهم من المفتين؟ فقالوا: ليسوا محاربين لأن الحاربة في الأموال دون الفروج - فقلت لهم: ألم تعلموا أنها في الفروج أقبح منها في الأموال، وأن الحر يرضى بسلب ماله دون الزنا بزوجه أو بنته، ولو كانت عقوبة فوق ما ذكر الله - تعالى - لكانت لمن يسلب الفروج، وحسبكم من بلاء صحبة الجهلاء خصوصاً في الفتيا أو القضاء^(٢).

بمكابرة قتال: أي بسبب مكابرة قتال. ولا يخفي أن المكابرة هي المغالبة، والمعاندة أي قتال بمغالبة، كذا مقتضى أهل اللغة، وفي بعض التقارير أن الإضافة بيانية^(٣).

أو خوفه: معطوفة على قوله بمكابرة قتال. والمعنى: لأخذ مال محترم بسبب مكابرة قتال، أو بسبب خوف القتال.

والقتال ليس شرطاً في تحقيق الحاربة، وإنما ذكر، لأنه الغالب^(٤).

(١) البضع بالضم يطلق على الفرج، والجماع، ويطلب على الترويج أيضاً من باب التوسع
يراجع: المصباح المنير ١ / ٨٢ مادة: بضع معجم لغة الفقهاء ص ١٠٨.

(٢) منح الجليل للشيخ عlish ٥٤٢/٤.

(٣) حاشية العدوي على شرح الخرشي ٥ / ٣٤٦.

(٤) المرجع السابق.

أو إذهاب عقل: معطوفة على قوله الخروج لإخافة سبيل.. فمن خرج قاصداً قطع الطريق وإذهاب عقل المارين فهو محارب.

أو قتل خفية: قيد لإدخال قتل الغيلة، وهي أن يغتال رجلاً أو صبياً، فيخدعه حتى يدخله موضعاً معيناً، فيأخذ ما معه، فهو كالحرابة، لأن القتل هو نفس الغيلة قال الرماصي - من المالكية: "وتفسير الغيلة بما ذكر يدل على أن القتل ليس شرطاً فيها وأن قتل الغيلة من الحرابة^(١).

أو لمجرد قطع الطريق: معطوف على قوله: لإخافة، والتقدير: أو الخروج لمجرد قطع الطريق أي مجرد عن أخذ المال. فمن خرج لقطع السبيل لغير مال فهو محارب كقوله لا أدع هؤلاء يخرجون إلى الشام، أو إلى مصر، أو إلى مكة، وكذلك من حمل السلاح على الناس وأخافهم، من غير عداوة ولا نائرة^(٢).

لا لإمرة: أي لا لأجل أن يجعلوه أميراً عليهم، فلا يكون محارباً، ويكون باغياً فيعامل معاملة الباغي. وبعبارة أخرى لا لإمرة، كالذين يخرجون لأخذ العشر^(٣).

ولا نائرة ولا عداوة: العطف بينهما للتفسير، لأن النائرة هي العداوة، كأن يكون بين أهل بلدين قتال، فيمنع أهل أحدهما أهل الأخرى من المرور، فهؤلاء ليسوا بمحاربين.

ويلاحظ في جميع ما تقدم اشتراط شرط: وهو أن يكون على وجه يتعذر معه الغوث: أي الإغاثة والإعانة على التخليص منه، وإلا إذا وجدت الإغاثة فيكون غاصباً^(٤).

(١) حاشية الدسوقي ٤ / ٣٤٩، منح الجليل ٤ / ٥٤٤.

(٢) منح الجليل ٤ / ٥٤٢.

(٣) حاشية العدوي على شرح الخرشي ٥ / ٣٤٦.

(٤) الشرح الكبير لأبي البركات الدردير ٤ / ٣٤٨.

وبناء على ذلك يكون قيد: "على وجه يتعذر معه الغوث، ملاحظاً في تعريف ابن عرفة".

تنبيهان:

الأول: يشمل التعريف النساء، والصبيان، لكن لا يتعلق بالصبي المحارب أحكامه، ولو قتل لأن عمده كالخطأ، ولا بالمرأة صلب، وكذا النفي على أحد قولين في المذهب^(١).

الثاني: قال ابن المواز: اختلف في المحارب في مدينة: فقال ابن القاسم هو محارب، ولعبد الملك في كتاب ابن سحنون: لا يكونون محاربين في قرية، إذا كانوا مختلفين، لا يفسدون إلا الواحد، والمستضعف، إلا أن يكونوا جماعة يريدون القرية كلها، مكابرين معلنين، فهم كاللصوص الذين يقتحمون القرى، وقال سحنون: هم سواء.

قال البنانى: "واستظهر ابن عاشر في كلام خليل مبالغتين: إن انفرد المحارب، وإن كان بمدينة ففي المدونة: من كابر رجلاً على ماله بسلاح أو غيره في زقاقه، أو دخل على حريمه في المصر حكم عليه بالحرابة"^(٢) وهذا هو الراجح.

أنواع الحرابة:

تتنوع الحرابة إلى أنواع تختلف باختلاف مقصود المحارب، وهذه الأنواع جمعها العلامة خليل في مختصره، فقال: "المحارب قاطع الطريق، لمنع سلوك، أو أخذ مال مسلم أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث، وإن انفرد بمدينة،

(١) حاشية العدوي على شرح الخرشي ٥ / ٣٤٦.

(٢) حاشية الدسوقي ٤ / ٣٤٨، منح الجليل ٤ / ٥٤٣.

كمسقي السيكران لذلك، ومخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه، والداخل في ليل أو نهار في زقاق، أو دار، قاتل ليأخذ المال....^(١).

وتفصيل ذلك:

قد تكون الحراية لأجل أخذ المال، وقتل النفس، وهتك العرض، وإخافة الطريق، بمعنى أن يكون قصد المحاربين تحقيق ذلك كله أو واحد منه إذا وجد. وقد تكون الحراية للقتل فقط، لكن يشترط - هنا - أن لا توجد عداوة بين المحارب ومن خرج لقتله.

وقد تكون الحراية لمجرد أخذ المال بمعنى أن يكون الهدف من الخروج على الجماعة هو أخذ المال فقط، سواء كان هذا المال لمسلم، أو لذمي، أو معاهد ولو لم يبلغ المال نصاباً.

وقد تكون الحراية مقصودة لهتك الأعراض.

وأخيراً قد تكون الحراية لمجرد قطع الطريق فقط، كقوله: لأدع هؤلاء يخرجون إلى مكة، أو حمل السلاح وأخاف الناس من غير عداوة. فإذا تحققت هذه الأنواع أو واحد منها، كان الشخص محارباً، بشرط أن يكون خروجه على وجه يتعذر معه الغوث في الجميع.

وإذا ثبتت الحراية وجب الحد، على تفصيل يأتي في حد المحارب.

وطرق الحراية تتعدد:

فقد تكون بالمكابرة والمقاتلة، وقد تكون بتغييب العقل، وإذهابه، كمسقي السيكران - وهو نبت كالبقل - ومثله البنج، وأشد منه الداتورة. وقد تكون بمخادعة الصبي المميز، أو غيره، لأجل أخذ ماله، ولو لم يقتله، فإن قتله: كان قتل غيلة.

(١) مختصر خليل، مع الشرح الكبير ٤ / ٣٤٨.

وقد تكون الحاربة بالدخول في زقاق، أو دار، ليلاً أو نهاراً لأجل أخذ المال، إن قاتل وأخذه على وجه يتعذر معه الغوث. واحترز بهذا عما لو أخذ المال ثم علم به، فقاتل لينجو به، فلا يكون محارباً، بل هو سارق إن علم به خارج الحرز، لا قبله فمختلس إن نجا به^(١).

وفي كل ما مضى لا يشترط أن يكون المحارب متعدداً، بل وإن انفرد، حيث كان خروجه للحاربة على وجه يتعذر معه الغوث وقصد أذية الناس.

حكم المحارب وحده:

المحارب له حكرمان: مع غير الإمام، ومع الإمام.

أما مع غير الإمام فله حكرمان: وجوب القتل، وجوازه.

فيجب قتله في خمس مسائل: دفع القتل، أو الجرح عن نفسه، والقتل والجرح والفاحشة بأهله.

ويندب أن يكون قتاله بعد المناشدة.

قال الزرقاني: "وهو فرض على من تعرض له المحارب، وخاف على نفسه أو أهله القتل، أو الجرح أو الفاحشة بأهله"^(٢).

وتجوز مقاتلته فيما عدا الخمس المتقدمة، ويندب أن تكون مقاتلته بعد مناشدته بأن يقول له ثلاث مرات: أناشدك الله أن تخلي سبيلي، أو سبيلنا ونحو ذلك ومحله: إن أمكن أن يناشده بأن لا يعاجله بالقتال، فإن عاجل بالقتل قاتله بلا مناشدة، بالسيف ونحوه، مما يسرع به إلى الموت، لأنه لا فائدة للقتال إلا القتل^(٣).

(١) حاشية الدسوقي والشرح الكبير ٤ / ٣٤٨ وما بعدها، شرح الخرشي ٥ / ٣٤٦، وما بعدها،

منح الجليل ٤ / ٥٤٣، شرح الزرقاني ٨ / ١٠٩، ١٠٩.

(٢) شرح الزرقاني على مختصر خليل ٨ / ١١٠.

(٣) شرح الخرشي ٥ / ٣٤٧، حاشية الدسوقي والشرح الكبير ٤ / ٣٤٩.

وأما حكم المحارب مع الإمام فيختلف:

فإن قتل المحارب أحدًا تعين قتله، ولو كان الذي قتله كافرًا أو عبدًا، مكافئًا له، أو غير مكافئ، لأن القتل للحاربة، فيقتل لها بلا صلب، أو مع صلب. ولا يجوز قطعه ولا نفيه. وليس لولي الدم عفو عنه قبل مجيئه تائبًا لأن الحق لله، وأما بعد مجيئه تائبًا فله العفو، لأن قتله حينئذ قصاص، لا حاربة. ولا يشترط مباشرته للقتل، بل ولو شاركه أحد فيه، بإعانة، كضرب أو إمساك ولو لم يعن بما ذكر، بل بممالة، بحيث لو استعين به لأعانه^(١). ومثل الإعانة التقوى بجاه المحارب، ولو لم يأمر بقتله، وإلا تسبب فيه، كما لو انحاز شخص للمحارب وقتل أحدًا فيقتلان معًا، إذ لولا جاه المحارب: ما تجرأ القاتل على القتل.

ودليل ذلك ما فعله عمر (رضي الله عنه) حينما قتل رجلًا كان ناظرًا للباقيين^(٢). وإن لم يقتل المحارب أحدًا، وقدر عليه الإمام فحكمه الوارد في الآية الكريمة ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^(٣).

وقد اختلف الفقهاء في تفسير هذه الآية على ثلاثة مذاهب: أحدها: أن الإمام أو من استتابه على قتالهم من الولاية بالخيار بين أن يقتل ولا يصلب، وبين أن يقتل ويصلب، وبين أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وبين أن ينفيهم من الأرض.

(١) شرح الخرشي ٥ / ٣٤٧، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٠.

(٢) منح الجليل ٤ / ٥٤٦.

(٣) آية رقم (٣٣) من سورة المائدة.

ثانيها: أن من كان منهم ذا رأي وتدبير قتله ولم يعف عنه، ومن كان ذا بطش وقوة قطع يده ورجله من خلاف، ومن لم يكن ذا رأي و بطش عزره وحبسه.

ثالثها: أن عقوباتهم تكون على أفعالهم، فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن لم يفعل شيئاً من ذلك وقد كان منهم وبه كثروا وهيبوا فإنه يعزر^(١).

والراجع في مذهب المالكية، وبه قال مالك: المذهب الأول.

وعليه: فالإمام مخير في حدود أربعة لا يخرج عنها، ولا يتعين واحد منها؛ إلا أنه يندب للإمام أن ينظر في ما هو الأصلح واللائق بذلك المحارب، فإن ظهر له ما هو الأصلح وخالفه أجزأ مع الكراهة^(٢).

والحدود الأربعة التي يخير فيها الإمام هي:

(أ) القتل بدون صلب.

(ب) الصلب، ثم القتل بعد الصلب على خشبة ونحوها، غير منكوس الرأس أي بأن يربط جميعه بها، لا من أعلى فقط، كإبطيه ووجهه أو ظهره لها، ثم ينزل وجوباً، إذا خيف تغييره، ويصلى عليه غير فاضل، ثم يدفن بعد ذلك. لكن ما الحكم لو مات قبل أن يصلب؟ لو تخير الإمام الصلب مع القتل، ثم مات المحارب قبل الصلب حياً فلا يصلب.

(١) شرعية الجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالقانون الوضعي المصري -

خالد عبد الحميد فراج ص ١٢.

(٢) حاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٠.

قال التتائي: "وإذا مات قبل أن يصلب، لم يصلب، ولو قتله إنسان قبل صلبه صلب، لأنه بقية حده" قال الزرقاني: "وإنما ترك صلبه إذا مات قبله لأنه قبل فعل شيء من الحد، وفي قتله قد فعله مع بعضه"^(١).

(ج) القطع من خلاف: فنقطع يده اليمنى من الكوع، ورجله اليسرى من مفصل الكعب، فإن كان مشلول اليد اليمنى، أو مقطوعها قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى، فإن لم يكن له إلا يد أو رجل قطعت، فإن كان له يداً فقط أو رجلان فقط، قطعت اليد اليمنى أو الرجل اليسرى فقط^(٢).

(د) النفي: ويكون للحر الذكر البالغ العاقل، أما المرأة فلا تنفي لما في نفيها من زيادة المفساد، كما أنها لا تصلب، لأن في صلب المرأة فضيحة لها، فحدها القتل أو القطع من خلاف.

وأما الرقيق فلا ينفي - أيضاً - لما في النفي من الضرر على سيده وإنما حده القتل، أو الصلب والقتل، أو القطع من خلاف.

والنفي للحر الذكر البالغ العاقل كالزنا في مسافة البعد، كفدك وخيبر من المدينة، ولكنه يسجن هنا حتى تظهر توبته، وأما في الزنا فيسجن سنة. ويكون النفي بعد الضرب باجتهاد الإمام، لأنه لا معنى للنفي بدون ضرب^(٣).

هذه هي الحدود الأربعة التي يخير فيها الإمام، لكن يندب أن يختار للمحارب ذي التدبير القتل، بمعنى أن المحارب الذي لم يصدر منه قتل: يندب للإمام أن ينظر في حاله، فمن كان له تدبير في الحروب والخلاص منها يقتل، ولا يقطع من خلاف، لأنه لا يدفع ضرره - وإن كان المحارب من أهل البطش

(١) شرح الزرقاني على مختصر خليل ٨ / ١١٠.

(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٤٩ وما بعدها.

(٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٤٩.

والشجاعة فيقطع من خلاف، فإن لم يكن عنده تدبير ولا بطش بل اتصف
بغيرهما، أو وقعت منه الحراة فلتة مخالفة لظاهر حاله، وموافقة لغيره ضرب
ونفي، والضرب باجتهاد الحاكم كما يراه من حال المحارب^(١).

دليل مشروعية حد المحارب:

شرع حد المحارب بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ
خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيمٌ﴾^(٢).

وقد اختلف في سبب نزول الآية، فقيل نزلت في المشركين الحربيين، وقيل
في قوم من أهل الذمة نقضوا عهدًا كان بينهم وبين رسول الله (ﷺ) وقيل في
المرتدين الذين ارتدوا وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، وقيل في قطاع الطريق من
المسلمين، وهذا قول الإمام مالك وغيره من فقهاء الأمصار - رضي الله عنهم
جميعًا - وهو الصحيح المستحسن لاتفاق الكل على أن حكم المرتد والكافر القتل،
لا القطع ولا النفي، وعلى أن الناقض للعهد ليس حكمه القطع.

قال مالك - رحمه الله: "جهاد قطعي الطريق أحب إلي من جهاد الروم".

وقد قضى الخلفاء الراشدون (رضي الله عنهم) بذلك.

فقد قتل عثمان (رضي الله عنه) مسلما قتل ذميا على وجه الحراة، على مال كان

معه .

وقتل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) رجلاً كان ناضراً للباقيين^(٣) .

(١) شرح الخرشي على مختصر خليل ٥ / ٣٤٨.

(٢) آية رقم (٣٣) من سورة المائدة.

(٣) منح الجليل ٤ / ٥٤٣ - ٥٤٦.

فهذا كله يدل دلالة صريحة على مشروعية قتال المحاربين الذين يسعون في الأرض فسادًا.

حكمة المشروعية من قتال المحاربين:

شرع قتال المحاربين دفعًا للضرر الواقع على جماعة المسلمين، فإنه وإن كان في قتلهم ضرر إلا أنه أخف من الضرر الأعظم الواقع على أفراد المجتمع، والذي يهدد أمنه وسكينته وعرضه وماله، فمن خرج لقطع السبيل وإخافها، وسعى في الأرض فسادًا بالقتل وأخذ المال، واستباحة الدماء، وهتك ما حرم الله هتكه من المحرمات، فهو محارب داخل تحت حكم الله (ﷻ) في المحاربين الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا، وقد قرن الله - تعالى - السعي بالفساد في الأرض بقتل النفس التي من قتلها كان كمن قتل الناس جميعًا، فمن كانت هذه حالته فعلى الإمام طلبه بكل ما يمكنه أن يقدر على أخذه^(١).

وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^(٢).

فشرعت الحدود - جميعًا - لرفع الأضرار الواقعة على الناس من جرائم تهدد أمنهم وسلامتهم، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.

ثبوت الحاربة وسقوط حدها

(١) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر ج ٢ ص ١٠٨٧، مكتبة الرياض الحديثة بالسعودية.

(٢) آية رقم (٣٢)، رقم (٣٣) من سورة المائدة.

تثبت الحراية بأحد أمرين:

الأول: بما لو شهد اثنان عدلان عند الحاكم على رجل اشتهر بالحراية أن هذا الشخص هو المشتبه بها عند الناس.

وتثبت الحراية بشهادة العدلين وإن لم يعاينا الحراية. قال في المدونة: "وتجوز على المحاربين شهادة من حاربوه، إن كانوا عدولاً شهدوا بقتل أو مال، ولا تقبل شهادة أحدهم في نفسه، وتقبل شهادة بعضهم لبعض" (١).

الثاني: الإقرار (٢) أي إقرار المحارب على نفسه بالحراية.

سقوط حد الحراية:

يقول العلامة خليل في مختصره: "وسقط حدها بإتيان الإمام طائعاً، أو ترك ما هو عليه".

ويستفاد من ذلك أن حد الحراية يسقط بأحد أمرين:

الأول: إتيان المحارب الإمام، طائعاً، وذلك يكون قبل القدرة عليه، وإن لم تظهر توبته، فإن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط شيء.

الثاني: تركه مما هو عليه من الحراية، وإن لم يأت الإمام طائعاً، بأن ألقى السلاح، وترك أعمال الإفساد، والعريضة في الأرض. فإن حد الحراية يسقط عنه، ما عدا حقوق الأدميين، فإنها لا تسقط.

قال الزرقاني في شرحه: "والفرق بين سقوط حد الحراية بما ذكر، وإن لم يتب، وبين عدم سقوط حد السرقة، بتوبة وعدالة: أن السرقة أخذ المال خفية، والتوبة أمر خفي، فلا يزال حد شيء خفي بأمر خفي".

والحراية ظاهرة للناس، فإذا كف أذاه لم يبق لنا فائدة في قتله، لأن الأحكام

تتبع المصالح (١).

(١) منح الجليل ٤ / ٥٤٨.

(٢) حاشية الدسوقي ٤ / ٣٥١.

فروع متفرقة في الحاربة.

الفرع الأول: المال الذي يظفر به الإمام تحت يد المحاربين.

يقول العلامة خليل في متته: "ودفع ما بأيديهم لمن طلبه بعد الاستيناء واليمين، أو بشهادة رجلين من الرفقة..."^(٢).

والمعنى أنه إذا ادعى شخص أن المال الذي بيد المحاربين هو له فإن أثبته ببينة دفع له بلا استيناء.

وإن لم تكن له بينة فلا يدفع له إلا بعد الاستيناء، وبعد وصفه وصفًا شافيًا والدفع يكون له بعد وصفه ويمينه.

والحكمة من عدم دفعه له إلا بعد الاستيناء: هي الخوف من أن يأتي غيره بأثبت مما أتى به، ولا يؤخذ منه حميل، وإنما يدفعه له الإمام ويشهد عليه، فإن جاء غيره بأثبت منه نزع منه، ودفعه الإمام لذلك الغير^(٣).

الفرع الثاني: هل يسقط الضمان بإتيان المحارب طائعًا؟

لا يسقط الضمان مطلقًا، بخلاف الحد، لأن الضمان خاص بالآدميين والحد لحاربة: حق لله - تعالى - فيسقط إذا جاء المحارب تائبًا قبل القدرة عليه، ولا يسقط حق الآدميين، لاحتياج العبد وغنى الرب (ﷺ)^(٤).

الفرع الثالث: المحاربون حملاء عن بعضهم.

المحاربون متضامنون، كالحملاء لتقوي أحدهم بصاحبه، وغرم كل واحد بانفراده من المحاربين - إذا أخذوا شيئًا من الأموال - عن الجميع، فكل من قدر عليه منهم أخذ بجميع ما أخذه هو وأصحابه^(١).

(١) شرح الزرقاني على مختصر خليل ٨ / ١١٢.

(٢) مختصر خليل مع الشرح الكبير ٤ / ٣٥١.

(٣) حاشية الدسوقي والشرح الكبير ٤ / ٢٥١، منح الجليل ٤ / ٥٤٧.

(٤) الشرح الكبير ٤ / ٣٥١، وما بعدها، شرح الخرشي ٥ / ٣٤٩.

الفرع الرابع: هل يعطى المحارب أماناً؟

لا يعطى المحارب أماناً إن سأل الأمان، وعليه فلا يعطيه الإمام أماناً، بخلاف المشرك، لأن المشرك يقر - إذا أمن - على حاله، وببيده أموال المسلمين، ولا يجوز تأمين المحارب على ذلك، ولا أمان له. وإذا امتنع المحارب بنفسه، أو امتنع بحصن حتى أعطي الأمان فاختلف فيه هل يتم له الأمان أم لا؟

ف قيل: يتم له ذلك، فإن امتنع في حصن أو مركب، أو غيره أمنه السلطان أو غيره؛ لأنه حق لله تعالى، وقيل: لا، قاله أصبغ^(١).

الفرع الخامس: لو قتل المحارب أحد ورثته فهل يرثه أو لا؟

قيل: يرثه، وقيل: لا.

قال الزرقاني: "قلت: وينبغي أن يكون الراجح الأول قياساً على ما في البغي من قوله: وكره للرجل قتل أبيه الباغي، وورثته"^(٢).

والله أعلم،،

(١) حاشية الدسوقي والشرح الكبير ٣٥٠ / ٤، وما بعدها، منح الجليل ٥٤٧ / ٤ وما بعدها.

(٢) شرح الخرشي ٣٤٩ / ٥، شرح الزرقاني ١١٢ / ٨.

(٣) شرح الزرقاني على مختصر خليل ١١٠ / ٨.

ملخص ما سبق دراسته في بابي البغي والحاربة

- ١- البغي : الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولا .
- ٢- خروج البغاة يكون لمنع حق لله وجب عليهم كالزكاة ، أو لآدمي كأن يرفضوا أمر الإمام بالوفاء بما عليهم من ديون ، وقد يكون الخروج لخلع إمام عادل ، وقد يكون الخروج لمجرد العناد ونشر الفوضى في الأرض .
- ٣- البغي محرم في الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع .
- ٤- يتدرج الإمام في التعامل مع البغاة ، بأن يدعوهم إلى الرجوع إلى الحق ، والدخول تحت طاعته، وموافقة جماعة المسلمين، فإن فاعوا قبل ذلك كف عنهم، وإن أبوا قاتلهم بكل ما يسكن شأفتهم، ويرجعهم عن غيهم .
- ٥- الحاربة :قطع الطريق وإشهار السلاح لمحاربة الأمة والتعاليم الإسلامية التي جاءت لتحقيق أمن الجماعة وسلامتها .
- ٦- الأصل في الحاربة أنها قطع الطريق لأخذ الأموال وإرهاب الناس ، وقد تكون للاعتداء على الأعراس ، وهما محرمان في الإسلام وعقابهما واحد .
- ٧- يجب على الإمام ومعاونيه مقاتلة المفسدين في الأرض أن قطعوا طريقا، أو أخذوا مالا، أو هتكوا عرضا .
- ٨- شرع قتال البغاة والمحاربين دفعا للضرر الواقع على جماعة المسلمين، فإنه وإن كان في قتلهم ضرر إلا أنه أخف من الضرر الأعظم الواقع على أفراد المجتمع، والذي يهدد أمنه وسكينته وعرضه وماله .

أسئلة على ما سبق دراسته في حد البغي والحاربة :

س١: عرف البغي، واذكر القصد من خروج البغاة، واستدل على حكم مقاتلتهم .

س٢: ما الذى يفعله الإمام قبل قتال البغاة ؟

س٣: بين الحكم فيما يأتي :

■ مال البغاة الذى يقع في حوزة الإمام أو من ينوبه .

■ ضمان البغاة لما أتلّفوه من نفس أو مال .

س٤: هل يعد الخروج بقصد التعدي على الأعراض حاربة ؟ اذكر الدليل .

س٥: اذكر العقوبات التي قررها الإسلام لقطاع الطريق .

س٦: بين الحكم فيما يأتي :

■ المال الذى يظفر به الإمام تحت يد المحاربين .

■ سقوط الضمان بإتيان المحارب طائعا .

■ تأمين المحارب .

س٧: أكمل العبارات الآتية :

أ- يكره للرجل قتلالباغى ، حالة كون ذلك من
البغاة ، سواء كانأولا ، بارز بالقتال أم ومثل
.....أمه ، بل هيلماولضعف

ب- يثبت حد الحراية بأحد أمرين :

١-.....٢-.....ويسقط بإتيان
.....طائعا ، قبلوإن لم تظهر..... فإن
.....بعد القدرةلم

س٨: ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة

الخاطئة مبينا السبب :

- المرأة الباغية إن قاتلت بالسلاح فكالرجل .
- من العقوبات المقررة للمرأة قاطعة الطريق القتل مع الصلب والنفي .
- قاطع الطريق في الحضر له نفس العقوبة المقررة له في الصحراء .
- من ادعى مالا في يد المحاربين يعطى له بدون انتظار .

الموضوع	الصفحة
مقدمة	
توصيف المقرر	
مقدمة في التعريف بالمذهب المالكي، وأشهر أعلامه	
أشهر كتب المالكية	
أولاً: الدراسة النصية	
باب الحوالة	
باب الضمان	
باب الإجارة	
ثانياً: الدراسة الموضوعية	
الباب الأول: الشركة وأحكامها	
أركان الشركة	
أقسام الشركة	
أولاً: شركة الأموال	
شركة المفاوضة.	
شركة العنان	
شركة الجبر	
شركة الذمم	
شركة المضاربة	
أحكام مخرجة على شروط صحة القراض (المضاربة)	
ثانياً: شركة الأبدان	

	ثالثاً: شركة الوجوه
	مسائل يقع فيها النزاع بين الشركاء وغيرهم
	أسئلة على باب الشركة
	الباب الثاني: المزارعة وأحكامها
	حكم المزارعة
	ثالثاً: دليل مشروعيتها
	رابعاً: صفة عقد المزارعة
	خامساً: شروط المزارعة
	سادساً: صور المزارعة الجائزة
	سابعاً: الصور الممنوعة في المزارعة
	ثامناً: حكم المزارعة إذا فسدت
	الباب الثالث: الإقرار
	تعريف الإقرار وحكمه ودليل حجيته
	أركان الإقرار
	أحكام مخرجة على شروط صحة الإقرار
	الاستلحاق وحكمه
	حكم الاستلحاق ودليله
	شروط صحة الاستلحاق
	الباب الرابع: أحكام الدماء
	الفصل الأول: الجناية على النفس
	المبحث الأول: القتل العمد
	المطلب الثاني: أنواع القتل العمد

	صور القتل المباشر
	المطلب الثالث: عقوبة القتل العمد
	الفرع الأول: تعريف القصاص
	الفرع الثاني: شروط القصاص
	موانع القصاص
	الفرع الثالث: مسقطات القصاص
	الفرع الرابع: لمن يكون حق استيفاء القصاص؟
	الفرع الخامس: صفة القصاص
	الفرع السادس: وقت استيفاء القصاص
	النوع الثاني من أنواع عقوبة القتل العمد: العقوبة البدلية
	الدية
	التعزير
	النوع الثالث: العقوبة التبعية للقتل العمد
	المبحث الثاني: القتل الخطأ
	العاقلة
	الكفارة في القتل الخطأ
	بم يثبت القتل؟
	القسامة
	الفصل الثاني: الجناية على ما دون النفس
	سراية القصاص فيما دون النفس
	الفصل الثالث: الجناية على نفس غير مكتملة (الجنين)
	الباب الخامس: البغي

	حكم البغي
	حكم قتال الإمام للبغاة
	فروع متعلقة بباب البغي
	الباب السادس: الحراية
	أنواع الحراية
	حكم المحارب وحدّه
	دليل مشروعية حد المحارب
	ثبوت الحراية وسقوط حدها
	فروع متفرقة في الحراية
	فهرس المواضيع